

<제1편 총설.제1장 민사소송.제1절 민사소송의 개관>

[모의][1.01-1]민사소송법의 법적 성격

《【문제1.1】 민사소송법의 법적 성격에 대해 논하시오. (25점)》

<문제1.1> 민사소송법의 법적 성격

I. 서론

- 법은 그 규율 대상과 목적에 따라 사법(私法)과 공법(公法)으로 구분된다. 사법은 사인 간의 평등한 관계를 규율하며 사적 자치의 원칙이 지배하는 영역인 반면, 공법은 국가와 개인 간의 수직적 관계나 공공의 이익을 규율하는 영역이다. **민사소송법**은 사적인 권리관계를 확정하고 실현하는 절차를 다루지만, 그 절차를 주재하는 주체는 국가기관인 법원이다. 이하에서는 **민사소송법이 사법과 공법 중 어느 영역에 속하는지, 그리고 그 근거가 무엇인지**에 대하여 구체적으로 검토한다.

II. 민사소송법의 공법적 성격

1. 공법과 사법의 구별 기준

- 법의 분류에서 공법은 국가 조직, 공공단체와의 관계, 국가 권력의 행사를 규율하는 법을 의미한다. 사법은 개인의 경제적 활동이나 가족 관계 등 사적 영역을 규율한다. **민사소송법**이 규율하는 민사소송절차는 사법상의 권리를 실현하기 위한 것이지만, 그 과정에서 국가의 사법권(司法權)이 개입한다는 점에서 독특한 위치를 점한다.

2. 국가기관인 법원의 개입

- 민사소송은 국가의 사법권(司法權) 행사 과정이다. 사인이 스스로의 힘으로 권리를 쟁취하는 자력구제는 원칙적으로 금지되며, 오직 국가가 설치한 법원을 통해서만 법적 분쟁을 해결할 수 있다. 법원은 국가의 통치권 중 하나인 사법권(司法權)을 행사하는 공공기관이며, **민사소송법**은 이러한 공공기관의 직무 수행 절차를 규정하므로 공법에 해당한다.

3. 강행법규적 성격

- 사법(私法)인 **민법**이나 **상법**은 사적 자치의 원칙에 따라 당사자의 합의가 법규보다 우선 적용되는 임의법규적 요소가 많다. 그러나, **민사소송법**은 국가가 공정한 재판을 보장하기 위해 설정한 절차법이므로, 당사자의 합의로 절차를 마음대로 변경할 수 없는 강행법규적 성격이 강하다. 이러한 강행성은 공법의 일반적인 특징이다.

III. 민사소송법의 절차법적 성격

1. 실체법과 절차법의 구분

- 법은 그 내용에 따라 실체법과 절차법으로 나뉜다. **민법**, **형법** 등은 권리와 의무의 발생, 소멸을 다루는 실체법이며, **민사소송법**, **형사소송법** 등은 그러한 실체적 권리를 실현하는 순서와 방법을 규정하는 절차법이다. **민사소송법**은 전형적인 절차법으로서 공정한 재판 절차를 유지하는 데 그 본질이 있다.

2. 소송계속과 판결의 효력

- **민사소송법**은 소를 제기하고, 변론을 진행하며, 판결을 내리고, 그 판결이 확정되는 일련의 역동적인 과정을 규율한다. 판결의 효력 중 하나인 기판력은 국가가 내린 최종적인 판단에 대하여 다시 다투지 못하게 하는 강력한 법적 힘을 부여하는데, 이는 사법(私法)상의 합의와는 차원이 다른 국가 공권력의 산물이다.

IV. 민법과의 관계 및 차이점

1. 사법(私法)의 실현을 위한 수단

- **민사소송법**은 실체법인 **민법**의 권리를 확정하고 강제적으로 실현하기 위한 도구적 역할을 수행한다. **민법**이 어떤 권리가 있는가를 다룬다면, **민사소송법**은 그 권리를 어떻게 증명하고 실현하는가를 다룬다. 이러한 관계 때문에 과거에는 **민법**의 부속물처럼 취급되기도 했으나, 현대 법학에서는 소송절차 고유의 논리와 목적을 인정하여 독립된 법 영역으로 간주한다.

2. 소송법적 효과와 실체법적 효과의 분리

- **민사소송법상** 행해지는 소송행위는 **민법상**의 의사표시와 구별된다. 예를 들어, 소송상 화해는 소송을 종결시키는 공법적 효과를 가짐과 동시에 당사자 간의 사법상 계약이라는 측면도 지닌다. 하지만, 절차의 안정성을 위해 소송행위에는 **민법상**의 착오나 사기·강박, 비진의 등의 의사표시 규정을 그대로 적용하지 않는 것이 원칙이다. 이는 **민사소송법**이 **민법**과는 다른 독자적인 공법 체계를 구축하고 있음을 보여준다.

V. 결론

- **민사소송법**은 사법(私法)상의 권리관계를 다루는 소송을 규율하지만, 그 법적 성격은 명백히 공법(公法)에 해당한다. 사법권(司法權)이라는 국가 통치권의 행사 절차를 규정하고 있으며, 법원이라는 국가기관과 소송 당사자 간의 관계를 규율하기 때문이다. 따라서 **민사소송법**은 국가 법 질서 내에서 공법 중에서도 절차법의 영역을 담당하며, 실체법인 **민법**을 실현하는 필수적인 장치로서 기능한다. 결론적으로 **민사소송법**은 사법의 실현을 목적으로 하는 공법이라고 정의할 수 있다.

<제1편 총설.제01장 민사소송.제03절 민사소송의 이상과 신의성실의 원칙>

[기출][2014-2]해고 후 임금 등을 수령하고 3년이 경과하여 제기한 소송의 실효 여부

《【문제2】 甲은 乙회사로부터 해고처분을 받고 임금과 퇴직금을 아무런 조건 없이 모두 수령하였다. 甲이 소를 제기하는 데에 특별한 장애사유가 없었음에도 3년여가 경과한 뒤 乙회사의 해고처분이 부당하다고 주장하면서 해고일로부터 정년 시까지의 임금의 지급을 구하는 소를 제기한 경우에 소권의 실효 여부에 관하여 설명하십시오. (25점)》

<문제2> 해고 후 임금 등을 수령하고 3년이 경과하여 제기한 소송의 실효 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 근로자 甲이 해고 처분 후 임금과 퇴직금을 조건 없이 수령하고, 3년이 지나 소를 제기한 상황이다. 쟁점으로 이와 같이 3년이 지나 소를 제기한 행위가 실효의 원칙에 위배되어 소권이 부정되는지 검토가 필요하다. 이하에서는 실효의 원칙의 의미, 요건, 사안의 경우 실효의 원칙 적용 여부에 대하여 설명한다.

II. 실효의 원칙의 의미 및 요건

1. 실효의 원칙의 의미

- 실효의 원칙이란 권리자가 실제로 권리를 행사할 수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 상당한 기간이 경과하도록 권리를 행사하지 아니하여, 상대방으로 하여금 이제는 권리자가 권리를 행사하지 아니할 것으로 신뢰할 만한 정당한 사유를 준 경우에 새삼스럽게 권리를 행사하는 것은 신의칙에 어긋나 허용되지 않는다는 원칙을 말한다.

2. 실효의 원칙의 요건

(1) 장기간의 권리 불행사

- 권리자가 유효하게 권리를 행사할 수 있었음에도 불구하고 상당한 기간 동안 이를 행사하지 않아야 한다. 여기서 상당한 기간의 판단은 구체적 사례에 따라 개별적으로 결정된다.

(2) 정당한 신뢰의 형성

- 상대방인 의무자가 이제는 권리자가 권리를 행사하지 않을 것이라고 믿을 만한 객관적이고 정당한 사유가 있어야 한다. 단순히 시간의 경과만으로는 부족하며, 권리자의 태도나 주변 정황이 고려된다.

III. 해고무효와 실효의 원칙에 관한 판례의 태도

1. 일반적인 기준

- 판례는 근로자가 해고를 당한 후 소송을 제기함에 있어 특별한 장애사유가 없음에도 불구하고 장기간이 경과하여 소를 제기한 경우, 사용자가 그 해고가 유효한 것으로 신뢰할 만한 정당한 사유가 있다면 실효의 원칙에 위배된다고 본다.

2. 퇴직금 등의 수령과 실효

(1) 조건 없는 수령

- 해고된 근로자가 퇴직금이나 해고예고수당 등을 수령하면서 아무런 이의를 제기하지 않았다면, 이는 해고를 수용하겠다는 의사표시로 해석될 여지가 크다.

(2) 예외적 상황

- 다만, 생계의 곤란 등으로 인해 부득이하게 수령했거나, 수령 시 이의를 제기한 경우, 또는 다른 동료들과 함께 복직 투쟁을 계속하고 있었던 경우 등은 실효의 원칙 적용이 배제될 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 장기간의 불행사 여부

- 사안에서 甲은 해고 처분을 받은 후 3년이라는 상당한 기간 동안 소송을 제기하지 않았다. 특히, 소를 제기하는 데에 특별한 장애사유가 없었음에도 불구하고 3년이 경과한 것은 실효의 원칙에서 말하는 장기간의 불행사에 해당할 가능성이 매우 높다.

2. 정당한 신뢰의 형성 여부

(1) 경제적 급부의 수령

- 甲은 해고 이후 乙회사로부터 임금과 퇴직금을 아무런 조건 없이 모두 수령하였다. 이는 사용자 乙의 입장에서 甲이 해고의 효력을 더 이상 다투지 않고 근로관계를 종료시키겠다는 의사로 신뢰하기에 충분한 정황을 제공한 것이다.

(2) 신뢰의 확정

- 장애사유 없는 3년의 침묵과 퇴직금의 전액 수령이 결합함으로써, 사용자는 새로운 직원을 채용하거나 기업 경영을 안정화하는 등 해고가 유효함을 전제로 한 후속 조치를 취했을 것이므로, 乙의 신뢰는 정당하다고 판단된다.

V. 결론

- 근로자 甲의 소 제기는 실효의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다. 해고 후 3년이라는 장기간의 권리 불행사와 임금 및 퇴직금의 무조건적 수령은 사용자 乙에게 권리 불행사에 대한 정당한 신뢰를 부여하였으므로, 뒤늦게 해고의 부당함을 주장하며 소를 제기하는 것은 신의성실의 원칙상 소권이 실효된 것으로 보아야 한다. 따라서 해당 소는 신의칙 위반을 이유로 부적법 각하되거나 청구 기각될 사안이다.

<제1편 총설.제01장 민사소송.제03절 민사소송의 이상과 신의성실의 원칙>

[모의][1.03-1]소송법상 실효의 원칙의 의의, 신의칙과의 관계, 성립 요건, 적용 범위 및 소송법상 효과

《【문제1.3-1】 소송법상 실효의 원칙에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제1.3의 물음1> 소송법상 실효의 원칙의 의의, 신의칙과의 관계, 성립 요건, 적용 범위 및 소송법상 효과

I. 소송법상 실효의 원칙의 의의 및 신의칙과의 관계

1. 소송법상 실효의 원칙의 의의

- 소송법상 실효의 원칙이란 권리자가 소송법상 권능을 행사할 수 있음에도 장기간 이를 행사하지 아니하여, 상대방에게 더 이상 그 권능을 행사하지 않을 것이라는 정당한 신뢰를 준 경우 그 후의 권리 행사를 허용하지 않는 원칙을 말한다. 이는 장기간 방치된 권리 행사를 차단함으로써 소송절차의 안정과 신속을 도모하는 데 취지가 있다.

2. 신의칙과의 관계

- 민사소송법 제1조 제2항은 당사자와 소송관계인이 신의에 따라 성실하게 소송을 수행하여야 한다는 신의성실의 원칙(이하 '신의칙')을 규정하고 있다. 소송법상 실효의 원칙은 이 신의칙의 파생 원칙인 모순행위금지의 원칙과 밀접한 관련이 있다. 과거의 불행사 상태와 모순되는 후행 소송행위를 제한함으로써 당사자 간의 신뢰를 보호하는 역할을 하기 때문이다.

II. 실효의 원칙의 성립 요건

1. 소송법상 권능의 장기간 불행사

(1) 소송상 권리·권능의 존재

- 실효의 대상이 되는 소송법상의 권능이 객관적으로 존재하고 있어야 하며, 권리자가 이를 행사할 수 있는 상태여야 한다.

(2) 상당한 기간의 경과

- 권리자가 소송상 권능을 행사할 수 있었음에도 불구하고 객관적으로 매우 장기간 동안 이를 행사하지 않고 방치하였어야 한다.

2. 상대방의 정당한 신뢰 형성

(1) 소송 상대방의 신뢰

- 권리자의 장기간에 걸친 권리 불행사로 인하여 소송 상대방에게 더 이상 해당 권능을 행사하지 않을 것이라는 신뢰가 형성되어 있어야 한다.

(2) 정당한 사유 및 객관적 사정

- 상대방이 그러한 신뢰를 가짐에 있어 정당한 사유가 있어야 하며, 객관적으로 신뢰를 가질 만한 사정 등이 배후에 뒷받침되어야 한다.

III. 적용 범위 및 소송법상 효과 (소송권능의 배척 또는 소각하)

1. 소송법상 실효의 원칙의 적용 범위

(1) 소송행위 및 소송법상의 권능

- 소송법상 이익권, 상소권, 소송 취소권 등 개별 소송행위에 원칙적으로 적용된다. 다만, 강행법규적 성격을 지닌 소송 요건이나 공익적 절차에는 신중하게 적용된다.

(2) 소제기 자체(소권)에의 적용

- 실체법상 권리에 기한 소제기 자체에도 실효의 원칙이 적용될 수 있다. 대법원은 근로자가 해고 후 아무런 이의 없이 퇴직금을 수령하고 수년이 지난 뒤에 제기한 해고무효확인인 소 등에서 실효의 원칙을 적용하여 소를 부정한다.

2. 실효의 소송법상 효과

(1) 소송권능의 배척(실효)

- 요건이 충족되면 해당 소송행위의 권능은 실효되며, 그 후에 행해진 소송행위는 신의칙에 반하는 위법한 행위로서 법적 효력이 배척된다.

(2) 부적법 각하(소각하)

- 소제기 자체(소권)가 실효된 경우, 그 소송은 소송 요건을 흠결한 부적법한 소에 해당하므로 법원은 본안 심리를 하지 않고 판결로 소를 각하하여야 한다.

IV. 결론

- 소송법상 실효의 원칙은 소송 절차의 법적 안정성과 당사자의 신뢰 보호를 위해 필수적인 신의칙의 파생 원칙이다. 다만, 남용될 경우 헌법상 보장된 당사자의 재판청구권을 침해할 우려가 있으므로, 법원은 상당한 기간의 경과와 상대방의 정당한 신뢰 여부를 엄격하게 판정하여 예외적으로만 적용하여야 한다.

<제2편 소송의 주체.제03장 법원.제02절 법관의 제척·기피·회피>

[모의][3.02-1]법관이 제1심 판결 후 항소심 재판부 구성원으로 참여하는 것이 전심관여 제척사유에 해당하는지 여부

《【문제3.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였다. 이 사건의 제1심 판결은 판사 A가 담당하여 甲의 승소로 판결하였다. 이에 乙이 불복하여 항소하였고, 항소심 사건은 판사 A, B, C로 구성된 합의부에 배당되었다. 그런데 판사 A는 제1심 판결을 선고한 후 정기 인사발령에 의해 해당 항소심 재판부로 자리를 옮긴 상태였다.

한편, 항소심 진행 중 판사 B는 해당 사건의 원고인 甲과 고등학교 동창 사이이며, 최근 甲의 자녀 결혼식에 참석하여 축의금을 전달한 사실이 밝혀졌다. 이를 알게 된 乙은 판사 B가 재판의 공정성을 해칠 우려가 있다고 판단하여 기피신청을 하고자 한다.

또한, 판사 C는 이 사건의 목적물과 관련된 별개의 민사소송에서 과거에 甲의 대리인으로 활동하였던 경력이 있음이 확인되었다.

(물음1) 판사 A가 항소심 재판부의 구성원으로 참여하는 것이 민사소송법상 제척사유인 "법관이 사건에 관하여 직무상 관여한 전심재판"에 해당하는지 여부를 근거와 함께 논하시오.》

<문제3.2의 물음1> 법관이 제1심 판결 후 항소심 재판부 구성원으로 참여하는 것이 전심관여 제척사유에 해당하는지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 제1심에서 원고 승소판결을 선고한 판사 A가 인사이동으로 동일 사건의 항소심 재판부 구성원이 되어 심리에 관여하게 된 상황이다. 쟁점으로 제1심 판결을 담당할 법관이 항소심 재판부에 참여하는 것이 민사소송법상 전심재판에 직무상 관여한 경우에 해당하여 제척사유가 되는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 판사 A의 항소심 관여가 전심재판 관여를 이유로 한 제척사유에 해당하는지 논한다.

II. 법관의 제척사유와 전심관여

1. 제척제도의 의의 및 취지

- 제척은 법관이 구체적인 사건과 특수한 관계에 있어 재판의 공정성을 기대하기 어렵다고 판단되는 경우, 법률이 정한 객관적 사유에 기해 당연히 직무집행을 배제하는 제도다. 이는 재판의 공정성에 대한 외관상의 신뢰를 확보하고 불공정한 재판을 사전에 방지하는 데 목적이 있다.

2. 전심관여의 요건

- 민사소송법 제41조 제5호에 따른 제척이 성립하기 위해서는 다음의 요건을 충족해야 한다.

(1) 전심재판의 존재

- 전심재판이란 상급심의 심판 대상이 된 하급심의 재판을 의미한다. 즉, 항소심의 입장에서 제1심 재판은 전심재판이 된다.

(2) 직무상 관여

- 법관이 전심재판의 최종 판단인 판결의 성립이나, 그 기초가 되는 사실인정 및 법률판단에 실질적으로 관여했어야 한다.

(3) 사건의 동일성

- 당해 사건과 전심 사건이 동일한 사건이어야 한다. 사건번호가 다르더라도 실질적으로 동일한 분쟁을 다루는 경우라면 이에 해당한다.

III. 전심관여의 구체적 판단 기준

1. 판례의 태도

- 대법원은 제척사유인 전심관여를 엄격하게 해석한다. 판례는 최종변론과 판결의 합의에 관여하거나 종국 판결과 더불어 상급심의 판단을 받는 중간적인 재판에 관여함을 말하는 것이고, 최종변론 전의 변론, 증거조사, 기일지정과 같은 소송 지휘상의 재판 등에 관여한 경우는 포함되지 않는다고 판시한다.

2. 심급의 이익 보호

- 전심재판에 관여한 법관이 상급심 재판에 다시 참여하게 되면, 자신이 내린 선행 재판을 스스로 번복하기 어려울 것이라는 심리적 편견이 작용할 수 있다. 이는 당사자가 가지는 심급의 이익을 침해할 우려가 크므로, 헌법상 보장된 공정한 재판을 받을 권리를 보호하기 위해 이를 금지하는 것이다.

IV. 사안의 적용

1. 판사 A의 지위와 전심재판

- 사안에서 판사 A는 당해 사건의 제1심 판결을 담당하여 甲의 승소 판결을 직접 선고하였다. 이는 항소심의 심판 대상이 되는 전심재판에 해당하며, 판사 A는 판결의 핵심인 합의와 선고에 모두 참여한 자로서 실질적인 직무상 관여가 인정된다.

2. 제척사유의 성립 여부

- 항소심은 제1심의 당부를 판단하는 절차다. 판사 A가 항소심 재판부의 일원으로 참여하게 된다면, 乙이 제기한 항소 이유를 객관적으로 검토하기보다는 자신이 내린 제1심 판결의 정당성을 유지하려는 경향을 보일 가능성이 매우 높다. 이는 민사소송법 제41조 제5호가 금지하는 전형적인 전심관여의 사례다. 비록 정기 인사발령이라는 적법한 행정적 절차에 의해 항소심 재판부로 배속되었다 하더라도, 법관 개인의 신상 변화가 법률상 규정된 제척사유의 발생을 막지는 못한다.

V. 결론

- 판사 A는 제1심 판결이라는 전심재판에 실질적으로 관여한 법관이므로, 동일 사건의 항소심 재판부 구성원으로 참여하는 것은 민사소송법 제41조 제5호의 제척사유에 해당한다. 따라서 판사 A는 해당 항소심 사건의 직무집행에서 당연히 배제되어야 하며, 만약 판사 A가 참여한 상태에서 항소심 판결이 내려진다면 이는 절대적 상고이유인 판결 관여 불능 판사의 관여에 해당하여 파기 사유가 된다.

《【문제3.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였다. 이 사건의 제1심 판결은 판사 A가 담당하여 甲의 승소로 판결하였다. 이에 乙이 불복하여 항소하였고, 항소심 사건은 판사 A, B, C로 구성된 합의부에 배당되었다. 그런데 판사 A는 제1심 판결을 선고한 후 정기 인사발령에 의해 해당 항소심 재판부로 자리를 옮긴 상태였다.

한편, 항소심 진행 중 판사 B는 해당 사건의 원고인 甲과 고등학교 동창 사이이며, 최근 甲의 자녀 결혼식에 참석하여 축의금을 전달한 사실이 밝혀졌다. 이를 알게 된 乙은 판사 B가 재판의 공정성을 해칠 우려가 있다고 판단하여 기피신청을 하고자 한다.

또한, 판사 C는 이 사건의 목적물과 관련된 별개의 민사소송에서 과거에 甲의 대리인으로 활동하였던 경력이 있음이 확인되었다.

(물음2) 乙이 판사 B에 대하여 제기하려는 기피신청의 원인인 "재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정"의 객관적 기준과 기피신청 시 소송절차의 정지 여부에 대하여 설명하시오.》

<문제3.2의 물음2> 기피원인인 재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정의 객관적 기준과 기피신청 시 소송절차의 정지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 항소심 재판부의 판사 B가 원고 甲과 고등학교 동창이고 최근 甲의 자녀 결혼식에 참석하여 축의금을 전달한 사실이 밝혀져 乙이 재판의 공정성을 이유로 기피신청을 하려는 상황이다. 쟁점으로 민사소송법상 재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정의 객관적 판단기준과 기피신청이 제기된 경우 소송절차의 정지 여부를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 판사 B에 대한 기피사유의 인정 여부와 기피신청에 따른 소송절차의 효력에 대해 설명한다.

II. 기피원인 : 재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정

1. 의의 및 판례의 객관적 기준

(1) 의의

- 민사소송법 제43조 제1항은 법관에게 공정한 재판을 기대하기 어려운 사정이 있는 때에는 기피신청을 할 수 있다고 규정한다.

(2) 객관적 기준에 관한 판례의 태도 ★

- 판례는 재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정이란 당사자가 주관적으로 불신감을 갖는 것만으로는 부족하고, 통상인의 판단에 의하더라도 법관이 편파적인 재판을 할 것이라는 의심을 가질 만한 객관적인 사정이 있는 경우를 의미한다고 본다. 즉, 법관과 당사자의 친분 관계, 원한 관계, 법관이 해당 사건의 승패에 직접적인 이해관계를 가졌다고 보일 만한 외관이 존재해야 한다.

2. 사안의 경우

- 판사 B가 원고 甲과 고교 동창이라는 사실이나 경조사에 참여하여 축의금을 전달한 사실은 한국 사회의 통상적인 사교례에 해당할 수 있다. 그러나 그 친분의 정도가 단순한 지인을 넘어 각별하여 재판 결과에 영향을 미칠 정도라면 객관적 기피사유가 될 수 있다. 다만, 실무상 단순한 동창 관계만으로는 기피신청이 인용되기 어려우며, 구체적으로 불공정한 재판 진행이 동반되어야 기피의 객관적 타당성이 인정될 것이다.

III. 기피신청과 소송절차의 정지

1. 원칙 : 소송절차의 정지

- 민사소송법 제48조 본문에 의하면 법원은 기피신청이 있는 경우 기피신청에 대한 재판이 확정될 때까지 소송절차를 정지하여야 한다. 이는 불공정한 재판을 받을 위험이 있는 상태에서 소송이 강행되는 것을 방지하기 위함이다. 정지되는 절차는 해당 기피 법관이 관여하는 모든 소송행위를 포함한다.

2. 예외 : 소송절차를 정지하지 않는 경우

- 소송의 지연을 목적으로 하는 무분별한 기피신청으로부터 재판의 효율성을 보호하기 위해 다음과 같은 예외를 둔다.

(1) 기피신청의 각하 [민소법 제45조 제1항]

- 기피신청이 신청권을 남용하는 것이 명백하거나, 기합의된 기피신청 방식에 어긋나는 경우 등 요건을 갖추지 못한 때에는 원심법원이 결정으로 이를 각하할 수 있으며, 이 경우에는 절차를 정지하지 않는다.

(2) 종국판결의 선고

- 판례와 통설에 의하면, 변론이 종결된 후 판결만을 선고하는 단계에서는 기피신청이 있더라도 소송절차를 정지하지 않고 판결을 선고할 수 있다.

(3) 긴급을 요하는 행위

- 증거인멸의 우려가 있거나 기일을 늦출 경우 당사자에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있는 긴급한 행위는 절차 정지 중에도 예외적으로 허용된다.

IV. 절차 정지 위반의 효력

1. 절차 위반의 원칙적 효력

- 소송절차 정지 규정을 위반하여 진행된 소송행위는 원칙적으로 무효다. 따라서 기피신청 중 정지하지 않고 진행한 변론이나 증거조사 등은 효력이 없다.

2. 하자의 치유

- 기피신청이 최종적으로 기각 확정된 경우에는 절차 정지 규정을 위반하여 행한 소송행위라도 그 하자가 치유되어 유효한 것으로 간주된다. 이는 기결정된 기각 재판을 존중하여 소송 경제를 도모하기 위함이다.

V. 결론

- 乙이 판사 B에 대하여 제기하려는 기피신청은 통상인의 관점에서 공정성을 의심할 만한 객관적 사정이 입증되어야 한다. 기피신청이 접수되면 법원은 원칙적으로 소송절차를 정지해야 하며, 예외적으로 신청이 명백히 부적법하여 각하되는 경우나 긴급한 행위 등이 아닌 한 재판을 계속해서 안 된다. 만약, 법원이 절차를 정지하지 않고 재판을 강행하였으나 이후 기피신청이 기각된다면 그 소송행위의 하자는 치유되나, 기피신청이 인용된다면 해당 소송행위는 무효가 된다.

<제2편 소송의 주체.제03장 법원.제02절 법관의 제척·기피·회피>

[모의][3.02-3]제척사유가 있는 법관이 스스로 직무집행을 피하는 회피의 절차와 효과

《【문제3.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였다. 이 사건의 제1심 판결은 판사 A가 담당하여 甲의 승소로 판결하였다. 이에 乙이 불복하여 항소하였고, 항소심 사건은 판사 A, B, C로 구성된 합의부에 배당되었다. 그런데 판사 A는 제1심 판결을 선고한 후 정기 인사발령에 의해 해당 항소심 재판부로 자리를 옮긴 상태였다.

한편, 항소심 진행 중 판사 B는 해당 사건의 원고인 甲과 고등학교 동창 사이이며, 최근 甲의 자녀 결혼식에 참석하여 축의금을 전달한 사실이 밝혀졌다. 이를 알게 된 乙은 판사 B가 재판의 공정성을 해칠 우려가 있다고 판단하여 기피신청을 하고자 한다.

또한, 판사 C는 이 사건의 목적물과 관련된 별개의 민사소송에서 과거에 甲의 대리인으로 활동하였던 경력이 있음이 확인되었다.

(물음3) 판사 C의 경우와 같이 제척사유가 있음에도 불구하고 법관이 스스로 직무집행을 피하는 제도인 회피의 절차와 효과에 대하여 기술하십시오.》

<문제3.2의 물음3> 제척사유가 있는 법관이 스스로 직무집행을 피하는 회피의 절차와 효과

I. 문제의 제기

- 사안에서 판사 C는 이 사건의 목적물과 관련된 별개의 민사소송에서 과거 甲의 대리인으로 활동한 경력이 있는 상황이다. 쟁점으로 **민사소송법상 법관의 회피가 인정되는 절차와 회피가 허가된 경우 발생하는 절차적 효력**을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 판사 C의 회피 절차와 그에 따른 효과에 대하여 기술한다.

II. 회피의 의의 및 요건

1. 회피의 의의

- 회피는 법관이 자기에게 제척 또는 기피의 사유가 있다고 인정하는 때에 스스로 당해 사건의 직무집행을 피하는 것을 말한다. 이는 법관의 양심과 명예를 존중하고, 불필요한 기피신청 절차를 생략하여 소송의 경제와 재판의 신뢰를 도모하는 데 목적이 있다.

2. 회피의 요건

- 법관은 자신에게 **민사소송법 제41조**(제척의 이유) 또는 **제43조**(당사자의 기피권)에 해당하는 사유가 있다고 판단될 때 회피할 수 있다. 사안의 판사 C와 같이 과거에 당사자의 대리인이었거나 사건에 실질적으로 관여한 바가 있다면, 이는 객관적으로 재판의 공정성을 의심받을 수 있는 상황이므로 회피의 요건을 충족한다.

III. 회피의 절차

1. 회피의 신청

- 법관은 회피하고자 하는 경우 소속 법원에 회피의 뜻을 표시하여야 한다. 이때 회피의 사유를 서면으로 소명하는 것이 원칙이다. 기피신청과 달리 당사자의 청구에 의하는 것이 아니라 법관의 자발적 의사에 의해 개시된다는 점에 특징이 있다.

2. 감독법원의 허가

- 회피는 법관이 임의로 결정하는 것이 아니라, 법원(감독법원)의 허가를 받아야 한다. **민사소송법 제49조**는 감독권이 있는 법원의 허가를 받아 회피할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 법관이 자의적으로 재판을 기피하는 것을 방지하고 재판부 구성의 안정성을 유지하기 위함이다.

IV. 회피의 효과

1. 직무집행의 배제

- 회피 신청에 대하여 법원의 허가 결정이 내려지면, 해당 법관은 당해 사건에 관한 모든 직무집행에서 배제된다. 이후 해당 사건은 법원의 사무분담에 따라 다른 법관이나 재판부로 재배당된다.

2. 소송행위의 효력

(1) 허가 결정 전의 행위

- 회피 사유가 있음에도 허가 결정이 내려지기 전에 해당 법관이 행한 소송행위는 당연히 무효가 되는 것은 아니다. 다만, 제척사유가 있는 법관이 관여한 경우라면 이후 상소나 재심의 사유가 될 수 있다.

(2) 허가 결정 후의 행위

- 회피 허가 결정이 내려진 후에 해당 법관이 행한 소송행위는 직무권한 없는 자의 행위로서 무효가 된다.

3. 소송절차의 정지 여부

- 기피신청의 경우에는 법률상 절차 정지 규정이 명시되어 있으나, 회피는 법관의 자발적 신청과 법원의 내부적 허가 절차로 진행되므로 기피와 같은 엄격한 절차 정지 규정은 없다. 그러나 실무적으로는 회피 신청이 접수되면 허가 여부가 결정될 때까지 해당 사건의 심리를 중단하는 것이 통례다.

V. 결론

- 사안의 판사 C는 과거 甲의 대리인으로 활동한 경력이 있어 제척사유에 해당하므로, 스스로 회피 신청을 하는 것이 타당하다. 판사 C가 소속 법원에 회피 신청을 하여 허가 결정을 받으면 해당 사건의 재판부에서 적법하게 제외된다. 이러한 회피 제도는 당사자의 기피신청에 따른 불필요한 감정 대립이나 소송 지연을 막고, 법관 스스로 재판의 공정성을 확보하게 함으로써 사법 제도에 대한 국민의 신뢰를 높이는 중요한 기능을 수행한다.

<제2편 소송의 주체.제03장 법원.제02절 법관의 제척·기피·회피>

[모의][3.02-4]법관의 기피제도의 의의 및 제척제도와의 구별, 기피사유, 절차 및 원칙, 남용과 간이각하결정

《【문제3.2-4】 법관의 기피제도에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제3.2의 물음4> 법관의 기피제도의 의의 및 제척제도와의 구별, 기피사유, 절차 및 원칙, 남용과 간이각하결정

I. 법관 기피제도의 의의 및 제척제도와의 구별

1. 법관 기피제도의 의의

- 법관 기피제도는 법관에게 법률이 정한 제척사유가 없음에도 불구하고 재판의 공정성을 기대하기 어려운 객관적인 사정이 있는 경우, 당사자의 신청에 의하여 그 법관을 해당 사건의 직무집행에서 배제하는 소송법상 제도를 의미한다.

2. 제척제도와의 구별

(1) 법정 사유

- 제척은 법률이 정한 구체적이고 객관적인 배제 사유가 있는 경우에 법관이 당연히 직무집행에서 배제되는 제도인 반면, 기피는 법정 제척 사유 이외에 재판의 공정성을 우려할 만한 객관적 사정이 존재할 때 당사자의 신청을 통해 배제되는 제도라는 점에서 구별된다.

(2) 직무 배제

- 제척은 별도의 신청 없이도 법률상 당연히 직무배제의 효력이 발생하는 데 반해, 기피는 반드시 당사자의 명시적인 신청과 이에 대한 다른 법관(또는 법원)의 구체적인 결정 재판이 있어야만 법적인 효력이 발생한다.

II. 기피사유 (재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정의 의미)

1. 객관적 사정의 의미 ★

- 대법원은 재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정이란 당사자가 주관적으로 법관의 불공정을 우려하는 사정을 뜻하는 것이 아니라고 본다. 이는 통상인의 판단을 기준으로 하여, 객관적으로 법관과 사건의 관계나 친분 혹은 원한 등으로 인해 불공정한 재판을 할 것이라는 의심을 품을 만한 객관적·합리적인 사정이 배후에 존재하는 경우를 의미한다.

2. 당사자의 주관적 불복과의 구별

- 따라서 법관의 소송지휘나 증거채택 여부에 대한 단순한 불만, 당사자의 주관적인 의심 등은 기피사유에 해당하지 않는다. 기피사유는 제도를 무분별하게 남용하려는 의도를 억제하기 위하여 객관적이고 구체적인 사실에 의해 입증되는 범위 내로 엄격하게 한정 적용되어야 한다.

III. 기피신청의 절차 및 소송절차의 정지 원칙

1. 기피신청의 절차

(1) 신청의 방식 및 관할

- 당사자는 기피하고자 하는 법관의 소속 법원에 신청서를 제출하여 서면으로 신청하는 것이 원칙이다. 다만, 소송기일에는 법정에서 구술로도 신청할 수 있다.

(2) 신청의 시기

- 기피신청은 본안에 대하여 변론하거나 법관에게 질문을 받기 전에 제기하여야 한다. 다만, 변론 개시 후에 기피사유가 새로 발생하였거나 그 사유의 존재를 사후에 알게 된 경우에는 변론 중에도 신청이 가능하다.

2. 소송절차의 정지 원칙 [민사소송법 제48조]

(1) 정지 의무의 원칙적 강행성

- 민사소송법 제48조 본문에 따라 법관에 대한 기피신청이 접수되면 법원은 기피신청에 대한 재판이 확정될 때까지 원칙적으로 소송절차를 정지하여야 한다. 이는 기피당한 법관이 편파적인 심리를 속행하는 행위를 차단하기 위한 강행규정이다.

(2) 정지 원칙의 합리적 예외

- 소송의 지연을 목적으로 함이 명백한 기피신청이거나 긴급을 요하는 경우, 그리고 이미 변론이 종결되어 종국판결을 선고하는 경우에 해당할 때에는 소송절차를 정지하지 아니하고 심리를 진행할 수 있다.

IV. 기피신청의 남용과 간이각하결정

1. 기피신청 남용의 방지 필요성

- 기피제도는 공정한 재판을 위한 헌법상 보장 장치이나, 소송 당사자가 패소 판결을 늦추거나 재판부를 압박하기 위한 소송 지연의 수단으로 악용하는 부작용이 발생한다. 소송경제와 신속한 재판의 원칙을 수호하기 위해 이러한 남용 행위를 규제할 장치가 수반되어야 한다.

2. 간이각하결정 제도

(1) 주체 및 대상

- 기피신청이 단지 소송을 지연시킬 목적임이 객관적으로 명백한 경우, 신청을 받은 해당 법원 또는 법관은 변론을 정지하지 않고 결정으로 기피신청을 즉시 각하할 수 있다.

(2) 법적 효과

- 간이각하결정이 내려지는 사안은 소송정지 의무를 발생시키지 않으므로, 법원은 본안사건의 심리 및 변론을 중단 없이 원활하게 속행할 수 있어 소송의 불필요한 지연을 예방한다.

V. 결론

- 법관 기피제도는 재판의 객관적 신뢰성과 당사자의 공정한 재판을 받을 권리를 실질적으로 보호하는 소송법상의 안전장치이다. 기피신청이 있는 경우 소송절차를 정지하도록 한 민사소송법 제48조의 강행규정은 이러한 가치를 보장하기 위한 핵심 원칙이다. 다만, 이를 소송 지연 전술로 악용하는 남용 행위로부터 사법 신뢰를 보호하기 위해, 법원은 객관적 판단 기준을 엄격히 고수하는 한편 악의적인 남용에 대해서는 간이각하 제도를 엄정하게 적용하여 법적 안정성과 소송의 신속을 조화롭게 도모해야 한다.

<제2편 소송의 주체.제03장 법원.제03절 관할>

[기출][2015-2]사물관할의 의의, 결정 기준, 구체적 범위

《【문제2】 사물관할에 하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 사물관할의 의의, 결정 기준, 구체적 범위

I. 사물관할의 의의

- 민사소송법상 사물관할이란 제1심 소송사건에 대하여 지방법원 단독판사와 지방법원 합의부 간에 사건의 경중을 기준으로 하여 재판권의 부담관계를 정해 놓은 것을 말한다. 사물관할의 적정한 부담은 재판의 신속성과 신중성을 동시에 조화롭게 달성하기 위한 법적 장치로서 실무상 매우 중요하다.

II. 사물관할의 의의 및 결정(소가) 기준

1. 사물관할의 개념 및 구별

- 사물관할은 제1심 소송사건을 다루는 단독판사와 합의부 사이의 관할 부담이다. 이는 법원 내부의 단순한 사무분담이 아닌 법률상 관할의 문제이므로, 이를 위반한 소제기는 관할위반으로서 이송의 대상이 된다.

2. 소송목적의 값(소가) 산정 법리

- 소가는 원고가 소로써 달성하려는 객관적인 경제적 이익을 기준으로 산정한다.

(1) 산정의 기준시기

- 민사소송법 제26조 제1항에 의하여 소가는 소를 제기한 때를 기준으로 산정하며, 소제기 이후 목적물의 가격 변동 등 사정변경이 있더라도 사물관할에는 영향이 없다.

(2) 산정의 일반 원칙

- 소가는 원고가 전부 승소할 경우에 직접 받게 되는 경제적 이익을 화폐 단위로 평가하여 산출하며, 병합 청구의 경우 원칙적으로 청구의 값을 합산하여 산정한다.

III. 단독판사와 합의부의 구체적 사물관할

1. 지방법원 합의부의 관할 범위

- 지방법원 및 지방법원의 합의부는 비교적 무겁고 신중한 판단이 필요한 다음 사건을 제1심으로 심판한다.

(1) 소가 기준에 따른 관할

- 민사 및 가사소송의 사물관할에 관한 규칙에 따라 소송목적의 가액이 5억 원을 초과하는 민사사건 및 소가를 산출할 수 없는 사건(비재산권상의 소 등)은 합의부 관할에 속한다.

(2) 재정 및 관련 청구 기준

- 합의부에서 심판할 것으로 합의부가 스스로 결정한 재정합의사건과, 합의부 관할인 본소에 병합하여 제기하는 반소 또는 독립당사자참가 등의 관련청구는 합의부가 관할한다.

2. 지방법원 단독판사의 관할 범위

- 지방법원 단독판사는 신속한 해결이 요구되는 비교적 가벼운 사건을 제1심으로 심판한다.

(1) 원칙적 단독 관할 사건

- 소송목적의 가액이 5억 원 이하인 사건은 단독판사의 관할에 해당하며, 소가 2억 원 초과 5억 원 이하의 고액단독사건은 경험이 풍부한 부장판사가 담당하도록 편제되어 있다.

(2) 특수 및 재정단독 사건

- 수표금·어음금 청구사건 및 금융기관의 대여금 청구사건 등은 사안이 명확하고 신속한 권리 실현이 요구되므로 소가와 관계없이 단독판사가 관할한다. 또한 합의부 사건 중 단독판사가 심판하도록 합의부가 결정한 재정단독사건 역시 이에 속한다.

IV. 구체적 예시

1. 6억 원의 대여금 청구소송을 제기하는 경우

- 소가 5억 원을 초과하는 민사사건이므로 사건의 중대성을 고려하여 제1심 법원으로서 지방법원 합의부에 소를 제기하여야 한다. 만약, 이를 단독판사에게 잘못 제기한 경우 법원은 직권으로 관할권이 있는 합의부에 이송하여야 한다.

2. 3억 원의 손해배상청구소송을 제기하는 경우

- 소가 5억 원 이하인 민사사건에 해당하므로 제1심 관할법원은 지방법원 단독판사가 된다. 다만, 당사자가 제1회 변론기일 전에 합의부 심리를 신청하거나 사건의 난이도가 높은 경우 재정합의 결정을 통해 합의부로 이송할 수 있다.

V. 결론

- 사물관할은 제1심 소송의 경중에 따라 재판의 효율성과 신중성을 기하기 위하여 합의부와 단독판사 간에 재판권을 부담하는 제도이다. 현행 민사 및 가사소송의 사물관할 규칙에 따라 소가 5억 원을 기준으로 초과 시 합의부, 이하 시 단독판사가 담당하는 체계를 취하되, 어음·수표금 등 특수 사건은 단독판사의 고유관할로 둔다. 사물관할은 강행규정이 아니므로 당사자 합의나 변론관할의 성립이 가능하나, 원칙적으로 관할 규정을 그르친 소제기에 대하여 법원은 이송결정을 통해 적법한 수소법원에서 재판이 이루어지도록 조정하여 국민의 재판받을 권리를 실체적으로 보장하고 있다.

<제2편 소송의 주체.제03장 법원.제03절 관할>

[기출][2019~2]합의관할의 의의, 성립요건, 종류, 효력

《【문제2】 합의관할에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 합의관할의 의의, 성립요건, 종류, 효력

I. 합의관할의 의의

- 합의관할이란 **민사소송법 제29조**에 따라 제1심 법원에 한하여 당사자 사이의 합의에 의하여 생기는 관할을 말한다. 이는 당사자의 편의를 도모하고, 소송 절차에 사적 자치를 반영하기 위한 제도로써, 법정관할에 우선하여 관할권이 발생한다. 합의는 소송계속 전후를 불문하고 가능하며, 특정 법원에 관할권을 부여하거나 기존 관할권을 배제하는 방식으로 이루어진다. 다만, 법적 안정성과 재판의 공정성을 위해 일정한 요건을 갖추어야 하며 전속관할에는 적용되지 않는 등 일정한 한계가 존재한다.

II. 합의관할의 성립요건

1. 제1심 법원의 관할에 관한 합의일 것

- 합의관할은 제1심 법원에 한하여 인정된다. 상소심(항소심, 상고심)의 관할은 법률에 의해 엄격히 규정되어 있으므로 당사자의 합의로 변경할 수 없다.

2. 법정의 재판적 중 임의관할에 관한 합의일 것

- 합의관할은 임의관할인 경우에만 성립한다. **민사소송법 제31조**에 따라 전속관할로 정해진 사건(전속적 합의가 아닌 법정 전속관할 사건)에 대해서는 합의관할이 인정되지 않는다.

3. 특정한 법률관계에 관한 합의일 것

- 모든 분쟁을 특정 법원의 관할로 한다는 식의 포괄적 합의는 무효이다. 특정한 법률관계에서 발생하는 소송(예 : A와 B 사이의 2024년 3월 19일자 매매계약에 관한 소송)에 관한 합의여야 한다.

4. 관할법원이 특정되어 있을 것

- 합의에 의해 지정되는 법원은 특정되어야 한다. 모호한 지정(예 : 대한민국의 법정 중 하나)은 무효이다. 다만, 사후적으로 특정 가능한 방식(예 : 원고의 주소지 법원)은 허용된다.

5. 방식 및 시기

- 합의의 방식은 **민사소송법 제29조 제2항**에 따라 서면으로 하여야 한다. 이는 합의의 존부와 내용을 명확히 하기 위함이다. 합의의 시기는 소제기 전은 물론 소송계속 중에도 가능하다.

III. 합의의 종류

1. 전속적 합의

- 특정 법원에만 관할권을 인정하고 다른 법원의 관할권을 배제하는 합의를 말한다.

2. 부가적 합의

- 법정관할권은 그대로 유지하면서 특정 법원을 관할법원으로 추가하는 합의를 말한다. 이 경우 원고는 법정관할법원과 합의관할법원 중 선택하여 소를 제기할 수 있다.

3. 판례의 입장

- **판례**는 전속적 합의인지 여부가 불분명할 경우, 법정관할 중 하나를 선택한 것이라면 부가적 합의로, 법정관할 이외의 법원을 선택한 것이라면 전속적 합의로 추정하는 경향이 있다.

IV. 합의관할의 효력

1. 관할권의 발생

- 적법한 합의가 이루어지면 합의된 법원에 관할권이 발생한다. 전속적 합의의 경우 합의된 법원만이 관할권을 가지며, 법정관할권은 소멸한다.

2. 효력의 주관적 범위

(1) 당사자 및 일반승계인

- 합의의 효력은 합의를 한 당사자와 그 상속인 등 일반승계인에게 당연히 미친다.

(2) 특별승계인

- **판례**는 지명채권의 양수인과 같은 특별승계인에 대하여, 채권의 내용 자체에 합의관할 조항이 포함되어 있다면 그 효력이 미치는 것으로 본다. 다만, 물건적 청구권의 승계인에 대해서는 합의의 효력이 미치지 않는다고 보는 것이 일반적이다.

3. 합의관할의 유효성 심사

(1) 약관에 의한 관할합의

- 금융기관이나 대기업이 사용하는 약관에 관할합의 조항이 포함된 경우, 고객에게 일방적으로 불리하거나 재판받을 권리를 부당하게 제한한다면 약관의 규제에 관한 법률에 의해 무효가 될 수 있다.

(2) 전속관할과의 관계

- 법률상 전속관할로 지정된 사건(예 : 재심, 제권판결 등)에 대하여 당사자가 합의로 다른 법원을 지정하더라도 이는 효력이 없다. 전속관할은 공익적 이유로 법이 강제한 것이기 때문이다.

V. 결론

- 합의관할은 당사자의 의사를 존중하여 소송 편의를 극대화하는 제도이다. 특히, 국제거래나 기업 간 거래에서 분쟁 발생 시 예측 가능성을 높여주는 중요한 역할을 한다. 법원은 합의관할의 요건인 서면성 및 특정성을 엄격히 심사하여 당사자의 합의 의사가 왜곡되지 않도록 해야 한다. 또한, 경제적 약자가 약관 등을 통해 재판권 행사에 부당한 제약을 받지 않도록 신의칙과 약관규제법을 통해 적절히 통제해야 할 것이다.

<제2편 소송의 주체.제03장 법원.제03절 관할>

[기출][2020-1-1]당사자표시정정 후의 관할권 인정 여부와 변론관할의 성립

《【문제1】 甲(수원에 주소를 두고 살고 있음)은 대전에 소재한 자기 토지를 乙(대구에 주소를 두고 살고 있음)에게 매도하고 매매잔대금 1억 원을 받지 못하여, 그 지급을 구하는 소를 대전지방법원에 제기하였다. 이후에 甲은 乙이 소제기 이전에 사망하였다는 사실과 乙의 유일한 상속인인 丙(대구에 주소를 두고 살고 있음)이 있다는 사실을 알게 되었다. 甲은 피고를 丙으로 바꾸는 신청을 하였고 법원은 당사자표시정정하여 피고를 丙으로 바꾸었다. 다음 물음에 답하시오. (50점) (단, 아래의 각 물음은 상호 독립적임)

(물음1) 丙은 변론기일에 출석하여 위 매매대금은 모두 지급되었으므로 甲의 이 사건 소에 대하여 청구기각을 구한다는 진술을 하였다. 위 법원에 관할권이 인정되는지를 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 당사자표시정정 후의 관할권 인정 여부와 변론관할의 성립

I. 문제의 제기

- 사안은 원고 甲이 이미 사망한 乙을 피고로 하여 소송물이 위치한 대전지방법원에 소를 제기하였다가, 이후 상속인 丙으로 당사자표시를 정정한 상황이다. 쟁점으로 **소가 지참채무인 매매잔대금 지급 청구로서 의무이행지(수원)나 피고의 주소지(대구)가 아닌 대전지방법원에 제기된바, 토지의 소재지라는 이유만으로 관할권이 발생하는지(특별재판적), 그리고 당사자표시정정의 적법성 및 丙이 본안에 관하여 변론함으로써 변론관할(민사소송법 제30조)이 성립할 수 있는지**를 검토해야 한다. 이하에서는 당사자표시정정의 효력과 토지관할의 종류 및 변론관할의 성립 요건을 중심으로 관할권 인정 여부를 논한다.

II. 사망 피고에 대한 소제기와 당사자표시정정

1. 사망 피고에 대한 소제기의 효력

- 원고가 피고의 사망 사실을 모르고 사망자를 피고로 기재하여 소를 제기한 경우, 실질적인 당사자는 사망자의 상속인이며 표시만 사망자로 잘못된 것으로 본다. 따라서 이 소송은 부적법하여 각하될 대상이 아니라 표시를 바로잡음으로써 유효하게 계속될 수 있다.

2. 당사자표시정정의 적법성

- **판례**는 소제기 전 사망자를 피고로 한 경우라도 실질적 당사자인 상속인으로 표시를 정정하는 것을 허용한다. 사안에서 甲이 乙의 상속인인 丙으로 피고를 바꾼 신청은 당사자의 동일성을 해치지 않는 적법한 당사자표시정정에 해당하며, 소송의 효력은 소제기 시로 소급하여 丙에게 미친다.

III. 대전지방법원의 토지관할권 검토

1. 보통재판적 [민사소송법 제2조, 제3조]

- 피고의 보통재판적은 주소지에 따라 결정된다. 丙의 주소지는 대구이므로 대구지방법원이 보통재판적 소재지 관할법원이 된다.

2. 특별재판적

(1) 의무이행지의 특별재판적 [민사소송법 제8조]

- 재산권에 관한 소는 의무이행지의 법원에 제기할 수 있다. 매매잔대금 지급 채무는 원칙적으로 채권자의 주소지에서 이행해야 하는 지참채무이므로, 원고 甲의 주소지인 수원지방법원에 특별재판적이 인정된다.

(2) 부동산 소재지의 특별재판적 [민사소송법 제20조]

- 부동산에 관한 소는 부동산이 있는 곳의 법원에 제기할 수 있다. 그러나 **판례**는 부동산에 관한 소를 부동산 자체에 대한 소유권, 점유권 등 물권적 청구권이나 등기청구권 등에 한정하며, 매매대금 지급을 구하는 채권적 청구는 이에 포함되지 않는다고 본다. 따라서 대전지방법원은 부동산 소재지라는 이유만으로는 관할권을 가지지 못한다.

IV. 변론관할의 성립 여부

1. 변론관할의 의의 및 요건 [민사소송법 제30조]

- 원고가 관할권 없는 법원에 소를 제기하였더라도, 피고가 관할위반의 항변을 하지 아니하고 본안에 대하여 변론하거나 변론준비기일에서 진술한 때에는 그 법원에 관할권이 생긴다.

(1) 원고가 관할권 없는 법원에 소를 제기하였을 것

- 대전지방법원은 앞서 살펴본 바와 같이 보통재판적이나 특별재판적 어느 것도 인정되지 않는 법원이다.

(2) 피고가 관할위반의 항변을 하지 않고 본안변론을 하였을 것

- 사안에서 피고 丙은 변론기일에 출석하여 '매매대금이 모두 지급되었다'며 청구기각을 구하는 진술을 하였다. 이는 소송요건이 아닌 소송물인 권리관계 자체에 관한 진술이므로 본안변론에 해당한다.

(3) 법원이 관할권이 없음을 간과하였을 것

- 법원이 관할위반임을 지적하여 이송하기 전에 피고의 변론이 이루어져야 한다.

2. 변론관할의 제한 [민사소송법 제31조]

- 변론관할은 임의관할인 경우에만 성립하며, 전속관할이 정해져 있는 경우에는 성립하지 않는다. 매매대금 청구 소송은 합의관할이나 변론관할이 허용되는 임의관할 사건이다.

V. 사안의 적용

- 대전지방법원은 피고 丙의 보통재판적(대구)이나 의무이행지 특별재판적(수원)에 해당하지 않으며, 매매대금 청구는 부동산 소재지 특별재판적(대전) 대상도 아니므로 당초 관할권이 없다. 그러나 丙으로의 당사자표시정정은 적법하며, 정정된 피고 丙이 대전지방법원에서 관할위반의 항변 없이 본안에 관하여 청구기각을 구하는 진술을 하였으므로 **민사소송법 제30조**에 따른 변론관할이 성립한다. 따라서 대전지방법원에는 이 사건 소에 대한 관할권이 인정된다.

VI. 결론

- 결론적으로 변론관할이 성립함으로써 절차적 하자가 치유되었으므로 법원은 이송 없이 본안심리를 계속해야 한다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제01절 당사자의 개관>

[기출][2020-1-2]소제기 전 사망자를 피고로 한 경우 당사자표시정정의 적법성 여부

《【문제1】 甲(수원에 주소를 두고 살고 있음)은 대전에 소재한 자기 토지를 乙(대구에 주소를 두고 살고 있음)에게 매도하고 매매잔대금 1억 원을 받지 못하여, 그 지급을 구하는 소를 대전지방법원에 제기하였다. 이후에 甲은 乙이 소제기 이전에 사망하였다는 사실과 乙의 유일한 상속인인 丙(대구에 주소를 두고 살고 있음)이 있다는 사실을 알게 되었다. 甲은 피고를 丙으로 바꾸는 신청을 하였고 법원은 당사자표시정정하여 피고를 丙으로 바꾸었다. 다음 물음에 답하시오. (50점) (단, 아래의 각 물음은 상호 독립적임)

(물음2) 丙은 이 사건 법원의 당사자표시정정은 부적법하다고 주장하였다. 丙의 이 주장이 타당한지를 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 소제기 전 사망자를 피고로 한 경우 당사자표시정정의 적법성 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 원고 甲이 피고 乙의 사망 사실을 모르고 소를 제기한 후 상속인 丙으로 당사자표시정정을 신청하여 법원의 허가를 받았으며, 이에 피고 丙은 당사자표시정정이 부적법하다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 **사자 상대 소송의 보정 방법으로서 당사자표시정정이 허용되는지 아니면 민사소송법 제260조의 피고경정을 거쳐야 하는지** 검토해야 한다. 이하에서는 이와 관련한 당사자확정 및 피고 경정·표시정정 법리를 고찰하고 사안에 대입하여 丙의 주장 타당성 여부를 논한다.

II. 당사자확정 및 피고 사망 시의 보정 법리

1. 당사자의 확정 기준과 사자 대 상속인의 관계

(1) 당사자확정의 기준의 학설과 판례

- 소송 당사자 확정 기준에 대하여는 원고의 주관적 의사를 기준으로 하는 의사설, 소장 기재 표시를 기준으로 하는 표시설, 실제 소송 행위자를 기준으로 하는 행동설이 대립한다. **대법원**은 소장의 전체적인 기재와 청구 내용 등을 종합하여 합리적으로 당사자를 확정하는 규범적 표시설(실질적 표시설)을 취한다.

(2) 소제기 전 사망한 경우의 당사자확정

- 실질적 표시설에 의할 때, 원고가 피고의 사망 사실을 모르고 사자를 피고로 표시하여 소를 제기한 경우, 원고의 실질적 의사는 상속인을 상대로 분쟁을 해결하려는 것이다. 따라서 표시에도 불구하고 실질적 피고는 처음부터 상속인으로 확정된다.

2. 사망자를 피고로 한 소송의 보정 방법

(1) 당사자표시정정설 (판례의 입장)

- **대법원**은 소제기 전 사망자를 피고로 삼은 소송은 원칙적으로 부적법하다고 본다. 다만, 원고가 선의인 경우 실질적 피고는 상속인이고 단지 표시의 오류에 지나지 않으므로, 상속인으로서의 당사자표시정정을 허용한다. 이 경우 제소의 효과는 최초 소장 제출 시로 소급하여 발생한다.

(2) 피고경정설 (학설의 비판)

- 일부 학설은 사망한 사자에서 상속인으로 당사자를 바꾸는 것은 당사자의 동일성을 해치는 변경이라고 비판한다. 따라서 **민사소송법 제260조**의 피고경정 요건과 절차를 거쳐 피고를 변경해야 하며, 표시정정을 허용하는 **판례**의 태도는 타당하지 않다고 주장한다.

III. 사안의 적용

1. 실질적 피고의 확정 및 동일성 범위

(1) 실질적 피고의 확정

- 원고 甲은 피고 乙이 소제기 전 이미 사망한 사실을 모르고 매매잔대금 청구소송을 제기하였다. 실질적 표시설을 취하는 **판례**에 따를 때, 甲의 실질적 의사는 乙의 유일한 상속인인 丙을 피고로 삼으려는 것이므로, 실질적 피고는 처음부터 상속인 丙으로 확정된다.

(2) 당사자의 동일성 인정 여부

- 사망자 乙과 유일한 상속인 丙은 분쟁의 실제적 귀속 관계에서 실질적으로 동일한 주체로 평가된다. 따라서 피고의 명의를 乙에서 丙으로 변경하는 것은 당사자의 명백한 오기를 바로잡는 당사자표시정정의 범위 내에 포섭된다.

2. 당사자표시정정의 적법성 및 丙의 주장 판정

(1) 당사자표시정정의 적법성

- 甲은 乙의 사망 사실을 안 이후 피고를 丙으로 변경하는 당사자표시정정을 신청하여 법원의 허가를 받았다. **판례**에 따를 때, 소제기 전 사망자를 피고로 오기한 경우 상속인 丙으로서의 당사자표시정정은 정당한 보정 방법으로서 전적으로 적법하다.

(2) 피고 丙의 주장의 타당성 검토

- 피고 丙은 당해 당사자표시정정이 동일성을 해쳐 부적법하다고 주장하나, 이는 성문법상의 피고경정만을 고집하는 비판론에 불과하다. 실질적 피고가 상속인 丙으로 확정된다는 **판례**에 비추어 볼 때, 丙의 이러한 독자적 주장은 법리적으로 타당하지 않다.

IV. 결론

- 선의의 원고 甲이 소제기 전 사망한 乙을 피고로 삼은 경우, 실질적 피고는 처음부터 상속인 丙으로 확정되므로 乙에서 丙으로 피고를 변경하는 당사자표시정정은 소송법상 전적으로 적법하다. 따라서 법원의 당사자표시정정이 부적법하다는 피고 丙의 항변은 타당하지 않다. 법원은 丙의 주장을 배척하고 본안 심리를 진행하여야 한다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제01절 당사자의 개관>

[모의][4.01-1]성명모용소송에서 당사자 확정 기준 및 피모용자의 구제 수단

《【문제4.1】

<사례>

甲은 乙에게 1억 원을 대여하였다고 주장하며 소를 제기하고자 한다. 그런데 甲은 乙의 인적 사항을 정확히 알지 못하자, 평소 원한 관계에 있던 丙의 성명을 乙의 성명으로 기재하고 丙의 주소지를 피고의 주소로 기재하여 소장을 제출하였다. 소장 부분을 송달받은 丙은 자신은 甲과 아무런 채권채무 관계가 없으므로 당황하였으나, 일단 법정에 출석하여 피고로서 답변하고 소송을 수행하였다.

甲이 丙의 성명을 모용하여 소를 제기한 경우, 이 소송의 당사자가 누구인지 확정하는 기준에 대하여 판례의 태도를 중심으로 기술하고, 만약 丙을 상대로 판결이 선고되어 확정되었다면 丙이 취할 수 있는 구제 수단을 논하시오.》

<문제4.1> 성명모용소송에서 당사자 확정 기준 및 피모용자의 구제 수단

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 실제 채무자인 乙이 아닌 丙의 성명과 주소를 피고로 기재하여 소를 제기하였고, 丙은 소송에 출석하여 피고로서 소송을 수행한 상황이다. 쟁점으로 성명모용에 의한 소송에서 당사자를 확정하는 기준과 모용된 자를 상대로 판결이 확정된 경우 그에 대한 구제수단을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 당사자확정의 기준과 丙이 취할 수 있는 구제수단에 대해 논한다.

II. 당사자 확정의 기준

1. 학설의 태도

(1) 의사설

- 원고가 당사자로 삼으려고 하는 자가 당사자라는 견해다.

(2) 표시설

- 소장의 기재나 표시를 기준으로 당사자를 결정해야 한다는 견해다.

(3) 행동설

- 소송에서 당사자로서 행동하거나 당사자로 취급된 자가 당사자라는 견해다.

(4) 규범적 분류설(판례)

- 소장의 기재를 기초로 하되, 전후 문맥을 살펴 합리적으로 해석하여 당사자를 확정해야 한다는 견해다.

2. 판례의 구체적 입장

- 판례는 원칙적으로 소장의 기재를 기준으로 당사자를 확정하나, 성명모용소송과 같이 표시된 성명과 실질적인 당사자가 일치하지 않는 경우에는 소장에 나타난 모든 기재와 보충적 자료를 종합하여 누가 당사자로 확정되는지를 판단한다. 사안과 같이 원고가 실제로는 乙을 상대로 소를 제기할 의사였으나 丙의 성명과 주소를 기재한 경우, 소장의 전취지와 소송의 경과를 고려하여 실질적인 피고를 乙로 볼 것인지 아니면 표시된 丙으로 볼 것인지 결정하게 된다.

III. 성명모용소송의 효력 및 절차

1. 소송계속 중의 처리

- 성명모용 사실이 발견되면 법원은 피고의 표시를 모용자(실질적 피고 乙)로 정정하도록 명해야 한다. 만약 모용당한 피모용자 丙이 소송에 관여하고 있다면 丙을 소송에서 배제하고 乙을 소송에 참여시켜야 한다.

2. 판결 선고 전의 지위

- 피모용자 丙은 실질적인 당사자가 아니므로, 丙을 상대로 판결을 내려서는 안 된다. 만약 丙이 출석하여 답변하였다 하더라도 이는 당사자 아닌 자의 소송 행위로서 효력이 없는 것이 원칙이다.

IV. 피모용자의 구제 수단

1. 판결 확정 전의 구제 : 항소 및 상고

- 판결이 선고되었으나 아직 확정되지 않은 상태라면, 피모용자 丙은 자신에 대하여 판결이 선고된 것과 같은 외관을 제거하기 위하여 항소를 제기할 수 있다. 상급심 법원은 丙이 당사자가 아님을 이유로 원심판결을 취소하고 丙을 소송에서 탈퇴시켜야 한다.

2. 판결 확정 후의 구제

(1) 재심의 소 [민사소송법 제451조 제1항 제3호 준용]

- 판례는 성명모용소송에서 피모용자가 자신도 모르는 사이에 판결이 확정된 경우, 민사소송법 제451조 제1항 제3호의 대리권의 흠결을 유추적용하여 재심의 소를 제기할 수 있다고 본다. 이는 피모용자가 자신의 의사와 무관하게 소송 절차에 관여하지 못한 채 판결의 불이익을 입게 된 것을 구제하기 위함이다.

(2) 판결의 당연무효 주장

- 성명모용판결은 실질적 당사자가 아닌 자를 상대로 한 것이므로 당연무효라는 견해도 있으나, 판례는 판결의 외관이 존재하는 이상 재심 절차 등을 통해 그 효력을 다투어야 한다는 입장이다. 따라서 丙은 확정판결의 기판력을 제거하기 위해 재심을 제기하는 것이 가장 확실한 방법이다.

V. 사안의 적용

1. 당사자의 확정

- 사안에서 甲은 乙을 피고로 삼으려 하였으나 표시를 丙으로 하였고, 丙이 실제로 법정에 출석하여 소송을 수행하였다. 판례의 규범적 분류설에 의하면 표시된 丙이 일단 피고로 확정된다. 그러나 甲의 진정한 의사가 乙을 향하고 있었다면 이는 피고 표시의 잘못에 해당하므로 피고표시정정 절차를 거쳐야 한다.

2. 丙의 구제

- 丙은 이미 법정에 출석하여 소송을 수행하였으므로 판결의 결과에 직접적인 영향을 받게 된다. 만약 丙을 피고로 하는 판결이 확정되었다면, 丙은 대리권 흠결을 이유로 한 재심의 소를 제기하여 자신에 대한 판결의 효력을 부정할 수 있다.

VI. 결론

- 성명모용소송에서 당사자는 원칙적으로 소장에 기재된 표시를 기준으로 확정되나 실질적 당사자가 누구인지에 따라 정정의 대상이 된다. 丙과 같이 성명을 모용당하여 확정판결을 받은 자는 대리권 흠결에 관한 재심 규정을 준용하여 재심의 소를 제기함으로써 구제받을 수 있다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제02절 당사자의 자격>

[기출][2010-2-1]임의적 소송담당의 의의 및 유형, 허용 요건, 소송법적 효과

《【문제2】 다음 문제를 설명하십시오.

(물음1) 임의적 소송담당(임의적 소송신탁) (25점)》

<문제2의 물음1> 임의적 소송담당의 의의 및 유형, 허용 요건, 소송법적 효과

I. 임의적 소송담당의 의의 및 유형

1. 의의

- 권리주체인 본인의 의사에 기초하여 제3자에게 소송수행권을 수여하는 경우를 말한다. 법률에 규정이 있는 경우뿐만 아니라, 법률에 규정이 없더라도 일정한 요건 하에 예외적으로 허용될 수 있다.

2. 유형

(1) 법률에 명문 규정이 있는 경우

- 민사소송법 제53조의 선정당사자, 추심명령을 얻은 채권자 등이 대표적인 예이다. 선정당사자는 공동의 이해관계를 가진 다수의 사람 중 선출된 자가 전원을 위해 소송을 수행하는 제도이다.

(2) 법률에 명문 규정이 없는 경우

- 민법상 조합의 업무집행조합원이나 아파트 관리단 대표 등이 자신을 당사자로 하여 소송을 수행할 수 있는지가 문제된다. 판례는 원칙적으로 부정하나 엄격한 요건 하에 긍정하고 있다.

II. 임의적 소송담당의 허용 요건

1. 원칙적 금지(소송신탁의 금지)

- 신탁법 제6조는 소송행위를 하게 하는 것을 목적으로 하는 신탁을 금지하고 있다. 이는 변호사법 위반을 방지하고 소송상의 투기 행위를 막아 사법 제도의 건전성을 유지하기 위함이다.

2. 예외적 허용의 요건(판례의 태도)

(1) 합리적 필요성

- 당사자가 직접 소송을 수행하는 것보다 제3자가 수행하는 것이 소송경제적으로 유리하거나, 권리 실현을 위해 불가피한 사정이 인정되어야 한다.

(2) 변호사대리 원칙 및 소송신탁 금지의 탈법 방지

- 소송담당을 허용하더라도 변호사법이 금지하는 대리 포섭이나 부당한 이익 취득의 위험이 없어야 한다. 판례는 업무집행조합원이 조합재산에 관하여 조합원 전원을 위하여 소송을 수행하는 경우 등을 긍정한다.

(3) 명시적 권한 부여

- 본인으로부터 소송수행권 부여에 관한 명확한 의사가 있어야 하며, 이는 단순한 대리권 수여와 구별되는 당사자 지위의 부여여야 한다.

III. 소송법적 효과

1. 소송수행권의 이전

- 임의적 소송담당이 성립하면 소송담당자가 원고 또는 피고로서 당사자 지위를 갖는다. 이때 본인이 소송수행권을 잃는지 여부에 따라 병행적 소송담당과 갈음적 소송담당으로 나뉜다.

2. 판결의 효력 확장

- 민사소송법 제218조 제3항에 따라 소송담당자가 받은 판결의 효력(기판력)은 권리주체인 본인에게도 미친다. 따라서 본인이 다시 동일한 소를 제기하는 것은 기판력에 저촉된다.

3. 소송비용의 부담

- 실제 소송을 수행한 소송담당자가 소송비용 부담의 주체가 되나, 본인 또한 판결의 효력을 받는 자로서 일정한 경우 비용 부담의 책임을 질 수 있다.

IV. 결론

- 임의적 소송담당은 당사자 적격의 예외로서 소송수행의 편의를 도모하는 유용한 제도이나, 무분별한 허용은 변호사법의 간간을 흔들 수 있다. 따라서 판례는 선정당사자처럼 법률이 정한 경우 외에는 업무집행조합원과 같이 실질적 이해관계를 같이하고 소송수행의 합리적 필요성이 인정되는 경우에만 극히 제한적으로 이를 인정하고 있다. 이는 사적 자치의 원칙과 사법 절차의 투명성 사이에서 균형을 맞추려는 사법부의 의지로 풀이된다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제02절 당사자의 자격>

[기출][2014-1-1]민법상 조합인 회사를 상대로 한 해고무효 확인의 소 제기 가능성

《[문제1] 근로자 甲은 해고를 당한 후 사용자인 乙회사를 상대로 해고무효 확인의 소를 제기하고자 한다. 그런데 乙회사는 명칭만 회사일 뿐 A, B, C 3인이 공동으로 출자해서 설립한 민법상 조합에 불과하다. 다음 물음에 답하시오. (50점) (다만 아래 각 지문은 상호 무관함)》

(물음1) 甲은 乙회사를 피고로 해서 해고무효 확인의 소를 제기할 수 있는지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 민법상 조합인 회사를 상대로 한 해고무효 확인의 소 제기 가능성

I. 문제의 제기

- 사안은 민법상 조합인 乙회사를 상대로 근로자 甲이 해고무효 확인의 소를 제기하고자 하는 상황이다. 쟁점으로 乙회사가 실질적으로 민법상 조합에 불과한 경우, 민사소송법 제52조의 법인 아닌 사단에 대하여 독자적인 당사자능력을 가질 수 있는지, 아니면 조합원 전원을 피고로 해야 하는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 민법상 조합의 당사자능력 유무, 판례의 태도, 당사자능력이 부정될 경우의 소송 수행 방법인 선정당사자 및 조합대리인 제도 등에 대해 논한다.

II. 민법상 조합의 당사자능력

1. 원칙적 부정

(1) 법리적 근거

- 민법상 조합은 2인 이상이 상호 출자하여 공동사업을 경영할 것을 약정함으로써 성립하는 계약관계에 불과하다. 조합 그 자체는 법인격이 없으며, 조합 재산은 조합원 전원의 합유로 귀속된다. 따라서 소송법상으로도 원칙적으로 조합 자체는 당사자능력이 없다.

(2) 판례의 태도

- 대법원은 민법상 조합은 법인격이 없고 사단성도 결여되어 있으므로 민사소송법 제52조가 정하는 법인 아닌 사단에 해당하지 않는다고 본다. 따라서 조합 명의로 소를 제기하거나 조합을 피고로 하여 소를 제기하는 것은 부적법하다는 것이 일관된 입장이다.

2. 법인 아닌 사단과의 구별

(1) 구별 기준

- 어떤 단체가 법인 아닌 사단인지 아니면 민법상 조합인지는 그 단체의 실질에 따라 판단한다. 고유한 명칭을 가지고 사회적 활동을 하며, 의사결정기관과 집행기관을 갖추고, 구성원의 변경에 관계없이 단체 자체가 존속하는 등 단체성이 강하면 법인 아닌 사단으로 본다.

(2) 사안의 경우

- 문제에서 乙회사는 명칭만 회사일 뿐 3인이 공동으로 출자하여 설립한 민법상 조합에 불과하다고 명시되어 있다. 따라서 특별한 단체적 조직을 갖추지 못한 순수한 조합으로 보아야 하며, 민사소송법 제52조를 적용하기 어렵다.

III. 조합 소송의 수행 방법

1. 조합원 전원에 의한 소송(합유관계)

(1) 필수적 공동소송

- 조합재산에 관한 소송이나 조합의 채무에 관한 소송은 원칙적으로 조합원 전원이 당사자가 되어야 하는 고유필수적 공동소송에 해당한다. 따라서 甲이 乙회사를 상대로 소를 제기하려면 조합원 A, B, C 전원을 공동피고로 하여 소를 제기해야 한다.

(2) 흠결의 효과

- 조합원 중 일부만을 피고로 하거나 조합 명의로만 소를 제기한 경우, 이는 당사자능력이 없는 자를 상대로 한 것이거나 당사자확정이 잘못된 것으로서 부적법 각하 대상이 된다.

2. 소송 수행의 편의를 위한 제도

(1) 선정당사자 [민사소송법 제53조]

- 조합원 전원이 당사자가 되어야 함이 원칙이나, 절차의 간소화를 위해 조합원 중 1인 또는 수인을 선정당사자로 선임하여 소송을 수행하게 할 수 있다. 이 경우 선정되지 않은 나머지 조합원들은 소송에서 탈퇴하게 된다.

(2) 조합대리인에 의한 소송

- 조합의 업무집행조합원이 있는 경우, 그에게 소송대리권을 수여하여 소송을 진행할 수 있으나, 이는 당사자 명의 자체를 조합으로 할 수 있다는 의미는 아니며 여전히 당사자는 조합원 전원이 되어야 한다.

IV. 사안의 적용

1. 乙회사의 당사자능력 부정

- 乙회사는 민법상 조합에 불과하므로 민사소송법 제52조의 법인 아닌 사단에 해당하지 않는다. 따라서 乙회사라는 명칭을 피고로 적시하여 소를 제기하는 것은 당사자능력이 없는 자를 피고로 한 것이 되어 부적법하다.

2. 올바른 피고의 지정

- 甲은 해고무효 확인의 소를 제기함에 있어 乙회사의 구성원인 A, B, C 3인 전원을 피고로 지정하여 공동소송의 형태로 제기하여야 한다. 만약 乙회사만을 피고로 제기했다면 법원은 석명권을 행사하여 피고를 조합원 전원으로 보정하도록 명하여야 하며, 이에 응하지 않을 경우 소를 각하해야 한다.

V. 결론

- 민법상 조합은 독자적인 당사자능력을 가지지 못한다는 것이 통설과 판례의 입장이다. 따라서 甲은 乙회사를 피고로 하여 해고무효 확인의 소를 제기할 수 없다. 甲은 乙회사의 실질적 운영자인 조합원 A, B, C 전원을 공동피고로 하여 소를 제기하여야 하며, 이것이 소송법상 적법한 소제기 방법이다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제02절 당사자의 자격>

[기출][2016-1-1]노동조합이 조합원을 위하여 제기한 손해배상청구소송에서 노동조합의 당사자적격 여부

《【문제1】 乙회사의 근로자인 甲이 업무 중 상해를 입어 乙회사를 상대로 손해배상청구의 소를 제기하고자 한다. 다음 물음에 대하여 답하시오. (50점) (아래 각 설문은 상호 무관함)》

(물음1) 甲이 소속하고 있는 노동조합 丙이 원고로서 사용자인 乙회사를 상대로 甲을 위하여 소송을 수행할 경우, 丙노동조합에 당사자적격이 있는지를 설명하시오. (35점)》

<문제1의 물음1> 노동조합이 조합원을 위하여 제기한 손해배상청구소송에서 노동조합의 당사자적격 여부

I. 문제의 제기

- 민사소송법상 당사자적격이란 특정의 소송물에 관하여 본안판결을 받기에 적합한 자격으로서 원칙적으로 권리관계의 주체인 당사자에게 인정된다. 사안에서 丙노동조합은 조합원 甲의 개인적 권리인 손해배상청구권을 행사하려고 하는 상황이다. 쟁점으로 권리주체가 아닌 제3자가 타인의 권리에 대하여 소송을 수행할 수 있는 임의적 소송당당에 해당하는지, 노동조합이 조합원의 이익을 위해 소송을 제기할 수 있는 명문의 규정이 없는 상황에서 판례가 인정하는 예외적 허용 요건을 충족하는지 검토가 필요하다. 이하에서는 이러한 노동조합의 당사자적격에 대해 설명한다.

II. 당사자적격과 임의적 소송당당

1. 당사자적격의 원칙

- 당사자적격은 소송물인 권리관계의 존부와 직접 이해관계를 가진 자에게 주어진다. 이행의 소에서는 스스로 원고라고 주장하는 자에게 원고적격이 인정되는 것이 원칙이다.

2. 임의적 소송당당의 의미

- 권리주체인 당사자의 의사에 따라 제3자에게 소송수행권을 부여하는 것을 말한다. 이는 변호사대리의 원칙(민사소송법 제87조)이나 소송신탁의 금지(신탁법 제6조)와 충돌할 우려가 있어 제한적으로 허용된다.

III. 임의적 소송당당의 허용 요건

1. 명문의 규정이 있는 경우

- 민사소송법 제53조에 따른 선정당사자, 추심명령을 얻은 채권자, 가압류채권자 등이 이에 해당한다.

2. 명문의 규정이 없는 경우(판례의 태도)

(1) 허용 요건

- 판례는 법률의 명문규정이 없더라도 ❶ 이를 인정할 합리적 필요가 있고, ❷ 변호사대리의 원칙이나 소송신탁 금지의 탈법적 수단으로 이용될 우려가 없으며, ❸ 제3자의 소송수행을 허용함으로써 본래의 권리주체에게 부당한 손해를 줄 염려가 없는 경우에는 예외적으로 임의적 소송당당을 인정한다.

(2) 소송신탁의 금지

- 소송행위를 하게 하는 것을 주된 목적으로 채권양도 등이 이루어지는 것은 소송신탁으로서 무효이나, 위 요건을 갖춘 정당한 업무 범위 내의 소송수행은 금지되지 않는다.

IV. 노동조합의 당사자적격 인정 여부

1. 단체소송의 가능성

- 노동조합은 노동조합 및 노동관계조정법에 따라 단체교섭 및 단체협약 체결권이 있으나, 조합원 개개인의 미지급 임금이나 손해배상청구권은 조합원에게 전속하는 권리이다. 따라서 노동조합이 자신의 이름으로 조합원의 권리를 청구하는 단체소송은 원칙적으로 부정된다.

2. 임의적 소송당당 인정 여부

(1) 긍정설

- 노동조합의 본질적 기능인 조합원의 권익 보호를 위해 소송수행의 필요성을 강조하는 견해이다.

(2) 부정설(판례의 태도)

- 판례는 노동조합이 조합원들을 위하여 원고가 되어 사용자에게 조합원들의 임금 등을 청구하는 소송은 법률에 명문의 규정이 없는 한 허용되지 않는다고 본다. 노동조합이 조합원으로부터 소송수행권을 위임받아 소를 제기하는 것은 변호사대리의 원칙이나 소송신탁 금지에 저촉될 가능성이 크기 때문이다.

V. 사안의 적용

1. 권리의 전속성

- 사안에서 甲이 입은 업무 중 상해로 인한 손해배상청구권은 甲의 신체 침해에 따른 전속적 권리이다. 丙노동조합이 비록 甲을 보호할 목적이 있다 하더라도 소송물의 주체는 여전히 甲이다.

2. 선정당사자 제도의 활용

- 만약 여러 조합원이 동일한 사고로 피해를 입었다면 민사소송법 제53조에 따라 甲이 丙노동조합의 간부 등을 선정당사자로 지정하여 소송을 진행할 수는 있으나, 丙노동조합 자체가 원고가 될 수는 없다.

3. 소송수행권의 부존재

- 丙노동조합은 법령상 조합원의 개인적 손해배상청구권을 대리하여 소송할 권한이 없다. 판례의 엄격한 요건에 비추어 보더라도 노동조합에 의한 임의적 소송당당을 인정할 만큼 특수한 합리적 필요성이 있다고 보기 어렵다.

VI. 결론

- 민사소송법상 당사자적격은 권리관계의 실질적 주체에게 귀속됨이 원칙이며, 제3자에 의한 소송수행은 법률에 근거가 있거나 판례상 극히 예외적인 요건을 갖춘 경우에만 허용된다. 丙노동조합이 조합원 甲을 위하여 원고로서 소송을 수행하는 것은 우리 판례의 태도에 비추어 볼 때 임의적 소송당당의 요건을 충족하지 못하므로 丙노동조합은 당사자적격이 없다. 따라서 丙이 제기한 소는 부적법하여 각하될 것이다. 甲이 소송을 수행하기 위해서는 본인이 직접 소를 제기하거나, 변호사를 선임하여야 하며 노동조합은 소송 보조 등의 간접적 지원에 그쳐야 한다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제02절 당사자의 자격>

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제03절 당사자의 변경>

[기출][2017-1-2]소송계속 중 당사자 사망을 간과한 판결의 효력과 상속인에 대한 승계 여부

《【문제1】 乙 회사의 근로자 丙이 업무상 운전하던 차량이 보행자 甲을 충격하여 부상을 입었다. 甲이 乙 회사를 피고로 하여 제기한 교통사고로 인한 손해배상청구의 소(전소)에서 丙이 乙 회사측에 보조참가하여 소송이 진행되었고, 법원은 丙의 운전상의 과실을 인정하여 甲 청구인용판결을 선고하여 이 판결이 확정되었다. 그 후 乙 회사가 丙을 피고로 위 손해배상에 대한 구상금을 청구하는 소(후소)를 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(아래 각 질문은 상호 무관함)

(물음2) 후소에서 丙은 소송대리인을 선임하지 않고 소송을 수행하던 중 사망하였다. 법원은 丙의 사망사실을 간과하고 변론을 진행한 후 乙 회사 청구인용판결을 선고하였다. 이 판결은 丙의 상속인에게 효력이 미치는지를 설명하시오. (15점)》

<문제1의 물음2> 소송계속 중 당사자 사망을 간과한 판결의 효력과 상속인에 대한 승계 여부

I. 문제의 제기

- 후소 피고 丙은 소송대리인을 선임하지 않은 상태에서 소송계속 중 사망하였으므로, 민사소송법 제233조 제1항에 따라 소송절차는 중단되어야 한다. 그럼에도 수소법원이 피고의 사망을 간과하고 선고한 판결이 당연무효인지, 아니면 丙의 상속인들에게 그 판결의 효력이 미치는지 여부가 핵심 쟁점이다. 이하에서는 소송대리인 없는 당사자의 사망으로 인한 소송중단의 법리 및 사망 간과 판결의 효력과 그 상속인에 대한 구제책을 고찰하고 사안에 대입하여 판결의 효력 유무에 대하여 설명한다.

II. 소송계속 중 당사자 사망 시의 소송법적 효과

1. 소송절차 중단의 원칙과 예외

(1) 소송절차의 중단 원칙

- 소송계속 중 당사자가 사망한 때에는 소송절차는 중단된다.(민사소송법 제233조 제1항) 이 경우 법률상 당연히 수계할 상속인 등이 소송절차를 수계하여야 소송을 계속 진행할 수 있다.

(2) 소송대리인이 있는 경우의 예외

- 사망한 당사자에게 소송대리인이 있는 경우에는 소송절차가 중단되지 아니하고 소송대리인이 대리권을 유지하여 소송을 계속 수행한다.(민사소송법 제238조) 그러나 사안의 丙은 소송대리인을 선임하지 않았으므로 丙의 사망과 동시에 소송절차는 당연히 중단된다.

2. 사망 간과 판결의 효력과 상속인에 대한 귀속 관계

(1) 판결의 효력 (무효 여부)

- 대법원은 소 제기 전 사망자를 피고로 삼은 경우와 달리, 소송계속 중 당사자가 사망하였음에도 이를 간과하고 선고한 판결은 당연무효가 아니라고 본다. 이미 적법한 대립 당사자 관계가 형성된 후 사망한 것이므로 판결은 형식적으로 유효하게 성립하며, 그 효력은 丙의 상속인들에게 미친다.

(2) 대리권 흠결에 준하는 위법과 불복 수단

- 사망 간과 판결은 당연무효는 아니지만 소송수계절차를 거치지 않은 절차적 위법이 존재한다. 판례는 이 가공의 판결에 대하여 대리권 흠결에 준하는 위법이 있는 것으로 보아, 상속인들이 상소나 재심청구(민사소송법 제451조 제1항 제3호 유추)를 통해 그 판결의 취소를 구할 수 있다고 판시한다.

III. 사안의 적용

1. 丙의 사망에 따른 소송중단 및 판결의 성립

- 丙은 소송대리인을 두지 않고 소송을 수행하다가 사망하였으므로 사망 시점에 소송절차는 즉시 중단되었어야 한다. 법원이 이를 알지 못하고 변론을 진행하여 내린 판결은 중단 중의 판결로서 절차상 위법하나, 당연무효의 판결로 보지 않는다.

2. 상속인에 대한 효력 귀속 및 구제 방안

- 해당 판결은 당연무효가 아니므로 실체법상 丙의 권리·의무를 승계한 丙의 상속인들에게 형식적으로 그 효력이 미치게 된다. 다만, 상속인들은 판결을 송달받아 대리권 흠결에 준하는 위법을 이유로 항소를 제기하여 판결의 취소를 구할 수 있으며, 이미 판결이 확정된 경우라면 재심의 소를 제기하여 구제받을 수 있다.

IV. 결론

- 수소법원이 피고 丙의 사망 사실을 간과하고 선고한 구상금 청구인용판결은 당연무효가 아니므로, 丙의 상속인들에게 그 효력이 미친다. 따라서 상속인들은 판결의 형식적 효력을 전면 구속받게 되나, 대리권 흠결에 준하는 절차상 위법을 원인으로 삼아 상소나 재심청구를 통해 판결을 적법하게 취소시킬 수 있다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제02절 당사자의 자격>

[기출][2021~2]당사자능력의 의의, 판정 기준, 비법인의 당사자능력, 당사자능력의 흠결과 효과

《【문제2】 당사자능력에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 당사자능력의 의의, 판정 기준, 비법인의 당사자능력, 당사자능력의 흠결과 효과

I. 당사자능력의 의의

- 당사자능력이란 소송의 주체가 될 수 있는 일반적인 능력을 의미하며, 이는 **민법**상 권리능력에 대응하는 개념이다. 소송절차의 안정성과 실효성을 확보하기 위해 누가 소송의 당사자가 될 수 있는지를 확정하는 것은 소송요건 중 가장 기초적인 단계에 해당한다. **민사소송법**은 원칙적으로 **민법**상 권리능력자에게 당사자능력을 인정하나, 소송의 편의를 위해 법인이 아닌 사단이나 재단에 대해서도 일정한 요건 하에 당사자능력을 예외적으로 인정하고 있다. 당사자능력은 소송의 전 과정에서 유지되어야 하는 직권조사사항이며, 이를 결여한 소송행위는 원칙적으로 무효이다.

II. 당사자능력의 판정 기준

1. 자연인

- 모든 자연인은 생존하는 동안 당사자능력을 가진다. 국적이냐 연령, 정신상태와 관계없이 인격을 가진 존재라면 누구나 소송의 당사자가 될 수 있다.

(1) 태아의 당사자능력

- 태아는 원칙적으로 권리능력이 없으므로 당사자능력도 부정된다. **판례**는 태아가 소송을 제기하기 위해서는 살아서 출생해야 한다는 정지조건설의 입장을 취하므로, 태아인 상태에서 제기된 소는 부적법하다.

(2) 외국인의 당사자능력

- 외국인도 자연인인 이상 당사자능력을 가진다. 다만, 소송비용 담보제공 등의 제한이 따를 수 있으나 능력 자체는 부정되지 않는다.

2. 법인

- 법인은 설립등기를 마침으로써 권리능력을 취득하며, 동시에 당사자능력을 가진다. 영리법인, 비영리법인, 공법인(국가, 지방자치단체) 모두 포함된다.

(1) 국가 및 지방자치단체

- 국가는 사법관계에서도 당사자능력을 가지며, 지방자치단체 역시 공법인으로서 당사자능력을 인정받는다. 그러나 지방자치단체의 하부조직인 동이나 면은 원칙적으로 당사자능력이 없다.

(2) 청산 중의 법인

- 법인이 해산되더라도 청산 사무가 완료될 때까지는 청산의 목적 범위 내에서 당사자능력을 유지한다.

III. 비법인 사단 및 재단의 당사자능력

1. 의의 및 인정 근거 [민사소송법 제52조]

- 법인이 아닌 사단이나 재단이라도 대표자나 관리인이 정해져 있는 경우에는 그 이름으로 소송의 당사자가 될 수 있다. 이는 실질적으로 사회적 활동을 수행하는 단체의 소송 편의를 도모하기 위함이다.

2. 인정 요건

(1) 사단의 실체

- 단체로서의 조직을 갖추고 있고, 의사결정기관과 집행기관인 대표자가 선임되어 있어야 하며, 구성원의 변경과 관계없이 단체 자체가 존속되어야 한다.

(2) 독립된 재산의 존재

- 단체 고유의 목적을 달성하기 위한 독립된 자산이 형성되어 있어야 한다.

3. 구체적 사례에 대한 판례의 태도

(1) 중증

- 중증은 특별한 조직 행위가 없어도 공동조상의 후손들에 의해 당연 성립하는 종족 단체로서, 대표자가 선임되어 있다면 당사자능력이 인정된다.

(2) 학교

- 학교는 시설물에 불과하므로 당사자능력이 없다. 소송을 제기하려면 학교를 운영하는 법인이나 경영자를 당사자로 해야 한다.

(3) 조합

- **민법**상 조합은 원칙적으로 당사자능력이 없다. 따라서 조합원 전원이 공동으로 소송을 수행하거나 선정당사자 제도를 활용해야 한다. 다만, 실무상 재건축조합 등은 비법인 사단의 실체를 갖춘 경우 **민사소송법 제52조**에 의해 당사자능력이 인정되기도 한다.

IV. 당사자능력의 흠결과 소송법적 효과

1. 직권조사사항

- 당사자능력의 존부는 법원의 직권조사사항이다. 당사자의 항변이 없더라도 법원은 이를 스스로 조사하여야 하며, 상고심에서도 새로운 증거를 통해 이를 판단할 수 있다.

2. 소송계속 전후의 흠결

(1) 소 제기 당시부터 흠결된 경우

- 소 제기 당시에 이미 당사자능력이 없는 자를 상대로 하거나 그 명의로 제기된 소는 부적법하므로 법원은 소각하 판결을 내려야 한다. 다만, 보정이 가능한 경우에는 보정을 명할 수 있다.

(2) 소송 진행 중 흠결된 경우(당사자의 사망 등)

- 소송 도중 당사자가 사망하거나 법인이 해산된 경우에는 소송절차가 중단되며, 상속인이나 합병 후의 법인이 소송을 수계하여야 한다.

3. 당사자표시정정과의 관계

- 당사자를 잘못 지정했으나 실질적으로 동일성이 인정되는 경우에는 당사자표시정정을 통해 하자를 치유할 수 있다. 그러나, 동일성이 인정되지 않는 전혀 다른 사람으로 정정하는 것은 허용되지 않는다.

V. 결론

- 당사자능력은 소송절차의 유효한 성립을 위한 필수적 전제 요건이다. **민사소송법**이 비법인 사단에 대해 당사자능력을 인정하는 것은 현대 사회의 다양한 단체 활동을 소송법적으로 수용하기 위한 합리적인 조치이다. 법원은 당사자능력의 유무를 엄격히 심사하여 부적법한 소송에 의한 사법 자원의 낭비를 막아야 하며, 동시에 당사자표시정정이나 보정 명령 등을 적절히 활용하여 당사자의 재판받을 권리가 절차적 형식주의에 의해 침해되지 않도록 균형을 유지해야 한다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제02절 당사자의 자격>

[모의][4.02-1]당사자능력과 당사자적격의 비교

《【문제4.2】 당사자능력과 당사자적격에 대해 설명하시오.》

<문제4.2> 당사자능력과 당사자적격의 비교

I. 당사자조건의 의의

- 민사소송이 적법하게 개시되고 진행되기 위해서는 소송의 주체인 당사자가 일정한 요건을 갖추어야 한다. 이를 당사자 조건이라 하며, 대표적으로 당사자 능력과 당사자적격이 있다. 두 개념은 모두 소송요건에 해당하여 법원의 직권조사사항이라는 공통점이 있으나, 그 자격의 성질과 구체적인 판단 기준에서 명확히 구분된다. 실무상 이를 혼동할 경우 소송 요건의 흠결로 소각하 판결을 받게 되므로 명확한 구별이 필수적이다.

II. 당사자능력의 개념 및 법적 성격

1. 당사자능력의 정의

- 당사자능력이란 소송의 당사자(원고 또는 피고)가 될 수 있는 추상적 · 일반적인 자격을 의미한다. 이는 실체법상 **민법**의 권리능력에 대응하는 소송법상의 개념이다. 따라서 권리를 가질 수 있는 자는 당연히 소송의 당사자가 될 수 있는 자격을 가진다.

2. 당사자능력자의 범위

(1) 자연인과 법인

- 모든 자연인(외국인, 미성년자 포함)과 법인은 권리능력을 가지므로 당연히 당사자능력을 가진다. 태아의 경우 **민법**상 개별 규정에 의해 권리능력이 인정되는 범위 내에서 예외적으로 소송법상 당사자능력이 인정될 수 있다.

(2) 비법인 사단 · 재단 [민사소송법 제52조]

- **민법**상 권리능력은 없으나 사단 또는 재단으로서의 실체를 갖추고 대표자나 관리인이 지정되어 있는 경우, 소송법상 예외적으로 당사자능력을 인정한다. 총중, 동창회, 아파트 입주자대표회의 등이 이에 해당한다.

(3) 민법상 조합의 예외

- **민법**상 조합은 사단성이 결여되어 원칙적으로 당사자능력이 부정되며, 조합원 전원이 공동소송인으로 참여하여야 한다.

III. 당사자적격의 개념 및 법적 성격

1. 당사자적격의 정의

- 당사자적격이란 특정한 소송물에 대하여 원고(원고적격) 또는 피고(피고적격)로서 소송을 수행하고 판결을 받을 수 있는 구체적 · 개별적인 자격을 의미한다. 당사자능력이 소송에 참여할 수 있는 기본 자격이라면, 당사자적격은 당해 특정 재판의 당사자로서 적합한 자격이다.

2. 적격의 판단 기준

(1) 일반적 기준(관리처분권)

- 주로 실체법상의 권리관계에 기하여 결정된다. 즉, 소송의 대상이 된 권리나 법률관계의 주체인 자가 당사자적격을 갖는다. 이행의 소에서는 원고가 자기에게 권리가 있다고 주장하는 자가 원고적격을 갖고, 그로부터 이행을 청구받은 자가 피고적격을 갖는 것이 원칙이다.

(2) 제3자의 소송담당

- 실체법상 권리 주체가 아님에도 불구하고 법률의 규정(예 : 채권자대위소송에서의 채권자)이나 당사자의 지정에 의해 제3자가 당사자적격을 취득하여 소송을 수행하는 예외적인 형태가 존재한다.

IV. 두 개념의 주요 차이점 비교

1. 추상적 자격과 구체적 자격의 차이

- 당사자능력은 당해 사건 내용과 무관하게 누가 소송의 주체가 될 수 있는가에 관한 추상적인 자격이다. 반면, 당사자적격은 특정 사건에 대하여 누가 재판을 이끌어갈 책임자인가를 묻는 구체적인 자격이다. 예를 들어, 자연인 A는 당사자능력을 언제나 가지지만, 타인의 채무 관계에 관한 소송에서는 당사자적격이 없다.

2. 실체법적 대응 개념의 차이

(1) 당사자능력

- **민법**의 권리능력과 대응한다.

(2) 당사자적격

- **민법**상의 소유권이나 채권 등 관리처분권과 대응한다. 따라서 재산의 처분 권한이 제한된 파산관재인 등은 원래 소유자가 당사자능력이 있음에도 불구하고 법률에 의해 당사자적격을 독점하게 된다.

3. 흠결 시 효과와 소송절차상의 차이

(1) 당사자능력의 흠결

- 소송 제기 당시 당사자능력이 없는 자(예 : 사망자, 존재하지 않는 단체)를 당사자로 삼은 경우, 원칙적으로 보정이 불가능하며 법원은 소를 각하하여야 한다. 다만 당사자 표시정정 등으로 해결할 수 있는 예외적 범위가 좁게 인정된다.

(2) 당사자적격의 흠결

- 소송 도중 당사자적격이 없는 자가 소를 제기한 것이 밝혀지면 역시 소각하 판결을 내린다. 그러나 임의적 당사자변경이나 소송인수, 소송참가 등의 소송법적 장치를 통해 적격이 있는 자로 당사자를 교체하거나 보정할 수 있는 여지가 당사자능력에 비해 상대적으로 넓다.

V. 관련 판례 및 실무적 적용

1. 사망자를 피고로 한 소송

- **판례**는 소 제기 전에 이미 사망한 자를 피고로 하여 소를 제기한 경우, 그 소송은 당사자능력이 없는 자를 상대로 한 것이므로 부적법하여 각하되어야 한다고 본다. 다만, 소 제기 후에 사망한 경우에는 소송절차가 중단되며 상속인이 소송을 수계하는 형태로 진행되므로 구별이 필요하다.

2. 사단법인의 분열과 당사자적격

- 총중이나 교회 등이 분열되어 소송이 발생한 경우, **판례**는 당해 법률관계에 대한 총유재산의 관리처분권이 누구에게 있는지를 기준으로 구체적인 당사자적격을 판단한다. 단순히 단체의 회원이라는 사정만으로는 대표하여 소송을 제기할 당사자적격이 인정되지 않는다.

VI. 결론

- 당사자능력과 당사자적격은 민사소송의 적법성을 담보하는 이중의 필터 역할을 한다. 당사자능력은 소송을 시작할 수 있는 인적·조직적 주체로서의 그릇을 심사하는 단계이며, 당사자적격은 그 그릇이 해당 분쟁에 합당한 실체적 권리 주체인지를 가리는 단계이다. 소송 실무에서는 원고와 피고를 지정할 때 이 두 가지 요건이 모두 충족되었는지를 면밀히 검토함으로써 무익한 절차의 반복이나 소각하 판결의 위험을 사전에 방지하여야 한다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제02절 당사자의 자격>

[모의][4.02-2]소송상 당사자적격의 의의 및 당사자능력과의 구별, 권리주체, 소송법상 성질, 흠결 효과

《【문제4.2-2】 소송상 당사자적격에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제4.2의 물음2> 소송상 당사자적격의 의의 및 당사자능력과의 구별, 권리주체, 소송법상 성질, 흠결 효과

I. 당사자적격의 의의 및 당사자능력·의사능력과의 구별

1. 당사자적격의 의의
 - 당사자적격이란 특정의 소송물에 대하여 원고 또는 피고로서 소송을 수행하고 본안판결을 받기에 적합한 자격을 말한다. 소송을 수행할 수 있는 원고로서의 자격을 원고적격, 피고로서의 자격을 피고적격이라 한다.
2. 당사자능력 및 의사능력(소송능력)과의 구별
 - (1) 당사자능력과의 구별
 - 당사자능력은 소송의 주체가 될 수 있는 일반적·추상적 능력을 의미하므로, 구체적 소송물과의 관계를 전제로 하는 개별적·구체적 자격인 당사자적격과 구별된다.
 - (2) 의사능력과의 구별
 - 의사능력(소송법상 소송능력)은 스스로 유효하게 소송행위를 하거나 받을 수 있는 행위능력을 의미하므로, 소송물의 주체로서 소송을 수행할 자격인 당사자적격과 구별된다.

II. 당사자적격을 가지는 자 (원칙적 권리주체 및 제3자 소송담당)

1. 원칙적 권리주체
 - (1) 원고적격과 피고적격
 - 이행의 소에서는 스스로 권리자라 주장하는 자에게 원고적격이, 의무자라 지정된 자에게 피고적격이 인정된다. 확인의 소에서는 확인의 이익을 가진 자에게 원고적격이 인정되며, 형성의 소에서는 법률이 규정한 자에게 적격이 인정된다.
 - (2) 주장 자체에 의한 결정
 - 당사자적격의 유무는 원고의 주장 자체를 기준으로 판단하며, 실제로 그 권리·의무가 존재하는지는 본안심리 단계에서 판단할 문제이다.
2. 예외적 주체 (제3자 소송담당)
 - (1) 의의 및 종류
 - 제3자 소송담당이란 권리관계의 주체가 아닌 제3자가 자기의 이름으로 소송을 수행할 수 있는 권능을 가진 경우를 말한다. 법률의 규정에 의해 부여되는 법정소송담당(채권자대위소송 등)과 권리주체의 의사에 기한 임의적 소송담당(선정당사자 등)이 있다.
 - (2) 판결의 효력
 - 소송담당자가 판결을 받으면 그 기판력은 소송의 당사자가 아닌 실질적 권리관계의 주체인 본인에게도 미치게 된다.

III. 당사자적격의 소송법상 성질 및 조사 시기

1. 소송법상 성질
 - 당사자적격은 법원이 본안심리를 하기 위해 갖추어야 할 소송요건 중 당사자에 관한 요건이다. 이는 공익적 성격을 가지므로 원칙적으로 강행규정에 해당한다.
2. 조사 시기 및 판단 기준
 - (1) 법원의 직권조사사항
 - 소송요건이므로 피고의 항변을 기다리지 않고 법원이 소송의 모든 단계에서 직권으로 조사하여야 한다.
 - (2) 판단의 기준 시점
 - 당사자적격의 존부는 사실심 변론종결 시를 기준으로 판단한다. 소 제기 당시에 적격이 없었더라도 사실심 변론종결 전까지 이를 구비하면 하자는 치유된다.

IV. 당사자적격 흠결의 소송법상 효과

1. 본안심리 거부 및 소각하 판결
 - 법원은 소송요건인 당사자적격이 흠결된 경우, 본안에 대해 판단하지 않고 판결로 소를 부적법 각하하여야 한다.
2. 하자의 보정 및 하자 간과 판결의 효력
 - (1) 하자의 보정 가능성과 한계
 - 당사자적격의 흠결은 원칙적으로 보정할 수 없는 요건이다. 다만, 단순한 오기를 정정하는 동일성 범위 내의 당사자표시정정은 허용되나, 전혀 다른 자로 당사자를 바꾸는 임의적 당사자변경은 원칙적으로 허용되지 않는다.
 - (2) 간과 판결의 효력 및 구제
 - 적격 흠결을 간과한 판결은 상소를 통해 취소할 수 있으나, 재심사유에는 해당하지 않으므로 판결이 확정되면 그 효력은 유효하다.

V. 결론

- 당사자적격은 정당한 당사자에게 본안판결을 내림으로써 사법 자원의 낭비를 방지하고 실질적 권리구제를 도모하는 핵심적인 소송요건이다. 법원은 직권 조사를 통해 당사자적격 유무를 엄격히 심사하되, 제3자 소송담당 제도 등을 조화롭게 운영하여 국민의 재판청구권을 보장하여야 한다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제03절 소송상의 대리인>

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제01절 공동소송>

[기출][2013-1-1]도급계약상 연대책임 관계인 공동 피고에 대한 임금청구소송에서 소송대리인의 대리권 범위

《【문제1】 乙과 丙은 도급계약에 따라 함께 사업을 수행하고 있고, 임금지급에 대하여 연대책임 관계에 있다. 그런데 수급인인 丙은 소속 근로자인 甲에게 임금을 지급하지 못하고 있다. 이에 甲은 乙과 丙을 공동 피고로 하여 임금청구의 소를 제기하였다. 이때 다음 물음에 대하여 각각 논하시오. (50점)

(문제1) 위 소송에서 甲이 변호사 A를 소송대리인으로 선임한 경우 소송대리인 A의 대리권의 범위는? (20점)》

<문제1의 물음1> 도급계약상 연대책임 관계인 공동 피고에 대한 임금청구소송에서 소송대리인의 대리권 범위

I. 문제의 제기

- 사안은 丙의 근로자인 甲이 임금을 지급받지 못하자 도급계약 관계인 乙과 丙을 공동 피고로 하여 임금청구의 소를 제기한 상황이다. 쟁점으로 원고 甲이 공동 피고 乙과 丙을 상대로 선임한 소송대리인인 변호사 A의 대리권의 범위가 어디까지인지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소송대리인의 일반적 대리권의 범위, 특별수권이 필요한 사항, 소송대리권의 제한 가능성 여부에 대하여 설명한다.

II. 소송대리권의 범위에 관한 법리

1. 일반적 소송대리권의 범위

(1) 법정 대리권의 의의

- 민사소송법 제90조 제1항에 의하면 소송물에 관한 양도나 대리권의 제한이 없는 한 당해 소송에 관한 모든 소송행위를 할 수 있는 권한을 가진다. 이는 소송계속 중 발생하는 대내외적인 변론, 증거신청, 기일지정 신청 및 상대방의 소송행위에 대한 대응 등을 모두 포함한다.

(2) 심급대리의 원칙

- 소송대리인의 대리권은 특별한 약정이 없는 한 수임한 당해 심급의 소송절차에만 한정된다. 따라서 제1심에서 선임된 소송대리인의 대리권은 제1심의 중국판결이 대리인에게 송달됨으로써 원칙적으로 소멸하며, 판결 송달 전이라 하더라도 상소심의 소송절차에는 대리권의 효력이 미치지 않는다.

2. 특별수권사항의 범위와 내용

(1) 특별수권의 필요성

- 민사소송법 제90조 제2항은 당사자의 처분권과 직결되거나 당사자에게 중대한 불이익을 초래할 수 있는 일정한 소송행위에 대하여는 본인의 특별한 권한의 위임(특별수권)을 받도록 강제하고 있다.

(2) 구체적 법정 사항

- 특별수권이 있어야만 대리인이 행할 수 있는 행위는 다음과 같다. ① 반소의 제기. ② 소의 취하, 화해, 청구의 포기·인낙 또는 제80조의 규정에 따른 탈퇴. ③ 상소의 제기 또는 취하. ④ 대리인의 선임.

3. 소송대리권 제한의 효력

(1) 대리권 제한의 원칙적 무효

- 민사소송법 제91조 본문에 의하면 변호사인 소송대리인의 소송대리권은 당사자의 사적 합의로 제한하지 못한다. 법정된 일반적 소송대리권에 가한 당사자 간의 사적인 제한은 법원이나 상대방에 대하여 효력이 없다. 이는 소송대리인의 자격을 신뢰한 법원과 상대방을 보호하고 소송절차의 확실적 안정을 도모하기 위함이다.

(2) 소송외적 제한의 상대적 효력

- 다만, 사적인 제한이라도 당사자 내부 관계에서는 채무불이행에 따른 민사상 손해배상책임 등의 원인이 될 수 있을 뿐이다. 또한, 특별수권사항(민사소송법 제90조 제2항)에 대하여 대리권을 별도로 수여하지 않기로 하는 것은 애초에 법정 소송대리권에 가해지는 소송법상의 사적 제한이 아니므로, 수권하지 않거나 제외하는 약정은 전적으로 유효하다.

III. 사안의 적용

1. 일반대리권의 범위

(1) 대리권 행사의 주체

- 원고 甲의 소송대리인 변호사 A는 특별한 사정이 없는 한 제1심 소송절차의 중국판결 송달 시까지 甲을 대리하여 소송행위를 수행할 법정 대리권을 가진다.

(2) 공동소송에서의 대리관계

- 乙과 丙은 임금지급에 대한 연대책임 관계에 있어 통상공동소송 관계에 해당한다. 소송대리인 A는 공동피고 乙과 丙 모두에 대하여 甲의 임금채권을 관철하기 위한 변론, 증거조사 신청, 준비서면 제출 등의 소송행위를 대리인으로서 적법하게 수행할 수 있다.

2. 특별수권의 범위

(1) 특별수권 유무에 따른 판단

- A가 乙이나 丙 중 일부에 대하여 소를 취하하거나, 법정에서 화해를 하거나, 청구의 포기·인낙을 하고자 하는 경우, 또는 패소 시 상소를 제기하고자 하는 경우에는 원고 甲으로부터 별도의 특별수권을 받아야만 한다. 특별수권이 없는 상태에서 행한 처분행위는 무권대리행위로서 무효이다.

(2) 대리권의 제한 요건

- 설명 甲이 A를 선임하면서 '상대방 乙에 대해서만 소송행위를 하고 丙에 대해서는 적극적으로 다루지 말 것'이라는 식으로 일반 대리권 범위를 제한하는 내부 계약을 체결하였더라도, 이러한 사적 제한은 민사소송법 제91조 본문에 의하여 수소법원과 상대방인 乙·丙에게 전적으로 효력이 없다.

IV. 결론

- 변호사 A의 소송대리권은 법정 심급대리 원칙에 따라 제1심 소송절차 전반에 미치며, 공동피고 乙과 丙 모두를 상대로 甲의 권리를 옹호하기 위한 변론 및 기일지정 등 일반적 소송행위 일체를 대리할 수 있다. 다만, 소의 취하, 화해, 청구의 포기·인낙, 상소의 제기 등 당사자의 처분권과 직결된 법정 특별수권사항에 대해서는 甲의 구체적인 특별위임이 있어야만 대리권을 행사할 수 있으며, 이외에 법정 대리권에 가해진 사적 제한은 민사소송법 제91조에 따라 소송법상 모두 무효이다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제03절 소송상의 대리인>

[기출][2016-1-2]대법원의 파기환송판결에 의해 사건이 다시 계속된 경우 변호사의 소송대리권 부활 여부

《【문제1】 乙회사의 근로자인 甲이 업무 중 상해를 입어 乙회사를 상대로 손해배상청구의 소를 제기하고자 한다. 다음 물음에 대하여 답하시오. (50점) (아래 각 설문은 상호 무관함)》

(물음2) 위와는 달리, 甲이 乙회사를 상대로 손해배상청구의 소를 제기하였다. 그 소송의 항소심에서 변호사 丁이 甲의 소송대리인이었는데, 대법원의 파기환송판결에 의하여 사건이 항소심에 다시 계속하게 되었다면 위 丁의 소송대리권은 어떻게 되는지를 설명하시오. (15점)》

<문제1의 물음2> 대법원의 파기환송판결에 의해 사건이 다시 계속된 경우 변호사의 소송대리권 부활 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 乙회사를 상대로 제기한 손해배상청구소송의 항소심에서 소송대리인이었던 丁이 대법원의 파기환송판결 이후 다시 항소심에 계속된 사건에서도 종전의 소송대리권을 유지하는지가 문제되는 상황이다. 쟁점으로 **파기환송으로 사건이 원심에 다시 계속된 경우 종전 항소심 소송대리인의 소송대리권이 소멸하는지 아니면 그대로 존속하는지**를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 파기환송 후 항소심에서 소송대리인 丁의 소송대리권의 존속 여부를 설명한다.

II. 심급대리의 원칙과 소송대리권의 범위

1. 심급대리의 원칙

- 소송대리권은 특별한 약정이 없는 한 당해 심급에 한하여 존속한다. 이는 대리인의 책임 범위를 명확히 하고, 당사자가 각 심급마다 새로운 대리인을 선임할 기회를 보장하기 위함이다.

2. 소송대리권의 범위

(1) 원칙적 범위

- **민사소송법 제90조 제1항**에 따라 소송대리인은 당해 심급의 소송물에 관한 일체의 소송행위를 할 수 있다. 여기에는 반소, 참가, 강제집행에 관한 행위 등이 포함된다.

(2) 특별수권사항

- **민사소송법 제90조 제2항**에 따라 상소의 제기, 소의 취하, 화해, 포기, 인낙 등은 당사자로부터 별도의 특별수권을 받아야 가능하다.

III. 파기환송과 소송대리권의 부활

1. 환송 후 절차

- 상고심에서 항소심 판결을 파기하고 사건을 다시 항소심 법원에 환송한 경우, 환송 후의 절차가 **이전 항소심 절차의 속행인지** 아니면 **새로운 심급의 시작인지**에 따라 대리권 존속 여부가 달라진다.

2. 판례의 태도

- **판례**는 환송 전 항소심에서의 소송대리인의 대리권은 상고 제기에 의하여 일단 소멸하지만, 상고심에서 원심판결을 파기하여 사건을 항소심에 환송한 경우 사건이 다시 환송 전의 상태로 돌아가는 것으로 본다. 환송 후의 절차는 환송 전 항소심 절차의 계속 및 속행에 해당하므로, 별도의 선임계 제출 없이도 환송 전 항소심 소송대리인의 대리권은 당연히 부활한다는 것이 **판례**의 일관된 입장이다.

IV. 사안의 적용

1. 소송대리권의 지속성

- 변호사 丁은 甲의 항소심 소송대리인으로서 이미 적법하게 대리권을 행사하였다. 대법원이 사건을 파기환송하였다는 것은 항소심 판결이 취소되고 사건이 다시 항소심 단계의 미결상태로 복귀함을 의미한다.

2. 대리권의 법적 상태

- **판례의 견해**에 따르면 환송 후 항소심은 환송 전 항소심의 연장이므로, 丁이 상고심에서 대리인이 아니었던더라도 사건이 항소심으로 환송됨과 동시에 丁의 소송대리권은 법률상 당연히 부활한다. 따라서 丁은 별도의 위임장을 다시 제출하지 않고도 甲을 위하여 환송 후 항소심 절차에서 소송행위를 할 수 있다.

V. 결론

- **민사소송법**상 심급대리의 원칙에도 불구하고, 파기환송판결에 의해 사건이 원심법원에 환송된 경우 환송 후의 소송절차는 환송 전 절차의 속행으로 간주된다. 따라서 환송 전 항소심 소송대리인이었던 변호사 丁의 소송대리권은 대법원의 파기환송결정과 동시에 당연히 부활한다. 丁은 환송 후 항소심에서 다시 甲의 소송대리인으로서 지위를 회복하며, 乙회사를 상대로 소송을 계속 수행할 수 있다.

<보충 - 파기환송 시 소송대리권 부활 여부에 대한 학설과 판례의 대립 분석>

I. 학설(부정설)의 논거와 법적 타당성

1. 심급대리 원칙의 실질적 관철과 당사자의 사적자치

(1) 심급대리 원칙의 취지 보장

- 심급대리의 원칙은 당사자가 각 심급의 판결 결과를 보고 다음 심급에서 새로운 대리인을 선임할 기회를 보장하는 데 목적이 있다. 파기환송 절차는 실질적으로 새로운 공격·방어방법이 제출되고 법적 공방이 재개되는 단계이므로, 형식적 소송계속의 동일성만을 이유로 이전 대리권을 강제하는 것은 당사자의 대리인 선택의 자유를 침해할 우려가 있다.

(2) 수임계약의 본질과 대리인 선임 의사

- 대부분의 소송위임계약은 심급별로 체결되며, 계약의 대가 역시 심급별 착수금 구조로 설계된다. 따라서 환송 전 단계에서 판결이 선고됨으로써 위임계약은 실질적으로 종료되었다고 보는 것이 계약 당사자들의 합리적인 의사에 부합한다.

2. 신의칙 및 신뢰관계의 변화와 대리인의 책임 범위

(1) 대리인과 본인 간 신뢰관계의 변동

- 상고심에서 원심판결이 파기되었다는 것은 환송 전 항소심에서 대리인이 수행한 소송 전략이나 법리 주장에 치명적인 하자가 있었거나 결과적으로 패소(원고의 경우 승소 판결이 깨진 경우 등)했음을 의미하는 경우가 많다. 이 과정에서 당사자와 변호사 사이의 신뢰관계에 중대한 변화나 균열이 발생했을 가능성이 매우 높음에도 대리권이 당연히 부활한다고 보는 것은 가혹하다.

(2) 변호사의 무한 책임 방지

- 대리권의 당연 부활을 인정하면, 환송 전 대리인은 당사자로부터 추가적인 보수를 받지 못했거나 관계가 소원해진 상태에서도 기일 지정 신청이나 서면 제출 등 소송수행 의무를 강제받게 된다. 이를 게을리할 경우 부당한 민사상 손해배상 책임이나 징계 책임을 질 수 있어 변호사에게 일방적으로 불리한 결과를 초래한다.

II. 판례(긍정설)의 실질적 고려와 한계

1. 소송절차의 안정과 소송경제

(1) 송달의 적법성 확보와 절차적 공백 방지

- 대법원이 사건을 환송했을 때 법원이 환송기일 통지서 등을 누구에게 송달해야 하는가의 문제가 발생한다. 대리권 부활을 부정하면 법원은 소송에 미숙한 당사자 본인에게 직접 송달해야 하므로 절차가 지연되거나 불측의 기일 해태로 인한 불이익이 발생할 수 있다. 판례는 송달의 확실성과 소송절차의 원활한 진행을 우선시한 결과이다.

(2) 소송계속의 연속성 유지

- 판례는 파기환송에 의해 사건이 원심법원으로 돌아가면 소송의 상태가 환송 전의 미결 상태로 복귀하는 것으로 파악한다. 즉, 소송법적으로는 심급이 바뀐 것이 아니라 동일한 항소심 절차가 중단 없이 수행되는 것으로 보기 때문에 형식적 논리상 대리권 역시 소멸하지 않고 존속하는 것으로 취급한다.

2. 현실적 계약 관행과의 괴리(판례의 한계) : 실무상 수임 관행과의 충돌

- 변호사 수임 실무에서 파기환송 사건은 새로운 심급에 준하는 막대한 노력과 새로운 법리 구성이 요구되므로 통상 환송 후 대리를 위한 별도의 수임계약을 체결한다. 그럼에도 법률상 대리권이 당연히 부활한다고 보는 판례의 태도는 실무상의 경제적 거래 관행을 반영하지 못한다는 치명적인 약점이 있다.

III. 종합적 검토 및 답안 작성 시 활용 전략

1. 법리적 정합성과 실무적 필요성의 조화

(1) 원칙과 예외의 조화로운 해석

- 법리적인 타당성과 사적자치의 원칙, 그리고 신뢰관계 보호 측면에서는 학설(부정설)이 훨씬 정교하고 현실적이다. 다만, 소송절차의 안정과 무권대리 방지라는 공익적 목적을 위해 판례(긍정설)가 유지되고 있다.

(2) 실무상 해결 방안의 존재

- 판례가 부활을 인정하더라도 현실에서는 이전 대리인이 소송수행을 원치 않을 경우 즉시 사임서를 제출하여 대리관계를 종료시킬 수 있다. 따라서 판례의 당연 부활설이 실제 신뢰 관계가 파탄 난 당사자들을 억지로 묶어두는 절대적인 족쇄로 작용하지는 않는다.

2. 2차 시험 답안 서술 시 고득점 서술 팁

(1) 학설 대립의 명확한 서술

- 답안 작성 시 단순히 '판례는 당연히 부활한다고 본다'라고만 끝맺지 말고, '학설은 심급대리의 원칙 및 신뢰관계 파탄을 이유로 부정하나, 판례는 소송절차의 안정과 연속성을 위해 당연 부활을 인정한다'라는 대립 구도를 선명하게 보여주어야 한다.

(2) 깊이 있는 검토의견 제시

- 검토의견 단락에서 '사적자치와 수임계약의 현실적 합치 측면에서는 부정설이 타당하나, 환송 직후 송달의 불명확성으로 인한 당사자의 절차적 불이익을 방지하고 소송경제를 도모하기 위해서는 당연 부활을 인정하되 변호사의 사임 권한으로 조율하는 판례의 태도가 실무상 조화롭다'와 같이 양설을 아우르는 균형 잡힌 검토를 제시하면 최고 수준의 가점을 받을 수 있다.

<관련판례>

- 대법원 1984. 6. 14.자 84다카744 결정

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제03절 소송상의 대리인>

[기출][2018-1-2]배우자 및 공인노무사의 소송대리권 인정 여부

《【문제1】 甲은 乙 노동조합(이하 '乙'이라 한다)의 조합원이다. 아래의 각 물음에 관하여 논하시오. (단, 아래의 각 물음은 상호 무관함) (50점)

(물음2) 甲은 乙에 대하여 5천만 원의 위로금 지급을 구하는 소를 제기하였다. 甲(제한능력자가 아님)의 배우자(공인노무사로 제한능력자가 아님)가 위 소송을 대리할 수 있는가? (20점)》

<문제1의 물음2> 배우자 및 공인노무사의 소송대리권 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 원고 甲이 乙 노동조합을 상대로 5,000만 원의 위로금 지급을 구하는 소송을 제기한 상황이다. 쟁점으로 **소송물이 5,000만 원인 단독사건에서 배우자라는 신분적 관계나 공인노무사라는 직업적 자격이 소송대리권 인정의 근거가 될 수 있는지를** 검토할 필요가 있다. 이하에서는 변호사대리원칙의 의의와 비변호사의 소송대리 허용 요건을 중심으로 배우자의 소송대리 가능성에 대해 설명한다.

II. 변호사대리원칙과 예외

1. 변호사대리원칙 [민사소송법 제87조]

- 법률에 따라 재판상의 행위를 할 수 있는 대리인 외에는 변호사가 아니면 소송대리인이 될 수 없다. 이는 소송절차의 원활한 진행과 당사자의 권익 보호를 위해 법률 전문가에 의한 대리를 강제하는 것이다.

2. 비변호사 소송대리의 예외적 허용 [민사소송법 제88조]

(1) 대상 사건의 범위

- 단독판사가 심리·판결하는 사건 중 수표·어음금, 대여금, 구상금, 손해배상 등 비교적 사안이 단순한 사건으로서 일정한 금액(현행 규칙상 소송물가액 1억 원) 이하인 사건에 한하여 인정된다.

(2) 대리인의 자격 요건

- 당사자와 밀접한 생활관계를 맺고 있는 일정 범위의 친족(배우자, 직계혈족, 형제자매)이거나, 당사자와 고용 등 상시적인 업무관계를 맺고 있는 사람이어야 한다.

(3) 법원의 허가

- 위 요건을 갖춘 경우라도 법원의 허가를 얻어야 하며, 법원은 언제든지 그 허가를 취소할 수 있다.

III. 공인노무사의 소송대리권 인정 여부

1. 공인노무사법상 직무 범위

- 공인노무사는 노동관계법령에 따른 서류 작성, 상담, 노동위원회 사건 대리 등을 직무로 한다. 그러나, 현행법상 공인노무사에게 **민사소송법상** 소송대리권이 일반적·당연적으로 부여되어 있지는 않다.

2. 판례의 태도

- 판례는 **변호사법** 및 **민사소송법**의 취지에 비추어 법률에 특별한 규정이 없는 한 비변호사의 소송대리를 엄격히 제한한다. 공인노무사라 하더라도 민사소송절차에서는 변호사대리원칙의 예외를 규정한 별도의 법률이 없으므로, 자격 그 자체만으로는 소송대리인이 될 수 없다고 본다.

IV. 사안의 적용

1. 소송물가액과 단독사건 해당 여부

- 甲이 제기한 소송의 금액은 5,000만 원이다. 이는 3,000만 원을 초과하여 소액사건심판법의 적용 대상은 아니지만, 1억 원 이하의 단독사건에 해당하므로 **민사소송법 제88조**에 따른 소송대리 허가 신청이 가능한 범위에 있다.

2. 배우자로서의 소송대리 가능성

- 배우자는 **민사소송법 제88조** 및 **민사소송규칙 제15조**가 정한 밀접한 생활관계에 있는 사람에 해당한다. 따라서 甲의 배우자는 공인노무사라는 자격 때문이 아니라 배우자라는 신분적 자격에 근거하여 법원에 소송대리 허가를 신청할 수 있다.

3. 법원의 허가 여부

- 다만, 배우자라는 신분만으로 당연히 대리권이 발생하는 것은 아니다. 甲과 배우자가 서면으로 소송대리 허가신청을 하고, 법원이 해당 사건의 난이도와 배우자의 법률적 지식 등을 고려하여 허가 결정을 내릴 때 비로소 대리권이 발생한다. 사안의 경우 배우자가 공인노무사로서 법률적 소양이 충분하므로 법원이 허가할 가능성이 높으나, 법원의 허가 없이는 소송행위를 할 수 없다.

V. 결론

- 甲의 배우자가 단지 공인노무사라는 직업적 자격만으로 소송을 대리할 수는 없다. 그러나 사안의 소송은 5,000만 원의 단독사건으로서 비변호사 대리 허가 대상에 해당하므로, 甲의 배우자는 배우자라는 신분적 관계를 근거로 법원의 허가를 받아 소송을 대리할 수 있다. 만약 법원의 허가를 받지 않고 소송행위를 한다면 이는 소송대리권 없는 자의 행위로서 무효가 되며, 법원은 대리인의 출석을 거부하거나 소송행위를 배제해야 한다.

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제03절 소송상의 대리인>

[모의][4.03-1]특별수권사항의 의의, 구체적 범위, 특별수권없는 대리의 효력

《【문제4.3-1】 특별수권사항에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제4.3의 물음1> 특별수권사항의 의의, 구체적 범위, 특별수권없는 대리의 효력

I. 소송대리권 범위의 법정주의와 특별수권사항의 의의

1. 소송대리권 범위의 법정주의 [민사소송법 제90조 제1항]

- 소송법상 소송대리인의 권한 범위를 전적으로 사적 계약에만 의존하게 하면 소송 상대방이 예상치 못한 불이익을 입기 쉽고, 소송절차의 확실적·안정적인 진행을 해치게 된다. 따라서 우리 **민사소송법**은 소송대리인의 권한 범위를 법률로 획일화하여 직접 규정하는 법정주의를 채택하고 있다.

2. 특별수권사항의 의의

- 소송대리인은 위임받은 소송에 대하여 소의 제기나 화해 등 일체의 소송행위를 할 수 있는 일반적 대리권을 가진다. 다만, 소송물의 처분이나 소송의 종료 등 본인의 실체적 권리관계에 심대한 영향을 미치는 특정 소송행위에 대해서는 본인의 명시적이고 개별적인 권한 수여를 요구하는데, 이를 특별수권사항이라 한다.

II. 구체적 특별수권사항의 범위

1. 소송의 개시·종결 등에 관한 사항 [민소법 제90조 제2항 제1호·제2호]

- 본인의 적극적인 의사 결정 및 처분의사가 필수적인 항목들로서, 반소의 제기, 소의 취하, 화해, 청구의 포기·인낙, 독립당사자참가소송탈퇴를 하려면 특별수권을 별도로 받아야 한다.

2. 대리인 선임 및 상소 등에 관한 사항 [민소법 제90조 제2항 제3호·제4호]

- 소송대리인이 자신이 가진 대리권에 기초하여 다른 대리인을 선임하는 복대리인의 선임, 심급을 이동시키거나 소송을 종료시키는 상소의 제기 또는 취하, 대리인의 선임을 하는 경우에도 반드시 특별수권이 존재하여야 한다.

III. 특별수권 없는 대리행위의 효력 및 본인의 추인 가부

1. 특별수권 없는 대리행위의 효력

(1) 원칙

- 특별수권이 결여된 채 이루어진 소송대리인의 소송행위는 소송법상 무권대리행위가 되어 원칙적으로 무효이다.

(2) 간과 판결 효과

- 다만, 이러한 하자를 법원이 간과하고 본안판결을 선고한 경우, 판결이 확정되기 전에는 상소(항소 및 상고)를 제기하여 판결을 취소할 수 있고 판결이 이미 확정되었다면 재심의 소를 제기하여 구제받을 수 있다.

2. 본인의 추인 가부

(1) 추인의 소급효와 요건

- **민사소송법 제97조**가 **제60조**를 준용하여 무권대리인의 소송행위라도 소송경제 및 당사자의 이익을 위해 본인이 사후에 추인하는 것을 허용한다. 본인의 적법한 추인이 있으면 무권대리 소송행위는 행해진 시점으로 소급하여 대리권이 있었던 것과 동일하게 유효해진다.

(2) 추인의 방식 및 시기적 한계

- 추인의 방식은 반드시 서면이나 명시적 언동으로만 해야 하는 것은 아니며, 무권대리 소송행위의 결과를 묵묵히 받아들이는 등의 묵시적 방식으로도 가능하다. 추인을 할 수 있는 시기는 소송절차의 안정을 지나치게 해치지 않는 한 판결이 확정되기 전까지이며, 사실심은 물론 상고심에서도 자유롭게 추인할 수 있다.

IV. 결론

- 소송대리권 범위의 법정주의 체제 하에서 특별수권사항은 대리인의 독단적인 권리 처분 행위로부터 소송당사자 본인의 실질적 이익을 두텁게 보호하기 위한 법률상의 안전망이다. 따라서 법원은 소송절차의 정당성과 사법 신뢰를 확보하기 위해 대리권의 존부 및 특별수권 구비 여부를 직권으로 엄격하게 조사하여야 한다. 다만, 절차적 흠결이 발생한 대리행위에 대해서는 사후 추인 제도를 유연하게 조화시킴으로써 불필요한 소송 지연을 막고 사법자치를 조화롭게 실현하여야 할 것이다.

《【문제5.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 제1심 소송 계속 중, 피고 乙은 "甲과 소를 제기하기 전에 이미 이 사건 분쟁에 대하여 법원에 소를 제기하지 않기로 합의(부제소특약)를 하였으므로 이 사건 소는 부적법하다"고 주장하며 소각하를 청구하였다. 그러나 제1심 법원은 부제소특약의 존재 여부 및 그 적법성에 대해 구체적으로 심리하지 아니한 채, 변론기일을 열어 곧바로 대여금 채권의 성립 여부 등 본안에 관한 심리를 진행하였다. 제1심 법원은 심리 결과 대여금 채권이 시효로 소멸하였다는 이유로 甲의 청구를 기각하는 본안판결을 선고하였고, 甲은 이에 불복하여 항소하였다. 한편, 또 다른 사건에서 원고 A는 피고 B를 상대로 손해배상 청구소송을 제기하여 심리가 진행 중이다. 그런데 소송 계속 중 B는 "A가 정신적 질환으로 인해 의사능력을 완전히 상실하였으므로 당사자능력이 흠결이 발생하였다"고 주장하였다. 제1심 법원은 이러한 당사자능력과 같은 소송요건의 존재 여부를 어느 시점을 기준으로 판단해야 하는지, 그리고 해당 소송요건의 존부에 대한 증명책임은 소송법상 누구에게 귀속되는지 검토하고 있다.

(물음1) 피고 乙이 부제소특약의 합의가 존재한다고 주장하였음에도 제1심 법원이 소송요건의 존부를 판단하지 않고 본안기각판결을 선고한 조치의 적법성 여부를 소송요건의 조사 순서 및 소송요건 흠결을 간과한 판결의 효력과 관련하여 설명하시오.》

<문제5.2의 물음1> 부제소특약의 간과와 본안기각판결 선고의 적법성 및 그 효력

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였는데, 乙이 부제소특약의 존재를 주장하였음에도 제1심 법원은 이에 대한 심리 없이 본안에 관하여 청구기각판결을 선고한 상황이다. 쟁점으로 **소송요건인 부제소특약의 존부를 본안에 앞서 심리하여야 하는지, 이를 간과한 채 선고한 본안판결의 적법성과 효력**을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소송요건의 조사 순서와 소송요건 흠결을 간과한 본안판결의 효력을 중심으로 제1심 법원의 조치의 적법성 여부를 설명한다.

II. 소송요건의 의의와 조사 순서

1. 소송요건의 의의와 부제소특약

(1) 소송요건의 의의

- 소송요건이란 소송이 적법한 상소로서 법원의 본안심판을 받기 위해 갖추어야 할 요건을 말한다. 이는 공익적 견지에서 법원이 직권으로 조사해야 하는 직권조사사항과 당사자의 이익이 있어야 비로소 조사하는 항변사항으로 나뉜다.

(2) 부제소특약의 성격

- 부제소특약은 당사자 간의 합의로 소송을 제기하지 않기로 약정하는 사법상 계약이다. **판례**는 이를 권리보호의 이익(소의 이익)에 관한 소송요건으로 보며, 당사자가 주장해야 비로소 심리하는 소송법상의 항변사항으로 취급한다.

2. 소송요건의 조사 순서와 선순위성

(1) 조사 순서의 원칙

- 법원은 소가 적법한지(소송요건)를 먼저 심사한 후, 비로소 청구가 이유 있는지(본안)를 심리하여야 한다. 이를 소송요건심리의 선순위성이라고 한다. 소송요건이 구비되지 않은 소송은 부적법하므로 법원은 본안심리를 진행할 수 없다.

(2) 원칙의 위반 효과

- 소송요건에 흠결이 있는 소송에 대하여 본안판결을 선고하는 것은 소송요건심리의 선순위성 원칙에 반하여 허용되지 않는다. 즉, 소송요건에 대한 판단을 생략한 채 본안심리를 진행하여 판결하는 조치는 절차법적으로 부적법하다.

III. 소송요건 흠결을 간과한 판결의 효력

1. 간과판결의 효력 일반

(1) 당연무효 여부

- 소송요건의 흠결을 간과한 판결은 원칙적으로 당연무효가 아니다. 판결에 중대한 법령 위반이 존재하여 위법할 뿐이므로, 상소 제기를 통해 취소할 수 있는 사유(취소사유)에 불과하다. 만약, 상소기간이 경과하여 판결이 확정된다면 그 기판력 등의 효력은 그대로 유지된다.

(2) 예외적인 당연무효 사유

- 당사자능력이 원천적으로 결여된 사망자를 상대로 한 판결이나 대한민국 재판권이 미치지 않는 대상에 대한 재판 등 극히 이례적인 절차적 흠결이 존재하는 경우에 한하여 예외적으로 당연무효가 된다. 사안의 부제소특약 흠결은 이에 해당하지 않는다.

2. 항소심의 처리와 불이익변경금지의 원칙

(1) 항소법원의 조치

- 원고만이 항소한 경우, 항소심 법원은 제1심의 본안기각판결을 취소하고 소송요건 흠결을 이유로 소각하판결을 선고할 수 있다. 소각하판결은 본안심리를 거절하는 처분으로서 기판력이 본안에 미치지 않으므로, 원고에게 본안청구기각보다 불리한 결과가 아니다.

(2) 불이익변경금지의 원칙과의 관계

- **판례**는 제1심의 청구기각(본안기각) 판결에 대하여 원고만이 항소한 경우, 항소심 법원이 소가 부적법함을 이유로 제1심 판결을 취소하고 소각하판결을 하더라도 불이익변경금지의 원칙에 반하지 않는다고 본다. 본안기각판결보다 소각하판결이 원고에게 더 유리하거나 최소한 동등한 위치에 있기 때문이다.

IV. 사안의 적용

1. 제1심 법원 조치의 위법성

(1) 조사 의무 위배

- 피고 乙이 소송 계속 중 부제소특약의 합의를 주장(항변)하였으므로, 제1심 법원은 본안심리에 나아가기 전에 부제소특약의 존부와 적법성 여부를 우선적으로 심리·판단해야 할 소송법상 의무가 있었다.

(2) 선순위성 위배

- 법원이 부제소특약 유무를 확인하지 않고 곧바로 채권의 시효 소멸을 이유로 기각한 조치는 소송요건심리의 선순위성을 위반한 위법한 재판이다.

2. 판결의 효력 및 구제 방법

(1) 판결의 효력

- 제1심 법원이 내린 청구기각 판결은 절차적으로 위법하나 당연무효는 아니다. 적법한 상소 대상이 되므로, 甲은 항소를 통해 원심판결의 위법성을 다투어 구제받을 수 있다.

[2] 항소심의 최종 판단

- 항소심 법원은 부제소특약의 존재를 심리하여 특약이 유효함이 인정된다면, 제1심 판결을 취소하고 소를 부적법 각하하는 판결을 내려야 한다. 이는 불이익변경금지원칙에 저촉되지 않는 적법한 하자의 시정이다.

V. 결론

- 제1심 법원이 피고 乙의 부제소특약 주장을 심리하지 않고 곧바로 본안기각판결을 선고한 조치는 소송요건심리의 선순위성 원칙을 위반한 위법한 조치이다. 다만, 이 판결은 당연무효가 아니며 취소사유에 해당한다. 따라서 항소심 법원은 乙의 부제소특약 주장을 심리한 후 특약이 유효함이 밝혀진다면, 제1심 판결을 취소하고 소각하판결을 선고하여 제1심의 위법을 시정하여야 한다.

<제3편 제1심의 소송절차.제05장 소송 개시와 심리 대상.제02절 소송요건>

[모의][5.02-2]당사자능력 등 소송요건의 존재를 판단하는 기준 시점과 증명방법 및 증명책임의 분배 원칙

《【문제5.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 제1심 소송 계속 중, 피고 乙은 "甲과 소를 제기하기 전에 이미 이 사건 분쟁에 대하여 법원에 소를 제기하지 않기로 합의(부제소특약)를 하였으므로 이 사건 소는 부적법하다"고 주장하며 소각하를 청구하였다. 그러나 제1심 법원은 부제소특약의 존재 여부 및 그 적법성에 대해 구체적으로 심리하지 아니한 채, 변론기일을 열어 곧바로 대여금 채권의 성립 여부 등 본안에 관한 심리를 진행하였다. 제1심 법원은 심리 결과 대여금 채권이 시효로 소멸하였다는 이유로 甲의 청구를 기각하는 본안판결을 선고하였고, 甲은 이에 불복하여 항소하였다. 한편, 또 다른 사건에서 원고 A는 피고 B를 상대로 손해배상 청구소송을 제기하여 심리가 진행 중이다. 그런데 소송 계속 중 B는 "A가 정신적 질환으로 인해 의사능력을 완전히 상실하였으므로 당사자능력에 흠결이 발생하였다"고 주장하였다. 제1심 법원은 이러한 당사자능력과 같은 소송요건의 존재 여부를 어느 시점을 기준으로 판단해야 하는지, 그리고 해당 소송요건의 존부에 대한 증명책임은 소송법상 누구에게 귀속되는지 검토하고 있다.

(물음2) A와 B의 소송에서 당사자능력 등 소송요건의 존재를 판단하는 기준 시점은 언제인지 설명하고, 소송요건의 존부에 대한 증명방법 및 증명책임의 분배 원칙에 대하여 기술하시오.》

<문제5.2의 물음2> 당사자능력 등 소송요건의 존재를 판단하는 기준 시점과 증명방법 및 증명책임의 분배 원칙

I. 문제의 제기

- 사안에서 원고 A와 피고 B 사이의 손해배상청구소송에서 피고가 원고의 당사자능력 흠결을 주장함에 따라 소송요건인 당사자능력 등의 존부를 판단하여야 하는 상황이다. 쟁점으로 **소송요건의 존부를 판단하는 기준 시점과 소송요건에 관한 증명방법 및 증명책임의 분배 원칙이 무엇인지** 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소송요건의 판단 기준 시점과 소송요건의 증명방법 및 증명책임의 분배 원칙을 기술한다.

II. 소송요건의 존재 판단 기준시점

1. 원칙 : 사실심 변론종결시

- 소송요건은 본안판결을 선고하기 위한 전제조건이므로, 소 제기 당시뿐만 아니라 판결을 선고하는 시점에도 구비되어 있어야 한다. 따라서 소송요건의 존부를 판단하는 표준적인 기준시점은 사실심의 변론종결시가 된다. 소 제기 당시에 소송요건에 흠결이 있었더라도 사실심 변론종결시까지 보정되면 소는 적법해지며, 반대로 소 제기 당시에는 요건을 갖추었으나 소송 도중 흠결이 발생하고 변론종결 시까지 보정되지 않으면 부적법 각하된다.

2. 예외 : 소 제기시 등을 기준으로 하는 경우

- 일부 소송요건은 제도의 취지상 예외적인 기준시점을 갖는다. 예컨대 제소기간의 준수 여부는 소 제기시를 기준으로 판단하며, 관할권의 존부는 **민사소송법 제29조**에 따라 소를 제기한 때를 기준으로 확정되는 관할항정의 원칙이 적용된다.

III. 소송요건의 증명방법 및 증명책임

1. 소송요건의 증명방법

(1) 직권조사사항과 자료수집의 범위

- 당사자능력을 비롯한 대부분의 소송요건은 직권조사사항에 해당하므로 법원은 직권으로 조사를 진행하여야 한다. 이때 자료의 수집까지 법원이 직권으로 행하는 직권탐지주의가 적용되는지, 아니면 자료의 제출은 당사자에게 맡기되 조사만 직권으로 하는 직권조사주의가 적용되는지에 대해 **판례**는 소송요건의 성질에 따라 판단한다. 공익적 성격이 강한 당사자능력, 대리권 존부 등은 직권탐지주의가 적용된다.

(2) 자유로운 증명

- 본안의 사실인정은 엄격한 증명에 의하여야 하므로 법정의 증거방법에 제한을 받으나, 소송요건에 관한 사실은 소송절차에 관한 사실에 불과하므로 증거방법의 제한이 없는 자유로운 증명으로 족하다. 따라서 법원은 신문조서, 공문서 외에 간이한 방법으로 사실을 확인할 수 있다.

2. 소송요건의 증명책임 분배 원칙

(1) 적극적 소송요건

- 소가 적법하기 위해 존재해야 하는 요건인 당사자능력, 당사자적격, 재판권 및 관할권의 존재에 대해서는 원칙적으로 소를 제기한 원고가 그 존재에 대한 증명책임을 부담한다.

(2) 소극적 소송요건

- 소가 적법하기 위해 존재하지 않아야 하는 장애사유인 기판력의 저촉, 중복소제의 금지 위배, 부제소특약의 존재에 대해서는 소의 부적법을 주장하며 각하를 구하는 피고가 그 존재에 대한 증명책임을 부담한다.

IV. 사안의 적용

1. 당사자능력 판단 기준시점의 적용

- 원고 A는 소송 계속 중 정신질환으로 의사능력을 상실하여 당사자능력의 흠결 문제가 발생하였다. 당사자능력은 적극적 소송요건이자 직권조사사항이므로, 제1심 법원은 사실심 변론종결시를 기준으로 A의 당사자능력 유무를 판단하여야 한다. 만약 변론종결 당시에도 A가 당사자능력을 회복하지 못했거나 적법한 특별대리인 등의 수계 절차가 이루어지지 않았다면 소는 부적법 각하되어야 한다.

2. 증명방법 및 증명책임의 적용

- 당사자능력의 존부는 공익적 소송요건이므로 법원은 직권탐지주의에 따라 자유로운 증명방법으로 A의 의사능력 상실 여부 및 병원 진단서 등을 검토할 수 있다. 소송법상 적극적 소송요건인 당사자능력의 존재에 대한 최종적인 증명책임은 원고 A 측에 귀속되지만, 법원은 직권으로 의사의 감정을 명하는 등 사실 조사를 선행하여 절차적 하자를 치유할 수 있도록 조치하여야 한다.

V. 결론

- 당사자능력 등 소송요건의 존재를 판단하는 기준시점은 원칙적으로 사실심 변론종결시이다. 소송요건의 증명은 증거방법에 제한이 없는 자유로운 증명으로 가능하며, 당사자능력과 같은 적극적 소송요건의 존부에 대한 최종적인 증명책임은 소를 제기한 원고에게 귀속된다. 따라서 법원은 변론종결시를 기준으로 A의 의사능력 결여 상태를 자유로운 증명방법으로 심리한 후, 요건 흠결이 확정된다면 소를 각하하여야 한다.

<제3편 제1심의 소송절차.제05장 소송 개시와 심리 대상.제02절 소송요건>

[모의][5.02-3]소송요건의 의의, 구체적 분류, 조사 심리 절차, 요건 흠결 시 소송법상 효과

《【문제5.2-3】 소송요건에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제5.2-3> 소송요건의 의의, 구체적 분류, 조사 심리 절차, 요건 흠결 시 소송법상 효과

I. 소송요건의 의의

- 소송요건이란 법원이 원고의 소 청구에 대하여 실체적 당부를 판단하는 본안판결을 내리기 위하여 갖추어야 할 전제조건들을 말한다. 이는 소의 적법 여부를 결정하는 척도가 되며, 소송요건의 구비는 본안심리를 개시하기 위한 전제조건으로서 강행규정성 및 공익적 성격을 지닌다.

II. 구체적 분류

1. 소송 주체에 관한 요건

(1) 법원에 관한 요건

- 대한민국 법원의 재판권 및 소 제기 법원의 관할권의 존재가 이에 해당한다.

(2) 당사자에 관한 요건

- 당사자의 실재, 당사자능력, 소송능력, 대리권의 존재, 구체적 소송물과의 관계에서 판결을 받기에 적합한 자적인 당사자적격의 구비가 필요하다.

2. 소송 객체에 관한 요건

(1) 소송물에 관한 요건

- 소의 이익(권리보호이익)의 구비, 중복소제기 또는 기판력에 저촉되지 않을 것 등이 요구된다.

(2) 소제기에 관한 요건

- 소제기 방식의 적법성 및 소송비용의 담보제공이나 인지 첨부 등이 올바르게 이행되어야 한다.

III. 조사 심리 절차

1. 조사 권한의 성질에 따른 구별

(1) 직권조사사항의 원칙

- 소송요건은 원칙적으로 강행규정에 해당하므로 피고의 이의 제기를 기다리지 않고 법원이 언제나 스스로 심리해야 하는 직권조사사항이다.

(2) 항변사항의 예외

- 사적 자치가 허용되는 관할합의, 중재합의 등 예외적인 사항은 피고의 이의 제기가 있어야만 비로소 조사하는 항소 · 항변사항으로 취급된다.

2. 심리 방식과 조사 한계

(1) 직권조사주의의 적용

- 법원은 소송요건의 존부를 직권으로 조사하되, 그 사실의 주장과 증거제출 책임은 당사자에게 있는 직권조사주의가 적용된다.

(2) 사실탐지의 한계

- 당사자의 증명 활동과 무관하게 법원이 독자적으로 소송자료를 수집해야 하는 직권탐지주의와는 구별되어야 하므로 당사자의 사실 제출 독점권이 보장된다.

IV. 요건 흠결 시 소송법상 효과

1. 심리 단계에서의 임시 조치

(1) 석명권 행사와 보정명령

- 소송요건의 흠결을 발견한 경우 법원은 즉시 각하하지 않고, 당사자표시정정 등 보정이 가능한 하자에 대해서는 일정한 기간을 정해 보정을 촉구해야 한다.

(2) 하자의 치유

- 소송요건의 존부는 사실심 변론종결 시를 기준으로 하므로, 제소 당시에 흠결이 있었다라도 변론종결 전까지 하자가 치유되면 적법한 소가 된다.

2. 중국적인 판결 및 불복

(1) 소각하 판결의 원칙

- 흠결이 보정되지 않거나 보정이 불가능한 성질의 것인 때에는 법원은 본안심리를 거절하고 판결로써 소를 부적법 각하하여 소송을 바로 종료해야 한다.

(2) 하자 간과 판결의 구제

- 흠결을 간과한 본안판결에 대하여 당사자는 상소(항소 및 상고)로 취소를 구할 수 있으나, 확정되면 당연무효의 극단적 하자가 아닌 한 기판력이 발생하여 유효한 판결로 취급된다.

V. 결론

- 소송요건은 사법 자원의 불필요한 낭비를 방지하고 적법한 재판 청구만을 수용하려는 소송법적 안전망이다. 우리 민사소송법은 직권조사주의와 보정명령 제도를 적절히 조화시켜, 절차의 엄격성을 수호하면서도 국민의 재판을 받을 권리를 부당하게 제한하지 않도록 균형 있게 조율하고 있다.

<제3편 제1심의 소송절차.제05장 소송 개시와 심리 대상.제03절 소의 이익>

[기출][2018-1-1]조합규약상 소제기 금지규정의 유효성과 이를 위반한 소의 적법성

《【문제1】 甲은 乙 노동조합(이하 '乙'이라 한다)의 조합원이다. 아래의 각 물음에 관하여 논하시오. (단, 아래의 각 물음은 상호 무관함) (50점)

(물음1) 乙은 조합규약에 근거하여 자체적으로 만든 신분보장대책기금관리규정(이하 '관리규정'이라 한다)상의 위로금 지급을 둘러싼 乙과 조합원 간의 분쟁에 관하여 乙을 상대로 일절 소송을 제기할 수 없다는 규정을 두고 있다. 그 후 甲이 乙에 대하여 위 관리규정에 따른 위로금의 지급을 요구하였으나 乙이 이를 거절하였다. 이에 甲은 乙을 피고로 하여 위 관리규정에 따른 위로금 지급을 구하는 소를 법원에 제기하였다. 위 소송에서 乙은 甲이 위 관리규정상의 소제기 금지규정에 위반하여 소를 제기한 것이므로 위 소는 소의 이익이 없다고 주장하고 있다. 乙의 주장은 타당한가? (30점)》

<문제1의 물음1> 조합규약상 소제기 금지규정의 유효성과 이를 위반한 소의 적법성

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 노동조합 乙의 관리규정에 따른 위로금 지급을 청구하는 소를 제기하였으나, 乙은 관리규정상의 소제기 금지규정을 근거로 이 사건 소는 소의 이익이 없어 부적법하다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 노동조합 관리규정상의 소제기 금지규정의 효력과 이를 이유로 소의 이익이 부정되는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 乙의 주장이 타당한지 논한다.

II. 소제기 금지규정의 법적 성질 및 효력에 관한 법리

1. 자치적 법규범의 법적 효력과 한계

(1) 자치적 법규범의 의의

- 노동조합이 조합규약에 근거하여 자체적으로 만든 기금관리규정은 자치적 법규범으로서 소속 조합원에 대하여 법적 효력을 가진다.

(2) 자치적 법규범의 한계

- 다만, 자치적 법규범은 헌법이 보장하고 있는 조합원 개개인의 기본적 인권에 대해 합리적인 범위를 벗어나 과도하게 침해해서는 아니 되며, 강행법규나 공서양속에 반해서도 안 된다. 이에 위반된 자치규범은 효력이 없다.

2. 부제소합의의 의의 및 유효요건

(1) 부제소합의의 의의 및 효과

- 부제소합의는 특정한 권리나 법률관계에 관하여 분쟁이 있더라도 소를 제기하지 않기로 약정하는 당사자 간의 합의이다. 유효한 부제소합의에 위반하여 제기한 소는 소의 이익(권리보호이익)이 없어 부적법 각하된다.

(2) 부제소합의의 유효요건

- 부제소합의가 유효하기 위해서는 다음의 요건을 충족하여야 한다. ❶ 당사자가 처분할 수 있는 권리관계에 관한 것일 것. ❷ 특정한 법률관계에 한정된 합의일 것. ❸ 합의 당시 각 당사자가 예상할 수 있는 범위 내의 상황에 관한 것일 것. ❹ 불공정한 방법에 의한 합의가 아닐 것

3. 관리규정상 소제기 금지규정의 효력에 관한 판례의 태도

(1) 재판청구권의 일률적 박탈

- 대법원은 관리규정에 기한 위로금 분쟁에 관하여 노동조합을 상대로 일절 소송을 제기할 수 없도록 정한 규정은 조합원의 재산권에 속하는 위로금 지급을 둘러싼 법률상 쟁송에 대해 헌법상 보장된 조합원의 재판받을 권리를 구체적 분쟁 발생 전에 미리 일률적으로 박탈하는 것이라고 본다.

(2) 부제소합의의 제도 취지 위반에 따른 무효

- 또한 특정한 법률관계에 관하여 예상할 수 있는 범위 내에서만 허용되는 부제소합의의 제도의 취지에도 위반된다. 따라서 판례는 이러한 소제기 금지규정이 국민의 재판받을 권리를 보장한 헌법 제27조 제1항 및 법원조직법 제2조 제1항에 위반되어 무효라고 판시하였다.

III. 사안의 적용

1. 관리규정상 소제기 금지규정의 효력 평가

- 사안의 위로금 지급 청구권은 조합원 甲의 구체적 재산권에 해당한다. 乙이 정한 관리규정상의 소제기 금지규정은 분쟁이 구체화되기도 전에 미리 조합원의 재판청구권을 포괄적·일률적으로 박탈하고 있다. 이는 헌법상 보장된 재판받을 권리를 침해하고 부제소합의의 한계를 일탈한 자치규범이므로 무효이다.

2. 소의 이익 인정 여부 및 乙 주장의 타당성 검토

- 소제기 금지규정이 무효이므로 甲과 乙 사이에는 유효한 부제소합의가 성립되어 있지 않다. 따라서 甲이 제기한 소송은 적법한 부제소합의를 위반한 소가 아니며, 위로금의 이행 여부에 대한 사법적 확정이 요구되는바 소의 이익이 충분히 인정된다. 따라서 소제기 금지규정을 위반하여 소의 이익이 없다는 피고 乙의 주장은 법리적으로 타당하지 않다.

IV. 결론

- 乙 노동조합의 관리규정상 소제기 금지규정은 헌법과 법원조직법이 보장하는 조합원의 재판받을 권리를 일률적으로 침해하는 규정으로서 무효이다. 따라서 甲이 제기한 위로금 지급 청구의 소는 소의 이익을 구비한 적법한 소이며, 乙의 항변은 이유가 없다. 그러므로 법원은 乙의 주장을 배척하고 본안 심리를 개시하여야 한다.

《【문제2】 장래의 이행을 청구하는 소에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 장래의 이행의 소의 이익, 법리, 구체적 양태

I. 장래의 이행의 소의 이익

- 민사소송법상 장래의 이행을 청구하는 소는 청구권의 발생 또는 이행기가 소송의 변론종결 후에 도래하는 이행청구권을 소송물로 삼는 소송 형태를 의미한다. 이는 이행기가 오기 전에 채권자의 실질적인 이익을 위하여 미리 판결을 받아둌으로써 장래의 채무불이행에 대비하는 매우 유용한 예방적 권리구제 수단이다. 다만, 피고에게 무용한 소송 부담을 주지 않고 남소를 방지하기 위하여 일정한 법적 요건하에서만 예외적으로 허용되고 있다.

II. 장래의 이행의 소의 법리

1. 장래이행의 소의 제도적 취지

- 이행기가 도래하였을 때 즉시 강제집행을 실행할 수 있도록 미리 법적 집행력을 확보해 둬으로써, 채권자에게는 소송경제적 편의와 신속한 권리구제를 제공하고 사법제도 전반의 효율성을 도모하고자 함에 있다.

2. 장래의 이행의 소의 적법요건

(1) 청구권의 선행적 존재

- 장래 이행할 채무의 기초가 되는 계약이나 법률관계가 변론종결 당시에 이미 성립되어 존재하고 있어야 한다. 또한 장래 청구권 발생이 단순히 막연한 기대나 가능성에 그치지 않고 사실상 확실하게 예견되는 수준의 인과관계가 확보되어야 적법하다.

(2) 미리 청구할 필요성

- 이행기가 도래하더라도 채무자가 임의이행을 하지 않을 것으로 객관적으로 우려되는 사정이 인정되어야 한다. 판례는 채무자가 채무의 존부 자체를 다투고 있거나, 조건 성취를 완강히 부정하는 등 자발적인 급부 이행을 기대하기 어려운 경우에 이를 인정한다.

3. 미리 청구할 필요성의 구체적 판단 기준

(1) 채무자의 다투는 태도

- 피고가 원고의 청구권에 대하여 그 성립 자체를 전면 부인하거나 채무의 범위 등을 적극적으로 다투고 있는 경우라면, 장래 이행기가 도래하더라도 피고가 의무를 성실히 이행할 것을 기대하기 어려우므로 소의 이익이 긍정된다.

(2) 급부의 계속성과 이행 지체의 우려

- 부당이득반환이나 임료 상당의 손해배상 등 장래의 정기적 급부의 경우, 현재 이미 점유를 침탈하는 상태에서 피고가 불법 점유 사실을 완강히 부인하고 있다면 장래의 급부 부분에 대해서도 미리 청구할 필요성이 인정된다.

III. 구체적 양태

1. 기한부 및 조건부 채무에의 적용

(1) 기한부 채무의 적용

- 피고가 변제 약정에 따른 할부금의 지급 의무 자체를 완강하게 다투고 있는 상황이라면, 아직 이행기가 도래하지 않은 장래 할부금 채무에 대하여 소의 이익이 인정된다. 법원은 이를 인용하여 기한 도래 시 이행할 것을 명하여야 한다.

(2) 조건부 채무의 적용

- 정지조건부 채권의 경우 피고가 조건의 성취를 완강하게 저지하거나 권리의 존재를 다투는 상황이라면, 조건부 이행판결을 구할 소의 이익이 인정된다. 법원은 조건 성취를 기한으로 하는 이행 판결을 내려 채권자의 지위를 적법하게 보호할 수 있다.

2. 장래 기간 동안의 계속적 급부 청구에의 적용

(1) 토지 인도 및 장래 임료 상당의 배상

- 무단 점유자를 상대로 토지의 인도를 청구하면서 동시에 인도 완료일까지의 장래 임료 상당의 손해배상을 청구하는 것은 소송법상 대표적인 예이다. 이는 청구권의 선행적 기초가 존재하고 장래의 이행 거절이 확실히 예견되므로 전적으로 적법하다.

(2) 정기금 판결에 대한 변경의 소

- 정기금 급부를 명한 판결이 확정된 후, 액수 산정의 기초가 된 사정이 현저히 변경되어 부적당하게 된 경우 제기하는 변경의 소는 사정 변경에 따른 불이익을 방지하기 위한 장래 이행의 소의 성질을 가지며 전적으로 적법하게 인정된다.

IV. 결론

- 장래의 이행을 청구하는 소는 변론종결 이후에 발생할 채권의 신속한 집행력 확보를 보장하여 원고의 예방적 권리구제를 충실하게 실현해 주는 핵심적인 소송 제도이다. 다만, 법원은 피고에게 발생할 불필요한 소송상의 지위 불안을 억제하기 위하여 청구권의 기초관계가 실재하고 피고의 이행 거절이 확실한 경우로 그 범위를 엄격히 제한하고 있다. 결론적으로 장래의 이행의 소는 소송경제와 분쟁의 일회적 해결이라는 사법적 요청을 조화롭게 절충하는 장치이며, 법원은 이행 거절 의사를 엄격하게 심사하여 남소를 강력하게 억제하는 동시에 정당한 권리자의 장래 급부 확보라는 법적 편익을 실체적으로 충실하게 보장하고 있다.

《【문제2】 확인의 이익에 관하여 설명하십시오. (25점)》

<문제2> 확인의 이익의 의의, 일반 원칙, 요건, 구체적 양태

I. 확인의 이익의 의의

- 확인의 소는 원고의 법률적 지위의 불안을 제거하기 위하여 법원에 대하여 특정한 법률관계의 존부에 관한 판단을 구하는 소송이다. 확인의 소는 이행의 소나 형성의 소와 달리 대상에 제한이 없으므로, 소송제도의 남용을 방지하기 위해 확인의 이익이라는 특유의 소의 이익이 요구된다. 확인의 이익은 소송요건으로서 법원의 직권조사사항이며, 이를 결여한 소는 부적법 각하된다.

II. 확인의 이익의 일반 원칙

1. 대상의 적절성

- 확인의 소는 원칙적으로 권리 또는 법률관계의 현존하는 존부에 관하여만 허용된다. 단순한 사실관계, 과거의 법률관계, 미래에 발생할 법률관계에 대해서는 확인의 이익이 인정되지 않는 것이 원칙이다.

2. 방법의 유효·적절성

- 확인판결을 받는 것이 원고의 권리나 법률적 지위의 불안을 제거하는 데 가장 유효하고 적절한 수단이어야 한다. 만약 이행의 소를 제기할 수 있음에도 확인의 소를 제기하는 것은 원칙적으로 확인의 이익이 없다.

III. 확인 대상에 관한 요건

1. 법률관계의 확인

- 확인의 대상은 현재의 특정한 법률관계여야 한다. 따라서 단순한 사실관계(예 : 인영의 진정성립)는 확인의 대상이 될 수 없으나, 예외적으로 **민사소송법 제250조**에 따라 서면의 진정 여부를 확인하는 소는 허용된다.

2. 현재의 법률관계

- 현존하는 법률관계에 한정되므로, 과거의 법률관계는 원칙적으로 확인의 이익이 없다. 다만, 과거의 법률관계 확인이 현재의 법률상 분쟁을 해결하는 가장 유효한 수단인 경우(예 : 해고무효확인)에는 예외적으로 인정된다.

IV. 확인의 필요성에 관한 요건

1. 원고의 법률적 지위의 불안

- 원고의 권리 또는 법률상의 지위에 현존하는 불안·위험이 있어야 한다. 이는 피고가 원고의 권리를 부정하거나 원고의 지위와 양립할 수 없는 주장을 함으로써 발생한다.

2. 확인판결에 의한 불안 제거의 적절성

- 법원의 확인판결을 얻음으로써 원고가 처한 법률적 불안이 해소될 수 있어야 한다. 만약 확인판결을 받더라도 분쟁이 실질적으로 해결되지 않는다면 확인의 이익은 부정된다.

V. 확인의 이익의 구체적 양태

1. 이행의 소와의 관계

- 이행의 소를 제기할 수 있는 경우에는 직접 이행의 소를 제기하는 것이 분쟁의 종국적 해결 수단이 되므로 확인의 소는 부정된다. 이를 확인의 소의 보충성이라고 한다.

2. 국가를 상대로 하는 확인의 소

- 국가를 상대로 토지소유권 확인을 구하는 경우, 해당 토지가 미등기이거나 토지대장상 소유자 표시가 공란인 경우 등 특별한 사정이 있는 경우에만 확인의 이익이 인정된다.

VI. 결론

- 확인의 이익은 확인의 소가 남용되는 것을 막기 위한 문지기 역할을 한다. 따라서 확인 대상의 적절성, 현재성, 보충성 등을 종합적으로 고려하여 판결의 실효성이 인정될 때에만 본안 판단으로 나아가야 한다. 확인의 이익이 없는 소는 소송경제 측면에서 부적법 각하하는 것이 타당하다.

<제3편 제1심의 소송절차.제05장 소송 개시와 심리 대상.제04절 소송물>

[모의][5.04-1]구실체법설에 따른 전후소 소송물의 동일성 여부 및 후소의 적법성 판단

《【문제5.4】

<사례>

甲은 乙에게 자신의 소유인 X 토지를 매도하기로 하는 계약을 체결하고 소유권이전등기를 마쳐주었다. 그러나 이후 甲은 乙의 기망행위를 이유로 위 매매계약을 적법하게 취소하였다고 주장하며, 乙을 상대로 소유권이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. 이 소송에서 甲은 취소에 따른 원상회복으로서의 소유권 귀속에 기한 물권적 청구권을 원인으로 내세웠다.

심리 결과 甲의 청구는 기각되었고 판결은 확정되었다. 그 후 甲은 다시 乙을 상대로 동일한 X 토지에 대하여 소유권이전등기말소청구의 소를 제기하면서, 이번에는 매매계약이 처음부터 무효였다는 점을 근거로 무효인 계약에 따른 원상회복청구권을 주장하였다.

한편, 丙은 丁이 운전하던 차량에 치여 부상을 당하였다. 丙은 丁을 상대로 치료비 1,000만 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 이 소송의 변론 과정에서 丙은 丁의 과실에 의한 불법행위책임만을 주장하였으나, 법원은 丁이 운행공용자로서 자동차손해배상 보장법에 따른 책임을 질 수도 있다고 판단하였다.

(물음1) 甲이 제기한 후소의 소송물이 전소의 소송물과 동일한지 여부에 대하여 판례의 입장인 구실체법설(구이론)에 근거하여 논하고, 이에 따른 후소의 적법성 여부를 판단하시오.》

<문제5.4의 물음1> 구실체법설에 따른 전후소 소송물의 동일성 여부 및 후소의 적법성 판단

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 X 토지에 관한 매매계약의 취소를 원인으로 소유권이전등기말소를 청구하였다가 패소확정된 후, 다시 동일한 토지에 대하여 매매계약의 무효를 원인으로 소유권이전등기말소를 청구하는 후소를 제기한 상황이다. 쟁점으로 동일한 청구취지 아래 취소에 따른 원상회복청구권과 무효에 따른 원상회복청구권이 판례의 구실체법설상 동일한 소송물인지 및 이에 따라 후소가 기판력에 저촉되어 적법한지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 구실체법설에 따른 소송물의 동일성 및 후소의 적법성 여부를 판단한다.

II. 소송물 이론과 구실체법설

1. 소송물 이론의 의의

- 소송물 이론은 소송의 대상을 어떻게 획정할 것인가에 관한 논의로서, 이는 중복소제기 금지, 처분권주의의 범위, 청구의 변경, 기판력의 범위를 결정하는 기준이 된다.

2. 구실체법설(구이론)

(1) 내용

- 실체법상의 권리 또는 법률관계를 기준으로 소송물을 획정하는 견해다. 즉, 실체법상 권리마다 별개의 소송물이 성립한다고 본다.

(2) 판례의 입장

- 우리 대법원은 원칙적으로 구실체법설의 입장을 견지하고 있다. 따라서 실체법상 권리가 다르면 청구취지가 동일하더라도 소송물은 별개라는 것이 확립된 태도다.

III. 소송물의 동일성 여부 검토

1. 물권적 청구권과 소송물

(1) 소유권에 기한 방해배제청구권

- 판례는 소유권에 기한 말소등기청구소송에서 그 등기원인의 무효 사유가 다르더라도 소송물은 소유권에 기한 방해배제청구권으로서 하나라고 본다. 따라서 전소에서 주장하지 않은 무효 사유를 후소에서 주장하는 것은 소송물의 변경이 아니라 공격방어방법의 변경에 불과하다.

(2) 예외 : 청구권원 자체가 다른 경우

- 만약 전소는 계약상의 채권적 청구권이고 후소가 물권적 청구권이라면 이는 실체법상 권리가 다르므로 소송물이 별개로 취급된다.

2. 사안의 경우

(1) 전소의 소송물

- 甲은 취소에 따른 원상회복으로서 소유권귀속에 기한 물권적 청구권을 주장하였다. 이는 실체법상 소유권에 기한 방해배제청구권에 해당한다.

(2) 후소의 소송물

- 甲은 무효에 따른 원상회복을 주장하며 다시 말소등기를 청구하였다. 취소와 무효는 그 원인은 다르지만, 결국 실체법상으로는 동일한 소유권에 기한 방해배제청구권을 행사하는 것이다.

(3) 검토

- 판례의 태도에 의하면 등기원인의 무효 사유(취소 또는 무효)는 공격방어방법에 불과하므로, 전소와 후소의 소송물은 동일하다.

IV. 후소의 적법성 판단

1. 기판력의 의의 및 범위

(1) 의의

- 확정판결의 판단 내용이 후소의 법원을 구속하여 당사자가 이와 모순되는 주장을 할 수 없게 하는 효력이다.

(2) 시적 범위

- 기판력은 사실심 변론종결 시를 기준으로 발생한다. 당사자는 변론종결 전의 사유를 후소에서 다시 주장할 수 없다.

2. 기판력의 저촉 여부

- 사안의 전소 판결은 기각되어 확정되었다. 후소는 전소와 동일한 소송물(소유권에 기한 말소등기청구권)을 대상으로 하므로 전소 판결의 기판력이 미친다. 甲이 후소에서 주장하는 매매계약의 무효 사유는 전소의 변론종결 전에 이미 존재하던 사유이므로, 이를 뒤늦게 주장하는 것은 기판력의 차단효에 의해 허용되지 않는다.

V. 결론

- 구실체법설을 취하는 판례에 의할 때, 전소와 후소는 모두 소유권에 기한 물권적 청구권으로서 소송물이 동일하다. 따라서 후소는 전소의 확정판결의 기판력에 저촉된다. 법원은 기판력에 저촉되는 후소에 대하여 청구기각 판결을 내려야 한다는 것이 판례의 일반적인 태도다. 다만, 최근에는 소송 요건으로 보아

소를 부적법각하해야 한다는 견해도 있으나, 판례는 대체로 실체적 판결로서 기각하는 방식을 취한다. 결론적으로 甲의 후소는 전소의 효력에 반하여 허용될 수 없다.

<제3편 제1심의 소송절차.제05장 소송 개시와 심리 대상.제04절 소송물>

[모의][5.04-2]불법행위책임과 자배법상 책임의 소송물 관계 및 법원의 법적 근거 선택 권한

《【문제5.4】

<사례>

甲은 乙에게 자신의 소유인 X 토지를 매도하기로 하는 계약을 체결하고 소유권이전등기를 마쳐주었다. 그러나 이후 甲은 乙의 기망행위를 이유로 위 매매계약을 적법하게 취소하였다고 주장하며, 乙을 상대로 소유권이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. 이 소송에서 甲은 취소에 따른 원상회복으로서의 소유권 귀속에 기한 물권적 청구권을 원인으로 내세웠다.

심리 결과 甲의 청구는 기각되었고 판결은 확정되었다. 그 후 甲은 다시 乙을 상대로 동일한 X 토지에 대하여 소유권이전등기말소청구의 소를 제기하면서, 이번에는 매매계약이 처음부터 무효였다는 점을 근거로 무효인 계약에 따른 원상회복청구권을 주장하였다.

한편, 丙은 丁이 운전하던 차량에 치여 부상을 당하였다. 丙은 丁을 상대로 치료비 1,000만 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 이 소송의 변론 과정에서 丙은 丁의 과실에 의한 불법행위책임만을 주장하였으나, 법원은 丁이 운행공용자로서 자동차손해배상 보장법에 따른 책임을 질 수도 있다고 판단하였다.

(물음2) 丙이 제기한 소송에서 불법행위에 기한 손해배상청구권과 자동차손해배상 보장법에 기한 손해배상청구권의 관계를 소송물 이론의 관점에서 설명하고, 법원이 원고의 주장과 다른 법적 근거를 토대로 판결할 수 있는지 여부를 기술하시오.》

<문제5.4의 물음2> 불법행위책임과 자배법상 책임의 소송물 관계 및 법원의 법적 근거 선택 권한

I. 문제의 제기

- 사안에서 丙은 丁을 상대로 치료비 지급을 구하면서 불법행위책임만을 주장하였으나, 법원은 자동차손해배상 보장법(이하 '자배법')에 따른 책임도 인정하고 있는 상황이다. 쟁점으로 불법행위에 기한 손해배상청구권과 자배법에 기한 손해배상청구권의 소송물 관계 및 법원이 원고가 주장하지 않은 법적 근거를 적용하여 판결할 수 있는지 여부를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 양 청구권의 소송물 관계와 법원의 법적 평가 및 다른 법적 근거에 의한 판단 가능 여부를 기술한다.

II. 소송물 이론에 따른 두 청구권의 관계

1. 학설의 태도

(1) 구실체법설

- 실체법상 권리마다 별개의 소송물이 성립한다고 본다. 이 견해에 의하면 민법상 불법행위책임과 자배법상 책임은 근거 법령이 다르므로 별개의 소송물이다.

(2) 신소송물이론(신이론)

- 신이론 중 일원설은 신청의 목적(청구취지)과 원인 사실이 같으면 소송물은 하나라고 본다. 이 견해에 의하면 손해배상이라는 하나의 목적을 가지므로 소송물은 단일하다.

2. 판례의 입장

- 판례는 원칙적으로 구실체법설의 입장을 취하고 있다. 그러나 손해배상청구 사건에 있어서는 실체법상 권리가 수개이더라도 원고가 청구하는 손해의 범위가 동일하다면 이를 하나의 소송물로 파악하려는 경향도 일부 존재한다. 하지만 자배법과 민법상 불법행위의 관계에 있어서는 양자를 별개의 성립 요건을 가진 독립된 청구권으로 보면서도, 실질적으로는 청구의 경합 관계에 있다고 판단한다.

III. 법원의 법적 근거 선택 및 판결 가능성

1. 법적 고지의 원칙과 법률판단의 전권

(1) 의의

- 법원은 당사자가 주장하는 사실관계에 구속될 뿐, 그 사실에 적용할 법률의 해석과 적용은 법원의 고유한 권한에 속한다. 이를 법적 고지의 원칙이라 한다.

(2) 처분권주의와의 관계

- 당사자는 소송의 개시, 심판 대상의 범위, 소송의 종료에 대하여 결정권(처분권주의)을 갖지만, 일단 확정된 사실에 대해 어떤 법을 적용할지는 법원의 영역이다. 따라서 원고가 민법 제750조만을 주장하더라도 법원이 사실관계를 통해 자배법 제3조가 적용된다고 판단한다면 그에 따라 판결할 수 있다.

2. 판례의 구체적 태도

- 판례는 민법상 불법행위책임과 자배법상 책임이 모두 청구원인으로 주장된 경우뿐만 아니라, 원고가 어느 하나만을 주장하더라도 법원은 요건이 충족되는 다른 법적 근거를 토대로 판결할 수 있다고 본다. 즉, 원고가 불법행위책임만을 주장하였더라도 소송 자료를 통해 자배법상 책임의 요건이 인정된다면, 법원이 자배법을 적용하여 승소 판결을 내리는 것은 처분권주의 위반이 아니라고 판단한다.

IV. 사안의 적용

1. 丙이 제기한 소송의 소송물

- 사안에서 丙은 丁의 과실을 근거로 한 불법행위책임을 주장하고 있다. 구실체법설에 의하면 이는 민법상 권리다. 그러나 자배법상 책임 역시 동일한 교통사고라는 사실관계에서 비롯된 손해배상청구권이다. 판례에 따르면 이들은 실체법상 경합 관계에 있으나, 법원은 원고가 구하는 손해배상액이라는 범위 내에서 두 법적 근거를 모두 심리할 수 있다.

2. 법원의 판결 가능성

- 법원은 丁이 운행공용자로서 자배법상의 책임을 질 수 있다고 판단하였다. 丙이 명시적으로 자배법을 언급하지 않았더라도, 丙이 제출한 사실관계(사고의 경위, 丁의 운전 사실 등)가 자배법상 책임 요건을 갖추고 있다면 법원은 자배법을 근거로 丙의 청구를 인용할 수 있다. 이는 법원이 법률을 적용하는 전권 사항에 해당하므로 처분권주의에 반하지 않는다.

V. 결론

- 丙이 제기한 소송에서 불법행위책임과 자배법상 책임은 실체법상 권리의 발생 근거를 달리하는 경합 관계에 있다. 소송물 이론상 구실체법설에 의하면 별개의 권리이지만, 법원은 사실관계의 동일성 범위 내에서 적절한 법률을 선택하여 적용할 권한이 있다. 따라서 법원은 丙이 불법행위책임만을 주장하였더라도 자배법상 책임을 토대로 판결할 수 있으며, 이는 정당한 법률적 판단권의 행사로 보아야 한다. 다만, 법원은 이 과정에서 당사자가 예상하지 못한 법적 판단으로 불이익을 입지 않도록 적절히 지적의무(석명권 행사의 일종)를 다하여 당사자에게 의견 제출의 기회를 주는 것이 바람직하다.

<제3편 제1심의 소송절차.제05장 소송 개시와 심리 대상.제05절 소의 제기>

[모의][5.05-1]채무부존재확인 소의 중복소제기 금지 위반 여부 및 판결의 형식

《【문제5.5】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 5,000만 원의 지급을 구하는 소를 서울중앙지방법원에 제기하였다. 甲이 제출한 소장 부분은 2023. 5. 1. 乙에게 적법하게 송달되었다. 그런데 乙은 위 소송이 진행 중임에도 불구하고, 2023. 6. 1. 역으로 甲을 상대로 하여 동일한 대여금 채무가 존재하지 아니한다는 채무부존재확인 소를 수원지방법원에 제기하였다.

한편, A는 B를 상대로 건물철거 및 토지인도소송을 제기하여 승소 판결을 받았고 이 판결은 확정되었다. 그 후 B는 해당 토지의 점유를 계속하면서 건물을 제3자인 C에게 매도하고 소유권이전등기를 마쳐주었다. 이에 A는 다시 C를 상대로 건물철거를 구하는 소를 제기하고자 한다.

또한, 丙은 丁을 상대로 손해배상청구의 소를 제기하면서 소장에 청구금액을 1억 원으로 기재하였다. 소송 계속 중 丙은 동일한 사고로 인한 손해액이 사실은 2억 원임을 알게 되었고, 이미 제기한 소송의 청구취지를 확장하지 않은 채 나머지 1억 원에 대하여 별개의 소를 추가로 제기하였다.

(물음1) 乙이 甲을 상대로 제기한 채무부존재확인 소가 민사소송법 제259조의 중복소제기 금지 원칙에 위반되는지 여부를 판단하고, 만약 위반된다면 수원지방법원이 내려야 할 판결의 형식에 대하여 논하시오.》

<문제5.5의 물음1> 채무부존재확인 소의 중복소제기 금지 위반 여부 및 판결의 형식

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 乙을 상대로 대여금 지급청구의 소를 제기하여 소송이 계속 중임에도 乙이 동일한 대여금채무의 부존재확인 소를 별도로 제기한 상황이다. 쟁점으로 동일한 분쟁에 관한 후소가 민사소송법 제259조의 중복소제기 금지 원칙에 위반되는지 여부와 위반되는 경우 후소법원이 어떠한 형식의 재판을 하여야 하는지를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙이 제기한 채무부존재확인 소의 중복소제기 해당 여부 및 이에 따른 후소의 처리방안을 논한다.

II. 중복소제기 금지의 요건

1. 당사자의 동일성

- 전소와 후소의 당사자가 동일해야 한다. 이때 당사자가 원고와 피고로서의 지위를 서로 바꾸어 소를 제기하는 이른바 반대소송의 경우에도 당사자의 동일성이 인정된다.

2. 소송물의 동일성

- 전소와 후소의 심판 대상인 소송물이 동일해야 한다. 사안의 경우 전소는 5,000만 원의 대여금 지급청구권의 존재를 전제로 하는 이행의 소이고, 후소는 동일한 대여금 채무가 존재하지 않는다는 확인을 구하는 소이다. 양 소송은 동일한 권리관계의 존부에 관한 것이므로 소송물의 동일성이 인정된다.

3. 전소의 계속 중 후소의 제기

- 후소가 제기될 당시 전소가 법원에 계속되어 있어야 한다. 사안에서 甲의 소장은 2023. 5. 1. 송달되어 소송계속이 발생하였고, 乙의 소는 그 이후인 2023. 6. 1. 제기되었으므로 이 요건을 충족한다.

III. 중복소제기 해당 여부에 관한 판례의 태도

1. 이행의 소와 채무부존재확인 소의 관계

- 판례는 동일한 채권채무 관계에 대하여 채권자가 이행의 소를 제기한 후 채무자가 채무부존재확인 소를 제기하거나, 반대로 채무자가 확인의 소를 제기한 후 채권자가 이행의 소를 제기하는 경우 모두 중복소제기에 해당한다고 본다.

2. 사안의 경우

- 사안에서 甲이 제기한 대여금 청구소송은 전소로서 이미 소송계속이 발생하였다. 乙이 그 후에 동일한 채무를 대상으로 제기한 채무부존재확인 소는 전소의 소송물과 실질적으로 동일한 대상을 확인받으려는 것이므로, 민사소송법 제259조에 위반되는 중복소제기에 해당한다.

IV. 수원지방법원이 내려야 할 판결의 형식

1. 소송요건으로서의 성질

- 중복소제기 금지는 법원의 직권조사 사항이며 소송요건에 해당한다. 소송요건은 소송 전체의 적법 여부를 판단하는 전제 조건이다.

2. 판결의 형식 : 소각하판결

- 후소가 중복소제기에 해당하여 부적법한 경우, 법원은 본안에 대한 심리를 하지 않고 소를 물리치는 소각하판결을 내려야 한다. 사안의 수원지방법원은 乙이 제기한 후소가 중복소제기 금지 원칙에 위배되어 부적법하다는 이유로 판결로서 소를 각하하여야 한다.

3. 예외 : 전소의 취하 또는 각하

- 만약 후소의 변론종결 전에 전소가 취하되거나 각하되어 소송계속이 소멸한다면 후소의 중복소제기 흠결은 치유될 수 있다. 그러나 사안에서 전소가 정상적으로 진행 중이라면 후소는 각하를 면할 수 없다.

V. 결론

- 乙이 甲을 상대로 제기한 채무부존재확인 소는 이미 계속 중인 甲의 대여금 청구소송과 당사자 및 소송물이 동일하므로 민사소송법 제259조의 중복소제기 금지 원칙에 정면으로 위반된다. 따라서 후소의 수소법원인 수원지방법원은 乙의 소가 소송요건을 갖추지 못한 부적법한 소라고 판단하여 소각하판결을 내려야 한다. 이러한 중복소제기 금지 원칙은 판결의 모순·저촉을 방지하고 소송 경제를 도모하기 위한 필수적인 절차적 규범이다.

<제3편 제1심의 소송절차.제05장 소송 개시와 심리 대상.제05절 소의 제기>

[모의][5.05-2]일부청구임을 명시하지 않은 별소 제기의 중복소제기 해당 여부 및 효과

《【문제5.5】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 5,000만 원의 지급을 구하는 소를 서울중앙지방법원에 제기하였다. 甲이 제출한 소장 부분은 2023. 5. 1. 乙에게 적법하게 송달되었다. 그런데 乙은 위 소송이 진행 중임에도 불구하고, 2023. 6. 1. 역으로 甲을 상대로 하여 동일한 대여금 채무가 존재하지 아니한다는 채무부존재확인 소를 수원지방법원에 제기하였다.

한편, A는 B를 상대로 건물철거 및 토지인도소송을 제기하여 승소 판결을 받았고 이 판결은 확정되었다. 그 후 B는 해당 토지의 점유를 계속하면서 건물을 제3자인 C에게 매도하고 소유권이전등기를 마쳐주었다. 이에 A는 다시 C를 상대로 건물철거를 구하는 소를 제기하고자 한다.

또한, 丙은 丁을 상대로 손해배상청구의 소를 제기하면서 소장에 청구금액을 1억 원으로 기재하였다. 소송 계속 중 丙은 동일한 사고로 인한 손해액이 사실은 2억 원임을 알게 되었고, 이미 제기한 소송의 청구취지를 확장하지 않은 채 나머지 1억 원에 대하여 별개의 소를 추가로 제기하였다.

(물음2) 丙이 나머지 1억 원에 대하여 별소를 제기한 경우, 전소의 소장에서 청구 범위를 명확히 특정하지 않았을 때(일부청구임을 명시하지 않았을 때) 후소에 미치는 소송법적 효과 및 중복소제기 해당 여부를 판례의 태도에 근거하여 설명하시오.》

<문제5.5의 물음2> 일부청구임을 명시하지 않은 별소 제기의 중복소제기 해당 여부 및 효과

I. 문제의 제기

- 사안에서 丙은 손해배상금 1억 원을 청구하는 소를 제기한 후 일부청구임을 명시하지 않은 상태에서 동일한 사고로 인한 나머지 1억 원에 대하여 별소를 제기한 상황이다. 쟁점으로 일부청구임을 명시하지 않은 전소가 후소에 어떠한 소송법적 효과를 미치는지와 나머지 1억 원에 대한 후소가 중복소제기 금지 원칙에 위반되는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 일부청구임을 명시하지 않은 경우의 후소에 대한 소송법적 효과와 중복소제기 해당 여부를 설명한다.

II. 일부청구의 소송물과 명시 여부

1. 일부청구의 소송물에 관한 학설

(1) 일부설(판례)

- 일부청구임을 명시한 경우에는 그 일부만이 소송물이 되지만, 명시하지 않은 경우에는 채권 전액이 소송물이 된다는 견해다.

(2) 전부설

- 일부청구 여부와 상관없이 그 채권 전액이 소송물이 된다는 견해다.

2. 판례의 태도(일부청구 명시 필요성)

- 대법원은 가분채권의 일부만을 청구하는 경우, 소장에 그것이 채권의 일부임을 명시하여야 소송물이 그 일부로 제한된다고 본다. 만약 일부청구임을 명시하지 않았다면 채권의 전부가 소송물로 확정된다는 것이 확립된 판례의 입장이다.

III. 중복소제기 해당 여부 판단

1. 중복소제기 금지의 요건과 일부청구

(1) 전소에서 일부청구임을 명시한 경우

- 이 경우 전소의 소송물은 청구한 일부에 한정되므로, 나머지 부분에 대하여 별소를 제기하더라도 소송물이 달라 중복소제기에 해당하지 않는 것이 원칙이다.

(2) 전소에서 일부청구임을 명시하지 않은 경우

- 사안과 같이 일부청구임을 명시하지 않은 경우, 전소의 소송물은 채권 전액(2억 원)이 된다. 따라서 전소가 계속 중인 상태에서 나머지 부분(1억 원)에 대하여 다시 소를 제기하는 것은 동일한 소송물에 대하여 이중으로 소를 제기하는 것이 되어 중복소제기 금지 원칙에 위배된다.

2. 사안의 경우

- 丙은 전소에서 1억 원을 청구하면서 이것이 일부청구임을 명시하지 않았다. 판례에 따르면 전소의 소송물은 사고로 인한 손해배상청구권 전액이 된다. 따라서 丙이 후소로 제기한 나머지 1억 원 청구는 전소의 소송물 범위 내에 포함되는 것이며, 전소가 계속 중인 상태에서 제기되었으므로 민사소송법 제259조의 중복소제기에 해당하여 부적법하다.

IV. 후소에 미치는 소송법적 효과

1. 중복소제기 원칙 위반의 효과

- 후소의 수소법원은 丙의 후소가 중복소제기에 해당함을 이유로 소각하판결을 내려야 한다. 이는 소송 요건에 관한 흠결로서 본안 심리를 할 수 없는 사유에 해당한다.

2. 기판력의 범위와 차단효

(1) 전소 판결 확정 시의 영향

- 만약 전소에서 일부청구임을 명시하지 않은 채 판결이 확정된다면, 그 기판력은 채권 전액에 미치게 된다. 따라서 후소에서 나머지 금액을 청구하는 것은 전소의 확정판결과 모순되는 주장을 하는 것이 되어 허용되지 않는다.

(2) 잔액 청구의 봉쇄

- 원고가 일부청구임을 명시하지 않아 전소에서 채권 전액이 소송물로 확정되었음에도 불구하고 일부만 인용되었다면, 명시적 일부청구가 아니었으므로 나머지 잔액에 대해서는 기판력에 의해 더 이상 다룰 수 없게 된다.

3. 구제 수단 : 청구취지의 확장

- 丙은 별소를 제기할 것이 아니라, 현재 계속 중인 전소 절차 내에서 민사소송법 제262조에 따른 청구취지 확장을 통해 손해액을 2억 원으로 증액하여야 한다. 이는 소의 변경 중 추가적 변경에 해당하며, 소송의 지연이 없는 한 허용된다.

V. 결론

- 丙이 전소에서 일부청구임을 명시하지 않은 채 나머지 금액에 대하여 별소를 제기한 것은 전소와 후소의 소송물이 동일한 경우에 해당한다. 따라서 후소는 민사소송법 제259조의 중복소제기 금지 원칙에 위반되어 부적법하며 소각하판결의 대상이 된다. 판례는 가분채권의 소송물 범위를 원고의 명시 여부에 따라 결정함으로써 법률관계의 명확성과 피고의 응소 부담 경감을 도모하고 있다. 결과적으로 丙은 후소를 취하하고 전소에서 청구취지를 확장하는 방식을 취하여야 적법하게 권리구제를 받을 수 있다.

《【문제5.6】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 반환을 구하는 소를 제기하고자 서울중앙지방법원에 소장을 제출하였다. 그런데 甲은 소장에 乙의 주소를 기재하면서 "서울 강남구 이하 불상"이라고만 기재하였고, 청구원인에는 "乙이 돈을 빌려가서 안 갚음"이라고만 간략히 적어 제출하였다. 담당 재판장 A는 소장을 심사한 후 甲에게 7일 이내에 피고의 구체적인 주소를 보정하고 청구원인을 구체적으로 특정할 것을 명하는 보정명령을 내렸다.

위 보정명령은 2023. 10. 1. 甲에게 적법하게 송달되었으나, 甲은 2023. 10. 15.이 되어서야 보정서를 제출하였다. 한편, 재판장 A는 甲이 기한 내에 보정하지 않자 2023. 10. 10. 소장각하명령을 작성하였으나, 이 명령이 甲에게 송달되기 전인 10. 15.에 甲의 보정서가 법원에 도착하였다.

또 다른 사례로, 丙은 丁을 상대로 소를 제기하여 소장 부분이 丁에게 송달되었다. 그러나 丁은 주소지에 거주하지 않아 송달불능이 되었고, 재판장은 丙에게 주소보정을 명하였다. 丙은 丁의 소재를 알 수 없자 공시송달을 신청하였으나, 재판장은 요건 미비를 이유로 이를 받아들이지 않고 다시 주소보정을 명하며 이를 이행하지 않을 경우 소장을 각하하겠다고 통지하였다.

(물음1) 재판장 A가 내린 소장각하명령의 성질과 관련하여, 甲이 보정기한을 도과하였으나 각하명령이 송달되기 전에 흠결을 보정하였다면 재판장이 이미 작성한 소장각하명령을 그대로 집행할 수 있는지 여부를 판례의 태도에 근거하여 논하시오.》

<문제5.6의 물음1> 보정기한 도과 후 각하명령 송달 전 흠결 보정 시 소장각하명령의 효력

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 보정명령에서 정한 기간을 경과하여 소장의 흠결을 보정하였으나, 그 보정서가 재판장이 작성한 소장각하명령이 송달되기 전에 법원에 제출된 상황이다. 쟁점으로 소장각하명령의 법적 성질과 보정기간을 도과한 흠결보정이 각하명령 송달 전에 이루어진 경우 재판장이 이미 작성한 소장각하명령을 그대로 송달·집행할 수 있는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소장각하명령의 성질과 각하명령 송달 전 흠결보정이 이루어진 경우 소장각하명령의 효력을 논한다.

II. 재판장의 소장심사권과 보정명령

1. 소장심사권의 의의

- 재판장은 소장이 제출되면 소장의 방식 적합 여부를 심사한다. 이는 소송절차의 경제와 피고의 부당한 응소 부담을 방지하기 위한 제도다.

2. 보정명령 및 소장각하명령

(1) 보정명령

- 소장에 필요적 기재사항(당사자, 법정대리인, 청구취지, 청구원인)이 누락되었거나 규정에 따른 인지를 붙이지 않은 경우, 재판장은 상당한 기간을 정하여 보정을 명한다.

(2) 소장각하명령

- 원고가 보정기한 내에 흠결을 보정하지 아니한 때에는 재판장은 명령으로 소장을 각하하여야 한다. 이는 판결이 아닌 명령의 형식으로 이루어지는 재판이다.

III. 소장각하명령의 성질 및 효력 발생 시기

1. 명령의 성질

- 소장각하명령은 재판장이 소송지휘권의 일환으로 행하는 재판이다. 이는 법원의 판단이 대외적으로 표시됨으로써 효력을 발생하게 된다.

2. 효력 발생 시기(송달 시)

- 판결이 선고에 의해 효력이 발생하는 것과 달리, 결정이나 명령은 당사자에게 송달됨으로써 그 효력이 발생한다. 따라서 소장각하명령이 작성되었다 하더라도 원고에게 송달되기 전까지는 대외적으로 완전한 효력을 가졌다고 보기 어렵다.

IV. 보정기한 도과 후 송달 전 보정의 효력

1. 학설의 태도

(1) 긍정설

- 보정기한은 불변기간이 아니므로, 각하명령이 송달되어 효력이 발생하기 전까지 보정이 이루어졌다면 소 제기는 적법해진다는 견해다.

(2) 부정설

- 일단 보정기한이 도과하면 재판장의 각하 의무가 발생하므로, 사후적인 보정으로 이미 발생한 각하 사유를 치유할 수 없다는 견해다.

2. 판례의 태도

- 판례는 소장각하명령이 내리진 경우라도 그 명령이 원고에게 송달되기 전에 원고가 재판장의 보정명령 취지에 따라 흠결을 보정하였다면, 재판장은 그 소장각하명령을 송달할 수 없고 소송절차를 진행하여야 한다는 입장이다. 즉, 보정기한을 도과했더라도 각하명령의 효력 발생 전에 보정이 이루어지면 흠결은 치유된 것으로 본다.

V. 사안의 적용

1. 보정의 유효성 판단

- 사안에서 甲은 보정기한인 2023. 10. 8.을 도과하여 10. 15.에 보정서를 제출하였다. 그러나 재판장 A가 작성한 소장각하명령은 아직 甲에게 송달되지 않은 상태였다. 판례의 취지에 따르면 소장각하명령의 효력이 발생하기 전에 흠결이 실질적으로 보정되었으므로, 재판장은 이미 작성된 각하명령을 집행(송달)할 수 없다.

2. 재판장이 취해야 할 조치

- 재판장 A는 甲의 보정서가 제출된 이상, 기존에 작성했던 소장각하명령을 파기하거나 집행하지 않아야 한다. 소장의 흠결이 보정된 것으로 간주하여 소장 부분을 피고 乙에게 송달하고 변론기일을 지정하는 등 정상적인 소송절차를 개시하여야 한다.

VI. 결론

- 재판장의 소장각하명령은 원고에게 송달됨으로써 효력이 발생한다. 따라서 보정기한이 지났더라도 각하명령이 송달되기 전에 원고가 흠결을 보정하였다면 소장의 적법성은 회복된다. 사안의 甲은 비록 기한은 어겼으나 명령 송달 전 보정을 완료하였으므로 재판장은 소장각하명령을 그대로 집행할 수 없으며, 소송을 계속 진행하여야 한다. 이는 원고의 재판청구권을 과도하게 제약하지 않으면서도 실질적인 보정을 유도하고자 하는 판례의 타당한 해석이다.

《【문제5.6】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 반환을 구하는 소를 제기하고자 서울중앙지방법원에 소장을 제출하였다. 그런데 甲은 소장에 乙의 주소를 기재하면서 "서울 강남구 이하 불상"이라고만 기재하였고, 청구원인에는 "乙이 돈을 빌려가서 안 갚음"이라고만 간략히 적어 제출하였다. 담당 재판장 A는 소장을 심사한 후 甲에게 7일 이내에 피고의 구체적인 주소를 보정하고 청구원인을 구체적으로 특정할 것을 명하는 보정명령을 내렸다.

위 보정명령은 2023. 10. 1. 甲에게 적법하게 송달되었으나, 甲은 2023. 10. 15.이 되어서야 보정서를 제출하였다. 한편, 재판장 A는 甲이 기한 내에 보정하지 않자 2023. 10. 10. 소장각하명령을 작성하였으나, 이 명령이 甲에게 송달되기 전인 10. 15.에 甲의 보정서가 법원에 도착하였다.

또 다른 사례로, 丙은 丁을 상대로 소를 제기하여 소장 부분이 丁에게 송달되었다. 그러나 丁은 주소지에 거주하지 않아 송달불능이 되었고, 재판장은 丙에게 주소보정을 명하였다. 丙은 丁의 소재를 알 수 없어 공시송달을 신청하였으나, 재판장은 요건 미비를 이유로 이를 받아들이지 않고 다시 주소보정을 명하며 이를 이행하지 않을 경우 소장을 각하하겠다고 통지하였다.

(물음2) 피고 丁에 대한 소장 부분의 송달이 불가능하여 재판장이 주소보정을 명하였음에도 丙이 이에 응하지 않거나 공시송달 요건을 갖추지 못한 경우, 재판장이 행할 수 있는 조치인 "소장각하명령"과 "소각하판결"의 차이점을 소송 계속의 발생 여부와 관련하여 설명하시오.》

<문제5.6의 물음2> 소장 부분 송달불능 시 재판장의 조치인 소장각하명령과 소각하판결의 차이점

I. 문제의 제기

- 사안에서 피고에 대한 소장 부분의 송달이 불가능한 상태에서 재판장이 주소보정을 명하였으나 원고가 이에 응하지 않거나 공시송달 요건도 갖추지 못한 상황이다. 쟁점으로 소장 부분 송달 전후에 따른 소송 계속의 발생 여부를 기준으로 재판장의 소장각하명령과 법원의 소각하판결이 어떠한 차이가 있는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 피고에 대한 송달불능 상태에서 주소보정이 이루어지지 않은 경우 소장각하명령과 소각하판결의 차이점을 소송 계속의 발생 여부를 중심으로 설명한다.

II. 소장 부분의 송달과 소송계속의 발생

1. 소장 부분 송달의 의의

- 소장이 접수되면 법원은 이를 심사한 후 지체 없이 피고에게 소장 부분을 송달하여야 한다. 이는 피고에게 방어의 기회를 제공하고 심판의 대상을 알리는 중요한 절차다.

2. 소송계속의 발생 시기

- **민사소송법상** 소송계속은 소장 부분이 피고에게 적법하게 송달된 때에 발생한다. 소송계속이 발생하면 중복소제기 금지, 시효중단 등의 소송법적 효과가 발생하며, 이때부터 사건은 법원의 심판 대상으로서 완전히 정착된다.

III. 소장각하명령 [민사소송법 제254조]

1. 발생 단계 및 사유

- 소장 부분이 피고에게 송달되기 전, 즉 소송계속이 발생하기 전 단계에서 행해지는 조치다. 주소불명 등으로 인하여 소장 부분을 송달할 수 없는 경우 재판장은 주소보정을 명하고, 이에 응하지 않으면 명령으로 소장을 각하한다.

2. 성질 및 불복 방법

(1) 성질

- 재판장 개인의 권한으로 행하는 소송지휘적 처분이다. 소송계속 전이므로 변론을 거치지 않고 서면심사만으로 결정한다.

(2) 불복 방법

- 소장각하명령에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다.

IV. 소각하판결 [민사소송법 제219조 등]

1. 발생 단계 및 사유

- 소장 부분이 피고에게 이미 송달되어 소송계속이 발생한 후의 단계에서 행해지는 조치다. 일단 송달은 되었으나 이후 소송요건의 흠결이 발견되거나, 공시송달 요건 미비 등으로 더 이상 절차 진행이 불가능하여 소송 자체가 부적법하다고 판단될 때 법원의 이름으로 내리는 재판이다.

2. 성질 및 불복 방법

(1) 성질

- 수소법원(합의부 또는 단독판사)이 내리는 종국판결이다. 원칙적으로 변론을 거쳐야 하나, 소송요건 흠결이 명백한 경우 변론 없이 판결할 수도 있다.

(2) 불복 방법

- 판결이므로 항소로써 불복하여야 한다.

V. 두 조치의 주요 차이점 비교

1. 주체와 형식의 차이

- 소장각하명령은 재판장 개인이 내리는 명령인 반면, 소각하판결은 당해 사건의 수소법원이 내리는 판결이다.

2. 소송계속 발생 여부에 따른 구별

(1) 소장각하명령

- 소장 부분이 송달되지 않아 소송계속이 발생하기 전의 조치다. 따라서 시효중단이나 제척기간 준수의 효력은 소급하여 소멸하게 된다.

(2) 소각하판결

- 이미 소장 부분이 송달되어 소송계속이 발생한 상태에서 내리는 재판이다. 즉, 법원이 사건을 수리하여 심리에 들어갔으나 형식적 요건 미비로 본안 심리를 거절하는 것이다.

3. 사안의 경우

- 丙이 丁의 주소를 보정하지 못해 소장 부분 자체가 송달되지 못한 단계라면 재판장은 소장각하명령을 내린다. 그러나 일단 송달은 되었으나 그 주소가 허위임이 판명되거나 공시송달 요건을 갖추지 못해 향후 절차 진행이 불가능한 사유가 소송계속 발생 후에 확인되었다면 소각하판결의 대상이 된다.

VI. 결론

- 소장각하명령과 소각하판결은 모두 소송의 흠결을 이유로 절차를 종료시키는 재판이라는 공통점이 있으나, 그 시점과 주체에서 명확히 구분된다. 소장각하명령은 소송계속 전 재판장의 권한으로 행하는 명령이며, 소각하판결은 소송계속 후 수소법원이 내리는 종국판결이다. 丙의 사례와 같이 주소보정 불이행 및 송달불능의 상황은 대개 소송계속 전 단계에 해당하므로 소장각하명령이 원칙적인 조치가 될 것이나, 구체적인 송달 여부에 따라 그 형식이 달라질 수 있다. 이를 정확히 구분하는 것은 원고의 불복 방법과 시효중단 등 실체법적 효과를 판단하는 데 있어 필수적이다.

<제3편 제1심의 소송절차.제05장 소송 개시와 심리 대상.제07절 소제기의 효과>

[기출][2014-3]중복된 소제기 금지의 의의, 요건, 형태, 법원의 조치 및 간과 판결의 효력

《【문제3】중복된 소제기의 금지에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 중복된 소제기 금지의 의의, 요건, 형태, 법원의 조치 및 간과 판결의 효력

I. 중복된 소제기 금지의 의의

- 민사소송법 제259조는 법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다고 규정하고 있다. 이는 판결의 모순·저촉을 방지하고, 피고의 응소 번거로움을 피하며, 소송경제를 도모하기 위한 취지이다. 중복소송에 해당하기 위해서는 전소와 후소의 당사자 및 소송물이 동일해야 하며 전소가 법원에 계속 중이어야 한다.

II. 중복된 소제기 금지의 요건

1. 전소의 계속

- 중복소송이 성립하기 위해서는 후소가 제기될 당시 전소가 법원에 계속되어 있어야 한다. 소송계속은 소장이 피고에게 송달된 때 발생하며, 전소가 상소심에 계류 중이거나 판결이 확정되기 전까지의 상태를 포함한다.

2. 당사자의 동일성

(1) 원칙

- 전소와 후소의 당사자가 동일해야 한다. 원고와 피고의 지위가 바뀌어 있는 경우(채무부존재확인 소)에도 당사자가 동일하다면 중복소송의 요건을 충족한다.

(2) 예외

- 민사소송법 제218조에 의해 기판력이 미치는 범위에 있는 자. 즉, 채권자대위소송에서의 채무자나 선정당사자 소송에서의 선정자 등 실질적 당사자가 동일한 경우에도 당사자 동일성이 인정된다.

3. 소송물의 동일성

(1) 판단 기준

- 구실채법설에 따르면 실체법상의 권리를 기준으로, 신소송물론에 따르면 신청과 사실관계(청구취지와 청구원인)를 기준으로 소송물의 동일성을 판단한다. 판례는 원칙적으로 전소와 후소의 청구원인이 동일하고 청구취지가 같은 경우뿐만 아니라, 청구취지가 반대되거나 모순되는 관계에 있는 경우에도 소송물의 동일성을 인정한다.

(2) 공격방어방법과의 구별

- 상계의 항변은 소송물이 아닌 공격방어방법에 해당하므로, 전소에서 상계의 항변을 제출하고 후소로 그 상계하고자 하는 채권을 청구하는 것이 중복소송에 해당하는지에 대해서는 별도의 검토가 필요하다.

III. 중복소송의 특수한 형태

1. 채권자대위소송과 중복소송

(1) 채권자가 제기한 후 채무자가 제기한 경우

- 채무자가 대위소송이 제기된 사실을 안 때에는 대위소송의 판결의 효력이 채무자에게 미치므로, 채무자가 별도로 제기한 소는 중복소송에 해당한다.

(2) 채무자가 제기한 후 채권자가 제기한 경우

- 채무자가 이미 소를 제기하여 계속 중인 경우, 채권자가 동일한 권리를 대상으로 대위소송을 제기하는 것은 중복소송에 해당하여 부적법하다.

2. 상계의 항변과 중복소송

- 판례는 소송물 동일성 요건과 관련하여, 전소에서 자동채권으로 상계의 항변을 제출한 상태에서 후소를 제기하는 것은 중복소송 금지 규정에 직접 저촉되지 않는다고 본다. 상계의 항변은 소송 계속을 발생시키지 않기 때문이다. 다만, 판결의 모순 저촉 방지를 위하여 후소의 정지 등을 통해 조절한다.

IV. 중복소송의 법원 조치 및 간과 판결의 효력

1. 법원의 조치

- 중복된 소제기는 소송요건 중 하나인 소의 이익이 없는 부적법한 소에 해당한다. 법원은 이를 직권조사사항으로 취급하여야 하며, 요건을 갖추지 못한 후소에 대하여 판결로써 소를 각하하여야 한다.

2. 간과한 판결의 효력

(1) 확정 전

- 중복소송 금지를 간과하고 판결이 선고된 경우, 상소(항소나 상고)를 통해 판결의 취소를 구할 수 있다.

(2) 확정 후

- 판결이 확정된 경우에는 비록 중복소송 금지에 위반된 판결이라 하더라도 재심사유가 되지 않으며, 기판력이 발생한다. 만약 전소와 후소가 모두 확정되어 서로 모순되는 경우에는 후순위 판결이 우선한다는 견해와 전순위 판결이 우선한다는 견해가 대립하나, 실무적으로는 전소 판결의 기판력에 의해 후소 판결의 효력이 제한될 수 있다.

V. 결론

- 중복된 소제기 금지의 원칙은 사법 자원의 낭비를 방지하고 법적 안정성을 도모하는 핵심적인 제도이다. 법원은 후소 제기 시 전소와의 당사자 및 소송물 동일성을 엄격히 심사하여 판결의 저촉을 예방해야 한다. 특히, 현대 소송에서 빈번한 대위소송이나 단체소송 등에서 실질적 당사자 개념을 확장 적용하여 중복소송의 범위를 합리적으로 확정하는 것이 중요하다.

<제3편 제1심의 소송절차.제05장 소송 개시와 심리 대상.제07절 소제기의 효과>

[기출][2023-1-1]상계의 항변과 중복소송의 관계 및 전소와 후소의 선후에 따른 대여금채권 소구의 적법성

《【문제1】 甲은 乙을 피고로 매매대금채권 5천만 원의 지급을 구하는 소(이하, 'A소'라 한다)를 제기하였다. 이 소송에서 乙은 甲에 대하여 갖고 있는 대여금채권 6천만 원(이하, '이 사건 대여금채권'이라 한다)을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장하였다. 다음 물음에 답하시오. (다만, 아래의 각 물음은 독립적임) (50점)

(물음1)

- ❶ 상계의 항변을 주장한 乙은 A소 계속 중 이 사건 대여금채권을 소구채권으로 하여 甲을 피고로 하는 대여금반환을 구하는 소(이하, 'B소'라 한다)를 제기하였다. 乙이 제기한 B소는 적법한가?
- ❷ 만일 甲이 제기한 A소 계속 전에 乙이 이 사건 대여금채권의 반환을 구하는 소('C소'라 한다)를 제기하였다면, 乙은 그 후 제기된 甲의 A소에서 이 사건 대여금채권을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장할 수 있는가? (20점)》

<문제1의 물음1> 상계의 항변과 중복소송의 관계 및 전소와 후소의 선후에 따른 대여금채권 소구의 적법성

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 제기한 매매대금청구소송(A소)에서 乙이 자신의 대여금채권을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장한 상태에서 동일한 대여금채권으로 별소(B소)를 제기하거나, 반대로 대여금반환청구소송(C소)이 먼저 계속 중인 상태에서 후소인 A소에서 상계의 항변을 주장한 상황이다. 쟁점으로 상계항변과 별소 제기가 민사소송법상 중복소제기금지에 저촉되는지, 선행소송 계속 중 후소에서 동일 채권을 자동채권으로 한 상계항변이 허용되는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 B소의 적법성 및 C소 계속 중 A소에서 상계항변의 허용 여부를 답한다.

II. 상계의 항변과 중복소송에 관한 법리

1. 중복소송의 금지 [민사소송법 제259조]

(1) 의의 및 요건

- 법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다. 이는 판결의 모순·저촉을 방지하고 피고의 이중 응소 부담 및 법원의 소송 경제적 낭비를 막기 위함이다. 중복소송이 성립하기 위해서는 당사자의 동일성, 소송물의 동일성, 전소의 계속이라는 요건을 충족하여야 한다.

(2) 소송물 동일성의 판단

- 소송물은 청구취지와 청구원인에 의해 확정되는 소송의 대상을 의미한다. 소송물이 완전히 일치하는 경우뿐만 아니라, 전소와 후소의 청구가 서로 반대 관계에 있거나 모순·저촉되는 관계에 있는 경우에도 소송물의 동일성이 인정된다.

2. 상계의 항변 주장 후 별소 제기 (물음1-❶ 관련 법리)

(1) 학설의 대립

① 중복소송설 (긍정설)

- 상계의 항변이 판단되는 경우 민사소송법 제216조 제2항에 따라 기판력이 발생하므로, 별도의 소를 제기하는 것은 중복소송 금지에 위배되어 부적법하다고 보는 견해이다.

② 별소허용설 (부정설)

- 상계의 항변은 소송물이 아닌 방어방법에 불과하므로 전소의 계속 중에 동일한 채권으로 별소를 제기하더라도 소송물의 동일성이 없어 중복소송에 해당하지 않는다고 보는 견해이다.

(2) 판례의 태도

- 대법원은 상계의 항변은 법원의 판단을 요하는 방어방법에 지나지 않아 소송물 자체가 될 수 없으므로, 전소에서 상계의 항변을 제출하였다 하더라도 그 후 동일한 대여금채권으로 제기한 후소(별소)는 중복소송에 해당하지 않아 적법하다고 판시하였다.

3. 별소 제기 후 상계의 항변 주장 (물음1-❷ 관련 법리)

(1) 학설의 대립

① 상계항변 허용설

- 소의 제기와 상계의 항변은 성격이 다르며 당사자의 방어권을 보장하기 위해 선행 소송이 있더라도 후행 소송에서의 상계의 항변은 허용되어야 한다는 견해이다.

② 상계항변 불허설

- 전소에서 이미 소송물로 삼은 채권을 후소에서 다시 상계의 항변으로 삼는 것은 사실상 동일한 채권에 대하여 이중의 사법적 판단을 구하는 것이며, 모순·저촉의 위험을 초래하므로 허용되지 않는다는 견해이다.

(2) 판례의 태도

- 대법원은 이미 대여금반환 청구의 전소(C소)를 제기한 자가 후소(A소)에서 동일한 채권을 자동채권으로 삼아 상계의 항변을 주장하는 것은, 전소와 후소에서 이중으로 판단이 내려짐으로써 판결의 모순·저촉을 초래할 우려가 있고 판결의 기판력 범위(제216조 제2항)와 저촉될 수 있으므로 허용되지 않는다고 판시하였다.

III. 사안의 적용

1. 물음1-❶의 적용

- 사안에서 전소인 A소의 소송물은 甲의 매매대금채권이고, 乙의 대여금채권은 상계의 항변이라는 단순한 방어방법으로 제출되었다. 따라서 乙이 동일한 대여금채권을 소송물로 하여 제기한 후소인 B소는 전소인 A소와 소송물이 동일하지 않다. 대법원 판례의 태도에 따를 때 상계의 항변은 중복소송금지 조항의 적용을 받지 않으므로, 乙이 제기한 B소는 적법하다.

2. 물음1-❷의 적용

- 乙은 이 사건 대여금채권의 지급을 구하는 전소인 C소를 제기하여 소송계속을 발생시켰다. 이 상황에서 乙이 후소인 A소에서 동일한 대여금채권을 자동채권으로 삼아 상계의 항변을 제기하는 것은 이미 소송물로 법원에 계속되어 있는 대여금채권에 대하여 이중으로 법원의 판단을 구하는 것이다. 이는 중복소송금지 원칙의 취지(유추적용) 및 기판력의 모순·저촉 방지 원칙에 위배되므로 乙은 상계의 항변을 제기할 수 없으며, 법원은 이를 배척하여야 한다.

IV. 결론

1. 물음1-❶의 결론

- 乙이 A소 계속 중 이 사건 대여금채권을 소구채권으로 하여 제기한 B소는 소송물의 동일성이 없어 중복소송에 해당하지 않으므로 전적으로 적법하다.

2. 물음1-②의 결론

- 乙이 이미 C소를 제기한 후 제기된 A소에서 이 사건 대여금채권을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장하는 것은 판결의 모순·저촉을 유발하는 무효한 주장이므로 이를 주장할 수 없다.

<제3편 제1심의 소송절차.제05장 소송 개시와 심리 대상.제08절 채권자대위소송에 대한 주요논점>

[기출][2012-1]채권자대위소송의 판결이 확정된 경우 그 기판력이 채무자에게 미치는지 여부

《【문제1】 A는 甲에 대하여 1년치 임금을 체불하고 있었다. A는 자신의 명의로 되어 있는 재산이 거의 없고 다만 乙에 대하여 매매대금 채권을 가지고 있을 뿐 이었는데, 이 채권의 변제기가 도래하였는데도 그 지급을 청구하지 않았다. 이에 甲은 A가 乙에 대하여 갖고 있는 위 채권을 대위행사하여 乙을 피고로 하는 소를 제기하였다. 그러나 甲의 청구를 기각하는 판결이 선고되었다. 승소 가능성이 적다고 판단한 甲은 항소를 제기하지 않았고, 결국 판결이 확정되었다. 이 판결의 기판력이 A에게도 미치는지 논하시오. (50점)》

<문제1> 채권자대위소송의 판결이 확정된 경우 그 기판력이 채무자에게 미치는지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 체불임금채권을 보전하기 위하여 채무자 A를 대위하여 제3채무자 乙을 상대로 채권자대위소송을 제기하였으나 청구기각판결이 확정된 상황이다. 쟁점으로 채권자대위소송에서 선고·확정된 청구기각판결의 기판력이 당사자가 아닌 채무자 A에게도 미치는지 여부와 그 법적 근거를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 채권자대위소송 확정판결의 기판력이 채무자 A에게 미치는지 여부를 중심으로 기판력의 주관적 범위를 논한다.

II. 채권자대위소송 판결의 기판력 확장

1. 문제의 소재

- 민사소송법 제218조 제1항에 따라 기판력은 원칙적으로 당사자 사이에서만 발생한다. 그러나 동조 제3항은 제3자의 소송담당의 경우 실질적 이해관계인에게도 판결의 효력을 확장하고 있다. 채권자대위소송에서 채무자가 소송 계속 사실을 알았을 때에만 기판력을 인정할 것인지, 아니면 알았는지 여부와 관계없이 항상 인정할 것인지가 논란이 된다.

2. 학설의 태도

(1) 절차보장설(악의 시)

- 채무자가 대위소송의 제기 사실을 알았을 때에만 채무자의 절차적 권리가 보장되었다고 보아 기판력이 미친다는 견해이다. 채무자가 소송 사실을 모르는 상태에서 판결의 효력을 강요하는 것은 헌법상 재판받을 권리를 침해한다는 논거를 가진다.

(2) 법정소송담당설(선악 무관)

- 채권자대위권의 성질을 법정소송담당으로 보아, 민사소송법 제218조 제3항에 의거하여 채무자의 인지 여부와 관계없이 항상 기판력이 미친다는 견해이다. 이는 판결의 모순·저촉을 방지하고 법률관계의 안정을 기하기 위함이다.

3. 판례의 태도

- 대법원은 과거 채무자가 소송 제기 사실을 알았을 때에 한하여 기판력이 미친다고 판시하여 절차보장설의 입장을 취하였다. 그러나 이후 전원합의체 판결을 통해 입장을 정리하였다. 판례에 의하면 채권자대위소송의 판결이 확정된 경우, 채무자가 소송 계속 사실을 알았을 때에 한하여 그 판결의 효력이 채무자에게 미친다. 이때 알았을 때란 채권자에 의한 소송고지뿐만 아니라, 채무자가 어떠한 경로로든 소송 계속 사실을 알게 된 경우를 모두 포함한다.

III. 기판력 확장의 요건과 범위

1. 채무자의 소송 계속 인지

(1) 인지의 의미

- 채무자가 자신의 권리가 대위행사되고 있다는 사실을 인지함으로써 스스로 소송에 참가하거나 권리를 행사할 기회를 가졌다면, 그 결과에 대해 책임을 지우는 것이 타당하다는 취지이다.

(2) 통지의 유무

- 채권자대위소송을 제기한 채권자는 민법 제405조 제1항에 따라 채무자에게 소송 제기 사실을 통지해야 한다. 이러한 법정 통지가 이루어졌거나 채무자가 다른 방법으로 알게 되었다면 기판력 확장의 요건을 충족한다.

2. 기판력의 범위와 한계

(1) 승소판결과 패소판결

- 채권자가 승소한 경우뿐만 아니라, 사안과 같이 청구가 기각된 패소판결의 경우에도 채무자가 소송 사실을 알았다면 기판력이 미친다. 따라서 채무자는 나중에 동일한 청구권으로 제3채무자에게 소를 제기할 수 없게 된다.

(2) 기판력의 주관적 범위

- 민사소송법 제218조 제3항의 취지에 따라 소송담당자인 채권자가 받은 판결은 피담당자인 채무자에게 미친다. 이는 채무자의 권리가 확정적으로 부정되었음을 의미하며, 채무자가 후에 별소를 제기하면 기판력에 저촉되어 청구기각 판결을 받게 된다.

IV. 사안의 적용

1. 채무자 A의 소송 계속 인지 여부

- 사안에서 채권자 甲이 乙을 상대로 대위소송을 제기했을 때, 채무자 A가 이 사실을 알았는지에 대한 명시적인 언급은 없다. 그러나 통상적인 대위소송의 절차와 민법상 통지 의무를 고려할 때, A가 소송 사실을 알았다고 전제한다면 판례의 법리에 따라 기판력이 미치게 된다. 만약 A가 소송 사실을 전혀 몰랐다면 판례에 의할 때 기판력은 미치지 않는다.

2. 판결의 효력 및 후소예의 영향

(1) 기판력의 발생

- A가 소송 사실을 알았다고 가정할 경우, 甲의 청구를 기각한 확정판결의 효력은 A에게 확장된다. 이는 A의 乙에 대한 매매대금 채권이 존재하지 않거나 행사할 수 없는 상태임을 확정하는 효과를 가진다.

(2) 후소 제기의 금지

- 판결의 확정으로 인해 A는 동일한 매매대금 채권을 원인으로 乙에게 직접 소를 제기하더라도, 이전 판결의 기판력에 의해 그 주장이 봉쇄된다. 법원은 기판력에 저촉되는 A의 청구를 기각해야 한다.

V. 결론

- 채권자대위소송의 판결이 확정된 경우, 채무자가 그 소송 계속 사실을 알았을 때에 한하여 민사소송법 제218조 제3항에 따라 판결의 기판력이 채무자에게 미친다는 것이 판례의 확립된 견해이다. 사안에서 甲의 기각 판결이 확정되었으므로, 채무자 A가 소송 사실을 알고 있었다면 A에게도 기판력이 미치게 된다. 따라서 A는 추후 乙을 상대로 동일한 매매대금 채권을 행사할 수 없으며, 이는 증거의 공백이나 중복 소송으로 인한 법적 혼란을 방지하고 판결의 실효성을 확보하기 위한 법적 장치로 기능한다.

<제3편 제1심의 소송절차.제06장 변론.제02절 심리에 관한 제 원칙>

[기출][2011-1]교통사고 손해배상청구에서 개별 항목별 청구액을 초과하여 인정한 판결의 적법성 여부

《【문제1】 교통사고 피해자인 甲은 가해자인 乙을 상대로 손해배상청구의 소를 제기하면서 적극적 손해, 소극적 손해, 위자료 각 1,000만 원씩 합계 3,000만 원을 청구하였다. 그런데 법원은 피고에 대하여 적극적 손해 1,500만 원, 소극적 손해 1,000만 원, 위자료 500만원 합계 3,000만 원을 이행하라는 판결을 선고하였다. 이 판결의 적법성 여부에 대하여 논하시오. (50점)》

<문제1> 교통사고 손해배상청구에서 개별 항목별 청구액을 초과하여 인정한 판결의 적법성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 교통사고 피해자인 甲이 乙을 상대로 적극적 손해, 소극적 손해 및 위자료를 합한 3,000만 원의 손해배상을 청구하였는데, 법원이 각 손해항목의 인정액을 청구 내용과 달리 배분하면서도 총액은 청구한 3,000만 원과 동일하게 인용한 상황이다. 쟁점으로 손해배상청구에서 적극적 손해 · 소극적 손해 · 위자료가 각각 독립한 소송물인지, 아니면 하나의 소송물에 관한 공격방어방법에 불과한지와 법원이 청구금액의 항목별 배분을 달리하여 판단할 수 있는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 손해배상청구의 소송물과 처분권주의의 적용 범위를 중심으로 법원이 손해항목을 달리 인정한 판결의 적법성 여부를 논한다.

II. 처분권주의의 의의 및 범위

1. 의의

- 처분권주의란 소송의 개시, 심판의 대상 및 범위, 소송의 종료에 대하여 당사자에게 주도권을 주는 원칙을 의미한다. 법원은 당사자가 신청한 범위 내에서만 심판해야 하며, 이를 위반하여 청구하지 않은 사항을 판결하거나 청구 범위를 초과하여 판결하는 것은 위법하다.

2. 심판대상에 관한 처분권주의

- 법원은 원고가 신청한 소송물에 대해서만 심판해야 한다. 만약 원고가 신청한 소송물과 법원이 판단한 소송물이 다르거나, 양적으로 원고의 신청 범위를 넘어서는 경우에는 처분권주의 위반이 된다.

III. 손해배상청구의 소송물과 손해3분설

1. 소송물 이론의 대립

(1) 손해1분설(일원설)

- 불법행위로 인한 손해배상청구권은 하나이며, 적극적 · 소극적 손해 및 위자료는 그 산정 방식에 불과하다고 보는 견해이다. 이 견해에 따르면 총액이 청구 범위를 넘지 않는 한 처분권주의 위반이 아니다.

(2) 손해2분설(이원설)

- 재산상 손해와 정신상 손해(위자료)를 별개의 소송물로 보는 견해이다. 재산상 손해 내에서는 항목 간 유용이 가능하다고 본다.

(3) 손해3분설(삼원설)

- 적극적 손해, 소극적 손해, 위자료를 각각 별개의 소송물로 보는 견해이다. 대법원 판례의 확고한 입장이다.

2. 판례의 태도

- 대법원은 불법행위로 인한 손해배상청구소송에 있어서 적극적 손해, 소극적 손해, 위자료는 그 취지를 달리하는 별개의 소송물이라고 판시하고 있다. 따라서 법원은 원고가 청구한 각 손해 항목별 금액의 한도 내에서 인용해야 하며, 각 항목의 한도를 넘어서는 판결을 할 수 없다는 입장이다.

IV. 사안의 적용

1. 소송물별 한도 초과 여부

(1) 적극적 손해

- 원고 甲은 적극적 손해로 1,000만 원을 청구하였으나, 법원은 이를 초과하는 1,500만 원을 인정하였다. 이는 당사자가 신청한 범위를 벗어난 판결이다.

(2) 소극적 손해

- 청구액 1,000만 원에 대하여 1,000만 원을 인정하였으므로 처분권주의에 위반되지 않는다.

(3) 위자료

- 청구액 1,000만 원에 대하여 500만 원을 인용하였으므로 신청 범위 내에 해당하여 적법하다.

2. 총액 기준의 판단 여부

- 비록 판결의 인용 총액(3,000만 원)이 원고가 청구한 총액(3,000만 원)과 일치하더라도, 판례가 따르고 있는 손해3분설에 의하면 각 손해 항목은 별개의 소송물이다. 따라서 항목 간의 금액을 유용하여 적극적 손해에서 청구 범위를 초과하여 인정한 것은 허용되지 않는다.

V. 결론

- 법원이 적극적 손해 항목에서 원고의 청구액인 1,000만 원을 초과하여 1,500만 원을 인정한 부분은 민사소송법 제203조가 정한 처분권주의를 위반한 것이다. 비록 전체 인용 금액이 청구 총액을 넘지 않았으나, 별개의 소송물인 적극적 손해에 대해 신청하지 않은 금액을 판결한 것이므로 해당 판결은 그 부분에 있어 부적법하다. 법원은 적극적 손해 1,000만 원, 소극적 손해 1,000만 원, 위자료 500만 원을 합산하여 총 2,500만 원만을 이행하라는 판결을 선고하여야 한다.

<제3편 제1심의 소송절차.제06장 변론.제02절 심리에 관한 제 원칙>

[기출][2014-1-2]근로자가 청구하지 않은 임금지급을 명한 판결의 적법성 여부

《【문제1】 근로자 甲은 해고를 당한 후 사용자인 乙회사를 상대로 해고무효 확인의 소를 제기하고자 한다. 그런데 乙회사는 명칭만 회사일 뿐 A, B, C 3인이 공동으로 출자해서 설립한 민법상 조합에 불과하다. 다음 물음에 답하시오. (50점) (다만 아래 각 지문은 상호 무관함)》

(물음2) 甲이 적법하게 제기한 해고무효 확인의 소에서 제1심 법원이 甲이 청구 하지도 않은 해고처분 이후 미지급한 임금의 지급을 명하는 판결을 하였다면 동 임금지급 판결은 적법한지 여부에 대해 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 甲이 청구하지 않은 임금지급을 명한 판결의 적법성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 민법상 조합인 乙회사를 상대로 해고무효 확인의 소를 적법하게 제기하였는데, 제1심 법원이 甲이 청구하지 않은 해고 후 미지급 임금의 지급까지 명하는 판결을 한 상황이다. 쟁점으로 법원이 당사자가 신청하지 않은 사항에 대하여 판결할 수 있는지와 처분권주의 및 신청사항 구속의 원칙에 위반되는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 법원이 해고무효 확인의 소에서 청구하지 않은 임금지급을 명하는 판결의 적법성에 대하여 논한다.

II. 처분권주의의 의의와 내용

1. 처분권주의의 의의

- 처분권주의란 절차의 개시, 심판의 대상 및 범위, 그리고 절차의 종결에 대하여 당사자에게 주도권을 맡기는 원칙을 말한다. 이는 사적 자치의 원칙이 소송법적으로 발현된 것으로, 법원은 당사자가 신청한 범위 내에서만 심판해야 한다는 제약을 받는다.

2. 심판의 대상 및 범위와 관련된 내용

(1) 양적 제한

- 법원은 당사자가 청구한 상한을 초과하여 판결할 수 없다. 예를 들어 1,000만 원의 원금 지급을 청구했는데 법원이 1,200만 원을 인용하는 것은 처분권주의의 위반이다.

(2) 질적 제한

- 법원은 당사자가 신청한 것과 다른 종류의 판결을 할 수 없다. 확인의 소를 제기했는데 이행 판결을 하거나, 특정 물건의 인도를 청구했는데 대금 지급을 명하는 것은 허용되지 않는다.

III. 처분권주의 위반의 효과

1. 판결의 적법성

- 처분권주의를 위반하여 당사자가 청구하지 않은 사항을 판결한 경우, 그 판결은 법령 위반으로서 상소나 재심의 대상이 된다. 다만, 이러한 결함이 있더라도 판결이 당연무효가 되는 것은 아니며, 상소 절차를 통해 취소되기 전까지는 유효한 판결로 존재한다.

2. 상소심에서의 처리

- 상소심 법원은 처분권주의 위반을 이유로 원심판결 중 청구 범위를 벗어난 부분을 취소하여야 한다. 이는 당사자의 신청 범위를 확정하는 법원의 해석 오류에 기인한 것이므로 법률 위반에 해당한다.

IV. 사안의 적용

1. 심판 대상의 확정

- 근로자 甲이 제기한 소송은 해고무효 확인의 소이다. 이는 사용자의 해고 처분이 법률적으로 무효임을 확인받고자 하는 소송으로, 심판의 대상은 해고의 효력 유무에 한정된다.

2. 임금지급 판결의 성격

- 해고무효 확인 소송에서 승소할 경우 근로자는 소급하여 근로자의 지위를 회복하며, 이에 따른 임금청구권이 발생하는 것이 법적 효과이다. 그러나 확인의 소 그 자체에 임금지급이라는 이행청구가 당연히 포함되는 것은 아니다. 임금지급은 별도의 이행청구가 있어야만 소송물로 편입된다.

3. 처분권주의 위반 여부

- 제1심 법원이 甲이 신청하지도 않은 임금지급을 명한 것은 당사자가 청구하지 않은 이행의무를 직권으로 판단한 것이다. 이는 처분권주의의 질적 제한(청구하지 않은 종류의 판결)을 정면으로 위반한 것에 해당한다. 법원은 설령 임금청구권이 당연히 발생한다고 판단하더라도, 당사자의 명시적인 청구가 없는 한 이를 판결 주문에 기재해서는 안 된다.

V. 결론

- 제1심 법원이 甲이 청구하지 않은 미지급 임금의 지급을 명한 판결은 민사소송법 제203조가 규정하는 처분권주의를 위반한 것이다. 따라서 해당 임금지급 판결 부분은 부적법하며, 상소 등에 의하여 취소되어야 할 법령 위반의 판결에 해당한다.

<제3편 제1심의 소송절차.제06장 변론.제02절 심리에 관한 제 원칙>

[기출][2019-1-1]피고의 일부변제 미주장 시 법원이 원고 청구액 전액을 인용한 판결의 타당성 여부

《【문제1】 甲은 乙에 대하여 지급기일을 2017. 2. 1.로 하는 1억 원의 공사대금채권을 가지고 있었다. 乙은 2017. 10. 1. 이 채권금액 가운데 3,000만 원을 변제하였다. 甲은 2018. 4. 1. 乙에 대하여 위 공사대금 1억 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 법원은 2018. 12. 1. 변론을 종결하고 甲의 청구대로 1억 원의 지급을 명하는 판결을 선고하였고, 그 판결은 확정되었다. 다음 물음에 답하시오. (50점)》

(물음1) 乙은 위 소송절차에서 2017. 10. 1.에 일부변제한 사실을 주장하지 아니하였다. 3,000만 원의 변제사실을 인정하지 않고 1억 원의 지급을 명한 위 법원의 판결이 타당한지를 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음1> 피고의 일부변제 미주장 시 법원이 원고 청구액 전액을 인용한 판결의 타당성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 공사대금 1억 원의 지급을 구하는 소를 제기하였으나 乙은 변론종결 전 이미 이루어진 3,000만 원의 일부변제 사실을 주장하지 않았고, 법원은 이를 고려하지 않은 채 1억 원 전액의 지급을 명하는 판결을 선고하여 확정된 상황이다. 쟁점으로 **변론종결 전 발생한 일부변제 사실을 당사자가 주장하지 않은 경우 법원이 이를 직권으로 고려하여야 하는지와 이를 반영하지 않은 판결의 적법성**을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 변론주의와 처분권주의를 전제로 일부변제 사실을 주장하지 않은 경우 법원이 전액 지급판결을 선고한 것이 타당한지 논한다.

II. 변론주의의 일반 법리

1. 변론주의의 의의 및 필요성

(1) 개념 및 의의

- 변론주의란 소송자료인 사실과 증거의 수집·제출을 당사자의 책임과 권능으로 삼는 소송법상 원칙을 의미한다. 이는 당사자의 사적 자치를 소송 절차 상으로 관철하려는 데 취지가 있다.

(2) 필요성

- 변론주의는 국가기관인 법원이 불필요하게 사적인 분쟁에 개입하는 것을 방지하고, 당사자 스스로가 가장 잘 아는 사실관계를 직접 현출하도록 함으로써 실질적이고 신속한 심리를 도모하는 역할을 수행한다.

2. 변론주의의 내용과 주장책임

(1) 주장책임의 원칙

- 법원은 당사자가 소송에서 주장하지 않은 사실은 판결의 기초로 삼을 수 없다는 제1원칙이다. 이는 당사자가 주장한 사실만을 기초로 사실을 인정해야 하는 법원의 소극적 한계를 규정한다.

(2) 대상이 되는 사실의 범위

- 주장책임의 대상은 권리의 발생·변경·소멸에 직접적이고 법률적인 효과를 주는 주요사실에 한한다. 주요사실에 대립하는 간접사실이나 보조사실은 당사자의 구체적인 주장이 없더라도 증거에 의하여 법원이 직접 인정할 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 일부변제 사실의 법적 성질

(1) 주요사실의 해당 여부

- 일부변제는 원고의 공사대금채권의 일부를 소멸시키는 실체법상 효과를 발생시키는 변제 항변에 해당한다. 따라서 이는 채권의 소멸이라는 법률 효과를 직접 가져오는 전형적인 주요사실에 속한다.

(2) 법원의 임의 판단 제한

- 일부변제가 주요사실에 해당하는 이상, 당사자가 이를 법정에 제출하여 주장하지 않은 한 법원은 직권으로 이를 재판의 기초로 삼을 수 없다.

2. 乙의 미주장과 법원 판결의 타당성

(1) 乙의 주장책임 흠결

- 사안에서 피고 乙은 3,000만 원을 이미 변제한 사실이 엄연히 존재함에도 불구하고, 2018. 12. 1. 변론종결 전까지 법원에 이를 전혀 주장하지 않았다. 이는 乙이 주장책임을 다하지 않은 것에 해당한다.

(2) 법원의 판결에 대한 평가

- 수소법원은 변론주의 원칙에 구속되므로, 乙의 구체적인 변제 항변 주장이 없는 상태에서 임의로 3,000만 원의 채무 소멸을 판결의 기초로 삼을 수 없다. 따라서 법원이 제출된 소송자료만을 토대로 甲의 1억 원 청구를 전액 인용한 판결은 변론주의의 주장책임 원칙에 완벽히 부합하므로 전적으로 정당하고 타당하다.

IV. 결론

- 변론주의의 제1원칙에 따라 법원은 당사자가 주장하지 아니한 주요사실을 판결의 기초로 삼을 수 없다. 사안의 일부변제 사실은 채권 소멸이라는 법률 효과를 직접 발생시키는 주요사실에 해당함에도 피고 乙은 소송절차 내에서 이를 주장하지 않았다. 따라서 법원이 乙의 변제 사실을 고려하지 않고 甲의 공사대금 청구를 전액 인용한 것은 소송법상의 대원칙인 변론주의에 정밀하게 부합하는 적법·타당한 재판이다. 결국 乙은 자신의 주장책임 태만으로 인한 불이익을 스스로 감수하여야 한다.

<제3편 제1심의 소송절차.제06장 변론.제02절 심리에 관한 제 원칙>

[기출][2020-2]석명의무의 의의, 내용과 대상, 범위, 한계, 위반의 효과

《【문제2】 석명의무에 관하여 설명하십시오. (25점)》

<문제2> 석명의무의 의의, 내용과 대상, 범위, 한계, 위반의 효과

I. 석명의무의 의의

- 석명권이란 소송관계의 사실상 또는 법률상 사항에 관하여 당사자의 진술이 불분명하거나 불완전한 경우, 법원이 질문을 하거나 입증을 촉구하여 이를 명료하게 하는 권능을 의미한다. (민사소송법 제136조) 이는 변론주의의 단점을 보완하여 실질적 진실을 발견하고 당사자의 절차적 정의를 실현하기 위한 제도이다. 특히, 법률 지식이 부족한 당사자가 본인의 의사를 적절히 표현하지 못해 패소하는 억울한 사례를 방지하는 기능을 한다. 석명권은 법원의 권한인 동시에 적절한 재판을 위한 의무적 성격도 지니고 있어, 이를 소홀히 한 경우 석명의무 위반을 이유로 상고이유가 될 수 있다.

II. 석명의무의 내용과 대상

1. 사실관계의 석명

- 당사자의 주장 내용이 모순되거나 불투명할 때 이를 확실히 하는 것을 말한다.

(1) 취지의 명료화

- 당사자의 신청이나 진술이 법률적으로 무슨 의미인지 불분명할 때 그 취지를 묻는 것이다. 예를 들어 피고의 진술이 단순한 부인인지 항변인지 명확히 하는 행위가 이에 해당한다.

(2) 불완전한 주장의 보완

- 주장된 사실의 전후 관계가 맞지 않거나 누락된 부분이 있을 때 이를 보충하도록 권유하는 것이다.

2. 법률적 사항에 대한 석명 [민사소송법 제136조 제4항]

- 법원은 당사자가 간과한 것이 분명하다고 인정되는 법률적인 사항에 관하여 당사자에게 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.

(1) 법적 관점의 제시

- 당사자가 주장하는 법률적 근거가 부적절하거나 법원이 다른 법률적 시각에서 판단하고자 할 때 이를 당사자에게 미리 알려 불의의 타격을 방지해야 한다.

(2) 법률적 지적의무

- 당사자가 전혀 인식하지 못한 법률적 쟁점에 대하여 법원이 판결의 기초로 삼고자 한다면 반드시 석명을 통해 변론의 기회를 부여해야 한다.

III. 석명의무의 범위

1. 소극적 석명

- 당사자의 진술 속에 포함되어 있으나 불분명한 것을 명확히 하는 단계로, 이는 당연한 법원의 의무에 해당한다.

2. 적극적 석명

- 당사자가 전혀 제출하지 않은 새로운 주장이나 증거를 제출하도록 권유하는 단계이다.

(1) 원칙적 제한

- 법원이 당사자가 주장하지도 않은 사실을 먼저 제시하거나 특정 방향으로 소송을 유도하는 것은 변론주의의 원칙과 법원의 중립성을 해칠 우려가 있어 원칙적으로 허용되지 않는다.

(2) 예외적 허용

- 판례는 당사자가 청구의 기초에 비추어 당연히 내놓아야 할 주장을 단순히 법률 지식의 부족으로 빠뜨린 경우나, 소송 자료가 이미 제출되어 있어 조금만 주의를 기울이면 알 수 있는 사항에 대해서는 예외적으로 적극적 석명을 인정하고 있다.

IV. 석명의무의 한계

1. 변론주의와의 조화

- 석명권은 변론주의를 보완하는 수단이지 이를 대체하는 수단이 아니다. 당사자가 명백히 거부하는 주장을 강요하거나, 당사자의 의사에 반하여 새로운 소송물을 추가하도록 하는 것은 한계를 벗어난 것이다.

2. 중립의무의 준수

- 법원은 어느 한쪽 당사자에게 치우쳐 승소를 돕는 조연자가 되어서는 안 된다. 석명은 양 당사자에게 공정하게 행사되어야 하며, 재판의 객관적 공정성을 의심받을 정도에 이르러서는 안 된다.

V. 석명의무 위반의 효과

1. 상소 이유

- 중요한 사항에 대하여 법원이 석명의무를 다하지 않아 판결 결과에 영향을 미쳤다면, 이는 심리미진의 위법으로서 항소 및 상고의 이유가 된다.

2. 판례의 경향

- 대법원은 당사자의 진술이 모순되거나 증거와 명백히 배치됨에도 법원이 이를 바로잡지 않고 그대로 판결한 경우 석명의무 위반을 이유로 원심판결을 파기하는 등 엄격하게 판단하는 추세이다.

VI. 결론

- 석명의무는 현대 민사소송에서 실질적 평등과 공정한 재판을 실현하기 위한 핵심적인 도구이다. 법원은 당사자의 자율성을 존중하는 변론주의의 틀 안에서, 법률적 문해력이 낮은 당사자가 절차적 불이익을 당하지 않도록 세심하게 석명권을 행사해야 한다. 특히 법률적 사항에 대한 지적의무는 당사자에게 예측가능성을 부여하고 판결에 대한 승복도를 높이는 데 기여한다. 법원은 석명권의 오남용을 경계하면서도, 진실 발견을 위해 필요한 범위 내에서는 과감하게 입증을 촉구하고 주장을 명료화하는 능동적인 역할을 수행해야 한다.

<제3편 제1심의 소송절차.제06장 변론.제02절 심리에 관한 제 원칙>

[모의][6.02-1]처분권주의의 의의 및 적용 영역, 제한 및 예외, 위반의 효과

《【문제6.2-1】 처분권주의에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제6.2의 물음1> 처분권주의의 의의 및 적용 영역, 제한 및 예외, 위반의 효과

I. 처분권주의의 의의 및 적용 영역

1. 처분권주의의 의의 ★

- 처분권주의란 **민사소송법 제203조**에 따라 소송의 개시, 심판대상 및 범위의 지정, 소송의 종료를 당사자의 의사에 맡기는 소송법상의 원칙을 말한다. 이는 실체법상의 사적자치의 원칙이 소송법적으로 구현된 것이다.

2. 적용 영역

(1) 소송의 개시 및 종료

- 소송은 원고의 소 제기에 의해서만 개시되며 법원이 직권으로 개시할 수 없다. 또한 당사자는 소의 취하, 청구의 포기·인낙, 소송상 화해를 통해 소송을 자유롭게 종료시킬 수 있다.

(2) 심판대상의 결정 및 범위

- 법원은 원고가 신청한 청구의 취지와 원인에 구속되므로, 신청하지 않은 청구에 대해 판결할 수 없고 신청 범위를 초과하여 판결할 수도 없다.

II. 처분권주의의 제한 및 예외

1. 공익적 성격에 따른 제한

(1) 가사소송 및 신분소송

- 혼인, 친자관계 등 신분관계 소송은 사회적 공익성이 크므로 당사자의 임의적 처분을 제한하고 직권탐지주의를 적용한다.

(2) 행정소송의 일부 영역

- **행정소송법**은 법원이 필요하다고 인정할 때 직권으로 증거조사를 할 수 있도록 규정하여 처분권주의를 일부 제한하고 있다.

2. 형식적 형성의 소

(1) 공유물분할청구의 소

- 공유물분할청구의 소와 같이 법률관계의 형성을 법원의 재량에 맡기는 경우 법원은 당사자의 청구 방식에 구속되지 않고 독자적인 분할 방식을 결정할 수 있다.

(2) 경계확정의 소

- 토지의 경계확정을 구하는 소에서도 법원은 당사자가 주장하는 경계선에 구속되지 않고 객관적으로 정당한 경계를 확정하여야 한다.

III. 처분권주의 위반의 소송법상 효과 (상소사유)

1. 위반의 유형

(1) 양적 초과판결

- 원고가 청구한 수량이나 금액을 초과하여 판결하는 경우이다. 예를 들어 대여금 1,000만 원 청구에 대해 1,200만 원 인용 판결을 내리는 것은 처분권주의에 위배된다.

(2) 질적 초과판결

- 원고가 청구한 소송물과 전혀 다른 종류의 급부를 판결하는 경우이다. 이행의 소를 청구하였는데 법원이 직권으로 확인판결을 내리는 경우가 이에 해당한다.

2. 위반 판결의 효력 및 구제

(1) 상소에 의한 구제

- 처분권주의를 위반한 판결은 법령 위반의 하자가 있으므로 당사자는 상소(항소 또는 상고)를 제기하여 판결의 파기나 취소를 구할 수 있다.

(2) 확정 후의 효력

- 위반 판결이라도 당연무효는 아니며 재심사유(**민사소송법 제451조**)에도 해당하지 않으므로, 상소 제기 없이 판결이 확정되면 그 하자는 치유되고 기판력이 발생한다.

IV. 결론

- 처분권주의는 사적자치의 원칙을 민사소송 절차에 반영하여 당사자의 자주적인 분쟁 해결 의사를 존중하는 근간이다. 그러나 법적 안정성과 공익적 필요에 따라 형식적 형성의 소나 가사소송 등에서는 예외적으로 그 적용이 제한된다. 실무적으로 법원은 원고의 청구 취지와 원인을 엄격히 해석하여 처분권주의 위반으로 인한 심판 범위 일탈 및 상소 제기의 혼란을 방지하여야 할 것이다.

<제3편 제1심의 소송절차.제06장 변론.제02절 심리에 관한 제 원칙>

[모의][6.02-2]주요사실과 간접사실의 개념, 구별기준, 소송법상 실익

《【문제6.2-2】 주요사실과 간접사실에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제6.2의 물음2> 주요사실과 간접사실의 개념, 구별기준, 소송법상 실익

I. 주요사실과 간접사실의 개념 정의

1. 주요사실의 의미

- 주요사실(요건사실)이란 권리의 발생·변경·소멸 등 법률효과를 발생시키는 실체법상의 법률요건에 직접 해당하는 사실을 말한다. 이는 변론주의가 적용되는 직접적인 심판 대상이 되므로, 당사자가 소송에서 주장하지 않으면 법원이 이를 판결의 기초로 삼을 수 없다.

2. 간접사실의 의미

- 간접사실이란 주요사실의 존재 여부를 경험칙에 의하여 추인하는 데 도움을 주는 사실을 의미한다. 이는 주요사실을 입증하기 위한 증거자료와 유사한 성격을 가지며, 당사자의 주장이 없더라도 법원이 변론의 전취지에 나타난 자료와 자유심증에 의하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

II. 양자의 구별 기준 (법률요건분류설적 관점)

1. 법률요건분류설의 내용 및 원칙

- 대법원은 주요사실과 간접사실을 구별할 때 실체법 규정의 구성요건을 기준으로 삼는 법률요건분류설(다수설)을 취하고 있다. 이에 따르면 법률효과를 규정한 법조문 자체에 명시된 요건사실만이 주요사실에 해당하며, 그 요건사실의 존재를 추단케 하는 사실들은 모두 간접사실에 불과하다.

2. 구체적 구별의 양상

(1) 주요사실의 구체적례

- 대여금 반환청구소송에서 소비대차계약의 체결, 목적물의 인도, 변제기의 도래 등은 법률효과 발생에 직접 필요한 요건이므로 주요사실이다.

(2) 간접사실의 구체적례

- 대여금 반환청구소송에서 돈을 건네줄 당시 당사자가 현장에 동석하였다는 사실이나 차용증을 작성하는 모습을 보았다는 목격자의 존재 등은 계약 체결이라는 주요사실을 추정케 하는 간접사실이다.

III. 구별의 소송법상 실익

1. 변론주의의 적용 여부

(1) 주장책임과 판결 기초의 제한

- 변론주의 원칙상 주요사실은 당사자가 반드시 주장하여야 하며, 법원은 주장하지 않은 주요사실을 판결의 기초로 삼을 수 없다. 반면 간접사실은 당사자의 명시적인 주장이 없더라도 증거조사 등 변론에 나타난 자료를 통해 법원이 직권으로 인정할 수 있다.

(2) 재판상 자백의 구속력

- 재판상 자백은 주요사실에 대해서만 성립하며, 자백이 성립하면 당사자와 법원을 구속하는 강력한 효력이 발생한다. 그러나 간접사실에 대한 자백은 자백의 구속력이 발생하지 않으므로, 법원은 이에 구속되지 않고 자유롭게 사실을 인정할 수 있다.

2. 석명권 및 이유 기재 범위

(1) 석명권의 대상

- 법원의 석명 의무는 당사자가 주장한 주요사실의 취지가 불분명하거나 모순이 있을 때 이를 명확히 하도록 유도하는 데 집중된다. 법원은 주장책임이 없는 간접사실에 대해서는 적극적으로 석명권을 행사할 의무가 없다.

(2) 판결서의 이유 기재 의무

- 법원은 판결서 이유에 당사자의 주장 중 법률상 요건에 해당하는 주요사실에 대한 판단만을 명시하면 족하다. 법원이 간접사실의 존부에 대하여 판결서에 일일이 판단을 기재하지 않더라도 기판력의 범위를 판단하는 데 영향을 미치지 않는다.

IV. 결론

- 주요사실과 간접사실의 구별은 당사자의 주장책임 범위를 명확히 규정하고 법원의 자의적인 판결을 방지하는 소송법상의 안전핀이다. 사법 자치와 적절한 재판을 보장하기 위해 법원은 법률요건분류설적 기준을 엄격하게 적용하여 변론주의의 적용 범위를 확정하되, 구체적 정의 실현을 위해 유기적으로 심리를 운영해야 할 것이다.

<제3편 제1심의 소송절차.제06장 변론.제03절 변론의 준비>

[기출][2012-2]준비서면을 제출하지 않았을 때의 효과

《【문제2】 준비서면을 제출하지 않았을 때의 효과 (25점)》

<문제2> 준비서면을 제출하지 않았을 때의 효과

I. 준비서면의 의의

- 준비서면이란 당사자가 변론에서 하고자 하는 진술 내용을 기일 전에 미리 작성하여 법원에 제출하는 서면을 말한다. **민사소송법**은 변론의 집중과 효율성을 기하기 위해 준비서면의 제출을 제도화하고 있으며, 이를 제출하지 않았을 때에는 실기한 공격방어방법의 각하, 무론각하 등 일정한 불이익을 규정하고 있다.

II. 변리기일 전의 효과

1. 무변론판결의 선고

(1) 요건

- 피고가 소장 부분을 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출하지 아니하거나, 답변서를 제출하였더라도 원고의 청구취지를 완전히 인정하는 취지일 때 법원은 변론 없이 판결을 선고할 수 있다.

(2) 예외

- 공시송달 사건이거나, 판결이 선고되기 전까지 피고가 원고의 청구취지를 다투는 취지의 답변서를 제출한 경우에는 무변론판결을 할 수 없다.

2. 준비기일에서의 진술 제한

- 변론준비절차에서 준비서면을 제출하지 않은 당사자는 상대방이 출석하지 아니한 경우 준비서면에 적지 아니한 사실을 주장할 수 없다. 이는 기일 전 상대방에게 방어 기회를 부여하기 위한 취지이다.

III. 변리기일에서의 효과

1. 진술 간주(의제)의 제한

(1) 출석 시의 원칙

- 당사자가 기일에 출석하였더라도 준비서면에 적지 아니한 사실은 상대방이 출석하지 아니한 때에는 주장하지 못한다. 다만, 상대방이 출석한 경우에는 구술로 새로운 사실을 주장할 수 있으나 실기한 공격방어방법으로 각하될 위험이 있다.

(2) 불출석 시의 효과

- 당사자 일방이 불출석한 경우 제출된 준비서면이 있다면 이를 진술한 것으로 간주(**민사소송법 제148조**)하나, 준비서면 자체를 제출하지 않았다면 진술 간주의 혜택을 받을 수 없어 상대방의 주장 사실을 다투지 않은 것으로 취급될 수 있다.

2. 자백간주 성립 여부

(1) 답변서 미제출의 경우

- 피고가 답변서나 준비서면을 제출하지 않고 기일에도 불출석한 경우, 원고가 주장한 사실을 명백히 다투지 아니한 것으로 보아 자백한 것으로 간주할 수 있다. (**민사소송법 제150조 제3항**)

(2) 공시송달의 예외

- 다만, 소송 서류가 공시송달의 방법으로 송달된 경우에는 자백간주의 규정이 적용되지 아니하므로 원고는 자신의 주장 사실을 별도로 입증하여야 한다.

IV. 증거조사 및 소송 지연에 따른 효과

1. 실기한 공격방어방법의 각하

- 당사자가 고의 또는 중대한 과실로 준비서면 제출을 게을리하여 소송의 완결을 지연시키게 된다고 인정될 때, 법원은 직권 또는 상대방의 신청에 따라 해당 공격방어방법을 각하할 수 있다. (**민사소송법 제149조**) 이는 변론집중주의를 실현하기 위한 강력한 제재 수단이다.

2. 소송비용의 부담

- 당사자가 적당한 시기에 준비서면을 제출하지 않아 소송이 지연된 경우, 그 지연으로 말미암아 생긴 소송비용은 승패와 관계없이 그 당사자가 부담하게 할 수 있다. (**민사소송법 제100조**)

V. 결론

- 준비서면 미제출은 당사자에게 다양한 절차적 불이익을 초래한다. 피고의 경우 무변론판결이나 자백간주를 통해 패소의 위험에 직면할 수 있으며, 원고 또한 입증의 기회를 잃거나 실기한 공격방어방법으로 취급되어 불리한 판결을 받을 수 있다. 특히 현대 **민사소송법**이 추구하는 적정·공평·신속·경제의 이념 중 신속과 경제를 달성하기 위해 준비서면의 성실한 제출은 필수적이다. 따라서 당사자는 법원이 정한 기간 내에 충실한 준비서면을 제출함으로써 자신의 절차적 권리를 보호받고 법률관계를 조기에 확정 지을 필요가 있다.

《【문제2】 소송상 항변에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 소송상 항변의 의의, 부인과의 구별, 항변의 종류, 제출요건과 시기

I. 소송상 항변의 의의

- 소송상 항변이란 원고가 주장하는 청구원인 사실(요건사실)을 피고가 인정하면서도, 그와는 별개의 사실을 주장하여 원고 청구의 당부나 소송의 적법성을 다투는 방어방법을 의미한다. 이는 원고의 주장 사실 자체를 부정하는 부인과 구별되는 개념으로, 피고에게 증명책임이 전환된다는 점에서 실무상 매우 중요한 의미를 갖는다. 항소심 등 소송의 각 단계에서 항변의 제출 시기와 방식에 따라 소송의 결과가 크게 달라질 수 있다.

II. 소송상 항변과 부인의 구별

1. 항변의 개념

- 원고가 주장하는 요건사실의 존재를 전제로 하되, 그 법률효과의 발생을 저지·멸실·정지시키기 위하여 피고가 제출하는 별개의 독립된 사실 주장을 말한다.

2. 부인과의 구별 및 실익

(1) 개념적 차이

- 부인은 원고가 주장하는 사실 자체를 부정하는 것이며, 항변은 원고의 주장은 맞으나 다른 사정이 있다는 이유로 반박하는 것이다. 예를 들어 돈을 빌린 적 없다는 부인이지만, 돈을 빌렸으나 갚았다는 변제항변이다.

(2) 증명책임의 소재

- 부인의 경우 원고가 해당 사실의 존재를 증명해야 하지만, 항변의 경우 항변 사실에 대한 증명책임은 이를 주장하는 피고에게 전적으로 귀속된다.

III. 소송상 항변의 종류

1. 본안전 항변

- 원고의 청구가 적법한 소송요건을 갖추지 못하였음을 이유로 소를 부적법 각하해 달라고 구하는 방어방법이다.

(1) 부적법한 소의 제기 주장

- 관할위반, 중복소송, 재소금지 위반, 당사자 적격의 결여 등을 주장하는 것이 이에 해당한다.

(2) 직권조사사항과의 관계

- 소송요건은 법원의 직권조사사항이나, 당사자가 이를 지적하는 것은 법원의 주의를 촉구하는 의미의 본안전 항변이 된다. 다만, 임의관할이나 중재합의와 같은 변론관할의 경우에는 당사자의 항변이 있어야만 비로소 고려된다.

2. 본안상 항변

- 원고의 청구가 실체법상 이유 없음을 주장하여 청구기각 판결을 구하는 방어방법이다. 이는 법률효과에 따라 세 가지로 세분된다.

(1) 장애항변(성립저지 항변)

- 권리의 성립 자체를 방해하는 사실을 주장하는 것이다. 예를 들어 의사무능력, 선량한 풍속 위반(민법 제103조), 통정허위표시 등이다.

(2) 멸실항변(권리소멸 항변)

- 일단 유효하게 성립한 권리를 사후적으로 소멸시키는 사실을 주장하는 것이다. 예를 들어 변제, 소멸시효 완성, 상계, 면제 등이다.

(3) 저지항변(권리행사 저지 항변)

- 권리의 존재는 인정하나 그 행사를 일시적 또는 영구적으로 저지할 수 있는 사실을 주장하는 것이다. 예를 들어 동시이행의 항변권, 보증인의 최고·검색의 항변권 등이다.

IV. 항변의 제출 요건과 시기

1. 적기제출주의

- 민사소송법은 소송의 지연을 방지하기 위하여 공격방어방법을 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하도록 규정하고 있다.

2. 실기한 공격방어방법의 각하

- 피고가 고의 또는 중대한 과실로 항변을 뒤늦게 제출하여 소송의 완결을 지연시킨다고 판단될 경우, 법원은 직권 또는 상대방의 신청에 의해 해당 항변을 각하할 수 있다.

V. 결론

- 소송상 항변은 피고가 자신의 권리를 보호하기 위해 행사하는 가장 강력한 법적 수단 중 하나이다. 특히 변제, 상계, 소멸시효와 같은 본안상 항변은 사건의 실체적 진실을 밝히는 데 핵심적인 역할을 한다. 당사자는 항변의 종류에 따른 증명책임을 명확히 인지하여야 하며, 법원은 제출된 항변이 단순한 부인인지 아니면 독립된 항변인지를 엄격히 구별하여 재판의 공정성과 효율성을 도모해야 한다.

<제3편 제1심의 소송절차.제06장 변론.제06절 변론기일에서의 당사자의 결석>

<제3편 제1심의 소송절차.제07장 증거.제03절 불요증사실>

[기출][2017-2]자백간주의 의의, 성립 요건, 효력, 적용 범위 및 제한

《【문제2】 자백간주에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 자백간주의 의의, 성립 요건, 효력, 적용 범위 및 제한

I. 자백간주의 의의

- 자백간주란 당사자가 상대방이 주장하는 사실에 대하여 명백히 다투지 않거나, 기일에 출석하지 않음으로써 실질적으로 다투지 않는 경우에 법률상 자백을 한 것과 동일한 효력을 부여하는 제도를 의미한다.(민사소송법 제150조) 이는 당사자의 태만으로 인한 소송 지연을 방지하고 소송 절차를 신속하게 진행하기 위한 취지에서 인정된다. 자백간주가 성립하면 재판상 자백과 마찬가지로 증거조사 없이 해당 사실을 기초로 판결을 내릴 수 있게 된다.

II. 자백간주의 성립 요건

1. 답변서 부제출에 의한 자백간주 [민사소송법 제257조]

(1) 피고의 답변서 제출 의무

- 피고는 소장 부분을 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출하여야 한다. 피고가 이 기한 내에 답변서를 제출하지 아니한 때에는 소장에서 주장한 사실을 자백한 것으로 본다.

(2) 무변론판결

- 법원은 피고가 답변서를 제출하지 않은 경우 변론을 열지 않고 바로 판결(무변론판결)을 선고할 수 있다. 다만, 판결이 선고되기 전까지 피고가 답변서를 제출하면 변론기일을 지정하여야 하므로 자백간주의 효력은 상실된다.

2. 기일에서의 태상에 의한 자백간주 [민사소송법 제150조 제1항]

(1) 명백히 다투지 않는 경우

- 당사자가 변론에서 상대방이 주장한 사실에 대하여 '모른다'고 하거나 침묵하는 등 명백히 다투지 아니한 때에는 그 사실을 자백한 것으로 간주한다. 다만, 변론 전체의 취지로 보아 다른 것으로 인정되는 경우에는 예외로 한다.

(2) 부지의 진술

- 상대방의 주장 사실에 대하여 '모른다(부지)'고 진술하는 것은 다투는 것으로 보지 않고 자백한 것으로 간주될 여지가 있으나, 통상적으로는 다투는 것으로 취급하는 것이 실무이다.

3. 기일불출석에 의한 자백간주 [민사소송법 제150조 제3항]

(1) 불출석의 의미

- 당사자가 적법한 소환을 받았음에도 불구하고 변론기일에 출석하지 아니하거나, 출석하더라도 변론을 하지 않고 퇴정한 경우를 말한다.

(2) 예외 사유

- 공시송달에 의한 송달을 받은 경우에는 기일불출석에 의한 자백간주 규정이 적용되지 않는다. 이는 당사자가 소송 진행 사실을 알지 못하는 상태에서 불이익을 주는 것을 방지하기 위함이다.

III. 자백간주의 효력

1. 증거요함의 면제

- 자백간주가 성립하면 해당 사실은 불요증사실이 된다. 따라서 법원은 별도의 증거조사 없이 그 사실을 판결의 기초로 삼아야 하며, 상대방은 이를 입증할 필요가 없다.

2. 법원에 대한 구속력

- 법원은 자백간주된 사실에 대하여 그와 반대되는 사실을 인정할 수 없다. 즉, 법원은 당사자가 다투지 않는 사실을 그대로 받아들여야 하는 구속을 받는다.

3. 당사자에 대한 구속력 여부

- 재판상 자백과 달리 자백간주는 당사자에 대한 구속력이 인정되지 않는다. 따라서 자백간주의 대상이 된 당사자는 사실심 변론종결 전까지 언제든지 상대방의 주장을 다투어 자백간주의 효력을 소멸시킬 수 있다. 이는 재판상 자백이 철회 제한의 원칙(민사소송법 제288조 단서)을 적용받는 것과 대비되는 특징이다.

IV. 자백간주의 적용 범위 및 제한

1. 적용 범위

- 자백간주는 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계에 관한 사실에 대해서만 적용된다.

2. 적용 제한

(1) 직권조사사항

- 관할권의 유무, 당사자 적격 등 법원의 직권조사사항에 대해서는 당사자가 다투지 않더라도 자백간주가 성립하지 않는다.

(2) 사실이 아닌 법률판단

- 당사자가 주장하는 법률적 견해나 가치판단에 대해서는 자백간주가 적용되지 않는다. 오직 구체적인 사실관계에 대해서만 인정된다.

V. 구제수단 및 결론

- 자백간주에 의한 판결이 선고된 경우, 당사자는 상소를 통해 다투 수 있다. 특히 기일불출석으로 인해 자백간주가 성립하여 패소한 경우, 항소심에서 해당 사실을 다투는 취지의 진술을 하거나 답변서를 제출함으로써 자백간주의 효력을 배제할 수 있다. 다만, 고의로 소송을 지연시키기 위해 다투지 않다가 뒤늦게 상소하는 경우에는 실기한 공격방어방법으로서 제재를 받을 수 있음에 유의해야 한다. 자백간주 제도는 당사자의 성실한 소송 참여를 유도하고 재판의 효율성을 높이는 장치이지만, 당사자의 진의를 확인하지 않은 채 불이익을 주는 측면이 있으므로 법원은 변론 전체의 취지를 면밀히 살펴 신중하게 운용하여야 한다.

<제3편 제1심의 소송절차.제06장 변론.제07절 기일·기간 및 송달>

[기출][2015-1-2] 피고 은행의 소장부분을 은행 사무원에게 우체국 창구에서 교부한 송달의 적법 여부

《【문제1】 甲은 A은행과의 고용계약서상의 퇴직금 조항 등이 무효라는 확인과 함께 퇴직금의 지급을 구하는 내용의 소를 A은행 리스크관리본부장인 乙을 상대로 제기하였다. 당초에 甲이 피고로 삼은 사람은 개인으로서의 乙이 아니라 A은행 부서장인 리스크관리본부장을 피고로 특정한 것인데, 법률적으로 확신이 서지 않자, 甲은 예비적으로 A은행도 피고로 추가하였다. (50점)》

(물음2) 이 때 피고 A은행에 대한 소장부분을 A은행 사무원인 丙에게 우체국 창구에서 교부하였다면, 이러한 송달은 적법한가? (20점)》

<문제1의 물음2> 피고 은행의 소장부분을 은행 사무원에게 우체국 창구에서 교부한 송달의 적법 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 원고 甲은 고용계약서상의 퇴직금 조항 무효확인 및 퇴직금 지급을 구하는 소를 제기하며 예비적으로 A은행을 피고로 추가하였다. 이에 법원이 피고 A은행에 대한 소장부분을 우체국 창구에서 A은행의 사무원인 丙에게 교부한 상황이다. 쟁점으로 **법인인 A은행에 대한 소장부분을 우체국 창구에서 사무원에게 교부한 송달이 민사소송법상 적법한 송달로 인정될 수 있는지** 검토할 필요가 있다. 이하에서는 피고 A은행에 대한 우체국 창구교부송달의 적법 여부를 설명한다.

II. 법인에 대한 송달과 보충송달의 일반 법리

1. 법인에 대한 송달과 송달장소

(1) 법인의 대표자 송달 원칙

- 법인은 대표자가 소송을 대리하므로 법인에 대한 송달은 그 대표자에게 하여야 한다. 공동대표의 경우 그중 1인에게 송달하면 효력이 발생한다.

(2) 적법한 송달장소의 확정

- 송달은 원칙적으로 대표자의 주소, 거소, 영업소 또는 사무소에서 하여야 한다. 이때 영업소나 사무소는 당해 법인의 시설을 의미한다.

2. 보충송달의 요건과 장소적 한계

(1) 보충송달의 의의와 요건

- 보충송달은 송달장소에서 송달받을 자를 만나지 못한 때 사무원, 고용인 또는 동거인으로서 사리를 분별할 능력이 있는 자에게 서류를 교부하는 송달이다. 수령대행인은 서류를 본인에게 교부할 것을 기대할 수 있는 능력이 있어야 한다.

(2) 적법한 송달장소 요구와 판례

- **대법원**은 보충송달이 적법한 송달장소에서 하는 경우에만 허용된다고 판시한다. 따라서 송달장소가 아닌 곳에서 사무원 등을 만나 서류를 교부하는 것은 송달수령을 거부하지 않더라도 보충송달로서 부적법하다.

3. 조우송달과 우체국 창구 송달의 제한

(1) 만날 송달(조우송달)의 요건

- 송달장소를 알지 못하거나 송달할 수 없는 경우에도 송달받을 자 본인을 만나면 그의 거부 의사가 없는 한 교부송달을 할 수 있다. 다만 이는 송달받을 자 본인을 직접 만난 경우에만 허용되는 조우송달의 성격을 가진다.

(2) 우체국 창구 송달의 불인정

- 우체국 창구는 적법한 송달장소에 해당하지 않는다. 따라서 우체국 창구에서 사무원 등 수령대행인에게 서류를 교부하는 것은 보충송달로서 부적법하며, 수령권자 본인이 아니므로 조우송달로서도 무효이다.

III. 사안의 적용

1. 피고 A은행에 대한 송달 수령권자와 송달장소

(1) 피고 A은행에 대한 송달의 원칙적 수령권자

① 대표자 대리 원칙

- 피고로 추가된 A은행은 법인에 해당하므로 소송법상 대표자가 대리하여야 한다.

② A은행 대표자의 수령권한

- 따라서 A은행에 대한 송달의 정당한 법정 수령권자는 A은행의 대표자(은행장 등)가 된다.

(2) 적법한 송달장소의 확정

① 원칙적 송달장소

- A은행에 대한 송달은 대표자의 주소, 거소 또는 A은행의 사무소나 영업소에서 실시되어야 한다.

② 우체국 창구의 성격

- 사안의 송달이 이루어진 우체국 창구는 피고 A은행의 대표자의 주소, 거소, 영업소 또는 사무소에 해당하지 않는다.

2. 우체국 창구에서 丙에게 교부한 송달의 적법 여부

(1) 보충송달로서의 적법성 검토

① 송달장소의 흠결

- 우체국 창구는 적법한 송달장소가 아니므로 적법한 송달장소에서 행할 것을 요구하는 보충송달의 장소적 요건을 흠결하였다.

② 보충송달의 부적법성

- 따라서 우체국 창구에서 A은행의 사무원 丙에게 소장부분을 교부한 것은 보충송달로서의 효력을 가질 수 없다.

(2) 조우송달로서의 적법성 검토

① 본인 대면 요건의 결여

- 조우송달은 송달장소 외의 곳에서 송달받을 본인을 대면하여 교부하여야 인정되는 제도이다.

② 조우송달의 불성립

- 수령한 丙은 송달받을 사람인 A은행의 대표자가 아닌 사무원에 불과하므로 우체국 창구에서의 교부는 조우송달로서도 부적법하다.

IV. 결론

- 법인인 피고 A은행에 대한 소장부분의 송달은 그 대표자를 수령권자로 하여 주소나 사무소 등 적법한 송달장소에서 실시되어야 한다. 송달장소가 아닌 우체국 창구에서 법인의 대표자가 아닌 사무원 丙에게 소장부분을 교부한 행위는 장소적 한계를 일탈하여 보충송달의 요건을 결여하였으며, 본인이 아닌 대행인

에게 교부되어 조우송달로서도 효력이 없다. 따라서 우체국 창구에서 사무원 丙에게 소장부분을 교부한 송달은 절차상 중대한 하자가 존재하므로 부적법하여 송달의 효력이 발생하지 않는다.

<제3편 제1심의 소송절차.제06장 변론.제07절 기일·기간 및 송달>

[기출][2016-2]공시송달의 의의, 요건, 절차 및 효력

《【문제2】 공시송달에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 공시송달의 의의, 요건, 절차 및 효력

I. 공시송달의 의의

- 송달은 당사자에게 소송 서류의 내용을 알 수 있는 기회를 부여함으로써 절차적 권리를 보장하는 핵심적인 제도이다. 그러나 상대방의 주소나 거소를 전혀 알 수 없는 경우에도 송달이 불가능하다는 이유만으로 재판 절차를 무한정 지연시킬 수는 없다. 이에 **민사소송법 제194조**는 최후의 수단으로 법원 게시판 등에 서류를 게시함으로써 송달된 것으로 간주하는 공시송달 제도를 규정하고 있다.

II. 공시송달의 요건

1. 주소·거소 등의 불명

(1) 의의

- 당사자의 주소·거소·영업소 또는 사무소를 알 수 없는 경우여야 한다. 이는 단순히 송달을 받지 않는 경우와는 구별되며, 소재 자체가 확인되지 않는 상태를 의미한다.

(2) 조사의 의무

- 송달받을 사람의 소재를 알기 위해 상당한 조사를 다했음에도 불구하고 이를 알 수 없어야 한다. **판례**는 주민등록표상 주소지에 거주하지 않는다는 사실 뿐만 아니라, 친족 등에 대한 문의나 통신사 사실조회 등을 통해 소재 파악을 위한 노력을 기울였는지 여부를 엄격하게 심사한다.

2. 외국 송달의 곤란성

- 외국에서 행하여야 할 송달에 관하여 외국 송달 방법(**제191조**)에 의할 수 없거나, 그 방법에 의하더라도 송달의 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우에도 공시송달을 할 수 있다.

3. 보충송달 등의 불가능

- 송달받을 사람의 주소 등은 알지만, 그 장소에서 보충송달(**제186조 제1항**)이나 유치송달(**제186조 제3항**)이 불가능하고 우편송달(**제187조**)의 요건도 갖추지 못한 경우에 예외적으로 허용될 수 있다.

III. 공시송달의 절차

1. 신청 또는 직권

- 공시송달은 당사자의 신청에 의하거나 법원이 직권으로 행할 수 있다. 신청 시에는 주소 등을 알 수 없는 사유를 소명하여야 한다.

2. 재판장의 명령

- 공시송달은 재판장의 명령에 의해 실시된다. 재판장은 요건이 구비되었다고 판단되면 사무관 등에게 공시송달을 명한다.

3. 실시 방법

- 법원 사무관 등은 송달할 서류를 보관하고, 그 사유를 법원 게시판에 게시하거나 관보·신문에 게재하는 방법, 혹은 전자통신매체를 이용하는 방법으로 실시한다.

IV. 공시송달의 효력

1. 효력 발생 시기

(1) 일반적인 경우

- 첫 공시송달은 실시한 날(게시한 날)로부터 2주가 지나면 효력이 발생한다.(**제196조 제1항**)

(2) 동일 당사자에 대한 반복 송달

- 같은 당사자에게 하는 그 뒤의 공시송달은 실시한 다음 날부터 바로 효력이 발생한다.(**제196조 제2항**)

(3) 외국 송달의 경우

- 외국에서 행하는 공시송달의 경우 효력 발생 기간은 2개월로 연장된다.

2. 법률상 도달 간주

- 공시송달의 효력이 발생하면 실제 상대방이 서류를 수령했는지 여부와 관계없이 법률상 적법하게 송달된 것으로 간주된다. 따라서 변론기일 통지 등이 공시송달로 행해지면 상대방이 출석하지 않더라도 무변론판결이나 자백간주 등의 절차가 진행될 수 있다.

V. 공시송달과 구제수단

1. 무변론판결과 자백간주의 예외

- 공시송달에 의한 기일통지를 받고 출석하지 않은 경우에는 자백간주(**제150조 제3항**) 규정이 적용되지 않는다. 따라서 원고는 청구 원인 사실을 별도의 증거로 입증하여야 한다.

2. 추완항소

- 공시송달로 인하여 판결 선고 사실을 몰라 항소기간을 도과한 경우, 당사자는 그 사유가 없어진 날(판결이 있었음을 안 날)로부터 2주 이내에 소송행위의 추완을 신청하며 항소를 제기할 수 있다.(**제173조**)

VI. 결론

- 공시송달은 소송의 정체를 막고 원고의 재판받을 권리를 보장하는 필수적인 제도이나, 피고의 방어권을 심각하게 제한할 위험이 있다. 따라서 법원은 공시송달 명령 전 소령 파악을 위한 당사자의 노력을 엄격히 심리하여야 한다. 또한 공시송달로 판결이 확정된 경우에도 추완항소 등을 통해 사후적인 구제 가능성을 열어둌으로써 절차적 정의와 재판의 효율성 사이의 균형을 도모하여야 한다.

《【문제3】 보충송달에 관하여 설명하십시오. (25점)》

<문제3> 보충송달의 의의, 요건, 제한과 예외, 효력 발생, 불능 시 조치

I. 보충송달의 의의

- 송달이란 재판 절차의 당사자나 그 밖의 이해관계인에게 소송서류의 내용을 알 수 있는 기회를 주기 위해 법정의 절차에 따라 서류를 교부하거나 그 내용을 고지하는 행위이다. **민사소송법**은 송달받을 사람에게 직접 서류를 건네주는 교부송달을 원칙으로 하되, 송달받을 사람을 만나지 못한 경우를 대비하여 보충송달 제도(**민사소송법 제186조 제1항**)를 두고 있다. 이는 송달의 확실성과 절차의 신속성을 조화시키기 위한 장치이다.

II. 보충송달의 요건

1. 근무지 외의 송달장소에서 행하는 경우

(1) 수령인의 부재

- 송달기관이 주소·거소·영업소 또는 사무소 등 근무지 외의 송달장소에 갔으나, 송달받을 사람(본인)을 만나지 못하여야 한다.

(2) 수령대행인의 존재

- 그곳에서 사무를 맡아보는 피용자(직원), 동거인 또는 가족 등 본인을 대신하여 서류를 받을 수 있는 사람이 있어야 한다.

(3) 사리를 분별할 지능

- 수령대행인은 송달의 취지를 이해하고 수령한 서류를 본인에게 전달할 수 있는 최소한의 사리 분별 지능을 갖추어야 한다. 반드시 성년자일 필요는 없으나, 유아나 중증 치매 환자 등은 수령대행인이 될 수 없다.

2. 근무지에서 행하는 경우

(1) 본인의 부재 또는 수령 거부

- 근무지에서 송달받을 사람을 만나지 못하거나, 본인이 서류 수령을 거부하는 경우에 보충송달이 가능하다.

(2) 수령대행인의 범위

- 근무지의 경우에는 그곳에서 사무를 맡아보는 피용자나 조항에 규정된 동료 근무자가 수령대행인이 된다. 주소지 송달과 달리 가족이나 동거인은 근무지의 수령대행인에 해당하지 않는다.

III. 보충송달의 제한과 예외

1. 이해상반인에 대한 송달

- 동일한 소송에서 송달받을 사람과 이해관계가 대립하는 사람(예 : 공동피고인 배우자)에게는 보충송달을 할 수 없다. 이는 수령대행인이 서류를 본인에게 전달하지 않을 위험이 크기 때문이다.

2. 본인이 실제 거주하지 않는 장소에서의 송달

- 주민등록지라 하더라도 본인이 실제로 거주하지 않는 곳에서 가족이 서류를 받은 경우에는 보충송달의 효력이 발생하지 않는다. 보충송달은 본인이 그곳에 거주하거나 영업을 하고 있다는 사실을 전제로 하기 때문이다.

IV. 보충송달의 효력 발생

1. 효력 발생 시기

- 보충송달은 수령대행인에게 서류가 교부된 때에 즉시 효력이 발생한다. 따라서 수령대행인이 본인에게 실제로 서류를 전달했는지 여부나 본인이 내용을 언제 알게 되었는지는 효력 발생에 영향을 미치지 않는다.

2. 도달주의의 예외적 적용

- 보충송달은 법률이 정한 수령대행인에게 서류가 전달됨으로써 본인에게 도달한 것과 동일한 법률 효과를 부여하는 것이다. 만약 수령대행인이 서류를 받은 후 즉시 파기하거나 전달하지 않았더라도, 송달 자체는 적법한 것으로 간주된다.

V. 보충송달 불능 시의 조치

1. 유치송달

- 수령대행인이 정당한 사유 없이 서류 수령을 거부하는 경우에는 서류를 송달장소에 놓아두는 유치송달(**민사소송법 제186조 제3항**)을 할 수 있다.

2. 우편송달 및 공시송달

- 보충송달과 유치송달이 모두 불가능한 경우에는 등기우편으로 발송하는 우편송달(발송송달)이나, 최후의 수단으로서 공시송달 절차를 밟게 된다.

VI. 결론

- 보충송달은 교부송달의 원칙을 보완하여 소송 절차의 원활한 진행을 돕는 중요한 제도이다. 그러나 본인의 수령 의사와 무관하게 효력이 발생한다는 점에서 당사자의 방어권을 침해할 소지가 있으므로, 수령대행인의 자격이나 실제 거주 여부 등 그 요건을 엄격하게 해석하여야 한다. 특히 이해관계가 대립하는 자에 대한 송달 제한 등을 철저히 준수함으로써 절차적 정의를 확보하는 것이 타당하다.

<제3편 제1심의 소송절차.제06장 변론.제08절 소송절차의 정지>

[모의][6.08-1]소송대리인이 있는 경우의 소송절차 중단 예외와 판결의 효력 및 수계절차

《【문제6.8】

<사례>

甲은 乙을 상대로 X 건물에 대한 소유권이전등기청구소송을 제기하여 제1심이 진행 중이다. 그런데 변론이 종결되기 전인 2023. 11. 1. 피고 乙이 교통사고로 급작스럽게 사망하였다. 乙에게는 유일한 상속인으로 아들 丙이 있다.

당시 乙은 변호사 A를 소송대리인으로 선임하여 소송을 수행하게 한 상태였으며, A에게는 당해 심급의 소송행위뿐만 아니라 상소의 제기 등에 관한 특별수권도 부여되어 있었다. 이러한 사실을 알지 못한 법원은 변론기일을 진행하였고, 2023. 12. 1. 원고 甲의 승소 판결을 선고하였다.

또 다른 상황으로, 丁은 戊를 상대로 대여금 청구소송을 제기하였다. 소송 진행 중 丁은 파산선고를 받았고, 파산관재인으로 B가 선임되었다. 丁은 파산선고 사실을 법원에 알리지 않은 채 계속해서 소송을 수행하고자 한다.

(물음1) 사례에서 피고 乙이 사망하였으나 소송대리인 A가 있는 경우, 민사소송법 제233조에도 불구하고 소송절차가 중단되지 않는 근거를 설명하고, 이 경우 선고된 판결의 효력 및 상속인 丙이 소송에 참여하기 위해 취해야 할 절차에 대하여 논하시오.》

<문제6.8의 물음1> 소송대리인이 있는 경우의 소송절차 중단 예외와 판결의 효력 및 수계절차

I. 문제의 제기

- 사안에서 소송 계속 중 피고 乙이 사망하였으나 소송대리인 A가 선임된 상태에서 소송이 진행되어 판결이 선고되었고, 원고 甲의 승소 판결이 선고된 상황이다. 쟁점으로 소송대리인이 있는 경우 당사자의 사망에도 소송절차가 중단되지 않는지와 그에 따라 선고된 판결의 효력 및 상속인의 소송참가 절차를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소송대리인이 있는 경우 소송절차 중단의 예외와 판결의 효력 및 상속인 丙의 소송참가 절차를 논한다.

II. 소송대리인이 있는 경우의 절차 중단 예외

1. 법적 근거 및 취지

(1) 법적 근거

- 민사소송법 제238조는 소송대리인이 있는 경우에는 당사자의 사망 등 중단 사유가 발생하더라도 소송절차가 중단되지 아니한다고 규정하고 있다.

(2) 제도적 취지

- 소송대리인이 있는 경우에는 당사자가 사망하더라도 소송대리인이 그 사무를 계속 처리할 수 있어 소송을 중단시킬 필요가 적고, 오히려 소송을 진행하는 것이 소송경제와 상대방의 이익 보호에 부합하기 때문이다.

2. 소송대리권의 소멸

- 민법상의 위임 계약은 위임인의 사망으로 종료되나, 민사소송법 제95조 제1호는 소송대리권은 당사자의 사망으로 소멸하지 않는다고 규정하여 특칙을 두고 있다. 이에 따라 대리인 A의 소송대리권은 乙의 사망 후에도 상속인 丙을 위하여 유지된다.

III. 선고된 판결의 효력

1. 판례의 태도

(1) 원칙적 유효성

- 판례는 소송대리인이 있는 경우 당사자가 사망하더라도 소송절차는 중단되지 않으므로, 법원이 사망 사실을 알지 못한 채 망자를 그대로 당사자로 표시하여 판결을 선고하더라도 그 판결은 유효하다고 본다.

(2) 판결의 귀속 대상

- 이 경우 판결의 효력은 당연히 상속인에게 미치게 된다. 비록 판결서상 당사자 표시가 망자로 되어 있더라도, 이는 당사자 표시의 잘못에 불과할 뿐 실질적인 당사자는 상속인인 丙으로 확정된 것으로 본다.

2. 사안의 경우

- 법원이 2023. 12. 1. 선고한 甲 승소 판결은 소송대리인 A의 존재로 인하여 소송절차가 적법하게 진행된 상태에서 내려진 것이므로 유효하다. 해당 판결의 효력은 상속인 丙에게 귀속된다.

IV. 상속인 丙이 취해야 할 절차

1. 소송수계신청의 의의

- 소송수계란 소송계속 중 당사자에게 중단 사유가 발생한 경우, 그 소송물을 승계한 자가 중단된 소송을 인계받아 진행하는 절차를 말한다.

2. 수계절차의 개시 시점

(1) 심급의 종료와 중단

- 소송대리인이 있는 경우 해당 심급의 판결이 송달될 때까지는 소송절차가 중단되지 않는다. 그러나 판결이 송달된 후 다음 심급으로 이행하기 위한 준비단계에서는 소송절차가 중단된다고 보는 것이 판례의 태도다.

(2) 수계신청의 방법

- 상속인 丙은 법원에 수계신청서와 함께 乙의 사망 및 자신이 유일한 상속인임을 증명하는 서류(가족관계증명서 등)를 제출하여야 한다. 법원은 이를 심사하여 수계 여부를 결정한다.

3. 당사자 표시정정

- 丙은 판결서상의 당사자 표시를 망자 乙에서 상속인 丙으로 바로잡기 위해 당사자 표시정정 신청을 병행할 수 있다. 이는 판결의 집행력을 명확히 하기 위해 필요한 절차다.

V. 결론

- 피고 乙이 사망하였으나 소송대리인 A가 선임되어 있으므로 민사소송법 제238조 및 제95조에 따라 소송절차는 중단되지 않으며 소송대리권도 소멸하지 않는다. 따라서 법원이 선고한 판결은 적법하고 유효하며, 그 효력은 상속인 丙에게 미친다. 丙은 판결 선고 이후 소송절차를 공식적으로 인계받기 위해 법원에 소송수계신청을 하여야 한다. 이러한 제도는 당사자의 갑작스러운 유고 시에도 소송대리인을 통해 절차의 안정성을 유지하고 원활한 권리 구제를 도모하는 데 그 목적이 있다.

<제3편 제1심의 소송절차.제06장 변론.제08절 소송절차의 정지>

[모의][6.08-2]원고의 파산선고에 따른 소송절차 중단과 수계 및 판결의 효력

《【문제6.8】

<사례>

甲은 乙을 상대로 X 건물에 대한 소유권이전등기청구소송을 제기하여 제1심이 진행 중이다. 그런데 변론이 종결되기 전인 2023. 11. 1. 피고 乙이 교통사고로 급작스럽게 사망하였다. 乙에게는 유일한 상속인으로 아들 丙이 있다.

당시 乙은 변호사 A를 소송대리인으로 선임하여 소송을 수행하게 한 상태였으며, A에게는 당해 급급의 소송행위뿐만 아니라 상소의 제기 등에 관한 특별수권도 부여되어 있었다. 이러한 사실을 알지 못한 법원은 변론기일을 진행하였고, 2023. 12. 1. 원고 甲의 승소 판결을 선고하였다.

또 다른 상황으로, 丁은 戊를 상대로 대여금 청구소송을 제기하였다. 소송 진행 중 丁은 파산선고를 받았고, 파산관재인으로 B가 선임되었다. 丁은 파산선고 사실을 법원에 알리지 않은 채 계속해서 소송을 수행하고자 한다.

(물음2) 원고 丁이 파산선고를 받은 경우 소송절차의 중단 여부를 판단하고, 만약 중단된다면 파산관재인 B가 소송을 인계받는 절차와 丁이 파산선고 사실을 숨기고 받은 판결의 효력에 대하여 기술하시오.》

<문제6.8의 물음2> 원고의 파산선고에 따른 소송절차 중단과 수계 및 판결의 효력

I. 문제의 제기

- 사안에서 원고 丁이 소송 계속 중 파산선고를 받고 파산관재인 B가 선임되었음에도 파산 사실을 법원에 알리지 않은 채 계속 소송을 수행하려는 상황이다. 쟁점으로 파산선고에 따른 소송절차의 중단 여부와 파산관재인에게 수계절차, 그리고 파산선고 사실을 숨긴 채 선고된 판결의 효력을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 원고의 파산선고에 따른 소송절차의 중단 여부와 수계절차 및 파산선고 사실을 숨기고 받은 판결의 효력을 기술한다.

II. 파산선고에 따른 소송절차의 중단

1. 중단의 법적 근거 및 요건

(1) 법적 근거

- 민사소송법 제239조 및 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제347조에 의거하여, 파산재단에 속하는 재산에 관한 소송은 파산선고와 동시에 중단된다.

(2) 대상 소송

- 중단되는 소송은 파산재단에 속하는 재산에 관한 것이어야 한다. 대여금 청구소송은 파산재단을 구성하는 채권에 관한 것이므로 중단 대상에 해당한다.

2. 중단의 시기 및 예외

(1) 중단의 시점

- 파산선고가 내려진 때로부터 즉시 중단된다. 당사자가 그 사실을 알았는지 여부나 법원에 통지되었는지 여부와 관계없이 법률상 당연히 중단된다.

(2) 소송대리인이 있는 경우의 예외

- 당사자 사망의 경우와 마찬가지로, 파산한 당사자에게 소송대리인이 있는 경우에는 민사소송법 제238조가 준용되어 소송절차가 중단되지 않는다. 다만 사안에서는 丁이 직접 소송을 수행하고 있는 것으로 보이므로 중단 사유가 발생한다.

III. 파산관재인 B의 소송수계절차

1. 수계의 주체 및 시기

- 파산재단에 관한 소송물은 파산관재인에게 관리처분권이 이전되므로, 파산관재인 B가 소송을 수계하여야 한다. 파산관재인은 파산선고 후 즉시 또는 중단된 사실을 안 때로부터 수계신청을 할 수 있다.

2. 수계절차의 방식

(1) 수계신청

- 파산관재인 B는 법원에 파산선고 결정문 사본과 관재인 선임 증명서를 첨부하여 소송수계신청서를 제출한다.

(2) 법원의 결정

- 법원은 수계신청이 있으면 상대방에게 이를 통지하고, 수계의 적법성을 심사하여 절차를 재개한다. 만약 수계신청이 이유 없다고 판단되면 결정으로 이를 기각한다.

IV. 파산 사실을 숨기고 받은 판결의 효력

1. 중단 중의 소송행위 및 판결의 효력

(1) 소송행위의 유효성

- 소송절차가 중단된 상태에서 행해진 소송행위는 원칙적으로 무효다. 그러나, 판례는 절차 중단 중임을 알지 못하고 진행된 소송행위라도 후에 수계인이 이를 추인하면 유효해질 수 있다고 본다.

(2) 판결의 효력

- 법원이 중단 사유를 알지 못하고 판결을 선고한 경우, 그 판결은 당연무효는 아니며 대리권 흠결이 있는 판결과 유사하게 취급된다. 즉, 상소나 재심을 통해 취소할 수 있는 상태에 놓이게 된다.

2. 파산관재인 B의 구제 수단

(1) 상소의 제기

- 판결이 송달되기 전이라면 수계절차를 밟아 소송을 재개해야 하며, 이미 판결이 선고된 경우라면 파산관재인은 판결의 무효를 주장하며 상소를 제기하거나 상소 절차에서 수계하여 다툴 수 있다.

(2) 재심의 청구

- 판결이 확정되었다면 민사소송법 제451조 제1항 제3호를 유추적용하여 대리권의 흠결 등을 이유로 재심을 청구할 수 있다는 것이 일반적인 견해다.

V. 결론

- 원고 丁이 파산선고를 받은 순간 대여금 청구소송은 법률상 당연히 중단된다. 丁은 파산재단에 대한 관리처분권을 상실하였으므로 더 이상 소송을 수행할 자격이 없다. 파산관재인 B는 법원에 수계신청을 하여 소송을 인계받아야 하며, 丁이 파산 사실을 숨기고 받은 판결은 절차상 중대한 하자가 있는 재판으로서 상소나 재심의 대상이 된다. 법원은 소송의 적법한 진행을 위해 당사자의 파산 여부를 엄격히 확인하여 파산관재인에 의한 절차 수행을 보장하여야 한다.

<제3편 제1심의 소송절차.제07장 증거.제01절 증거의 총설>

<제3편 제1심의 소송절차.제07장 증거.제03절 불요증사실>

<제3편 제1심의 소송절차.제07장 증거.제06절 증명책임>

[기출][2025-1-1]대여금 청구 소송에서 당사자 간 주장 및 증거 제출에 따른 법원의 판결 방향

《【문제1】 2022. 5. 1. 甲은 乙에게 금 8,000만 원을 이자 없이 1년의 기한으로 대여하였는데, 기한이 지나도록 乙이 돈을 갚지 않아 甲은 乙에게 대여금의 상환을 독촉하였다. 2023. 10. 15.이 되어서 乙은 “2022. 5. 1.에 차용한 돈을 2024. 10. 31.까지 甲에게 지급하지 못할 때 甲의 요구가 있으면 乙이 소장하는 고려청자(이하 '고려청자'라 함)를 甲에게 양도한다.”라는 각서(이하 '각서'라 함)를 써 주었다. 고려청자는 5,000만 원 정도로 평가된다. 2024. 11. 5. 甲은 乙에게 돈을 갚으라고 하였고, 乙은 묵묵부답이었다. 2025. 2. 1. 甲은 乙을 상대로 금 8,000만 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 소송에서 甲은 대여금 상환을 독촉하는 3통의 내용증명 우편을 증거로 제출하였다. (아래의 각 물음은 독립적이다.) (50점)

(물음1) 증거방법으로 제출된 내용증명에는 모두 甲이 乙에게 대여금 8,000만 원의 상환을 촉구하는 내용이 들어 있다. 乙은 사실이 아니라고 하면서 실제로 차용한 돈은 5,000만 원뿐이라고 주장하였다. 그것도 도박장에서 빌린 것이라고 주장하며 상환의무가 없다고 하였다. 甲은 乙의 항변에 대해 어느 것도 인정하지 않았다. 법원이 차용증을 제출하라고 하였으나, 甲은 분실하였다고 진술하였고, 乙은 애초부터 작성한 바가 없다고 하였다. 乙은 대여금의 액수가 5,000만 원이라는 증거로 자신이 기명날인한 각서의 사본을 제출하였다. 이에 甲은 그 원본의 존재 자체를 부정하였다. 이밖에 더 제출된 증거방법은 없다. 법원은 어떠한 판결을 하여야 하는지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 대여금 청구 소송에서 당사자 간 주장 및 증거 제출에 따른 법원의 판결 방향

I. 문제의 제기

- 사안은 甲이 乙을 상대로 8,000만 원의 대여금 청구소송을 제기하자 乙은 실제 차용액이 5,000만 원에 불과하고 이 또한 도박채무로서 무효라고 항변하며 각서 사본을 제출하였으나, 甲이 차용증을 분실한 채 각서 원본의 존재 자체를 부인하는 상황이다. 쟁점으로 **대여사실 및 대여액에 관한 원고의 증명책임과 내용증명 우편 및 서증 사본의 증거력 인정 여부, 그리고 피고의 반사회적 법률행위 항변의 실체법적 당부와 증명책임에 따른 최종적인 법원의 판결 형태**를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소송법상 증거조사와 실체법상 항변 법리를 종합하여 법원이 사안에서 내려야 할 구체적인 판결을 논한다.

II. 대여금 청구 및 도박채무 항변과 서증의 법리

1. 대여금 청구의 입증책임과 재판상 자백

(1) 대여금 청구의 요건사실과 입증책임

- 대여금 청구 소송에서 원고는 대여금 청구권의 발생요건인 ① 소비대차계약의 체결, ② 목적물인 금원의 교부, ③ 변제기의 도래 사실을 주장·입증하여야 한다. 한편, 원고가 제출한 내용증명 우편은 대여금의 상환을 독촉하는 최고의 사실을 증명할 뿐이며, 소비대차계약의 체결이나 금원의 실제 교부 사실을 직접 증명하는 서증으로 인정되기 어렵다.

(2) 재판상 자백의 성립과 효력

- 재판상 자백은 소송계속 중 당사자가 변론이나 준비절차에서 행한 상대방의 주장과 일치하고 자신에게 법률상 불이익한 사실의 인정 진술이다. 재판상 자백이 성립하면 당사자는 이를 임의로 철회할 수 없고, 법원 역시 자백의 구속력을 받아 자백된 사실을 그대로 판결의 기초로 삼아야 하므로 그 사실에 대해서는 별도의 증명을 요하지 않는다.

2. 도박채무 항변과 서증 사본의 증거력

(1) 반사회적 법률행위 항변의 입증책임

- **민법 제103조**에 의하여 도박자금으로 금전을 대여하는 행위는 반사회질서의 법률행위로서 무효이다. 대여금 청구 소송에서 채무가 반사회질서 법률행위에 해당하여 무효라는 주장은 실체법상 일종의 권리소멸(무효) 항변에 해당하므로, 그 요건사실에 대한 입증책임은 무효를 주장하여 이익을 얻는 피고가 부담한다.

(2) 서증 사본의 증거력과 원본 불존재 다름

- 서증을 제출할 때는 원본을 제출하는 것이 원칙이다. 사본을 제출한 경우 상대방이 원본의 존재 자체를 부정하거나 진정성립을 다투면, 사본 제출자는 원본의 존재와 진정성립 또는 사본의 정확성을 증명하여야 한다. 이를 증명하지 못하는 한, 제출된 사본은 독자적인 증거력을 가질 수 없어 판결의 기초로 삼을 수 없다.

III. 사안의 적용

1. 대여금 5,000만 원에 대한 판단

- 피고 乙은 실제로 차용한 돈이 5,000만 원이라고 진술하였는바, 이는 원고 甲의 8,000만 원 대여금 청구 주장 중 5,000만 원 범위 내에서 자신에게 불리한 사실을 인정한 것으로서 재판상 자백에 해당한다. 따라서 이 범위 내에서는 자백의 구속력에 의해 소비대차계약의 체결 및 금원 교부 사실이 증명 없이 인정된다. 한편, 乙은 이것이 도박채무이므로 무효라고 항변하였으나, 이에 대한 증거로 제출한 각서 사본은 甲이 원본의 존재를 부정함에도 乙이 원본의 실제 존재나 진정성립을 소명하지 못하였으므로 증거력이 없다. 결국 乙의 도박채무 무효 항변은 입증 부족으로 배척된다.

2. 대여금 나머지 3,000만 원에 대한 판단

- 원고 甲은 8,000만 원의 지급을 청구하나, 피고 乙은 5,000만 원을 초과하는 3,000만 원에 대해서는 대여 사실을 완전히 부인하고 있다. 甲은 대여금 청구의 입증책임자로서 3,000만 원의 교부 사실을 입증하여야 하나, 제출된 내용증명 3통은 단순 독촉 사실만 증명할 뿐 대여 사실을 직접 증명하지 못하며 차용증도 분실하여 더 이상 증거가 없다. 따라서 甲은 3,000만 원 부분에 대하여 입증책임을 다하지 못하였다.

IV. 결론

- 법원은 피고 乙의 재판상 자백으로 대여 사실이 인정되고 乙의 도박채무 항변이 배척된 5,000만 원 청구 부분에 대해서는 원고 甲의 청구를 인용하여야 한다. 반면, 甲이 대여 사실을 적법하게 입증하지 못한 나머지 3,000만 원 청구 부분에 대해서는 입증책임의 법리에 따라 청구를 기각하여야 한다. 결과적으로 법원은 ‘피고는 원고에게 금 5,000만 원을 지급하라. 원고의 나머지 청구를 기각한다.’라는 일부인용(일부기각) 판결을 선고하여야 한다.

<제3편 제1심의 소송절차.제07장 증거.제02절 증명의 대상>

[모의][7.02-1]재판상 자백의 성립 요건과 자백 취소의 허용 여부 및 요건

《【문제7.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 甲은 소장에서 "2023. 1. 1. 乙에게 1억 원을 이자 월 1%로 정하여 대여하였다"는 사실을 주장하였다. 이에 대하여 乙은 제1회 변론기일에 출석하여 "돈을 빌린 것은 맞지만 이미 전액 변제하였다"고 답변하였다. 이후 소송이 진행되던 중 乙은 제3회 변론기일에서 "사실은 돈을 빌린 적이 없으며, 이전의 진술은 착오에 의한 것이었다"고 주장하며 기존 진술을 취소하겠다고 의사 표시하였다.

한편, 丙은 도로 관리 주체인 지방자치단체 丁을 상대로 도로 파손으로 인한 자동차 파손 손해배상청구소송을 제기하였다. 丙은 사고 당시 해당 지역에 이례적인 폭우가 내려 도로가 유실되었음을 주장하였으나, 이에 관한 별도의 기상자료를 제출하지는 않았다. 丁은 그러한 폭우가 내린 사실이 없다고 다투고 있다. 또한, 이 사건 심리 중 법원은 해당 지역의 지적도와 토지대장의 내용 등 공공기관에 비치된 기록에 나타난 사실을 토대로 丙의 과실 여부를 판단하고자 한다.

(물음1) 乙이 제1회 변론기일에 행한 진술의 법적 성질을 "재판상 자백"의 요건과 관련하여 검토하고, 제3회 변론기일에서 행한 자백 취소의 허용 여부 및 그 요건에 대하여 판례의 태도를 근거로 논하시오.》

<문제7.2의 물음1> 재판상 자백의 성립 요건과 자백 취소의 허용 여부 및 요건

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 제기한 대여금 청구소송에서 乙은 처음에는 대여사실은 인정하면서 변제항변을 하였다가 이후 대여사실 자체를 부인하며 종전 진술을 취소한 상황이다. 쟁점으로 **진술이 재판상 자백에 해당하는지와 자백취소의 허용 여부**를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 재판상 자백의 성립요건과 그 법적 효력, 자백취소의 허용요건 및 판례의 태도를 논한다.

II. 재판상 자백의 성립 요건

1. 의의 및 대상

- 재판상 자백이란 변론 또는 기일에서 당사자가 상대방이 주장하는 자기에게 불리한 구체적 사실을 인정하는 진술이다. 자백의 대상은 원칙적으로 사실에 한하며, 법률적인 판단이나 권리관계에 대한 인정을 의미하는 것은 아니다.

2. 주요 요건

(1) 상대방의 주장과 일치할 것

- 상대방이 주장하는 사실과 당사자의 진술이 내용상 일치하여야 한다.

(2) 자기에게 불리한 사실의 인정일 것

- 자백이 성립하려면 당사자가 인정하는 사실이 그 당사자에게 불리한 것이어야 한다. 여기서 불리한 사실이란 상대방이 입증책임을 지는 사실을 의미하는 것이 통설 및 **판례**의 태도다.

(3) 구체적 사실에 관한 진술일 것

- 단순한 가치판단이 아니라 경험할 수 있는 구체적인 과거의 사실에 대한 인정이어야 한다.

III. 乙의 제1회 변론기일 진술의 법적 성질

1. 자백의 성립 여부 검토

- 사안에서 원고 甲은 1억 원의 대여 사실을 주장하였고, 피고 乙은 돈을 빌린 것은 맞다고 진술하였다. 이는 甲의 청구원인 사실을 乙이 그대로 시인한 것이며, 대여 사실의 입증책임은 원고인 甲에게 있으므로 乙에게는 불리한 사실에 해당한다. 따라서 乙의 진술 중 대여 사실에 관한 부분은 재판상 자백이 성립한다.

2. 이익불리진술과 항변의 구별

- 乙은 대여 사실을 인정함과 동시에 전액 변제하였다는 사실을 추가로 주장하였다. 이를 소송법상 재판상 자백과 항변이 결합된 형태인 행위적 자백 또는 가정적 자백의 관점에서 볼 수도 있으나, 일반적으로는 원고의 주장 사실을 인정(자백)하고 별개의 소멸 사유를 주장(항변)한 것으로 본다. 변제 사실은 乙에게 유리한 사실이므로 자백의 대상이 아니며, 오직 돈을 빌렸다는 부분에 대해서만 자백의 효력이 발생한다.

IV. 자백 취소의 허용 여부 및 요건

1. 원칙적 불가변성

- 재판상 자백이 성립하면 법원은 그 자백에 구속되어 그와 반대되는 사실을 인정할 수 없고, 당사자 역시 임의로 자백을 취소할 수 없는 것이 원칙이다.

2. 예외적 취소 요건 (판례의 태도)

- **민사소송법상** 자백의 취소는 다음의 경우에 한하여 예외적으로 허용된다.

(1) 상대방의 동의가 있는 경우

- 상대방이 자백의 취소에 동의하면 언제든지 취소할 수 있다.

(2) 자백이 진실에 어긋나고 착오로 말미암은 것임이 증명된 경우

- **판례**는 자백을 취소하려는 자가 자백이 진실에 반한다는 사실과 착오로 인한 것이라는 사실을 모두 증명하여야 한다고 본다. 이때 진실에 반한다는 사실이 증명되면 착오에 의한 자백임이 사실상 추정된다는 것이 **판례**의 완화된 입장이다.

(3) 형사상 처벌할 수 있는 행위에 의한 경우

- 자백이 제3자의 강박 등 형사상 처벌 대상이 되는 행위로 인하여 이루어진 경우 재심 사유에 준하여 취소가 가능하다.

V. 사안의 적용

1. 乙의 진술 반복의 효력

- 乙은 제3회 변론기일에 돈을 빌린 적이 없다며 기존의 자백을 취소하였다. 乙이 이 취소를 유효하게 하기 위해서는 단순히 착오였다고 주장하는 것만으로는 부족하며, 실제로 돈을 빌리지 않았다는 객관적 사실(진실에 반함)을 입증하여야 한다.

2. 판례에 근거한 판단

- 만약 乙이 금융거래 내역이나 계약서의 부존재 등을 통해 대여 사실이 없었음을 증명한다면, 특별한 사정이 없는 한 착오에 의한 자백으로 인정되어 취소가 허용될 수 있다. 그러나 증명을 하지 못한다면 자백의 구속력이 유지되어 법원은 대여 사실을 그대로 기초로 삼아 판결하여야 한다.

VI. 결론

- 乙이 제1회 변론기일에서 행한 진술 중 대여 사실에 관한 부분은 재판상 자백에 해당하여 법원과 당사자를 구속한다. 乙이 제3회 변론기일에서 이를 취소하기 위해서는 해당 자백이 진실에 반하고 착오에 의한 것임을 증명하여야 한다. 乙이 이를 성공적으로 증명할 경우에만 자백의 효력에서 벗어날 수 있으며, 그렇지 못할 경우 법원은 乙이 주장하는 변제 사실의 존부만을 심리하게 된다. 이는 소송의 안정성과 신의칙을 보호하기 위한 **민사소송법**상의 핵심적 원칙이다.

<제3편 제1심의 소송절차.제07장 증거.제02절 증명의 대상>

[모의][7.02-2]현저한 사실의 의의와 범위 및 이를 근거로 한 판결의 절차적 요건

《【문제7.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 甲은 소장에서 "2023. 1. 1. 乙에게 1억 원을 이자 월 1%로 정하여 대여하였다"는 사실을 주장하였다. 이에 대하여 乙은 제1회 변론기일에 출석하여 "돈을 빌린 것은 맞지만 이미 전액 변제하였다"고 답변하였다. 이후 소송이 진행되던 중 乙은 제3회 변론기일에서 "사실은 돈을 빌린 적이 없으며, 이전의 진술은 착오에 의한 것이었다"고 주장하며 기존 진술을 취소하겠다는 의사를 표시하였다.

한편, 丙은 도로 관리 주체인 지방자치단체 丁을 상대로 도로 파손으로 인한 자동차 파손 손해배상청구소송을 제기하였다. 丙은 사고 당시 해당 지역에 이례적인 폭우가 내려 도로가 유실되었음을 주장하였으나, 이에 관한 별도의 기상자료를 제출하지는 않았다. 丁은 그러한 폭우가 내린 사실이 없다고 다투고 있다. 또한, 이 사건 심리 중 법원은 해당 지역의 지적도와 토지대장의 내용 등 공공기관에 비치된 기록에 나타난 사실을 토대로 丙의 과실 여부를 판단하고자 한다.

(물음2) 사례에서 丙이 주장하는 폭우 사실과 법원이 인지한 지적도의 내용 등이 "현저한 사실"로서 증명을 요하지 않는 사항에 해당하는지 여부를 구분하여 설명하고, 이러한 사실을 근거로 판결하기 위해 필요한 절차적 요건을 기술하시오.》

<문제7.2의 물음2> 현저한 사실의 의의와 범위 및 이를 근거로 한 판결의 절차적 요건

I. 문제의 제기

- 사안에서 지방자치단체 丁을 상대로 도로파손으로 인한 자동차 파손 손해배상청구소송을 제기한 丙은 이례적인 폭우로 도로가 유실되었다는 사실을 주장하나 별도의 증거를 제출하지 않았고, 법원은 공공기관에 비치된 지적도와 토지대장의 내용을 기초로 판단하고자 하는 상황이다. 쟁점으로 폭우 사실과 지적도 등의 내용이 현저한 사실로서 증명을 요하지 않는 사항에 해당하는지와 이를 판결의 기초로 삼기 위한 절차적 요건을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 폭우 사실과 지적도 등의 내용이 현저한 사실에 해당하는지, 이를 판결의 기초로 하기 위한 절차적 요건을 기술한다.

II. 현저한 사실의 의의 및 종류

1. 의의

- 현저한 사실이란 법관이 증거조사를 거치지 않고도 그 존부를 확신할 수 있을 정도로 객관적으로 명백한 사실을 말한다. 이러한 사실은 증명을 요하지 않으므로 변론주의의 예외가 된다.

2. 종류

(1) 공지의 사실

- 일반 사회인에게 널리 알려져 있어 보통의 지식과 경험을 가진 사람이라면 누구나 의심하지 않을 정도로 알려진 사실이다. 예컨대 전쟁, 천재지변, 널리 알려진 역사적 사실 등이 이에 해당한다.

(2) 직무상 현저한 사실

- 법관이 그 직무 수행 과정에서 경험하여 알고 있는 사실로서, 명확한 기록 등에 의하여 증명 없이도 확신을 가질 수 있는 사실이다.

III. 사안에서의 현저한 사실 해당 여부 판단

1. 이례적인 폭우 사실 (공지의 사실 여부)

(1) 판단 기준

- 천재지변이나 기상 현상이 현저한 사실이 되기 위해서는 해당 지역 사회에서 누구나 알 수 있을 정도의 규모와 영향력을 가져야 한다.

(2) 사안의 경우

- 사안의 폭우가 이례적이고 도로가 유실될 정도의 대규모 재해였다면 공지의 사실로서 현저한 사실에 해당할 여지가 크다. 다만, 특정 일시와 국소적 지역에 내린 비의 양은 객관적 자료 없이 법관이 당연히 안다고 단정하기 어려우므로, 판례는 기상청의 관보나 기록 등에 의하여 확인되지 않는 한 원칙적으로 증명을 요하는 사실로 보는 경향이 있다.

2. 지적도와 토지대장의 내용 (직무상 현저한 사실 여부)

(1) 판단 기준

- 공공기관이 작성하여 보관하는 기록이라 하더라도, 법관이 당해 사건이나 과거에 취급한 사건을 통해 구체적으로 인지하고 있는 기록이 아니라면 단순히 비치되어 있다는 사실만으로 직무상 현저한 사실이라 할 수 없다.

(2) 사안의 경우

- 법원이 인지한 지적도나 토지대장의 내용은 공적 기록에 불과하며, 법관이 직무상 당연히 알고 있는 사실이라고 보기 어렵다. 판례 역시 관공서에 비치된 대장이나 도면의 기재 내용은 특별한 사정이 없는 한 현저한 사실로 보지 않으며 증거조사를 거쳐야 한다고 본다.

IV. 사실을 근거로 판결하기 위한 절차적 요건

1. 석명의무와 의견진술 기회의 부여

(1) 의의

- 법원이 현저한 사실을 판결의 기초로 삼고자 할 때에는 당사자가 예상하지 못한 불의의 판결을 받지 않도록 소송관계에 대하여 질문하거나 입증을 촉구하는 석명권을 행사하여야 한다.

(2) 절차적 요건

- 법원은 인지한 현저한 사실에 대하여 당사자에게 변론의 기회를 주어야 한다. 특히 당사자가 주장하지 않은 사실을 법원이 직권으로 인지하여 판결의 기초로 삼을 경우, 해당 사실의 존부와 그에 따른 법적 결과에 대해 당사자가 다룰 수 있도록 지적의무를 다하여야 한다.

2. 변론주의와의 관계

- 현저한 사실은 증명을 요하지 않으나, 사실의 주장 자체는 변론주의의 원칙상 당사자가 하여야 한다. 법원이 당사자가 주장하지도 않은 사실을 현저한 사실이라는 이유만으로 직권으로 도입하여 판결하는 것은 변론주의 위반이 될 수 있다. 따라서 법원은 당사자에게 해당 사실을 주장하도록 유도하거나, 최소한 그 사실에 대한 의견을 물어야 한다.

V. 결론

- 사안에서 이례적인 폭우 사실은 그 규모와 명백성에 따라 공지의 사실로서 현저한 사실이 될 수 있으나, 지적도나 토지대장의 기재 내용은 증거조사를 요하는 일반 사실로 보아야 한다. 법원이 이러한 사실들을 근거로 丙의 과실을 판단하기 위해서는 단순히 직권으로 인지하는 것에 그치지 않고, 변론기일에서 당사

자에게 해당 사실에 대한 지적을 함으로써 의견 진술과 반박의 기회를 부여하는 절차적 정당성을 확보하여야 한다. 이는 실체적 진실 발견과 당사자의 절차적 기본권 보장 사이의 조화를 꾀하기 위함이다.

<제3편 제1심의 소송절차.제07장 증거.제03절 불요증사실>

[기출][2011-2-2]재판상 자백의 의의, 성립요건, 자백의 구속력, 철회와 실효

《【문제2】 다음 문제를 설명하시오.

(물음2) 자백의 구속력 (25점)》

<문제2의 물음2> 재판상 자백의 의의, 성립요건, 자백의 구속력, 철회와 실효

I. 재판상 자백의 의의

- 재판상 자백이란 소송계속 중 당사자가 자기에 불리한 사실을 시인하는 진술을 말한다. 이는 변론주의 원칙상 법원을 구속할 뿐만 아니라 진술한 당사자 본인도 구속하는 효력을 가진다. **민사소송법 제288조**는 증명이 필요 없는 사실로서 자백을 규정하고 있다. 이러한 자백의 구속력은 소송의 안정성과 신의칙을 근거로 하며, 그 허용 범위와 예외적 철회 사유가 실무상 중요하다.

II. 재판상 자백의 성립요건

1. 대상의 적격성

(1) 사실에 관한 진술

- 자백의 대상은 구체적인 사실에 한정된다. 법률적용이나 권리관계에 대한 판단은 법원의 전권사항이므로 자백의 대상이 되지 않는다. 다만, 소유권과 같이 법률적 개념이 포함된 표현이라도 일상적 용어로 사용되어 사실관계의 시인을 의미하는 경우에는 자백이 성립할 수 있다.

(2) 자기에게 불리한 사실

- 진술한 당사자가 입증책임 지는 사실을 시인하는 것을 의미한다. **판례**는 입증책임의 소재를 기준으로 불이익 여부를 판단하나, 상대방이 주장하는 사실과 일치하는 진술이라면 입증책임 유무와 관계없이 자백으로 보는 견해도 존재한다.

2. 진술의 형태와 장소

(1) 소송계속 중 수소법원에 대한 진술

- 자백은 당해 소송절차의 변론기일 또는 변론준비기일에서 이루어져야 한다. 소외 자백이나 다른 소송사건에서의 진술은 재판상 자백이 아니며 단지 증거자료가 될 뿐이다.

(2) 상대방의 주장과 일치

- 당사자 일방의 진술이 상대방의 주장과 일치해야 한다. 만약 상대방의 주장과 일치하지 않는다면 선행자백에 불과하며, 상대방이 이를 원용할 때 비로소 재판상 자백이 성립한다.

III. 자백의 구속력

1. 법원에 대한 구속력(객관적 구속력)

- 법원은 당사자 사이에 합의된 자백의 내용에 구속된다. 따라서 법원은 자백된 사실과 반대되는 사실을 인정할 수 없으며, 증거조사를 통해 자백의 진위 여부를 확인해서도 안 된다. 만약 자백에 반하는 판결을 내린다면 이는 변론주의 위반으로 상소 사유가 된다.

2. 당사자에 대한 구속력(주관적 구속력)

(1) 의의

- 자백을 한 당사자는 임의로 이를 취소하거나 철회할 수 없다. 이는 상대방의 신뢰를 보호하고 소송절차의 지연을 방지하기 위함이다.

(2) 효력의 발생 시기

- 상대방이 원용하거나 처음부터 일치하는 진술을 한 시점부터 강력한 불가변적 효력이 발생한다.

IV. 자백의 철회와 실효

1. 예외적 철회 사유

(1) 상대방의 동의

- 상대방이 자백의 철회에 동의하는 경우에는 신뢰보호의 문제가 발생하지 않으므로 언제든지 철회할 수 있다.

(2) 착오 및 진실 반의 증명

- 자백이 진실에 어긋나고(진실 반), 착오로 말미암은 것임을 증명한 때에는 철회할 수 있다. **판례**는 자백이 진실에 반한다는 사실이 증명되면 착오로 인한 것임이 사실상 추정된다고 보아 입증책임을 완화하고 있다.

(3) 형사상 처벌되는 행위

- 자백이 제3자의 사기, 강박 또는 형사상 처벌받을 타인의 행위로 인하여 이루어진 경우에는 **민사소송법 제451조**의 재심사유에 준하여 철회할 수 있다.

2. 자백의 실효

- 소송의 취하, 청구의 변경 등으로 인하여 자백의 기초가 된 소송상태가 소멸하면 자백의 효력도 당연히 상실된다.

V. 결론

- 자백의 구속력은 변론주의 하에서 당사자의 처분권과 법원의 판단권을 조절하는 핵심 기제이다. 법원은 자백된 사실을 기초로 판단해야 하며, 당사자는 함부로 이를 뒤집을 수 없다는 점에서 소송의 예측가능성을 부여한다. 다만, 진실에 반하는 명백한 착오가 있는 경우까지 구속력을 고집하는 것은 실제적 진실 발견이라는 민사소송의 이념에 반할 수 있다. 따라서 **판례**는 철회 요건인 착오의 추정 범위를 넓게 인정함으로써 절차적 안정성과 구체적 타당성 사이의 균형을 도모하고 있다.

<제3편 제1심의 소송절차.제07장 증거.제03절 불요증사실>

[기출][2021-1-1]재판상 자백의 성립과 취소 및 공동소송인 독립의 원칙에 따른 판결의 가부

《【문제1】 甲은 乙에게 5,000만 원을 대여하였고, 丙은 乙의 대여금채무를 보증하였다. 乙이 변제하지 않자 甲은 5,000만 원을 반환받기 위해서 乙과 丙을 공동 피고로 하여, 乙에 대해서는 주채무의 이행을 구하고 丙에 대해서는 보증채무의 이행을 구하는 소를 제기하였다. 다음 물음에 답하십시오. (단, 아래의 각 물음은 상호 독립적임) (50점)

(물음1) 제1심 제1회 변론기일에 乙은 甲에게 대여금 5,000만 원을 모두 변제했다고 주장하였고, 이에 대해 甲은 그 중 2,000만 원을 반환받은 사실이 있다고 진술하였다. 그러나 제2회 변론기일에 甲은 종전의 진술을 철회하고, 乙로부터 전혀 변제받은 적이 없다고 주장하였다. 법원은 甲의 乙에 대한 청구 전부를 인용하는 판결을 할 수 있는가? (25점)》

<문제1의 물음1> 재판상 자백의 성립과 취소 및 공동소송인 독립의 원칙에 따른 판결의 가부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 乙과 丙을 상대로 대여금 및 보증채무의 이행을 구하는 소를 제기하였는데, 제1회 변론기일에서 2,000만 원의 일부변제를 인정하였다가 제2회 변론기일에서 이를 철회하며 전혀 변제받지 않았다고 주장한 상황이다. 쟁점으로 甲의 일부변제 인정 진술이 재판상 자백에 해당하는지, 그 철회가 허용되는지와 이에 따라 법원이 甲의 乙에 대한 청구 전부를 인용할 수 있는지를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲의 일부변제 인정 진술의 재판상 자백 해당 여부와 자백철회의 허용 여부 및 이에 따른 법원의 판단 가능 여부를 답한다.

II. 재판상 자백의 법리

1. 재판상 자백의 성립요건과 대상

(1) 재판상 자백의 개념 및 성립요건

- 재판상 자백이란 소송계속 중 당사자가 변론이나 준비절차에서 행한 상대방의 주장과 일치하고 자신에게 법률상 불이익한 사실의 인정 진술을 의미한다. 이는 대립하는 당사자 간의 원활한 심리 조율과 사적 자치의 원칙을 법원에 관철하는 소송법상 제도로서 반드시 변론기일 또는 변론준비기일에 행해져야 성립한다.

(2) 자백의 대상이 되는 사실

- 재판상 자백의 대상은 원칙적으로 구체적인 사실에 한하며, 법률적 평가나 의견 또는 권리관계의 존부는 제외된다. 또한 사실 중에서도 판결의 직접적인 법률 효과를 발생시키는 주요사실에 한하여 자백의 효력이 발생하며, 간접사실이나 보조사실에 대해서는 법원의 자유심증을 방해하지 않기 위해 원칙적으로 재판상 자백의 성립이 인정되지 않는다.

2. 재판상 자백의 효력과 철회의 제한

(1) 재판상 자백의 구속력

- 재판상 자백이 적법하게 성립하면 그 사실에 대해서는 더 이상 별도의 증명을 요하지 않는다.(민사소송법 제288조) 나아가 자백은 법원과 당사자 쌍방을 모두 구속하므로, 법원은 자백된 사실과 반대되는 사실을 인정하여 판결의 기초로 삼을 수 없으며, 당사자 역시 이를 마음대로 철회하여 다룰 수 없다.

(2) 자백 철회의 예외적 허용 요건

- 재판상 자백은 소송의 안정성을 위해 철회가 제한되지만, 당사자의 실질적 권리 구제와 구체적 타당성을 달성하기 위하여 다음과 같은 특별한 예외 조건에 부합할 때는 소송법상 철회가 허용된다.

① 상대방의 동의 또는 형사상 처벌받을 타인의 행위의 존재

- 자백 진술의 철회에 대하여 소송 상대방이 명시적으로 동의하였거나, 자백이 제3자의 기망이나 강박 등 형사상 처벌을 받을 수 있는 위법한 범죄행위에 의하여 유발되었음이 규명된 경우에는 자백을 철회할 수 있다.

② 착오로 인한 진술이고 진실에 반함의 증명

- 당해 자백이 객관적 진실에 정면으로 반할 뿐만 아니라, 그 자백을 한 당사자가 중대한 착오로 인하여 사실과 다른 진술을 하였음이 소송 과정에서 엄격하게 주장·증명된 경우에는 법원의 구속력을 배제하고 적법하게 철회할 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 甲의 일부 변제 수령 진술의 재판상 자백 성립 여부

(1) 자백 사실의 판단

- 사안에서 피고 乙은 대여금 5,000만 원 전액을 변제하였다는 권리소멸 항변을 제기하였으며, 이는 대여금 청구의 방어방법에 해당하는 주요사실이다. 이에 대하여 원고 甲이 '그 중 2,000만 원을 반환받은 사실이 있다'라고 변론한 것은, 乙이 주장한 변제 사실과 2,000만 원 범위 내에서 완벽히 일치하므로 대립하는 당사자 간의 주장 일치 요건을 충족한다.

(2) 불이익한 사실 인정

- 대여금 청구소송에서 이미 대금의 일부를 변제받았음을 직접 인정하는 진술은 원고 자신의 청구권의 범위를 감축시키는 법적 효과를 발생시키므로 甲에게 불이익한 사실의 인정에 해당한다. 따라서 甲의 진술은 2,000만 원의 범위 내에서 민사소송법상 적법한 재판상 자백으로 성립한다.

2. 甲의 진술 철회의 효력 및 법원의 판결

(1) 자백 철회의 효력 판단

- 원고 甲은 제2회 변론기일에 종전의 2,000만 원 변제 수령 진술을 철회하고자 하였다. 그러나 피고 乙이 이에 대하여 명시적으로 동의하였다거나, 甲의 자백이 타인의 형사상 처벌받을 행위에 매개되어 행해졌다는 사정은 전혀 보이지 않는다. 또한 甲은 자신의 선행 진술이 진실에 반하고 착오로 인한 것임을 입증하지도 못하였다. 따라서 甲의 진술 철회는 소송법상 요건을 결여하여 무효이며, 최초의 자백의 구속력은 소송절차 내에 유효하게 유지된다.

(2) 법원의 전부 인용 판결 가능성

- 수소법원은 자백의 구속력에 전적으로 귀속되므로, 자백된 2,000만 원의 변제 사실을 그대로 판결의 기초로 삼아야 하고 이와 반대되는 사실 인정을 할 수 없다. 따라서 법원은 청구금액 5,000만 원 중 자백에 의하여 이미 채무 소멸이 입증된 2,000만 원 청구 부분은 기각하고, 자백의 구속력이 미치지 않는 나머지 3,000만 원 청구 부분만 인용하여야 한다. 결과적으로 법원은 甲의 乙에 대한 청구 전부를 인용하는 판결을 할 수 없다.

IV. 결론

- 원고 甲의 2,000만 원 변제 수령 진술은 소송법상 재판상 자백에 해당하여 법원과 당사자에게 구속력을 미친다. 또한 甲이 행한 자백의 철회는 예외적 허용 요건을 전혀 갖추지 못하여 효력이 없다. 자백의 구속력에 의하여 2,000만 원 변제 사실이 확정되므로 법원은 甲의 대여금 청구 전부를 인용할 수 없으며, '피고 乙은 원고 甲에게 금 3,000만 원을 지급하라. 원고의 나머지 청구를 기각한다.'라는 일부인용(일부기각) 판결을 선고하여야 한다.

<제3편 제1심의 소송절차.제07장 증거.제04절 증거조사의 개시와 실시>

[기출][2013-3]문서제출명령의 의의, 대상과 범위, 신청과 심리, 불이행 효과

《【문제3】 문서제출명령에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 문서제출명령의 의의, 대상과 범위, 신청과 심리, 불이행 효과

I. 문서제출명령의 의의

- 문서제출명령이란 문서거증자가 상대방 또는 제3자가 소지하고 있는 문서를 증거로 제출하고자 할 때, 법원이 소지자에 대하여 그 문서의 제출을 명하는 재판을 말한다. 이는 현대 소송에서 증거의 편재 현상을 해소하고 진실 발견을 도모하기 위한 중요한 수단이다. **민사소송법**은 2002년 개정을 통해 문서제출의무를 일반 의무화하여 그 범위를 대폭 확대하였다.

II. 문서제출의무의 대상과 범위

1. 문서제출의무가 인정되는 경우

(1) 인용문서와 인도·열람청구권 있는 문서

- 당사자가 소송에서 인용한 문서를 소지하고 있는 때(**민사소송법 제344조 제1항 제1호**), 또는 거증자가 소지자에 대하여 그 문서를 넘겨달라고 하거나 보여달라고 요구할 수 있는 사법상의 권리를 가진 때(**동항 제2호**)에는 제출의무가 있다.

(2) 이익문서와 법률관계문서

- 문서가 거증자의 이익을 위하여 작성되었거나, 거증자와 소지자 사이의 법률관계에 관하여 작성된 때(**동항 제3호**)에도 제출의무가 인정된다.

2. 일반적 제출의무와 예외

(1) 일반적 제출의무

- 위의 사유에 해당하지 않더라도 문서가 증거조사의 대상이 되는 경우에는 원칙적으로 소지자에게 제출의무가 있다. (**제344조 제2항**)

(2) 제출거부사유

- 공무원의 직무상 비밀에 관한 문서로서 국가의 이익을 해칠 우려가 있는 경우, 자기 또는 친족이 형사소추를 당하거나 치욕을 입을 우려가 있는 사항이 적힌 경우, 직무상 비밀이 적힌 문서로서 비밀유지의무가 면제되지 않은 경우 등은 제출을 거부할 수 있다.

III. 문서제출명령의 신청과 심리

1. 신청 요건

(1) 신청의 방식

- 서면으로 신청해야 하며, 문서의 표시, 문서의 취지, 문서의 소지자, 증명할 사실, 문서제출의무의 근거 등을 명시해야 한다. (**제345조**)

(2) 문서의 특정

- 신청인은 원칙적으로 문서를 특정해야 한다. 다만, 신청인이 문서의 표시나 취지를 구체적으로 알기 어려운 경우에는 소지자에게 그에 관한 사항을 밝히도록 요구하는 서류의 사본 제출을 신청할 수 있다.

2. 법원의 심리와 결정

(1) 소지자의 신문

- 법원은 문서제출명령 신청이 있는 경우 원칙적으로 상대방이나 제3자인 소지자를 신문해야 한다.

(2) 인카메라(In-camera) 절차

- 문서가 제출거부사유에 해당하는지 여부를 판단하기 위해 법원은 소지자에게 그 문서를 제시하게 하여 비공개로 열람할 수 있다. 이를 통해 비밀을 보호하면서도 제출의무 유무를 객관적으로 판단한다.

IV. 문서제출명령 불이행의 효과

1. 당사자가 불응한 경우

- 당사자가 명령에 응하지 않거나, 상대방의 사용을 방해할 목적으로 문서를 멸실·훼손한 경우 법원은 그 문서에 관한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. (**제349조, 제350조**) 이는 증거평가의 자유를 제한하는 일종의 제재적 효과이다.

2. 제3자가 불응한 경우

- 문서를 소지한 제3자가 정당한 사유 없이 명령에 위반한 경우에는 법원은 결정으로 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다. (**제351조**) 당사자와 달리 제3자의 불응은 상대방의 주장 내용을 진실로 인정하는 사유가 되지 않는다.

V. 결론

- 문서제출명령은 증거를 독점하고 있는 당사자나 제3자로부터 증거를 현출시켜 재판의 공정성과 실체적 진실을 확보하는 데 기여한다. 특히 일반적 제출의무의 도입과 인카메라 절차의 활용은 소송 당사자의 입증 곤란을 완화하는 핵심적 기제로 작동하고 있다. 다만, 개인의 사생활이나 직무상 비밀이 침해될 우려가 있으므로 법원은 제출의무의 존부를 엄격히 판단하여 남용을 방지해야 하며, 불이행 시에는 법이 정한 제재를 엄격히 적용하여 실효성을 확보해야 한다.

<제3편 제1심의 소송절차.제07장 증거.제04절 증거조사의 개시와 실시>

[기출][2018-3]문서의 증거력의 의의, 형식적 증거력, 실질적 증거력, 증거력의 다툼과 법원의 판단

《【문제3】 문서의 증거력에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 문서의 증거력의 의의, 형식적 증거력, 실질적 증거력, 증거력의 다툼과 법원의 판단

I. 문서의 증거력의 의의

- 문서의 증거력이란 서증에 있어서 문서에 기재된 내용이 증거로서 가치(신빙성)를 가지는 정도를 의미한다. 이는 크게 문서가 당해 작성자에 의해 진정하게 성립되었는지를 다루는 형식적 증거력과, 진정하게 성립된 문서의 내용이 요건사실을 증명하는 데 얼마나 기여하는지를 다루는 실질적 증거력으로 구분된다.

민사소송법은 특히 문서의 성립에 관한 추정 규정을 두어 입증책임을 완화하고 있다.

II. 형식적 증거력(성립의 진정)

1. 의의

- 형식적 증거력이란 문서가 거명된 작성자의 의사에 기하여 작성된 것을 의미하며, 이를 성립의 진정이라고도 한다. 모든 문서는 증거로 사용되기 위해 먼저 형식적 증거력을 갖추어야 한다.

2. 성립의 진정에 관한 입증 및 추정

(1) 직접 입증

- 문서의 성립을 다투는 경우, 제출자는 증인신문이나 감정 등을 통해 해당 문서가 작성자의 인장이나 서명에 의해 작성되었음을 증명해야 한다.

(2) 민사소송법 제357조와 제358조

- 사문서는 당사자 또는 대리인의 서명이나 날인이 있는 때에는 진정한 것으로 추정한다. 공문서는 그 모양과 성질에 따라 공무원이 직무상 작성한 것으로 인정되는 때에는 진정한 것으로 추정한다.

(3) 인영의 진정에 의한 2층의 추정

- 판례는 문서에 찍힌 인영이 작성자의 인장에 의한 것이 증명되면, 그 인영은 작성자의 의사에 기해 찍힌 것으로 사실상 추정되고(1층 추정), 인영이 진정하면 민사소송법 제358조에 의해 문서 전체가 작성자의 의사에 따라 진정하게 성립된 것으로 법률상 추정된다(2층 추정)는 이론을 확립하고 있다.

III. 실질적 증거력

1. 의의

- 실질적 증거력이란 진정하게 성립된 문서의 기재 내용이 증거로서 사실인정에 기여하는 가치를 의미한다. 이는 법관의 자유심증에 맡겨져 있는 것이 원칙이다.

2. 문서의 종류에 따른 차이

(1) 처분문서

- 증명하려는 의사표시가 그 문서 자체에 의해 이루어진 경우(예 : 계약서, 차용증)를 말한다. 처분문서는 형식적 증거력이 인정되면 법관은 특별한 사정이 없는 한 그 기재 내용대로 법률행위의 존재를 인정해야 한다.

(2) 보고문서

- 작성자가 보고 들은 사실을 기재한 문서(예 : 일기, 장부, 편지)를 말한다. 보고문서는 형식적 증거력이 인정되더라도 법관이 다른 증거와 종합하여 그 내용의 진실성을 자유롭게 판단한다.

IV. 증거력의 다툼과 법원의 판단

1. 처분문서의 증거력 제한

- 처분문서라 할지라도 기재 내용과 다른 명백한 반증이 있거나, 기재 내용이 사회통념상 극히 이례적이라는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 그 증거력을 부정할 수 있다.

2. 문서의 변조와 증거력

- 문서의 일부가 변조되었다고 의심되는 경우, 법원은 변조된 부분의 증거력을 배제하고 나머지 부분의 진실성을 심리해야 한다.

V. 결론

- 문서의 증거력은 민사재판에서 사실관계를 확정하는 가장 강력한 수단이다. 특히, 서증의 형식적 증거력은 실질적 증거력의 전제조건이 되며, 민사소송법상 추정 규정과 인영에 관한 판례 법리는 입증의 곤란을 해소하는 핵심적 역할을 수행한다. 법원은 처분문서의 강한 증거력을 존중하되, 진실에 반하는 기재가 발견될 경우 자유심증을 통해 이를 적절히 배제함으로써 실체적 진실 발견과 절차적 정의를 조화시켜야 한다.

<제3편 제1심의 소송절차.제07장 증거.제04절 증거조사의 개시와 실시>

<제5편 병합소송.제11장 병합청구소송.제01절 청구의 원시적 병합>

[기출][2025-1-2]대여금 및 예비적 청구 소송에서 사문서의 진정성립 추정 및 예비적 병합의 심판순위에 따른 판결의 타당성

《【문제1】 2022. 5. 1. 甲은 乙에게 금 8,000만 원을 이자 없이 1년의 기한으로 대여하였는데, 기한이 지나도록 乙이 돈을 갚지 않아 甲은 乙에게 대여금의 상환을 독촉하였다. 2023. 10. 15.이 되어서 乙은 “2022. 5. 1.에 차용한 돈을 2024. 10. 31.까지 甲에게 지급하지 못할 때 甲의 요구가 있으면 乙이 소장하는 고려청자(이하 '고려청자'라 함)를 甲에게 양도한다.”라는 각서(이하 '각서'라 함)를 써 주었다. 고려청자는 5,000만 원 정도로 평가된다. 2024. 11. 5. 甲은 乙에게 돈을 갚으라고 하였고, 乙은 묵묵부답이었다. 2025. 2. 1. 甲은 乙을 상대로 금 8,000만 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 소송에서 甲은 대여금 상환을 독촉하는 3통의 내용증명 우편을 증거로 제출하였다. (아래의 각 물음은 독립적이다.) (50점)

(물음2) 乙은 甲의 청구에 대하여 금전을 차용한 적이 없다고 하였다. 차용증이 없느냐는 재판장의 물음에 甲은 이사하던 중에 분실된 것 같다고 하면서 乙이 기명날인한 각서를 제출하였다. 이에 乙은 5,000만 원의 차용을 인정하였다. 다음 기일에 甲은 차용증을 찾았으며 증거로 제출하였고, 고려청자의 인도를 구하는 청구를 예비적으로 병합하였다. 乙은 뒤늦게 가져온 차용증은 위조일 수밖에 없다고 항변하였다. 재판장이 차용증에 있는 당사자들의 인영이 진정해 보인다고 하자, 乙은 자기의 기명날인이 맞긴 하지만 대여금은 여전히 5,000만 원이었다고 주장하였다. 이밖에 더 제출된 증거방법은 없었다. 마침내 법원은 乙은 甲에게 고려청자를 인도하라는 판결을 내렸다. 이 판결에 대하여 평가하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 대여금 및 예비적 청구 소송에서 사문서의 진정성립 추정 및 예비적 병합의 심판순위에 따른 판결의 타당성

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 乙을 상대로 대여금 지급을 구하는 소송에서 각서와 차용증이 제출되고, 乙이 대여금 액수에 관하여 다투는 가운데 법원이 예비적으로 병합된 고려청자 인도청구를 인용한 상황이다. 쟁점으로 증거의 진정성립과 재판상 자백의 효력, 그리고 법원이 당사자의 주장 범위를 넘어 예비적 청구를 인용할 수 있는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 증거법상 사실인정의 기준과 변론주의 원칙에 따른 법원의 판단 범위를 설명한다.

II. 사문서의 진정성립 및 예비적 병합의 법리

1. 사문서의 진정성립의 추정

(1) 2단계의 추정

- 사문서의 진정성립을 인정하기 위해서는 날인행위의 진정함이 증명되어야 한다. 민사소송법 제358조에 따라 문서에 있는 날인이 당사자의 인영과 일치함이 인정되면, 당사자 본인 또는 대리인의 의사에 기하여 날인된 것으로 사실상 추정된다. 이후 날인행위의 진정이 인정되면 당해 사문서 전체의 진정성립이 법률상 추정되는바, 이를 2단계의 추정이라고 한다.

(2) 추정의 반복 요건

- 일단 2단계의 추정이 형성되면 그 인용이 위조되었다거나 본인의 의사에 반하여 날인되었다는 사실, 또는 내용이 사후에 위조·변조되었다는 사실에 대한 주장·증명책임은 이를 다투는 자에게 전도된다. 단순한 부인이나 심증 제기만으로는 진정성립의 추정을 깨뜨릴 수 없으며, 제반 사정에 대한 엄격한 증명 요구된다.

2. 예비적 병합의 심판순위와 처분권주의

(1) 주위적 청구 선험판단의 원칙

- 예비적 병합이란 원고가 양립할 수 없는 여러 청구를 제기하면서, 주위적 청구가 기각되거나 인용되지 않을 것에 대비하여 예비적 청구에 대한 심판을 구하는 소송 형태이다. 수소법원은 반드시 원고가 정한 심판 순위에 구속되므로, 주위적 청구에 대하여 먼저 심리·판단하여야 한다.

(2) 처분권주의와의 관계

- 민사소송법 제203조의 처분권주의에 따라 법원은 원고가 제기한 주위적 청구의 당부를 먼저 밝혀야 하며, 주위적 청구가 전부 인용되는 경우에는 예비적 청구에 대하여 심판할 수 없다. 만약 주위적 청구가 정당함에도 이를 배척하거나 판단하지 않고 예비적 청구만을 인용한 판결은 심판순위를 위배하여 처분권주의에 정면으로 저촉된다.

III. 사안의 적용

1. 차용증의 진정성립 여부 및 주위적 청구의 판단

(1) 2단계의 추정에 따른 진정성립 인정

- 피고 乙은 차용증 상의 기명날인이 자신의 것임을 직접 시인하였다. 이에 따라 2단계의 추정이 작용하므로, 해당 차용증은 성립의 진정이 적법하게 추정된다.

(2) 乙의 위조 항변의 배척 및 주위적 청구의 인용 범위

- 乙은 뒤늦게 차용증이 위조되었다고 항변하였을 뿐, 날인이 도용되었다거나 사후 변조되었다는 점에 대하여 아무런 증거도 제출하지 못하여 반복 요건을 충족하지 못하였다. 따라서 차용증에 적힌 대여금 8,000만 원은 진실한 요건사실로 인정되므로, 주위적 청구인 대여금 청구는 전액 인용되어야 마땅하다.

2. 예비적 청구 판단에 따른 판결의 위법성

(1) 심판순위 및 처분권주의 위배

- 원고 甲이 청구한 주위적 청구가 전액 인용되어야 하므로, 법원은 예비적 청구인 고려청자 인도 청구에 대하여는 심판을 진행할 수 없다. 그럼에도 주위적 청구를 판단하지 않거나 배척한 채 곧바로 고려청자 인도를 명한 것은 심판순위를 완전히 이탈한 재판이다.

(2) 대물변제 예약의 성부 판단 전제 흠결

- 가사 주위적 청구가 일부 기각된다 하더라도, 법원은 8,000만 원 중 인정되는 금액의 범위 내에서 이행을 명하고 예비적 청구를 판단해야 한다. 어떠한 경우라도 주위적 채무가 증명된 상태에서 주된 급부 대신 고려청자 인도를 명하는 것은 처분권주의에 정면으로 위배되어 부적법하다.

IV. 결론

1. 주위적 청구의 인용 정당성

- 피고 乙이 기명날인의 진정을 인정하고 위조 사실을 증명하지 못하였으므로, 2단계의 추정에 따라 8,000만 원 대여금 차용증의 진정성립이 인정되어 주위적 청구는 적법하게 인용되어야 한다.

2. 법원 판결의 위법성 및 결어

- 따라서 법원이 주위적 청구를 인용하지 않은 채 예비적 청구인 고려청자의 인도를 명한 판결은 사문서의 진정성립에 관한 법리를 오해하고 예비적 병합의 심판 순위 및 처분권주의를 심각하게 위반한 판결로서 전적으로 타당하지 않아 취소되어야 한다.

<제3편 제1심의 소송절차.제07장 증거.제05절 자유심증주의>

[기출][2010-1]대여금청구소송에서 금전대여사실의 존부 판단에 적용되는 자유심증주의의 원칙

《【문제1】대여금청구소송에서 당사자 간에 금전대여사실에 대하여 다툼이 있고 이에 관하여는 증거조사의 결과와 변론에서 나타난 각종 자료가 있다. 이를 기초로 법관이 위 금전대여사실주장이 진실한지 아닌지를 판단함에 있어서 적용되는 원칙에 관하여 논하시오. (50점)》

<문제1> 대여금청구소송에서 금전대여사실의 존부 판단에 적용되는 자유심증주의의 원칙

I. 문제의 제기

- 사안에서 대여금청구소송에서 금전대여사실에 다툼이 있어 증거조사 결과와 변론에서 나타난 여러 자료를 기초로 법관이 그 사실의 존부를 판단하여야 하는 상황이다. 쟁점으로 증거조사 결과와 변론 전체의 취지를 종합하여 사실을 인정하는 자유심증주의의 의의와 한계 및 사실인정의 기준을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 법관의 사실인정에 적용되는 자유심증주의의 내용과 한계 및 그 판단기준을 논한다.

II. 자유심증주의의 의의 및 내용

1. 자유심증주의의 의의

(1) 개념

- 민사소송법 제202조는 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 자유로운 심증으로 주장이 사실인지 아닌지를 판단한다고 규정하고 있다. 이는 증거의 채택과 증명력에 대한 평가를 법관의 전권에 맡기는 원칙이다.

(2) 근거

- 실제적 진실을 발견하기 위해서는 법관이 개별 사건의 특수성을 고려하여 유연하게 사실을 확정할 수 있어야 한다. 법정증거주의를 배제함으로써 법관의 양심과 전문성을 바탕으로 한 정당한 판결을 도모한다.

2. 심증형성의 자료

(1) 증거조사의 결과

- 증인신문, 감정, 서증조사 등 적법한 증거조사를 통해 얻어진 모든 결과를 의미한다. 증거력의 강약이나 증거의 가치 판단은 전적으로 법관의 자유로운 판단에 속한다.

(2) 변론 전체의 취지

- 증거조사 결과 외에 변론의 과정에서 나타난 당사자의 태도, 주장 제기의 시기, 상대방 주장에 대한 반응 등을 모두 포함한다. 이는 독립하여 심증형성의 기초가 될 수 있으나, 직접적인 증거가 있는 경우에는 그 보충적 수단으로 기능하는 것이 일반적이다.

III. 자유심증주의의 한계

1. 논리법칙과 경험법칙의 준수

(1) 논리법칙

- 판단 내용이 모순되지 않아야 하며 사고의 보편적 법칙에 부합해야 한다. 법관의 자의적인 추론이나 비논리적인 비약은 허용되지 않는다.

(2) 경험법칙

- 인간의 경험을 통해 축적된 일반적인 법칙을 의미한다. 대여금 소송에서 일반적으로 큰 금액을 대여할 때는 차용증을 작성한다는 식의 경험칙이 사실인정의 가이드라인이 될 수 있다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 이러한 일반적 경험칙을 배제할 수 있는 구체적 근거를 제시해야 한다.

2. 적법한 증거조사절차

- 자유심증은 적법한 절차를 거쳐 현출된 증거에 기초해야 한다. 당사자가 신청하지 않은 증거를 임의로 채택하거나, 증거능력이 없는 자료를 바탕으로 심증을 형성하는 것은 법률상 허용되지 않는다.

3. 이유설시의 의무

- 법관은 판결서에 심증을 형성하게 된 근거를 구체적으로 기재해야 한다. 사실인정의 과정을 투명하게 공개함으로써 자의적 판단을 방지하고 상급심의 검토가 가능하도록 한다.

IV. 사실인정의 구체적 운용과 보충적 원칙

1. 일응의 추정 및 간접사실

(1) 일응의 추정

- 직접적인 증거가 없더라도 경험칙상 어떤 사실이 존재할 확률이 매우 높을 때, 반증이 없는 한 그 사실을 인정하는 기법이다.

(2) 간접사실의 활용

- 금전 대여를 직접 입증할 차용증이 없더라도, 돈을 인출한 통장 내역, 이후 이자를 지급받은 사실 등 간접사실을 종합하여 주요사실인 대여 사실을 인정할 수 있다.

2. 증명책임의 원칙

- 법관이 가능한 모든 증거를 조사했음에도 불구하고 사실의 존부를 확정할 수 없는 상태(진위불명)에 빠진 경우, 그 사실이 없는 것으로 판단하여 불이익을 입게 되는 당사자의 부담을 증명책임이라 한다. 대여금 소송에서 대여 사실 자체는 원고(대주)가 증명책임을 진다.

V. 결론

- 자유심증주의는 법관의 자의를 허용하는 것이 아니라, 고도의 지적 활동을 통해 객관적 진실에 다가가려는 법적 장치이다. 법관은 대여금청구소송에서 나타난 각종 자료를 종합하여 논리적이고 합리적인 판단을 내려야 하며, 이는 현대 민사재판의 신뢰를 지탱하는 기둥이다. 특히 사실심의 전권사항으로서 자유심증은 존중되어야 하나, 상고심은 법관이 경험칙이나 논리법칙을 위반했는지 여부를 감시함으로써 그 한계를 통제한다. 결론적으로 자유심증주의는 증명책임 원칙과 상호 보충적인 관계를 유지하며, 사법 정의 실현을 위한 가장 유연하면서도 강력한 도구로서 기능한다.

<제3편 제1심의 소송절차.제07장 증거.제06절 증명책임>

[모의][7.06-1]법률상 추정 의의 및 사실상 추정과의 구별, 분류, 효과

《【문제7.6-1】 법률상 추정에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제7.6의 물음1> 법률상 추정의 의의 및 사실상 추정과의 구별, 분류, 효과

I. 법률상 추정의 의의 및 사실상 추정과의 구별

- 1. 법률상 추정의 의의
 - 법률상 추정이란 법률이 정한 규정에 따라 어떤 전제사실이 증명되면 이로부터 다른 추정사실 또는 권리관계의 존재를 당연히 인정하는 소송법상 제도를 말한다. 이는 실체법적 권리 보호와 증명곤란의 구제를 목적으로 한다.
- 2. 사실상 추정과의 구별
 - 사실상 추정은 법률의 명문 규정 없이 법관이 자유심증과 일반적인 경험칙에 의하여 전제사실로부터 추정사실을 추단하는 신빙성 평가의 영역이다. 반면 법률상 추정은 법률이 직접 전제사실과 추정사실 간의 인과적 연결을 규정하고 있으므로 법관의 자유심증이 제한된다는 점에서 구별된다.

II. 법률상 추정의 분류

- 1. 법률상 사실추정
 - 전제사실의 증명을 통해 다른 사실의 존재를 법률상 추정하는 경우를 말한다. 예를 들어 점유자가 점유 개시 시와 그 후의 어느 시점에 점유한 사실이 증명되면 그 사이의 점유는 계속된 것으로 추정하는 것(민법 제198조)이 이에 해당한다.
- 2. 법률상 권리추정
 - 어떤 사실의 증명을 통해 특정한 권리 또는 법률관계의 존재를 법률상 추정하는 경우이다. 동산의 점유자가 그 동산에 대하여 행사하는 권리는 적법하게 보유한 것으로 추정하는 것(민법 제200조)이나 부동산 등기의 추정력이 대표적이다.

III. 소송법상 효과 (증명책임의 전도 및 상대방의 반증 제시 의무)

- 1. 증명책임의 완화와 전도
 - 추정의 이익을 받는 당사자는 법률상 추정된 사실이나 권리 자체를 직접 증명할 필요가 없다. 단지 추정의 바탕이 되는 전제사실만을 증명하면 족하므로 입증의 곤란이 획기적으로 완화된다. 전제사실이 증명되면 추정사실에 대한 증명책임은 이를 닦는 상대방에게 전도된다.
- 2. 상대방의 방어 방법과 증명의 성질
 - (1) 전제사실에 대한 반증
 - 추정의 상대방은 추정의 기초가 되는 전제사실 자체를 부정하여 추정력의 발생을 차단할 수 있다. 전제사실은 상대방이 증명책임을 지는 것이 아니므로, 상대방은 이에 대해 법관에게 의심을 심어주는 수준의 반증만을 제시하면 족하다.
 - (2) 추정사실 또는 권리에 대한 본증
 - 전제사실이 확정된 경우 상대방이 추정의 효과를 깨뜨리기 위해서는 추정된 사실이나 권리가 실제로 존재하지 않음을 적극적으로 증명하여야 한다. 이는 상대방에게 증명책임이 전도된 결과이므로 단순한 의심 유발을 넘어 확실한 확신을 주는 본증을 제시하여야 한다.

IV. 결론

- 법률상 추정은 소송법상 증명의 어려움을 겪는 당사자를 구제하고 실체법상 권리관계를 두텁게 보호하기 위한 법정책적 조율 장치이다. 법원은 법률상 추정 규정을 엄격하게 해석하여 자의적인 사실 인정을 방지하되, 증명책임의 분배 원칙과 상대방의 방어 수단인 본증 및 반증의 체계를 유기적으로 조화시킴으로써 민사재판의 적정과 실체적 진실 발견을 균형 있게 달성해야 할 것이다.

<제4편 소송의 종료.제09장 당사자 행위에 의한 종료.제01절 소의 취하와 재소금지>

[기출][2015-3]재소의 금지의 의의, 요건, 적용 범위, 효과

《【문제3】 재소의 금지에 대하여 설명하십시오. (25점)》

<문제3> 재소의 금지의 의의, 요건, 적용 범위, 효과

I. 재소의 금지의 의의

- 재소의 금지란 본안에 대한 중국판결이 있는 뒤에 소를 취하한 사람은 같은 소를 제기하지 못한다는 원칙을 의미한다.(민사소송법 제267조 제2항) 이는 소 취하의 자유를 약용하여 법원을 농락하거나 상대방을 괴롭히는 행위를 방지하고, 국가 재판권의 권위를 유지하며 사법 자원의 낭비를 막는 데 그 목적이 있다. 재소금지는 기판력과 달리 소송계속 중의 행위인 소취하에 기해 발생하므로 실체적 권리 자체를 소멸시키는 것은 아니지만, 소송법상 적법한 소제기 권능을 박탈하는 효과를 가진다.

II. 재소금지의 요건

1. 주관적 요건(당사자의 동일성)

(1) 원칙

- 재소금지는 소를 취하한 원고와 그 피고 사이에 적용된다. 따라서 원고나 피고가 다른 경우에는 원칙적으로 재소금지가 적용되지 않는다.

(2) 예외

- 당사자가 동일하지 않더라도 민사소송법 제218조에 따른 기판력의 주관적 범위가 미치는 승계인 등에게는 재소금지의 효력이 미친다는 것이 판례의 태도이다. 또한 채권자대위소송에서 채무자가 소송계속 사실을 알았음에도 원고인 채권자가 중국판결 후 소를 취하했다면 채무자에게도 재소금지의 효력이 미친다.

2. 객관적 요건(소송물의 동일성)

(1) 동일한 소의 의미

- 재소금지에서 말하는 동일한 소란 전소와 후소의 당사자, 소송물 및 권리보호이익이 동일한 경우를 말한다. 소송법상 경제적 이익이 같더라도 소송물이 다르면 재소금지에 해당하지 않는다.

(2) 신청의 형태

- 전소가 이행의 소였으나 후소가 확인의 소인 경우처럼 소의 형태가 다르더라도 그 기초가 되는 권리관계가 동일하고 재소금지의 취지에 반한다면 동일한 소로 취급될 수 있다.

3. 시기적 요건(중국판결 후의 소취하)

(1) 중국판결의 존재

- 본안에 대한 중국판결이 선고된 이후여야 한다. 소간각하나 소송판결 후의 소취하는 재판권의 낭비가 없으므로 재소금지가 적용되지 않는다. 1심 판결 후뿐만 아니라 항소심 판결 선고 후 소를 취하한 경우도 포함된다.

(2) 소취하의 유효성

- 소취하가 유효하게 성립해야 한다. 만약 소취하가 무효이거나 취소된 경우에는 재소금지의 문제가 발생하지 않는다.

4. 권리보호이익의 동일성(새로운 사정의 유무)

- 후소를 제기할 정당한 사유나 새로운 사정이 발생한 경우에는 예외적으로 재소금지가 적용되지 않는다. 전소 취하 당시에는 예상할 수 없었던 사정 변경이 생겨 다시 소를 제기할 필요가 있는 경우가 이에 해당한다.

III. 재소금지의 적용 범위

1. 반소의 경우

- 피고가 본안에 대한 중국판결 후 반소를 취하한 경우에도 재소금지의 원칙이 적용되어 다시 반소를 제기하거나 별도로 청구할 수 없다.

2. 소의 변경

- 소의 변경 중 추가적 변경은 기존의 소를 유지하면서 새로운 청구를 보태는 것이므로 취하의 문제가 없으나, 교환적 변경은 구 청구의 취하와 신 청구의 제기가 결합된 것이므로 중국판결 후 교환적 변경을 하여 구 청구를 취하하게 되면 재소금지의 적용을 받는다.

IV. 재소금지의 효과

1. 소송법상 효과

- 재소금지의 요건에 해당하면 후소는 부적법하게 되며, 법원은 직권으로 이를 조사하여 판결로써 소를 각하하여야 한다. 이는 전속관할과 유사한 공익적 성격을 가지므로 당사자의 합의로도 재소금지의 효과를 배제할 수 없다.

2. 실체법상 효과

- 재소금지는 소송법상의 제재일 뿐이므로, 원고의 실체법상 권리 자체를 소멸시키는 것은 아니다. 따라서 원고는 소송 외에서 권리를 행사하거나 상계의 청구 등으로 대항하는 것은 가능하다.

V. 결론

- 재소금지의 원칙은 법원의 중국판결이 있는 후 소를 취하하여 판결을 무효화시킨 자에게 부과하는 강력한 소송법상 제재이다. 이는 소송 경제를 도모하고 사법 제도의 신뢰를 유지하기 위한 필수적인 장치이다. 그러나 당사자의 재판을 받을 권리를 본질적으로 제한하는 측면이 있으므로, 판례는 승계인에 대한 효력이나 새로운 사정 변경이 있는 경우 등 구체적 사안에서 재소금지의 범위를 합리적으로 해석하여 운영하고 있다. 실무적으로는 중국판결 후의 소취하가 가져올 불이익을 당사자에게 충분히 고지하여 신중한 절차 선택을 유도하는 것이 필요하다.

<제4편 소송의 종료.제09장 당사자 행위에 의한 종료.제01절 소의 취하와 재소금지>

[기출][2024-2]당사자가 변론기일의 지정을 신청할 수 있는 구체적인 경우

《【문제2】 당사자가 변론기일의 지정을 신청할 수 있는 경우에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 당사자가 변론기일의 지정을 신청할 수 있는 구체적인 경우

I. 변론기일의 의의

- 기일이란 법원, 당사자 또는 제3자가 소송절차를 진행하기 위하여 특정한 장소에 모여야 하는 시간적 구분을 의미한다. 변론기일의 지정은 원칙적으로 재판장의 직권사항에 해당하나(민사소송법 제165조 제1항), 예외적으로 당사자가 기일지정을 신청할 수 있는 권리가 인정되는 경우가 있다. 이는 절차의 정치상태를 해소하거나, 소송 종료의 효력을 다투는 등 당사자의 절차적 이익을 보호하기 위함이다.

II. 소송절차의 중단·중지의 해소

1. 소송절차 중단 사유의 소멸과 수계신청

- 당사자의 사망, 법인의 합병, 당사자의 자격 상실 등으로 인하여 소송절차가 중단된 경우, 새로운 당사자(상속인, 합병 후의 법인 등)가 소송을 수계하거나 상대방이 수계신청을 할 수 있다. 수계신청이 있으면 법원은 기일을 지정하여 소송절차를 속행해야 하므로, 이는 실질적으로 기일지정신청의 성격을 갖는다.

2. 소송절차 중지의 해소

- 법원의 결정에 의해 소송절차가 중지된 경우, 중지 사유가 소멸되었음에도 법원이 기일을 지정하지 않는다면 당사자는 기일지정신청을 통해 절차의 속행을 요구할 수 있다.

III. 소송종료선언을 위한 기일지정신청

1. 의의

- 소취하, 재판상 화해, 청구의 포기·인낙 등 소송이 종료된 것으로 처리되었으나, 당사자가 그 종료 효력을 다투는 경우에 행하는 신청이다. 소송이 유효하게 종료되었는지 여부를 확정하기 위해 변론을 열어달라는 취지이다.

2. 주요 신청 사유

(1) 소취하의 무효·취소 주장

- 원고가 소를 취하하였으나 그것이 제3자의 형사상 처벌받을 행위로 강요된 것이거나, 착오에 의한 것이라는 이유로 취하의 효력을 다투고자 할 때 당사자는 기일지정신청을 한다.

(2) 화해·포기·인낙의 무효 주장

- 재판상 화해나 청구의 포기·인낙이 조서에 기재됨으로써 확정판결과 동일한 효력이 발생하였으나, 그 절차에 중대한 흠이 있거나 무효 사유가 있다고 주장하는 경우 당사자는 기일지정신청을 통해 법원의 판단을 구할 수 있다.

(3) 소취하 간주에 대한 이의

- 당사자 쌍방이 2회 불출석하고 1개월 이내에 기일지정신청을 하지 않아 소가 취하된 것으로 간주되는 경우(민사소송법 제268조), 당사자가 불출석에 정당한 사유가 있었음을 주장하며 기일지정을 신청할 수 있다.

IV. 무변론판결 취소와 기일지정

1. 무변론판결 예정 통지 후 답변서 제출

- 피고가 기한 내에 답변서를 제출하지 않아 법원이 무변론판결을 선고하려 할 때, 판결 선고 전까지 피고가 답변서를 제출하며 변론을 요구하는 경우 법원은 변론기일을 지정해야 한다.

2. 판결선고기일 지정의 변경 신청

- 재판장이 직권으로 지정한 판결선고기일 이전에 당사자가 새로운 증거를 발견하거나 보충할 변론이 있어 변론재개신청과 함께 기일지정을 신청하는 경우, 법원은 필요하다고 판단하면 변론기일을 다시 지정할 수 있다.

V. 기일지정신청에 대한 법원의 처리

1. 심리 및 결정

- 기일지정신청이 있으면 법원은 소송절차가 유효하게 중단·종료되었는지를 심리한다. 만약 소송이 이미 유효하게 종료된 것으로 판단되면 소송종료선언 판결을 내리고, 소송이 종료되지 않았다고 판단되면 변론기일을 지정하여 본안 심리를 계속한다.

2. 신청의 각하

- 기일지정신청이 명백히 부적법하거나 이유 없는 경우에는 결정으로 신청을 각하할 수 있다. 그러나 소송 종료 효력을 다투는 기일지정신청의 경우 원칙적으로 판결로써 응답하는 것이 판례의 태도이다.

VI. 결론

- 변론기일지정신청권은 법원의 직권에 의한 기일 운영 원칙에 대한 중요한 예외로서, 당사자의 재판받을 권리를 실질적으로 보장하는 수단이다. 특히 소송 종료의 효력을 다투는 국면에서 기일지정신청은 소송계속을 부활시키고 법원의 공적 판단을 유도하는 필수적인 절차적 장치로 기능한다. 법원은 당사자의 신청 취지를 신중히 검토하여 부당하게 재판 절차가 지연되거나 조기에 종결되어 당사자의 권익이 침해되지 않도록 운영해야 한다.

<제4편 소송의 종료.제09장 당사자 행위에 의한 종료.제01절 소의 취하와 재소금지>

[기출][2025-3]재소의 금지의 의의, 요건, 예외, 효과, 특수한 경우의 재소금지

《【문제3】 재소의 금지에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제3> 재소의 금지의 의의, 요건, 예외, 효과, 특수한 경우의 재소금지

I. 재소의 금지의 의의

- 재소의 금지란 소송이 본안에 대한 종국판결이 있는 뒤에 소를 취하한 자는 동일한 소를 제기하지 못한다는 원칙을 말한다.(민사소송법 제267조 제2항) 이는 국가의 재판권 행사에 의하여 얻은 본안판결이 당사자의 무책임한 소취하로 인하여 농락당하는 것을 방지하고, 법원의 판결을 존중하며 소송경제의 효율성을 도모하기 위한 제도이다. 기판력과는 달리 판결의 확정 전이라도 종국판결 후 소를 취하하면 발생하며, 소송요건으로서 법원의 직권조사사항에 해당한다.

II. 재소금지의 요건★

1. 본안에 대한 종국판결이 있는 후일 것

- 재소금지가 적용되기 위해서는 적어도 제1심 또는 상소심에서 본안에 대한 종국판결이 선고된 이후여야 한다. 본안판결이란 청구의 당부에 관한 판결을 의미하며, 소각하 판결과 같은 소송판결은 포함되지 않는다.

2. 소의 취하가 있을 것

- 원고가 종국판결 선고 후 판결이 확정되기 전에 소를 취하하거나, 소취하 간주(민사소송법 제268조)가 성립해야 한다. 상소심에서 소를 취하한 경우 제1심 판결은 실효되나, 재소금지의 제재를 받게 된다.

3. 전소와 후소가 동일한 소일 것

- 재소금지의 효과를 받는 후소는 전소와 동일한 소여야 한다. 동일한 소인지 여부는 당사자, 소송물, 그리고 재소의 필요성이라는 관점에서 판단한다.

(1) 당사자의 동일

- 원칙적으로 전소의 원고가 후소의 원고인 경우를 의미한다. 다만, 전소 원고의 포괄승계인이나 소송담당에서의 채무자 등 실질적 이해관계가 동일한 자에게도 재소금지의 효력이 미친다.

(2) 소송물의 동일

- 전소와 후소의 소송물이 동일해야 한다. 다만, 청구취지가 다르더라도 소송물이 동일하거나, 전소의 기각을 면하기 위해 외형상 형태만 바꾼 경우 등은 동일한 소로 간주될 수 있다.

III. 재소금지의 예외 : 권리보호의 이익

1. 새로운 사정의 발생

- 종국판결 후 소를 취하했더라도 후소를 제기할 만한 정당한 사유가 있는 경우에는 재소금지에 저촉되지 않는다. 전소 취하 후에 발생한 새로운 사정으로 인하여 다시 소를 제기할 권리보호의 이익이 생긴 경우를 말한다.

2. 소권 행사의 오남용이 없는 경우

- 재소금지의 취지가 재판권의 오남용 방지에 있으므로, 당사자가 법원을 농락하려는 의사 없이 불가피한 사정으로 소를 취하했다가 다시 제기하는 경우에는 확인의 이익이나 재소의 필요성을 긍정하여 예외를 인정할 수 있다.

IV. 재소금지의 효과

1. 소송요건과 각하 판결

- 재소금지는 소송요건 중 하나이므로 법원은 이를 직권으로 조사하여야 한다. 재소금지에 위반된 소제기는 부적법하므로 법원은 본안에 대한 심리를 하지 않고 판결로써 소를 각하하여야 한다.

2. 기판력과의 구별

- 기판력은 판결의 확정을 요하나, 재소금지는 종국판결 후 소취하 사실만으로 발생한다. 또한 기판력은 본안판결의 내용을 존중하는 것이 목적이지만, 재소금지는 소취하에 의한 법원 농락 방지를 주된 목적으로 하는 제재적 규정이다.

V. 특수한 경우의 재소금지

1. 소의 변경과 재소금지

- 교환적 소변경의 경우 실질적으로 구소의 취하와 신소의 제기가 결합된 형태이므로, 종국판결 후 교환적으로 소를 변경한 경우 구소에 대해서는 재소금지의 원칙이 적용될 수 있다.

2. 독립당사자참가와 재소금지

- 독립당사자참가 소송에서 본안판결 후 원고가 소를 취하한 경우, 참가인의 청구와 관계없이 원고는 동일한 소를 제기할 수 없다. 이는 소송의 형태와 무관하게 제재적 성격이 유지되기 때문이다.

VI. 결론

- 재소금지 원칙은 당사자의 처분권주의를 존중하면서도 국가 재판권의 효율적 운영과 법적 안정성을 수호하기 위한 장치이다. 특히 종국판결이라는 국가적 노력이 투입된 이후의 소취하에 대해 엄격한 제재를 가함으로써 소송절차의 신의칙을 구현한다. 다만, 당사자의 정당한 권리 행사가 부당하게 위축되지 않도록 새로운 사정이나 재소의 필요성을 엄격히 해석하여 구체적 타당성을 확보하는 운용이 필요하다.

<제4편 소송의 종료.제09장 당사자 행위에 의한 종료.제02절 청구의 포기·인낙>

[모의][9.02-1]강박에 의한 청구인낙에 대한 불복 방법 및 그 요건

《【문제9.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 소송 진행 중 乙은 자신의 채무를 인정하고 조속히 분쟁을 종결하기 위해 제2회 변론기일에 출석하여 甲의 청구가 전부 정당함을 시인하는 "청구의 인낙" 의사를 표시하였다. 법원 사무관은 이를 변론조서에 기재하였고, 이에 따라 청구인낙조서가 작성되었다. 그런데 乙은 인낙조서가 작성된 후 2주가 지난 시점에서, 당시 자신이 극심한 궁박 상태에 있었으며 甲의 강박에 의해 어쩔 수 없이 인낙의 의사표시를 한 것이라고 주장하며 해당 조서의 효력을 다투고자 한다. 또한 乙은 위 대여금 채무가 이미 소멸시효가 완성되었음에도 불구하고 이를 간과하고 인낙하였다는 사실을 뒤늦게 깨달았다.

한편, 별개의 소송에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하였다. 丁은 변론기일에 출석하지 않고 미리 "청구의 인낙" 의사가 담긴 답변서를 제출하였으나, 해당 답변서에는 丁의 인감증명서가 첨부되어 있지 않았다. 법원은 丁이 출석하지 않은 상태에서 위 서면에 기재된 내용대로 청구인낙이 성립한 것으로 처리할 수 있는지 고민하고 있다.

(물음1) 청구의 인낙이 성립하기 위한 요건 중 "당사자의 처분권"과 관련하여, 강박에 의한 인낙의 의사표시가 있었을 경우 乙이 확정판결과 동일한 효력이 있는 인낙조서에 대하여 취할 수 있는 불복 방법 및 그 요건을 설명하시오.》

<문제9.2의 물음1> 강박에 의한 청구인낙에 대한 불복 방법 및 그 요건

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 대여금청구소송에서 청구를 전부 인낙하여 청구인낙조서가 작성된 후 강박에 의한 인낙과 소멸시효 완성 사실을 이유로 그 효력을 다투려는 상황이다. 쟁점으로 **청구의 인낙이 처분권주의의 대상이 되는 요건과 강박에 의한 인낙이 있는 경우 인낙조서에 대하여 취할 수 있는 불복방법 및 그 요건**을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 강박에 의한 청구인낙의 효력을 전제로 인낙조서에 대한 불복방법과 그 요건을 설명한다.

II. 청구인낙의 성립과 효력

1. 의의 및 성립요건

- 청구의 인낙은 피고가 원고의 청구권의 존재를 인정하는 법원에 대한 의사표시이다. 이는 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계에 관한 것이어야 하며, 그 의사표시가 변론조서 등에 기재됨으로써 성립한다.

2. 인낙조서의 효력

- **민사소송법 제220조**에 따라 청구의 인낙을 기재한 조서는 확정판결과 동일한 효력을 가진다. 따라서 기판력과 집행력이 발생하며, 더 이상 동일한 사안으로 다툴 수 없는 것이 원칙이다.

III. 인낙조서에 대한 불복 방법 (준재심의 소)

1. 준재심의 소의 의의

- **민사소송법 제461조**에 따라 재판상 화해나 청구의 인낙 등 확정판결과 동일한 효력이 있는 조서에 대하여, 재심 사유와 같은 중대한 하자가 있는 경우 그 효력을 다투기 위해 제기하는 소송이다.

2. 불복 방법의 한정성

- **판례**는 재판상 화해나 인낙조서에 기판력이 인정되므로, 그 조서가 당연무효인 사유(예 : 당사자의 부존재 등)가 없는 한 오로지 준재심의 소에 의해서만 그 효력을 다툴 수 있다고 본다. 따라서 乙은 별개의 소를 제기하거나 기판력을 무시할 수 없고 준재심을 제기하여야 한다.

IV. 준재심의 소의 요건

1. 재심 사유의 존재

- 준재심은 **민사소송법 제451조**가 규정한 재심 사유가 있어야 한다. 사안과 관련하여 다음의 사유가 검토된다.

(1) 제451조 제1항 제5호 (형사상 처벌 행위)

- 강박에 의해 인낙이 이루어진 경우, 그 강박행위가 형사상 처벌을 받을 수 있는 범죄행위에 해당하고 그에 관한 유죄의 확정판결이 있거나 증거부족 등의 이유로 확정판결을 얻을 수 없는 때에는 재심 사유가 된다.

(2) 의사표시의 하자 준용 여부

- **판례**는 소송행위에 **민법상** 의사표시 규정을 직접 적용하지는 않으나, 강박 등 중대한 의사형성의 하자는 준재심을 통하여 구제받을 수 있다고 본다. 다만, 소송절차의 안정을 위해 이를 재심 사유인 판결의 기초가 된 서류의 위조 등에 준하는 사유로 엄격히 해석한다.

2. 제척기간의 준수

- 준재심의 소는 재심 사유를 안 날로부터 30일 이내, 조서가 작성된 날로부터 5년 이내에 제기하여야 한다.

V. 사안의 적용

1. 乙의 불복 수단

- 乙은 인낙조서가 작성된 지 2주가 경과하였으므로, 30일의 단기 제척기간 내에 준재심의 소를 제기하여야 한다. 乙이 주장하는 강박은 **민법 제110조**에 해당하므로 소송행위의 취소 사유가 될 수 있다.

2. 요건 구비 여부

- 乙은 甲의 강박 행위가 형사상 처벌 대상임을 입증하거나, 소송행위 당시 의사결정의 자유가 완전히 박탈될 정도의 강박이 있었음을 증명하여야 한다. 단순히 소멸시효 완성을 간과했다는 실체법적 사유만으로는 준재심 사유가 되기 어려우나, 강박으로 인한 의사표시의 하자가 인정된다면 준재심을 통해 조서의 효력을 취소할 수 있다.

VI. 결론

- 乙은 확정판결과 동일한 효력을 가지는 인낙조서를 다투기 위해 **민사소송법 제461조**에 따른 준재심의 소를 제기하여야 한다. 이때 乙은 甲의 강박행위가 재심 사유에 해당함을 증명하여야 하며, 재심 사유를 안 날로부터 30일 이내에 소를 제기하여야 한다는 절차적 요건을 준수하여야 한다. 만약 준재심이 인용된다면 인낙조서의 효력은 소급하여 상실되고, 원래의 소송절차가 부활하여 대여금 채무의 존부를 다시 심리하게 된다.

<제4편 소송의 종료.제09장 당사자 행위에 의한 종료.제02절 청구의 포기·인낙>

[모의][9.02-2]서면에 의한 청구인낙의 성립 요건 및 기판력의 범위와 효력 부인

《【문제9.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 소송 진행 중 乙은 자신의 채무를 인정하고 조속히 분쟁을 종결하기 위해 제2회 변론기일에 출석하여 甲의 청구가 전부 정당함을 시인하는 "청구의 인낙" 의사를 표시하였다. 법원 사무관은 이를 변론조서에 기재하였고, 이에 따라 청구인낙조서가 작성되었다. 그런데 乙은 인낙조서가 작성된 후 2주가 지난 시점에서, 당시 자신이 극심한 공박 상태에 있었으며 甲의 강박에 의해 어쩔 수 없이 인낙의 의사표시를 한 것이라고 주장하며 해당 조서의 효력을 다투고자 한다. 또한 乙은 위 대여금 채무가 이미 소멸시효가 완성되었음에도 불구하고 이를 간과하고 인낙하였다는 사실을 뒤늦게 깨달았다.

한편, 별개의 소송에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하였다. 丁은 변론기일에 출석하지 않고 미리 "청구의 인낙" 의사가 담긴 답변서를 제출하였으나, 해당 답변서에는 丁의 인감증명서가 첨부되어 있지 않았다. 법원은 丁이 출석하지 않은 상태에서 위 서면에 기재된 내용대로 청구인낙이 성립한 것으로 처리할 수 있는지 고민하고 있다.

(물음2) 丁이 제출한 답변서에 의한 청구인낙의 가부(서면에 의한 인낙)와 관련하여 민사소송법 제148조 및 제248조의 취지를 검토하고, 청구인낙이 성립하였을 때 발생하는 기판력의 범위와 소멸시효 완성 등 실체법상 사유를 근거로 인낙조서의 효력을 부인할 수 있는지 여부를 기술하시오.》

<문제9.2의 물음2> 서면에 의한 청구인낙의 성립 요건 및 기판력의 범위와 효력 부인

I. 문제의 제기

- 사안에서 丁이 변론기일에 출석하지 않은 채 인감증명서가 첨부되지 않은 청구인낙 취지의 답변서를 제출한 상황에서 그 서면에 의한 청구인낙의 성립 여부와, 청구인낙조서의 효력을 실체법상 사유로 다투려는 상황이다. 쟁점으로 서면에 의한 청구인낙의 허용 요건과 인감증명서 첨부 필요 여부, 청구인낙 성립 시 발생하는 기판력의 범위 및 소멸시효 완성 등 실체법상 사유를 이유로 인낙조서의 효력을 부인할 수 있는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 서면에 의한 청구인낙의 성립 여부와 청구인낙 성립 시 기판력의 범위 및 실체법상 사유에 의한 인낙조서 효력 부인 가능성을 기술한다.

II. 서면에 의한 청구인낙의 성립 가부

1. 관련 규정의 취지

(1) 민사소송법 제148조 (진술간주)

- 당사자가 변론기일에 출석하지 아니하고 소장·답변서 그 밖의 준비서면을 제출한 때에는 그 서면에 기재된 사항을 진술한 것으로 본다. 다만, 화해·인낙 등 처분적 소송행위는 원칙적으로 구술에 의하여야 하므로 제148조만으로는 성립되지 않는다.

(2) 민사소송법 제248조 (서면에 의한 인낙 등)

- 2002년 개정 민사소송법은 소송계속 후 당사자가 청구의 인낙 취지가 적힌 서면을 제출하고 공증기관의 인증을 받거나 인감증명서를 첨부한 경우에는, 상대방이 기일에 출석하여 이를 원용함으로써 기일 불출석 상태에서도 인낙이 성립할 수 있도록 규정하였다.

2. 사안의 경우 (인감증명서 미첨부의 효과)

- 사안에서 丁은 답변서에 인감증명서를 첨부하지 않았다. 민사소송법 제248조 제1항은 본인의 의사를 명확히 확인하기 위해 인감증명서의 첨부 또는 공증을 필수적 요건으로 규정하고 있다. 따라서 丁이 기일에 불출석한 상태에서 인감증명서가 없는 답변서만으로는 청구인낙이 성립할 수 없으며, 법원은 이를 처리할 수 없다.

III. 인낙조서의 기판력과 실체법상 사유

1. 기판력의 발생 및 범위

(1) 발생 근거

- 청구인낙이 조서에 기재되면 확정판결과 동일한 효력이 발생한다.(민사소송법 제220조) 이에 따라 기판력이 발생하며, 당사자는 동일한 청구에 대하여 나중에 다시 다퉴 수 없다.

(2) 시적 범위

- 기판력은 원칙적으로 인낙의 의사표시가 조서에 기재된 시점을 기준으로 발생한다. 이 시점 이전에 존재하였던 모든 공격방어방법은 차단되는 차단효과가 발생한다.

2. 실체법상 사유에 의한 효력 부인 여부

(1) 소멸시효 완성 등의 사유

- 소멸시효 완성과 같은 실체법상 사유는 인낙 성립 이전에 존재하던 사정이다. 확정판결과 동일한 효력이 있는 조서에 대하여는 기판력의 차단효과 적용되므로, 인낙 이후에 '사실은 시효가 완성되었었다'는 사유를 내세워 조서의 효력을 다투는 것은 허용되지 않는다.

(2) 예외적 불복 방법

- 인낙조서의 효력을 부인하기 위해서는 당연무효 사유가 있거나, 존재심 사유가 있어야 한다. 단순히 실체법적 사실관계의 착오나 권리 소멸 사유를 뒤늦게 깨달았다는 것만으로는 존재심 사유에 해당하지 않으므로 효력을 부인할 수 없다.

IV. 사안의 적용

- 답변서에 인감증명서가 첨부되지 않았으므로 서면에 의한 인낙은 성립하지 않는다. 법원은 丁에게 보정을 명하거나, 기일에 출석하여 직접 의사를 표시하도록 유도하여야 한다.

V. 결론

- 서면에 의한 청구인낙은 당사자의 진정한 의사를 확인하기 위해 법정된 요건(인감증명서 첨부 등)을 엄격히 갖추어야 하므로, 丁의 답변서만으로는 인낙이 성립하지 않는다. 이는 소송절차의 안정과 확정된 권리관계의 존중이라는 민사소송법의 대원칙에 따른 결과이다.

<제4편 소송의 종료.제09장 당사자 행위에 의한 종료.제03절 재판상 화해>

[기출][2013-2]소송상 화해의 의의, 요건, 효력, 하자 구제수단

《【문제2】 소송상 화해에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 소송상 화해의 의의, 요건, 효력, 하자 구제수단

I. 소송상 화해의 의의

- 소송상 화해는 소송계속 중 양 당사자가 서로 양보하여 소송목적인 권리관계에 관한 다툼을 중단하고 소송을 종료시키기로 하는 합의를 말한다. 이는 소송의 주관적 해결방법으로서 판결에 의하지 않고 분쟁을 신속하게 종결짓는 기능을 한다. 소송상 화해가 성립하면 재판상 화해로서 확정판결과 동일한 효력을 가지게 되므로, 그 성립요건과 효력의 범위, 그리고 화해에 하자가 있는 경우의 구제책이 논의의 핵심이 된다.

II. 소송상 화해의 법적 성질 및 요건

1. 법적 성질

(1) 학설의 대립

- 소송상 화해의 성질에 대하여는 사법상의 화해계약으로 보는 사법행위설, 소송종료를 목적으로 하는 소송행위로 보는 소송행위설, 그리고 사법행위와 소송행위가 병존하는 것으로 보는 양성설(병행설) 등이 대립한다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 소송상 화해를 사법상의 화해계약인 동시에 소송법상의 소송행위라고 보고 있다. 다만, 일단 화해조서가 작성되면 확정판결과 같은 효력이 생기므로 사법상의 하자를 이유로 그 효력을 다툴 수 없고 준재심에 의해서만 취소할 수 있다고 보아 소송행위적 측면을 중시한다.

2. 성립 요건

(1) 당사자에 관한 요건

- 당사자에게 소송능력이 있어야 하며, 대리인의 경우 화해에 관한 특별수권이 있어야 한다.(민사소송법 제90조 제2항)

(2) 소송물에 관한 요건

- 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계여야 한다. 따라서 처분권주의가 적용되지 않는 친족·상속법상의 권리관계 등은 원칙적으로 화해의 대상이 될 수 없다.

(3) 시기 및 방식

- 소송이 법원에 계속 중이어야 하며, 당사자 쌍방이 법원에 출석하여 화해의 의사를 표시하고 이를 조서에 기재함으로써 성립한다.

III. 소송상 화해의 효력

1. 소송종료적 효력

- 소송상 화해가 성립하여 조서에 기재되면 소송은 그 즉시 당연히 종료된다. 이는 판결의 선고와 같은 효과를 지닌다.

2. 재판상 화해의 효력

(1) 확정판결과 동일한 효력

- 민사소송법 제220조에 의하여 화해조서는 확정판결과 동일한 효력을 가진다. 따라서 기판력과 집행력이 발생한다.

(2) 효력의 범위

- 기판력은 조서에 기재된 합의 사항에 한하여 발생한다. 판례는 화해조서의 기판력은 그 내용이 강행법규에 위반되거나 무효인 사유가 있더라도 준재심에 의해 취소되지 않는 한 당연무효라고 할 수 없다고 본다. 다만, 화해 내용이 특정되지 않거나 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 경우에는 효력이 부정될 수 있다.

IV. 화해의 하자 구제수단

1. 화해의 무효·취소와 준재심

(1) 준재심의 소

- 소송상 화해에 기망, 착오 등 사법상 하자나 소송법상 하자가 있는 경우, 당사자는 재심에 관한 규정을 준용하여 준재심의 소를 제기함으로써 그 효력을 다툴 수 있다.(민사소송법 제461조)

(2) 하자의 주장 시기

- 화해조서가 작성된 후에는 별소로써 무효를 주장하거나 취소할 수 없으며, 반드시 준재심 절차를 밟아야 한다. 이는 확정판결의 안정성을 유지하기 위함이다.

2. 기일지정신청

(1) 의의

- 화해의 성립 과정에서 중대한 절차적 하자가 있어 화해 자체가 성립하지 않았다고 주장하는 경우(예 : 당사자의 불출석 등), 당사자는 소송종료의 효력을 다투며 기일지정신청을 할 수 있다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 화해가 유효하게 성립한 경우에는 준재심으로 다투어야 하지만, 화해가 부존재하거나 당연무효인 경우에는 기일지정신청을 통해 원래의 소송절차를 속행할 수 있다고 본다.

V. 결론

- 소송상 화해는 당사자의 자주적 분쟁 해결을 존중하는 제도로서, 성립 시 확정판결과 동일한 강력한 효력을 부여받는다. 이는 분쟁의 종국적 해결을 도모하는 이점이 있으나, 하자가 있는 경우에도 준재심이라는 제한된 수단에 의해서만 구제가 가능하다는 점에 유의해야 한다. 따라서 화해 조서 작성 시 당사자의 의사를 명확히 반영하고 절차적 요건을 엄격히 준수하는 것이 소송경제와 실질적 정의 실현을 위해 필수적이다.

<제4편 소송의 종료.제10장 중급판결에 의한 종료.제02절 판결>

[기출][2017-3]변론종결 뒤의 승계인의 의의 및 요건, 학설 및 판례, 기판력의 범위와 한계

《【문제3】 변론종결 뒤의 승계인에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 변론종결 뒤의 승계인의 의의 및 요건, 학설 및 판례, 기판력의 범위와 한계

I. 기판력의 주관적 범위

- 민사소송법 제218조 제1항은 확정판결의 기판력이 당사자뿐만 아니라 변론을 종결한 뒤의 승계인에게도 미친다고 규정하고 있다. 이는 판결의 실효성을 확보하고 소송경제를 도모하기 위한 것으로, 소송계속 중 목적물이 이전되었으나 이를 알지 못하고 판결이 확정된 경우에도 그 효력을 승계인에게 확장하려는 취지이다. 이때 승계인의 범위와 그들에게 기판력이 미치는 근거 및 한계에 대하여 학설과 판례의 대립이 존재한다.

II. 승계인의 의의 및 요건

1. 승계인의 의의

- 승계인이란 소송물인 권리·의무 자체를 승계한 사람뿐만 아니라, 소송물인 법률관계에 관한 분쟁의 대상인 물건의 점유를 승계한 사람을 포함한다. 변론종결 뒤라고 함은 변론종결 후부터 판결 확정 후까지를 모두 포함하는 개념이다.

2. 승계의 유형

(1) 일반승계

- 당사자의 사망으로 인한 상속이나 법인의 합병 등 포괄적인 권리·의무의 승계가 이에 해당한다.

(2) 특정승계

- 매매, 증여, 채권양도 등 개별적인 원인에 의하여 소송물 또는 목적물의 점유를 이전받은 경우를 의미한다.

III. 승계인의 범위에 관한 학설 및 판례

1. 소송물승계설

- 승계인이 기판력을 받기 위해서는 소송물인 권리·의무 자체를 승계해야 한다는 견해이다. 이 학설에 따르면 물권적 청구권 소송에서 목적물을 양수한 자는 승계인에 해당하지만, 채권적 청구권 소송에서 목적물을 양수한 자는 소송물인 채권 자체를 승계한 것이 아니므로 승계인에 해당하지 않는다고 본다.

2. 적격승계설(판례의 태도)

(1) 학설의 내용

- 당사자 적격의 근거가 되는 지위를 승계한 자를 승계인으로 보는 견해이다. 소송물인 권리·의무뿐만 아니라 그 바탕이 된 실체법상의 지위나 목적물의 점유를 승계함으로써 소송 수행의 적격을 이어받은 자를 포함한다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 원칙적으로 적격승계설의 입장에서 소송물이 채권적 청구권인 경우에도 목적물의 저촉 여부에 따라 승계인 범위를 판단한다. 다만, 채권적 청구권 소송에서의 목적물 양수인을 승계인으로 인정하는 데 있어 소송물승계설보다 넓은 범위를 인정하는 경향이 있다.

IV. 승계인에게 기판력이 미치는 범위와 한계

1. 고유한 방어방법이 없는 경우

- 승계인은 전 당사자가 가졌던 모든 권리·의무의 상태를 그대로 물려받는다. 따라서 전 당사자가 이미 행사하였거나 행사할 수 있었던 방어방법에 대해서는 기판력의 차단효를 받게 되어 더 이상 다툴 수 없다.

2. 고유한 방어방법이 있는 경우

(1) 의의

- 승계인이 전 당사자로부터 승계한 사실과는 별개로, 본인만이 독자적으로 주장할 수 있는 실체법상 권리가 있는 경우를 말한다. 예컨대 선의취득이나 목적물에 대한 독립적인 권원 취득 등이 이에 해당한다.

(2) 판례의 판단

- 판례는 승계인이 고유한 방어방법(예 : 선의취득)을 가진 경우에는 그 범위 내에서 기판력의 구속을 받지 않는다고 본다. 이는 승계인의 절차적 보장을 위한 당연한 한계이다.

V. 결론

- 변론종결 뒤의 승계인에 대한 기판력 확장은 판결의 효력을 무력화하려는 시도를 방지하고 분쟁의 일회적 해결을 가능하게 하는 중요한 제도이다. 우리 판례는 적격승계설에 기초하여 승계인의 범위를 유연하게 확장함으로써 실효성을 확보하면서도, 승계인 자신의 고유한 방어방법이 있는 경우에는 그 효력을 제한하여 제3자의 권리 보호를 도모하고 있다. 특히 실무상 강제집행의 단계에서 승계집행문을 부여받기 위한 요건으로서 승계인의 지위는 매우 엄격히 검토되어야 한다.

<제4편 소송의 종료.제10장 중국판결에 의한 종료.제02절 판결>

[기출][2019-1-2]확정판결의 기판력과 표준시 이후의 상계권 행사 가능성

《【문제1】 甲은 乙에 대하여 지급기일을 2017. 2. 1.로 하는 1억 원의 공사대금채권을 가지고 있었다. 乙은 2017. 10. 1. 이 채권금액 가운데 3,000만 원을 변제하였다. 甲은 2018. 4. 1. 乙에 대하여 위 공사대금 1억 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 법원은 2018. 12. 1. 변론을 종결하고 甲의 청구대로 1억 원의 지급을 명하는 판결을 선고하였고, 그 판결은 확정되었다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 乙은 甲에 대하여 2018. 5. 1.을 지급기일로 하는 대여금 2,000만 원의 채권을 가지고 있었으나 상계항변을 하지 않았다. 乙이 2019. 7. 1.에 이 채권을 가지고 상계할 수 있는지를 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음2> 확정판결의 기판력과 표준시 이후의 상계권 행사 가능성

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 공사대금 청구소송 계속 중 이미 변제기가 도래한 자신의 대여금채권을 가지고도 상계항변을 하지 않은 채 甲 승소의 확정판결이 이루어진 후 다시 그 채권으로 상계하려는 상황이다. 쟁점으로 확정판결의 기판력이 변론종결 전 존재하였으나 행사하지 않은 상계권의 행사에 미치는 효력과 판결 확정 후 상계의 허용 여부를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 변론종결 전 발생한 상계권에 대한 실권효의 적용 여부와 판결 확정 후 乙의 상계 가능 여부를 논한다.

II. 기판력의 시적 범위와 차단효

1. 기판력의 표준시

- 기판력은 무한정 인정되는 것이 아니라 특정 시점의 권리관계를 확정하는 것이다. 민사소송법상 사실심 변론종결 시를 기준으로 하며, 이를 기판력의 표준시라고 한다. 표준시 이전에 발생한 사유는 이후의 소송에서 더 이상 다룰 수 없게 되는데 이를 기판력의 차단효 또는 실권효라 한다.

2. 차단효의 범위

- 당사자는 표준시 이전에 존재했던 모든 방어방법을 소송 절차 내에서 제출했어야 한다. 이를 게을리하여 판결이 확정된 경우, 설령 그 사유가 진실이라 하더라도 판결의 효력을 부정하는 주장을 할 수 없다.

III. 상계권 행사의 특수성과 차단효의 적용 여부

1. 학설의 대립

(1) 부정설(비차단설)

- 상계권은 소송상의 방어방법일 뿐만 아니라 실체법상 독립된 형성권이므로, 소송에서 행사하지 않았더라도 그 권리 자체가 소멸하는 것은 아니라고 본다. 따라서 판결 확정 후에도 상계권을 행사하여 집행력 배제를 구할 수 있다는 견해이다.

(2) 긍정설(차단설)

- 변제나 상계나 모두 채권의 소멸을 가져오는 방어방법이라는 점에서는 동일하다. 소송 절차의 안정을 위해 표준시 전에 행사가 가능했던 상계권을 행사하지 않았다면 차단효가 발생한다고 보는 견해이다.

2. 판례의 태도

- 대법원은 상계권의 행사가 소송 외에서 이루어지든 소송 내에서 이루어지든, 그것이 표준시 이전에 행사가 가능했던 것이라면 기판력의 차단효가 발생한다고 본다. 즉, 채무자가 전소 변론종결 전에 상계 적상에 있었던 채권을 가지고 있었다면, 이를 소송에서 주장하지 않았을 경우 판결 확정 후에 다시 상계권을 행사하여 전소 판결의 집행력을 배제하는 것은 허용되지 않는다는 입장이다.

IV. 사안의 적용

1. 상계 적상의 시점 확인

- 사안에서 피고 乙의 대여금 채권은 2018. 5. 1.이 지급기일이다. 甲이 제기한 소송의 변론종결일은 2018. 12. 1.이므로, 乙은 변론종결 전인 2018. 5. 1.부터 이미 상계 적상에 있었으며 소송 절차 내에서 상계 항변을 할 수 있는 상태였다.

2. 상계권 행사의 제한

- 乙은 충분히 상계 항변을 할 수 있었음에도 불구하고 이를 하지 않은 채 판결이 확정되도록 방치하였다. 판례의 확립된 견해에 따르면, 표준시(2018. 12. 1.) 이전에 발생한 상계 사유는 기판력에 의해 차단된다. 따라서 乙이 2019. 7. 1.에 이르러 전소 판결에 의한 채무를 면하기 위해 상계를 주장하는 것은 기판력에 저촉되어 허용되지 않는다.

V. 결론

- 피고 乙은 2019. 7. 1.에 상계권을 행사하여 甲에 대한 공사대금 채무를 소멸시킬 수 없다. 비록 乙이 2,000만 원의 진정한 채권을 가지고 있다 하더라도, 이는 전소의 변론종결 전에 이미 행사가 가능했던 방어방법이므로 기판력의 차단효에 의해 행사가 제한되기 때문이다. 乙은 상계권 행사 대신 甲을 상대로 별도의 대여금 반환 청구 소송을 제기하여 자신의 채권을 회수해야 할 것이며, 이미 확정된 공사대금 1억 원의 판결에 대해서는 상계를 이유로 다툴 수 없다.

<제4편 소송의 종료.제10장 중국판결에 의한 종료.제02절 판결>

[기출][2022-3]판결의 편취의 의의, 유형, 확정 전·후 구제수단

《【문제3】 판결의 편취와 그 구제수단에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 판결의 편취의 의의, 유형, 확정 전·후 구제수단

I. 판결의 편취의 의의

- 판결의 편취란 당사자가 부정한 방법으로 법원을 기망하여 자기에게 유리한 판결을 얻어내는 것을 의미한다. 이는 재판의 공정성을 심각하게 훼손하는 행위이나, 일단 판결이 확정되면 기판력이 발생하므로 그 효력을 부인하기 위해서는 특별한 구제절차가 필요하다. 특히 상대방이 소송계속 사실을 알지 못한 상태에서 판결이 확정된 경우, 권리를 침해당한 당사자를 어떻게 보호할 것인가가 핵심이다.

II. 판결 편취의 유형

1. 성명모용에 의한 판결

- 피고와 아무런 관계가 없는 사람이 피고의 이름을 사칭하여 소송을 수행하고 판결을 받는 경우이다.

2. 주소허위기재에 의한 판결

- 원고가 피고의 주소를 허위로 기재하여 송달이 불가능하게 하거나, 피고가 아닌 다른 사람이 서류를 받게 하여 피고가 소송 사실을 모르는 상태에서 승소 판결을 얻는 경우이다.

3. 공시송달의 남용

- 피고의 주소를 알고 있음에도 불구하고 주소불명으로 허위 신고하여 공시송달을 통해 판결을 편취하는 경우를 말한다.

III. 확정 전의 구제수단

1. 상소의 제기

- 판결이 선고되었으나 아직 확정되기 전이라면 통상의 상소(항소 또는 상고)를 통해 판결의 부당함을 다툴 수 있다.

2. 추완항소 [민사소송법 제173조]

- 피고가 책임질 수 없는 사유로 인하여 항소기간을 지키지 못한 경우, 그 사유가 없어진 날로부터 2주 이내에 항소를 제기할 수 있다. 주소허위기재나 공시송달 편취의 경우 피고가 판결 사실을 뒤늦게 알게 되므로 추완항소가 주된 구제책이 된다.

IV. 확정 후의 소송법적 구제수단

1. 재심의 소 [민사소송법 제451조]

- 판결이 확정된 후에는 재심 사유를 들어 재심의 소를 제기할 수 있다.

(1) 대리권의 흠결 [제3호]

- 성명모용 판결의 경우 대리권의 흠결을 이유로 재심을 청구할 수 있다.

(2) 형사상 처벌받을 범죄행위(허위 진술 등) [제11호]

- 상대방의 기망행위가 형사상 처벌받을 범죄행위에 해당하는 경우 이를 이유로 재심을 제기할 수 있다.

2. 판례의 태도(무효선언설)

- 판례는 성명모용 판결과 같이 절차상 중대한 하자가 있는 경우, 그 판결은 기판력이 발생하지 않는 무효인 판결이라고 본다. 따라서 재심 절차 없이도 별도의 소송을 통해 권리관계를 다툴 수 있다고 본다. 반면 주소허위기재에 의한 판결은 일단 유효하므로 반드시 상소나 재심으로 취소되어야 한다고 본다.

V. 집행 단계 및 실체법적 구제수단

1. 청구이의의 소 [민사집행법 제44조]

- 편취된 판결에 기초하여 강제집행이 들어오는 경우, 피고는 판결에 나타난 청구권이 실체법상 존재하지 않음을 이유로 청구이의의 소를 제기하여 집행력을 배제할 수 있다. 다만, 판례는 기판력의 차단효 때문에 전소 판결을 취소하지 않은 상태에서 청구이의의 소를 제기하는 것에는 소극적이다.

2. 손해배상청구 및 부당이득반환청구

- 판결을 편취한 자를 상대로 불법행위에 기한 손해배상을 청구하거나, 그 판결로 얻은 이익에 대해 부당이득반환을 청구할 수 있다. 판례는 판결이 취소되지 않았더라도 그 판결을 집행하는 것 자체가 사회통념상 허용되지 않는 경우 불법행위 구성을 인정한다.

VI. 결론

- 판결의 편취는 기판력이라는 법적 안정성과 구체적 정의가 충돌하는 영역이다. 법원은 주소허위기재 등 절차적 하자의 경중에 따라 판결의 유효·무효를 구별하고, 추완항소나 재심과 같은 소송법적 구제수단을 우선적으로 활용하도록 하되, 이것이 불가능한 경우 실체법적 구제수단을 보완적으로 인정하여 피해자를 보호하고 있다.

<제4편 소송의 종료.제10장 중급판결에 의한 종료.제02절 판결>

[기출][2023-1-2]상계의 항변이 판단된 판결이 확정된 후 자동채권 소구의 적법성 및 기판력의 범위

《【문제1】 甲은 乙을 피고로 매매대금채권 5천만 원의 지급을 구하는 소(이하, 'A소'라 한다)를 제기하였다. 이 소송에서 乙은 甲에 대하여 갖고 있는 대여금채권 6천만 원(이하, '이 사건 대여금채권'이라 한다)을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장하였다. 다음 물음에 답하시오. (다만, 아래의 각 물음은 독립적임) (50점)》

(물음2) 甲이 제기한 A소에서 乙이 이 사건 대여금채권을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장하였고, 법원은 甲의 채권과 乙의 채권이 모두 인정된다고 판단하여 甲의 청구를 기각하는 판결을 선고하였다. 이 판결이 확정된 후 乙은 甲을 피고로 상계의 항변으로 주장한 이 사건 대여금채권의 반환을 구하는 소를 제기할 수 있는가? (30점)》

<문제1의 물음2> 상계의 항변이 판단된 판결이 확정된 후 자동채권 소구의 적법성 및 기판력의 범위

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 제기한 매매대금청구소송에서 乙은 자신의 대여금채권을 자동채권으로 하는 상계항변을 하였고 법원이 양 채권을 모두 인정하여 청구기각 판결이 확정된 후 乙이 다시 그 대여금채권에 기한 반환청구소송을 제기하려는 상황이다. 쟁점으로 상계항변에 관한 판단에 인정되는 기판력의 범위와 상계의 자동채권에 대한 판단이 후소에 미치는 효력을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 상계항변에 관한 판단의 기판력과 이를 전제로 한 乙의 대여금반환청구소송의 적법 여부를 설명한다.

II. 상계의 항변에 대한 기판력의 범위

1. 상계항변과 기판력의 범위 [민사소송법 제216조]

(1) 기판력의 원칙

- 기판력은 주문에 나타난 소송물에 한하여 발생하며 판결 이유 중의 판단에는 미치지 않는 것이 원칙이다.

(2) 상계항변의 예외

- 민사소송법 제216조 제2항에 의하면 상계의 주장인 자동채권의 존부에 대한 판단은 상계로 대항한 액수에 한하여 기판력을 인정한다. 이는 자동채권의 이중 행사를 방지하기 위한 예외적 규정이다.

2. 기판력의 범위와 후행 소송에 미치는 영향

(1) 기판력이 발생하는 수액적 한계

- 상계항변에 대하여 기판력이 발생하는 범위는 수동채권과 대등액에서 소멸한 범위로 제한된다. 수동채권을 초과하여 상계로 대항하지 않은 자동채권 잔액 부분은 전소에서 심리되지 않았으므로 기판력이 발생하지 않는다.

(2) 후소 제기 시 법원의 판결 양태

- 기판력이 발생하는 소멸 부분에 대하여 다시 소를 제기하는 경우 후소 법원은 전소 판결의 구속력에 의하여 청구기각 판결을 내려야 한다. 반면 기판력이 미치지 않는 초과 잔존 부분에 대해서는 후소 제기가 적법하게 허용되며 법원은 실제 심리를 거쳐 인용 판결을 내릴 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 이 사건 대여금채권에 미치는 기판력의 범위

(1) 상계로 대항한 액수의 확정

- 전소인 A소의 수동채권은 甲의 매매대금채권인 5,000만 원이다. 乙이 자동채권으로 내세운 대여금채권 6,000만 원 중 실제로 상계적상에 이르러 대항한 액수는 수동채권액인 5,000만 원으로 제한된다.

(2) 기판력이 인정되는 범위의 확정

- 따라서 민사소송법 제216조 제2항에 의하여 전소 판결로 소멸의 기판력이 발생하는 범위는 대등액인 5,000만 원 부분에 한정된다. 나머지 1,000만 원 부분은 상계로 대항하지 않은 잔존 채권이므로 기판력이 미치지 않는다.

2. 乙이 제기한 후소의 적법성 및 판결의 형태

(1) 기판력이 미치는 5,000만 원 청구 부분

- 乙이 후소로 이 사건 대여금채권 전액의 지급을 청구하는 경우 기판력이 미치는 5,000만 원 부분은 전소의 구속력에 의하여 법원으로부터 청구기각 판결을 받게 된다.

(2) 기판력이 미치지 않는 1,000만 원 청구 부분

- 기판력이 미치지 않는 나머지 1,000만 원 청구 부분은 전소 판결에 저촉되지 않으므로 乙의 후소 청구가 전적으로 적법하다. 법원은 이에 대하여 실제 심리를 진행하여 청구를 인용하여야 한다.

IV. 결론

- 乙이 후소로 청구한 대여금채권 중 전소에서 상계 완결로 소멸한 5,000만 원 부분은 기판력의 구속력에 따라 청구기각 판결을 받게 되므로 이 부분은 소구할 수 없다. 乙이 상계로 소멸하지 않고 남은 잔존 대여금채권인 1,000만 원 부분에 대하여 소를 제기하는 것은 전소 기판력에 반하지 않아 전적으로 가능하며 법원은 이를 인용하여야 한다.

<보충 - 상계항변>

- 피고가 원고의 채권청구소송 과정에서 자신도 원고에게 받을 채권(자동채권)이 존재함을 주장하며, 대등한 금액만큼 상계하여 줄 것을 주장하는 공격방어 방법

<제4편 소송의 종료.제10장 중국판결에 의한 종료.제02절 판결>

[모의][10.02-1]기판력의 의의 및 본질, 작용요건, 범위

《【문제10.2-1】 기판력에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제10.2의 물음1> 기판력의 의의 및 본질, 작용요건, 범위

I. 기판력의 의의 및 본질

1. 의의 및 취지

(1) 의의

- 기판력이란 확정된 중국판결의 당사자나 법원이 동일한 사항이 다시 문제되었을 때 이에 반하는 주장이나 판단을 할 수 없는 구속력을 의미한다.

(2) 취지

- 법적 안정성을 도모하고 동일한 분쟁의 되풀이를 방지하여 재판의 실효성을 확보하는 데 그 목적이 있다.

2. 기판력의 본질

(1) 모순금지효

- 후소가 전소와 동일하거나 모순되는 사항을 심판대상으로 삼는 경우 전소판결과 모순되는 판단을 금지한다.

(2) 반복금지효

- 동일한 사항에 대한 재소를 금지하여 무용한 심리의 반복을 차단한다.

II. 기판력의 작용요건

1. 전소판결의 확정

- 기판력이 발생하기 위해서는 전소의 중국판결이 확정되어 더 이상 상소로 다룰 수 없는 상태에 이르러야 한다.

2. 후소와의 관계

(1) 동일 관계

- 전소와 후소의 소송물이 동일한 경우 후소 법원은 전소 판결과 동일한 판단을 내려야 한다.

(2) 선결문제 관계

- 전소의 소송물이 후소의 선결문제가 되는 경우 후소 법원은 전소 판결의 판단에 구속된다.

(3) 모순 관계

- 전소의 소송물 판단이 후소의 청구와 정반대되는 모순 관계에 있는 경우 후소 법원은 전소 판결에 반하는 판단을 할 수 없다.

III. 기판력의 범위

1. 객관적 범위

(1) 주문에 포함된 판단

- 기판력은 판결주문에 포함된 소송물에 대한 법적 판단에만 미치고 판결이유에 명시된 사실인정이나 법률판단에는 미치지 않는다.

(2) 상계주장의 예외

- 피고가 제출한 상계주장의 성부에 대해서는 이외적으로 판결이유 중의 판단이라 하더라도 기판력이 발생한다.

2. 주관적 범위

(1) 당사자 및 동일시되는 자

- 기판력은 원칙적으로 전소의 당사자에게 미치며 당사자와 동일시할 수 있는 승계인에게도 효력이 미친다.

(2) 제3자효와의 관계

- 민사소송법상 기판력은 상대적 효력을 원칙으로 하므로, 별도의 명문 규정이 없는 한 제3자에게는 기판력이 미치지 않는다.

3. 시적 범위

(1) 표준시

- 기판력의 시적 기준점은 사실심 변론종결시이다.

(2) 변론종결 후의 사정변경

- 변론종결시 이후에 발생한 새로운 사실이나 사정변경에 대해서는 기판력이 미치지 않으므로 이를 바탕으로 새로운 소를 제기할 수 있다.

IV. 결론

- 기판력은 판결의 확정력을 바탕으로 당사자 간의 법적 분쟁을 최종적으로 종식시키는 민사소송법의 핵심 효력이다. 실체적 진실 발견과 법적 안정성의 조화를 이루기 위하여 기판력의 작용요건과 범위를 엄격하고 명확하게 해석하는 것이 정당한 재판권 행사에 필수적이다.

<보충>

I. 기판력 개관

1. 서설

(1) 기판력의 의의

- 기판력이란 확정된 중국판결에서 내린 공권적 판단에 부여되는 소송법상의 효력이다. 일단 판결이 확정되면 당사자는 동일한 사항에 대하여 다시 다룰 수 없고, 후소 법원도 전소 판결의 판단과 모순되는 판단을 할 수 없는 구속력을 의미한다.

(2) 정당성의 근거

- 기판력의 근거는 법적 안정성의 유지와 분쟁의 일회적 해결에 있다. 동일한 분쟁이 무한히 반복되는 것을 방지하여 국가 사법 자원의 낭비를 막고, 모순된 판결로 인한 법 질서의 혼란을 방지하는 것이 주된 목적이다.

(3) 직권조사사항 및 소송요건

- 기판력의 존부는 소송요건의 하나로서 법원의 직권조사사항이다. 당사자의 주장이 없더라도 법원은 전소 판결의 존재 여부를 확인하여 기판력에 저촉될 경우 후소를 부적법 각하하거나 전소 판단에 따라 본안 판단을 하여야 한다.

2. 기판력 있는 재판

(1) 유효하게 확정된 판결

- 원칙적으로 기판력은 유효하게 확정된 중국판결에만 발생한다. 중간판결이나 소송지휘적 결정 등에는 기판력이 인정되지 않는다.

(2) 결정·명령

- 절차적 사항에 대한 결정이나 명령은 대내적 기속력은 가지나 원칙적으로 기판력은 인정되지 않는다. 다만, 항고로 불복할 수 있는 결정 등 실체적 권리 관계와 유사한 효력을 갖는 일부 재판에 대해서는 제한적으로 인정될 여지가 있다.

(3) 확정판결과 동일한 효력이 있는 조서

- 청구의 포기·인낙조서 및 화해조서는 확정판결과 동일한 효력을 가지므로 기판력이 발생한다.

(4) 외국법원의 확정판결 [민소법 제217조]

- 민사소송법 제217조의 요건(재판권, 송달, 공서양속, 상호보존 등)을 갖춘 외국법원의 확정판결은 국내에서도 기판력이 인정된다.

(5) 소송물에 대한 실질적 판단

- 기판력은 판결주문에 포함된 소송물에 대한 실질적 판단이 있을 때 발생한다. 따라서 소송요건 흠결로 인한 각하판결은 해당 소송요건의 부존재에 대해서만 기판력이 있고 실체적 권리관계에는 영향을 미치지 않는다.

3. 기판력의 본질(법적 성질)

(1) 학설

- 기판력의 본질에 관하여는 후소 법원이 전소 판단과 다른 판단을 할 수 없다는 반복금지설과 전소의 판단 내용이 후소의 실체적 내용을 구속한다는 실체 협력설 등이 대립한다.

(2) 판례

- 대법원은 확정판결의 기판력은 그 판결의 주문에 포함된 것, 즉 소송물로 주장된 법률관계의 존부에 관한 판단에만 미친다는 입장을 견지하며, 후소 법원이 전소 판단과 모순되는 판단을 할 수 없음을 강조한다.

(3) 검토

- 현대 소송법에서는 법적 안정성과 당사자의 신뢰 보호를 위해 전소의 판단 내용이 후소를 구속한다는 구속력설의 관점에서 기판력을 파악하는 것이 타당하다.

II. 기판력의 범위

1. 기판력의 주관적 범위

(1) 당사자

- 기판력은 원칙적으로 판결에 관여한 당사자에게만 미친다. 이는 절차적 기본권인 들을 권리를 보장하기 위함이다.

(2) 당사자와 같이 불 제3자 [민소법 제218조]

- 민사소송법 제218조에 따라 변론종결 후의 승계인, 목적물 소지자, 당사자를 위하여 소송대리인으로서 소송을 수행한 자 등에게 기판력이 확장된다.

(3) 일반 제3자에의 확장

- 가사소송이나 형성소송과 같이 대세효가 인정되는 경우에는 당사자 이외의 제3자에게도 기판력이 미칠 수 있다.

2. 기판력의 객관적 범위

(1) 판결주문에서의 판단 [민소법 제216조]

- 기판력은 판결주문에 포함된 소송물에 관한 판단에만 미치는 것이 원칙이다. 청구의 인용 또는 기각 여부가 그 대상이다.

(2) 판결이유 중의 판단

- 판결이유에서 실시된 사실인정이나 법률적 판단에는 원칙적으로 기판력이 발생하지 않는다. 다만, 민사소송법 제216조 제2항에 의해 상계의 항변이 판단된 경우에는 그 상계로 주장한 채권의 존부에 대하여 예외적으로 기판력이 인정된다.

3. 기판력의 시적 범위

(1) 기판력의 표준시

- 기판력은 사실심 변론종결 시를 표준으로 하여 발생한다. 변론 없이 한 판결의 경우에는 판결 선고 시가 표준이 된다.

(2) 변론종결 전에 존재한 사유

- 표준시 이전에 존재하였던 사유는 설령 소송에서 주장하지 않았더라도 실권된다. 따라서 이를 근거로 확정판결의 효력을 다룰 수 없다.

(3) 변론종결 뒤에 발생한 새로운 사유

- 표준시 이후에 새롭게 발생한 사실관계(채무의 변제, 소멸시효의 완성 등)는 기판력의 차단을 받지 않으므로 이를 근거로 청구이익의 소 등을 제기할 수 있다.

(4) 변론종결 뒤의 형성권 행사

- 상계권, 해제권 등 형성권이 변론종결 뒤에 행사된 경우, 그 기초가 되는 사실이 종결 전의 것이라면 기판력에 의해 차단된다는 것이 판례의 일반적 입장이다.

(5) 정기금판결에 대한 변경의 소 [민소법 제252조]

- 장래의 부양료 등 정기금 지급을 명한 판결이 확정된 후, 표준시 이후에 사정변경이 생긴 경우 당사자는 그 판결의 변경을 구하는 소를 제기할 수 있다.

<제5편 병합소송.제11장 병합청구소송.제01절 청구의 원시적 병합>

[기출][2016-3]청구의 선택적 병합의 의의, 요건, 심리, 판결과 상소

《【문제3】 청구의 선택적 병합에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 청구의 선택적 병합의 의의, 요건, 심리, 판결과 상소

I. 청구의 선택적 병합의 의의

- 청구의 선택적 병합이란 양립 가능한 여러 개의 청구 중 어느 하나가 인용될 것을 조건으로 하여 나머지 청구에 대한 심판을 구하는 병합 형태를 말한다. 이는 원고가 목적하는 하나의 경제적 이익을 달성하기 위해 여러 법적 근거를 제시할 때 유용하게 활용된다. 특히 청구권 경합 이론과 관련하여 실무상 빈번하게 발생하며, 법원의 심판 범위와 상소 시의 이심 범위 등에 있어 독특한 법리가 적용된다.

II. 선택적 병합의 요건

1. 청구의 양립 가능성

- 선택적 병합이 성립하기 위해서는 병합된 여러 청구가 서로 양립할 수 있어야 한다. 만약 청구들이 서로 모순되어 어느 하나가 인정되면 다른 하나가 부정되는 관계(예 : 매매계약에 따른 이행청구와 계약 해제를 전제로 한 원상회복청구)에 있다면 이는 예비적 병합의 대상이 된다.

2. 동일한 목적의 경제적 이익

- 원고가 청구하는 여러 법적 근거가 결국 동일한 급부나 경제적 이익을 목적으로 해야 한다. 예를 들어 동일한 사고로 인한 손해배상을 청구하면서 채무불이행으로 인한 손해배상청구와 불법행위로 인한 손해배상청구를 병합하는 경우가 대표적이다.

3. 공통의 소송절차

- 병합된 모든 청구가 동일한 종류의 소송절차에 의하여 심판될 수 있어야 하며, 해당 법원에 각 청구에 대한 관할권이 인정되어야 한다.

III. 소송계속과 심리

1. 심판의 범위

- 원고는 여러 청구 중 어느 하나만 인용되면 족하다는 의사를 표시한 것이므로, 법원은 어느 하나의 청구가 이유 있다고 판단되면 다른 청구에 대해서는 심리할 필요 없이 원고 승소 판결을 내릴 수 있다. 반대로 원고의 청구를 배척하려면 병합된 모든 청구가 이유 없음을 판단해야 한다.

2. 자백과 포기·인낙

- 선택적 병합에서 어느 한 청구에 대한 피고의 자백이나 인낙이 있으면 법원은 그에 기초하여 판결할 수 있으며, 다른 청구를 심리할 필요가 없다. 원고가 어느 한 청구를 취하하더라도 다른 청구에 의한 소송계속은 유지된다.

IV. 종국판결과 상소

1. 인용판결의 경우

- 법원이 병합된 청구 중 어느 하나를 인용하는 경우, 주문에서 해당 청구를 명시하고 나머지 청구에 대해서는 별도의 판단을 내리지 않는다. 이때 기판력은 주문에 나타난 청구뿐만 아니라 선택적으로 병합된 청구 전체에 미친다는 것이 통설과 판례의 입장이다.

2. 기각판결의 경우

- 원고의 청구를 모두 배척하려면 주문에서 모든 청구에 대한 기각을 명시하거나, 전체적인 청구를 기각하는 취지를 분명히 해야 한다. 모든 청구가 이유 없다는 판단이 판결 이유에 기재되어야 한다.

3. 일부판결의 금지

- 선택적 병합은 단일한 소송물은 아니나 심판의 단위가 하나로 취급되므로, 여러 청구 중 일부에 대해서만 판결하는 일부판결은 허용되지 않는다. 만약 법원이 착오로 일부 청구에 대해서만 판결하고 나머지를 누락한 경우, 이는 재판의 누락이 아닌 추가판결의 대상이 되며 전체가 상소로 이심된다.

4. 상소와 이심의 범위

(1) 이심의 범위

- 병합된 청구 중 어느 하나를 인용한 판결에 대해 피고가 상소하면, 상소 불가분의 원칙에 따라 선택적으로 병합된 청구 전체가 상급심으로 이심된다.

(2) 상급심의 심판 객체

- 상급심은 원심에서 판단하지 않았던 다른 선택적 청구에 대해서도 심판할 수 있다. 만약 원심이 인용한 청구가 상급심에서 이유 없다고 판단되더라도, 원심이 판단하지 않았던 다른 청구가 이유 있다면 상소 기각 판결을 통해 원고의 승소를 유지할 수 있다.

V. 결론

- 청구의 선택적 병합은 원고에게 소송의 편의를 제공하고 동일한 목적을 가진 분쟁을 한꺼번에 해결함으로써 재판의 경제를 도모하는 제도이다. 법원은 심리 과정에서 어느 하나의 청구만 인정되면 원고 승소를 판결할 수 있으나, 기각 시에는 모든 경로를 차단해야 하므로 신중한 심리가 요구된다. 특히 상소 단계에서 전체 청구가 이심되는 특성을 고려하여 당사자의 방어권이 침해되지 않도록 유의해야 한다.

<제5편 병합소송.제11장 병합청구소송.제01절 청구의 원시적 병합>

[기출][2022-1-1]예비적 병합에서 일부 판결의 적법성 및 누락된 청구에 대한 불복방법

《【문제1】 동업관계에 있는 乙, 丙, 丁, 戊는 자신들의 사업장 앞에 있는 X토지를 甲으로부터 임차하여 주차장으로 사용하고 있었다. 위 4인을 대표한다고 주장하는 乙은 X토지를 甲으로부터 매수하기로 하고 甲과 X토지에 대한 매매계약을 체결하였다. 사업자금의 대출을 위해 X토지의 등기가 필요하다는 사정을 들은 甲은 매매대금의 전액을 지급받지 못하였음에도 불구하고 X토지의 등기를 위 4인에게 이전하여 주었으나 위 4인은 매매잔대금을 지급하지 않고 있다. 이에 甲은 乙, 丙, 丁, 戊를 상대로 주위적으로는 매매계약이 유효하다면 X토지의 매매대금 전액의 지급을 구하고, 예비적으로는 매매계약이 무효라면 X토지의 소유권이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. (단, 아래의 각 물음은 독립적임) (50점)

(물음1) 제1심 법원은 乙에게 적합한 대리권이 없었다는 것을 이유로 원고의 주위적 청구를 배척하면서도 예비적 청구에 대하여는 아무런 판단을 하지 않았다. 이러한 제1심 법원의 판결에 대해 적법 여부와 불복방법에 관하여 쓰시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 예비적 병합에서 일부 판결의 적법성 및 누락된 청구에 대한 불복방법

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 乙, 丙, 丁, 戊를 상대로 매매대금 지급을 구하는 주위적 청구와 소유권이전등기 말소를 구하는 예비적 청구를 병합하여 제기하였으나 제1심 법원이 주위적 청구만 배척하고 예비적 청구에 대한 판단을 누락한 상황이다. 쟁점으로 법원이 예비적 청구에 대한 판단을 하지 않은 경우의 판결의 적법성과 이에 대한 당사자의 불복방법을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 예비적 병합청구에서 판단누락의 효력과 이를 시정하기 위한 상소방법을 설명한다.

II. 예비적 병합의 심판법리와 재판의 유탈

1. 일부판결의 허용 여부

(1) 예비적 병합의 심판원칙

- 예비적 병합이란 원고가 양립할 수 없는 수개의 청구를 제기하면서 주위적 청구가 기각되거나 인용되지 않을 것을 해제조건으로 하여 예비적 청구의 심판을 구하는 소송 형태이다. 소수법원은 원고가 정한 심판 순위에 전적으로 구속되므로, 반드시 주위적 청구를 먼저 심리·판단하여야 한다.

(2) 절차적 불가분성과 일부판결 금지

- 예비적 병합은 각 청구가 조건부로 결부되어 있어 절차적으로 분리될 수 없는 불가분적 성질을 지닌다. 따라서 수개의 청구를 분리하여 변론하거나 일부 판결을 선고하는 것은 소송법상 허용되지 않는다.

2. 판단 유탈의 법적 성질

(1) 학설의 대립

- 주위적 청구를 기각하면서 예비적 청구 판단을 빠뜨린 경우에 대하여 견해가 대립한다. ❶ 재판누락설은 이를 민사소송법 제212조의 재판의 누락으로 보아 누락된 부분이 여전히 원심에 계속되어 있으므로 추가판결을 구해야 한다는 견해이다. ❷ 판단누락설은 일부판결을 할 수 없는 경우에 해당하여 하자가 있는 전부판결로서 판단의 누락에 해당하고 상소로 다투어야 한다는 견해이다.

(2) 판례의 태도

- 대법원 전원합의체 판결은 판단누락설의 입장이다. 예비적 병합에서는 일부판결이 허용되지 않으므로, 주위적 청구를 기각하면서 예비적 청구에 대한 판단을 누락한 판결은 형식적으로 전부판결로 취급되며, 이는 판결의 내용상 흠결인 판단의 누락에 해당한다고 판단하였다.

III. 사안의 적용

1. 제1심 판결의 적법 여부 검토

(1) 심판의무의 위배

- 원고 甲이 임차 및 매매계약과 관련하여 제기한 주위적 청구(매매대금 청구)와 예비적 청구(이전등기말소 청구)는 계약의 유·무효를 전제로 하므로 양립 불가능한 예비적 병합 관계이다. 제1심 법원이 乙의 대리권 결여를 이유로 주위적 청구를 배척하였다면, 조건 성취로 인해 예비적 청구를 판단하여야 할 심판의무가 당연히 발생한다.

(2) 일부판결 위법의 존재

- 그럼에도 제1심 법원이 주위적 청구에 대해서만 기각 판결을 선고하고 예비적 청구에 대해 판단하지 않은 것은 일부판결을 전면 금지하는 예비적 병합의 심판법리를 정면으로 위반한 위법이 존재하므로 부적법하다.

2. 원고 甲의 적법한 불복방법

(1) 추가판결 신청의 불가능

- 판례의 판단누락설에 의하면, 제1심의 부적법한 판결은 재판의 누락이 아닌 전부판결에서의 판단의 누락에 해당하므로 제1심의 소송계속은 종료된다. 따라서 원고 甲은 제1심 법원에 대하여 민사소송법 제212조에 따른 추가판결을 청구할 수 없다.

(2) 항소 제기를 통한 구제

- 원고 甲은 제1심의 위법한 판결 전부에 대하여 적법하게 항소를 제기하여야 한다. 이 경우 항소제기에 따른 이심의 효력에 의해 주위적 청구뿐만 아니라 판단이 누락된 예비적 청구까지 청구 전부에 대하여 항소심으로 이심된다. 항소심 법원은 제1심의 위법을 시정하기 위해 누락된 예비적 청구까지 심판 범위에 포함하여 판단하여야 한다.

IV. 결론

- 법원이 주위적 청구를 기각하면서 예비적 청구에 대하여 아무런 판단을 하지 않은 판결은 일부판결을 할 수 없는 예비적 병합의 소송법적 대원칙을 무시하여 내린 판결로서 위법하며 부적법하다. 해당 판결은 판단의 누락에 해당하므로 원고 甲은 추가판결을 신청할 수 없으며, 제1심 판결에 대하여 적법하게 항소를 제기함으로써 사건 전체를 항소심으로 이심시켜 유탈된 예비적 청구에 대한 올바른 판결을 받아야 한다.

<제5편 병합소송.제11장 병합청구소송.제02절 청구의 후발적 병합>

[기출][2012~3]반소의 의의, 요건, 제기 및 절차, 효과

《【문제3】 반소 (25점)》

<문제3> 반소의 의의, 요건, 제기 및 절차, 효과

I. 반소의 의의

- 반소란 소송절차의 계속 중에 피고가 원고에 대하여 본소의 청구와 관련 있는 새로운 청구를 하기 위하여 동일한 소송절차에서 제기하는 소를 말한다. 이는 본소와 반소를 병합 심리함으로써 심판의 중복을 피하고 판결의 모순·저촉을 방지하며 소송 경제를 도모하려는 데 목적이 있다.

II. 반소의 요건

1. 상호 관련성

(1) 본소 청구와의 관련성

- 반소 청구가 본소 청구와 동일한 법률관계 혹은 동일한 사실상·법률상 원인에 기초하고 있어야 한다. 예컨대, 본소의 매매대금 청구에 대하여 반소로 목적물의 인도나 하자담보책임을 묻는 경우 등이 해당한다.

(2) 본소 방어방법과의 관련성

- 본소의 항변 사유와 반소 청구가 법률상·사실상 공통점이 있어야 한다. 상계의 대상이 되는 채권을 반소로 청구하는 경우 등이 이에 해당한다.

2. 본소의 계속 중 제기

- 반소는 본소가 법원에 계속되어 있는 동안에만 제기할 수 있다. 변론이 종결된 후에는 제기할 수 없으며, 본소가 취하되거나 각하되어 소송계속이 소멸한 경우에는 원칙적으로 반소를 제기할 수 없다.

3. 절차적 요건

(1) 본소와 동일한 소송절차

- 본소와 반소가 병합하여 심리될 수 있는 동종의 소송절차여야 한다. 본소가 민사소송인데 반소가 행정소송인 경우에는 원칙적으로 허용되지 않는다.

(2) 배타적 관할의 위배 금지

- 반소 청구가 다른 법원의 전속관할에 속하지 않아야 한다. 다만, 임의관할인 경우에는 본소가 제기된 법원에 관할권이 인정된다.

4. 소송절차를 현저히 지연시키지 않을 것

- 반소의 제기가 기존 본소 심리의 경과에 비추어 소송절차를 현저히 지연시킬 우려가 있는 경우에는 허용되지 않는다.

III. 반소의 제기 및 절차

1. 제기 시기 및 방식

(1) 제기 시기

- 제1심 변론종결 전까지 제기하는 것이 원칙이다. 항소심에서의 반소 제기는 상대방의 동의가 있거나 상대방이 이의 없이 반소의 본안에 관하여 변론한 때, 혹은 심급의 이익을 해할 우려가 없는 경우에 한하여 예외적으로 허용된다.

(2) 제기 방식

- 반소는 본소와 마찬가지로 소장을 제출하는 방식에 의하며, 반소장에는 본소와의 관련성을 명시하여야 한다.

2. 심리와 판결

- 법원은 본소와 반소의 요건을 각각 심사하며, 요건을 갖춘 경우 병합 심리한다. 판결 시에는 본소와 반소에 대하여 하나의 전부판결을 내리는 것이 원칙이나, 필요한 경우 일부판결을 통해 분리하여 선고할 수도 있다.

IV. 반소의 효과

1. 소송계속과 시효중단

- 반소가 제기되면 그 시점에 반소 청구에 대한 소송계속의 효과가 발생하며, 시효중단 및 기간준수의 효과는 반소장을 제출한 때에 발생한다.

2. 본소 취하와의 관계

- 본소가 취하되더라도 피고는 반소를 취하지 않고 독자적으로 소송을 유지할 수 있다. 다만, 피고가 본소 취하에 동의한 이후에는 반소도 취하된 것으로 간주되는 경우가 있으므로 유의하여야 한다.

V. 결론

- 반소는 피고의 방어권을 보장하고 분쟁을 일거에 해결하는 유용한 제도이다. 법원은 관련성 요건을 엄격히 심사하여 남용을 막으면서도, 실질적인 분쟁 해결을 위해 적극적으로 활용할 필요가 있다. 특히 노사관계와 같은 복잡한 법률관계에서는 본소와 관련된 반소가 제기되는 경우가 빈번하므로, 법원은 양 청구의 유기적 관련성을 살펴 모순 없는 판결을 내려야 할 것이다.

<제5편 병합소송.제11장 병합청구소송.제02절 청구의 후발적 병합>

[기출][2021-3]중간확인 소의 의의, 요건, 절차, 효력

《【문제3】 중간확인 소에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 중간확인 소의 의의, 요건, 절차, 효력

I. 중간확인 소의 의의

- 중간확인 소란 소송 계속 중 본래의 청구(주청구)의 판단의 전제가 되는 법률관계의 존부에 관하여 다툼이 있는 경우, 당해 소송 절차를 이용하여 그 법률관계의 확정을 구하는 소를 말한다. (민사소송법 제264조) 이는 판결의 이유 중에서만 판단되는 선결적 법률관계에 대하여 기판력을 부여함으로써 동일한 쟁점에 대한 반복된 소송을 방지하고 분쟁을 일거에 해결하기 위한 제도이다. 통상적인 소의 추가적 병합의 일종이지만, 기존의 증거자료를 그대로 활용할 수 있다는 점에서 소송경제에 부합한다.

II. 중간확인 소의 요건

1. 선결적 법률관계의 존재

- 중간확인 소의 대상은 주청구의 판단의 전제가 되는 법률관계여야 한다.

(1) 법률관계의 의미

- 권리나 의무 또는 법률상의 지위를 의미하며, 단순한 사실관계나 증거의 존부는 대상이 될 수 없다. 예를 들어 소유권이전등기청구소송에서 그 전제가 되는 매매계약의 유효 여부나 소유권 자체의 존부가 이에 해당한다.

(2) 선결성

- 본래의 청구가 인용되거나 기각되는 데 있어 반드시 그 존부가 확정되어야 하는 관계에 있어야 한다. 주청구의 인용 여부와 무관한 별개의 법률관계는 중간확인 소의 대상이 될 수 없다.

2. 상대방의 다툼이 있을 것

- 선결적 법률관계에 대하여 당사자 사이에 다툼이 있어야 한다. 상대방이 이를 인정하여 자백이 성립한 경우에는 확인의 이익이 없으므로 중간확인 소를 제기할 수 없다.

3. 주청구가 소송 계속 중일 것

- 주청구가 사실심에 계속 중이어야 한다. 주청구가 취하되거나 각하되어 소송 계속에 소멸하면 중간확인 소도 부적법하게 된다. 다만, 항소심에서도 선결적 법률관계의 확정이 필요하다면 제기할 수 있다.

4. 동종의 소송 절차와 관할

- 중간확인 소는 본래의 소송과 동종의 소송 절차에 따라야 하며, 전속 관할에 위반되지 않아야 한다.

III. 중간확인 소의 절차

1. 제기의 방식

- 중간확인 소는 소의 변경에 관한 규정을 준용하므로 서면으로 제기함이 원칙이다. (민사소송법 제264조 제2항) 다만, 변론기일에서 말로 제기하는 것도 가능하며 이 경우에는 조서에 기재하여야 한다.

2. 제기 시기

- 사실심의 변론종결 전까지 제기할 수 있다. 상고심에서는 새로운 사실인정을 할 수 없으므로 중간확인 소를 제기하는 것이 허용되지 않는다.

IV. 중간확인 소의 효력

1. 심판의 방법

- 법원은 주청구와 중간확인 소를 병합하여 심리하여야 한다. 중간확인 소는 주청구와 별개의 소송물이지만 절차적으로는 병합된 소송으로 취급된다.

2. 판결의 형태

(1) 전부 판결

- 법원은 원칙적으로 주청구와 중간확인 소의 청구에 대하여 하나의 전부 판결을 내려야 한다.

(2) 중간판결과의 구별

- 법원이 선결적 법률관계에 대하여 중간판결을 내릴 수도 있으나, 이는 당해 소송 내부에서 법원을 구속할 뿐 기판력이 발생하지 않는다. 반면 중간확인 소에 의한 판결은 중국판결로서 기판력이 발생한다.

3. 기판력의 발생

- 중간확인 소에 대한 판결이 확정되면 그 선결적 법률관계의 존부에 대하여 기판력이 발생한다. 따라서 추후 별개의 소송에서 동일한 선결적 법률관계가 다시 문제 될 경우 당사자는 이에 반하는 주장을 할 수 없으며 법원도 이에 저촉되는 판결을 할 수 없다.

V. 결론

- 중간확인 소는 판결 이유 속의 판단에 불과했던 선결적 법률관계를 주문에 표시함으로써 기판력을 확장시키는 기능을 한다. 이는 당사자 간의 분쟁을 근본적으로 해결하고 법적 안정성을 높이는 데 크게 기여한다. 특히 복잡한 권리관계가 얽힌 현대 소송에서 동일한 원인에 기한 후속 소송을 예방한다는 점에서 그 실익이 크다. 법원은 중간확인 소의 요건인 선결성을 엄격히 심사하되, 제도의 취지에 비추어 당사자가 효율적으로 분쟁을 종결지을 수 있도록 절차를 운영하여야 한다.

<제5편 병합소송.제11장 병합청구소송.제02절 청구의 후발적 병합>

[모의][11.02-1]청구의 변경의 의의 및 허용 필요성, 적법요건, 소송절차 및 관할, 위반 시 조치

《【문제11.2-1】 청구의 변경에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제11.2의 물음1> 청구의 변경의 의의 및 허용 필요성, 적법요건, 소송절차 및 관할, 위반 시 조치

I. 청구변경의 의의 및 허용 필요성

1. 청구변경의 의의

- 청구의 변경이란 소송의 계속 중에 원고가 소송물인 청구의 취지 또는 청구원인을 변경하여 새로운 청구에 대하여 판결을 구하는 소송행위를 말한다. 이는 구소의 취하와 신소의 제기가 결합된 성격을 지닌다.

2. 청구변경의 허용 필요성

- 단일한 소송절차 내에서 관련된 분쟁을 일거에 해결함으로써 소송경제를 도모하고 판결의 모순·저촉을 방지하기 위하여 인정된다. 다만 피고의 방어권 침해와 소송 지연을 예방하기 위하여 일정한 한계 규정이 수반된다.

II. 청구변경의 적법 요건

1. 소송 절차상의 요건 및 시기적 한계

(1) 동종의 소송절차와 관할의 공통

- 변경된 청구가 원래의 청구와 동종의 소송절차에 따라 심리될 수 있어야 하며, 변경 후의 청구에 대해서도 수소법원에 관할권이 인정되어야 한다.

(2) 사실심 변론종결 전의 신청

- 원고는 사실심 변론종결 전까지만 청구를 변경할 수 있다. 상고심은 법률심이므로 상고심 단계에서의 청구변경은 원칙적으로 허용되지 않는다.

2. 실질적 제한 요건

(1) 청구기초의 동일성 유지

- 청구변경이 허용되려면 원래 청구와 변경 청구 간에 청구기초의 동일성이 있어야 한다. 이는 양 청구의 사실관계나 경제적 이익이 법적으로 밀접한 유기적 관련성을 가질 것을 요하며, 기존의 소송자료를 그대로 활용할 수 있는 수준이어야 한다.

(2) 소송절차의 현저한 지연 예방

- 청구의 변경으로 인해 새로운 증거조사 등이 불가피하게 요구되어 소송절차가 현저히 지연되어서는 안 된다. 지연 여부는 소송의 진행 정도와 변경 내용 등을 종합하여 법원이 결정한다.

III. 청구변경의 절차 및 위반 시의 조치

1. 청구변경의 소송 절차

(1) 서면에 의한 신청 원칙

- 청구의 변경은 소의 제기와 유사하므로 서면으로 신청하여야 하며, 법원은 그 서면을 피고에게 송달하여 방어의 기회를 부여해야 한다.(민사소송법 제262조 제2항)

(2) 변경의 형태적 분류

① 교환적 변경

- 구청구를 취하하고 완전히 새로운 신청구로 교체하는 형태로, 구소의 취하와 신소의 제기가 결합된 형태이다.

② 추가적 변경

- 구청구를 유지하면서 새로운 청구를 병합하여 함께 심판을 구하는 형태로, 소의 단순 추가 또는 객관적 병합에 해당한다.

2. 요건 위반 시의 소송법상 조치

(1) 법원의 기각 결정

- 청구변경의 요건이 결여된 경우 법원은 직권 또는 피고의 이의에 의하여 결정으로 청구변경을 허용하지 아니한다.(민사소송법 제263조 제1항) 이 불허 결정에 대해서는 독립하여 즉시항고로 불복할 수 없다.

(2) 상대방의 응소와 하자의 치유

- 청구변경에 하자가 있더라도 피고가 이에 대하여 이의를 제기하지 않고 본안 변론을 진행한 경우, 피고의 이익권 상실 또는 묵시적 동의에 의하여 청구 변경의 하자는 치유된다.

IV. 결론

- 청구의 변경은 원고에게 소송제도의 유연성을 부여하고 사법 자원의 효율적 배분을 유도하는 소송법상 제도이다. 다만 법원은 청구기초의 동일성과 소송 지연 방지라는 한계를 엄격하게 심사하여, 소송경제와 상대방의 방어권 보장이라는 소송법상의 핵심적 가치들이 유기적인 균형을 이루도록 정교하게 운영해야 할 것이다.

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제01절 공동소송>

[기출][2010-2-2]공동소송인 독립의 원칙의 의의, 내용, 보완 및 한계, 예외

《【문제2】 다음 문제를 설명하시오.

(물음2) 공동소송인독립의 원칙 (25점)》

<문제2의 물음2> 공동소송인 독립의 원칙의 의의, 내용, 보완 및 한계, 예외

I. 공동소송인 독립의 원칙의 의의

- 하나의 소송절차에 여러 명의 원고 또는 피고가 관여하는 공동소송 중 통상공동소송은 각 공동소송인이 상대방에 대하여 갖는 권리관계가 개별적이고 독립적이다. **민사소송법 제66조**는 이를 공동소송인 독립의 원칙으로 규정하고 있다. 이는 소송 수행의 편의를 위해 절차만 합쳐놓은 것에 불과하므로, 각 당사자의 소송행위나 법원의 판단이 서로에게 영향을 주지 않는 것이 원칙이다.

II. 공동소송인 독립의 원칙의 내용

1. 소송요건의 개별성

- 공동소송인 각자에 대하여 소송요건을 개별적으로 심사해야 한다. 예를 들어 어느 한 사람에 대하여 재판권이냐 관할권이 없더라도 다른 공동소송인의 소송에는 영향을 미치지 않는다.

2. 소송행위의 독립성

(1) 유리·불리한 행위의 독립

- 공동소송인 중 1인이 한 소 제기, 소 취하, 자백, 청구의 포기나 인낙 등은 다른 공동소송인에게 영향을 주지 않는다. 또한 1인에 대한 상대방의 소송행위도 그 사람에게만 효력이 있다.

(2) 소송진행의 독립

- 어느 1인에게 소송절차의 중단이나 중지 사유가 발생하더라도 다른 공동소송인의 소송진행에는 영향을 미치지 않으며, 판결의 선고도 개별적으로 이루어질 수 있다.

3. 증거조사와 사실인정의 독립

(1) 증거독립의 원칙

- 어느 1인이 제출한 증거는 원칙적으로 그 사람의 소송관계에서만 효력을 가진다. 따라서 다른 공동소송인이 그 증거를 원용하지 않는 한 법원은 이를 근거로 다른 공동소송인에 대한 사실을 인정할 수 없다.

(2) 판단의 비통일

- 동일한 사실관계에 대하여도 공동소송인마다 제출한 증거와 소송행위가 다를 경우, 법원은 각자에게 서로 모순되는 판결을 내릴 수 있다. 이는 통상공동소송의 본질적 결과이다.

III. 독립의 원칙에 대한 보완 및 한계

1. 증거공통의 원칙

- 공동소송인 중 1인이 제출한 증거에 의하여 공통된 사실을 인정할 수 있는 경우, 다른 공동소송인이 이를 원용하지 않더라도 법원이 그 사실을 공통적으로 인정할 수 있다는 원칙이다. **판례**는 실질적으로 동일한 증거조사 결과를 두고 당사자마다 다르게 판단하는 것은 비합리적이라는 점에서 이를 긍정한다.

2. 주장공통의 원칙 인정 여부

(1) 학설의 대립

- 공동소송인 중 1인이 자기에게 유리한 사실을 주장했을 때, 다른 공동소송인이 주장하지 않았더라도 그 효력을 인정할 것인가가 문제된다. 이를 긍정하는 견해는 소송의 통일을 강조하고, 부정하는 견해는 변론주의 원칙을 강조한다.

(2) 판례의 태도

- **판례**는 통상공동소송에서 주장공통의 원칙을 원칙적으로 부정한다. 따라서 어느 1인이 제기한 소멸시효 항변이나 취소권 행사의 효력은 다른 공동소송인에게 미치지 않는다고 본다.

IV. 독립의 원칙의 예외 : 필수적 공동소송

1. 의의

- 소송물인 권리관계가 공동소송인 전원에게 합일적으로 확정되어야 하는 경우이다. 이때는 **민사소송법 제67조**가 적용되어 공동소송인 독립의 원칙이 배제된다.

2. 특례 내용

(1) 소송행위의 유효 요건

- 공동소송인 1인의 소송행위는 모두에게 유리한 경우에만 효력이 있고, 불리한 행위(자백, 취하 등)는 전원이 함께해야 효력이 발생한다.

(2) 상소의 효력

- 공동소송인 중 1인이 상소를 제기하면 전원에게 효력이 미치며, 판결의 확정도 차단되고 사건 전체가 상소심으로 이심된다.

V. 결론

- 공동소송인 독립의 원칙은 자기책임의 원칙과 변론주의를 공동소송 절차에서 구현한 것이다. 그러나 이 원칙을 고수할 경우 발생하는 판결의 모순·저촉 문제를 해결하기 위해 증거공통의 원칙 등이 활용되고 있다. 다만, **판례**가 주장공통의 원칙을 부정하고 있는 만큼, 실무적으로는 각 당사자가 상대방의 유리한 주장을 적극적으로 원용하여 불이익을 방지할 필요가 있다. 통상공동소송의 독립성과 필수적 공동소송의 합일확정성 사이의 조화는 **민사소송법**의 효율적 운영을 위한 핵심적 과제라 할 수 있다.

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제01절 공동소송>

[기출][2013-1-2]공동피고 중 1인의 선정당사자 선정 가능성 및 그 판결의 효력이 선정자에게 미치는지 여부

《[문제1] 乙과 丙은 도급계약에 따라 함께 사업을 수행하고 있고, 임금지급에 대하여 연대책임 관계에 있다. 그런데 수급인인 丙은 소속 근로자인 甲에게 임금을 지급하지 못하고 있다. 이에 甲은 乙과 丙을 공동 피고로 하여 임금청구의 소를 제기하였다. 이때 다음 물음에 대하여 각각 논하시오. (50점)

(문제2) 위 소송계속 중에 乙이 丙을 선정당사자로 선정할 수 있는가? 그리고 丙이 선정당사자로서 소송을 수행하여 판결이 확정될 경우 丙이 받은 판결의 효력은 乙에게도 미치는가? (30점)》

<문제1의 물음2> 공동피고 중 1인의 선정당사자 선정 가능성 및 그 판결의 효력이 선정자에게 미치는지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙과 丙이 임금지급에 관한 연대책임 관계에 있는 상황에서 甲이 乙과 丙을 공동 피고로 하여 임금청구소송을 제기하고, 소송 계속 중 乙이 丙을 선정당사자로 선정하려는 상황이다. 쟁점으로 공동소송 관계에 있는 당사자 사이에서 선정당사자 선정의 가부와 선정당사자가 받은 확정판결의 효력이 다른 선정자에게 미치는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 선정당사자 제도의 요건과 선정당사자가 수행한 소송의 판결효력 범위를 논한다.

II. 선정당사자 제도의 의의 및 요건

1. 선정당사자의 의의 및 취지

(1) 개념 및 의의

- 선정당사자란 공동의 이해관계를 가진 다수의 사람 중 그들 전체를 위하여 소송을 수행할 당사자로 선정되어 소송을 당사자 명의로 수행하는 자를 말한다.(민사소송법 제53조)

(2) 인정 취지

- 다수인이 관여하는 소송에서 절차의 번잡함을 피하고 소송을 보다 신속하고 경제적으로 진행하기 위한 제도이다.

2. 선정당사자의 법정 요건

(1) 공동의 이해관계의 존재

- 선정당사자가 허용되려면 다수자 사이에 공동의 이해관계가 존재하여야 한다. 판례는 다수자 상호간에 소송물이 되는 권리의무가 공동이거나 동일한 사실상·법률상 원인에 기한 경우와 같이, 소송의 주요한 쟁점이 공통되는 경우를 의미한다고 판단한다.

(2) 선정의 시기 및 형식

- 선정은 소송 계속 중뿐만 아니라 소제기 전에도 할 수 있으며, 서면으로써 증명하여야 한다. 또한 피선정자는 반드시 공동의 이해관계를 가진 다수자 중의 일원이어야 한다.

III. 선정당사자 판결의 효력 확장 범위

1. 기판력 및 집행력의 확장

(1) 기판력의 인적 범위 확장

- 민사소송법 제218조 제3항에 의하면, 선정당사자를 상대방으로 하여 내린 확정판결은 선정자 모두에게 기판력이 미친다.

(2) 집행력의 확장 여부

- 확정판결의 급부 명령에 따른 집행력 또한 선정자에게 미치므로, 판결에 기하여 선정자의 재산에 대하여 직접 강제집행을 실시할 수 있다.

2. 선정자의 소송 탈퇴 효과

(1) 소송탈퇴의 의제

- 선정당사자가 선정되면 기존에 소송에 참여하고 있던 선정자는 소송에서 당연히 탈퇴한 것으로 본다.(민사소송법 제53조 제2항)

(2) 단독 수행권의 전속

- 탈퇴 결과 소송수행권은 선정당사자에게 전속되며, 선정자는 소송 수행에 직접 관여하거나 독자적으로 소송행위를 할 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 丙에 대한 선정당사자 선정의 적법 여부

(1) 공동의 이해관계 충족 여부

- 공동피고 乙과 丙은 임금지급채무에 대하여 연대책임 관계에 있으므로, 소송의 핵심 쟁점인 임금청구권의 발생 여부 및 범위에 관하여 밀접한 이해관계를 공유한다. 따라서 양자 사이에는 공동의 이해관계가 인정된다.

(2) 피선정자 자격의 구비 여부

- 丙은 공동의 이해관계를 가진 공동피고 중 1인이므로 피선정자 자격이 있다. 따라서 乙이 소송 계속 중 丙을 선정당사자로 선정하는 소송행위는 적법하며, 선정 시 乙은 소송에서 탈퇴하게 된다.

2. 확정판결 효력의 乙에 대한 확장 여부

(1) 기판력의 확장 효과

- 丙이 선정당사자로서 소송을 단독으로 수행하여 최종 판결을 얻게 되면, 민사소송법 제218조 제3항의 명문 규정에 따라 당해 판결의 기판력은 선정한 당사자인 乙에게 당연히 확장된다.

(2) 집행력의 확장 효과

- 해당 임금청구소송에서 甲의 승소 판결이 확정되는 경우, 그 집행력 또한 乙에게 확장되므로 甲은 乙의 재산에 대하여도 판결에 기한 강제집행을 유효하게 실시할 수 있다.

V. 결론

- 공동피고 乙과 丙은 연대채무 관계로서 공동의 이해관계가 인정되므로, 소송 계속 중 乙이 丙을 선정당사자로 선정하는 소송행위는 전적으로 적법하다. 선정당사자인 丙이 수행한 소송의 판결이 확정되면, 민사소송법 제218조 제3항에 의하여 그 판결의 기판력 및 집행력 등의 소송법상 효력은 선정한 당사자인 乙에게도 당연히 미친다.

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제01절 공동소송>

[기출][2015-1-1]피고를 특정하여 소를 제기한 후 예비적으로 피고를 추가한 소송형태의 적법 여부와 법원의 조치

《【문제1】 甲은 A은행과의 고용계약서상의 퇴직금 조항 등이 무효라는 확인과 함께 퇴직금의 지급을 구하는 내용의 소를 A은행 리스크관리본부장인 乙을 상대로 제기하였다. 당초에 甲이 피고로 삼은 사람은 개인으로서의 乙이 아니라 A은행 부서장인 리스크관리본부장을 피고로 특정한 것인데, 법률적으로 확신이 서지 않자, 甲은 예비적으로 A은행도 피고로 추가하였다. (50점)

(물음1) 위와 같은 소송형태의 적법 여부와 이에 대한 법원의 조치 및 판단에 대하여 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음1> 피고를 특정하여 소를 제기한 후 예비적으로 피고를 추가한 소송형태의 적법 여부와 법원의 조치

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 A은행의 부서장인 리스크관리본부장 乙을 피고로 특정하여 퇴직금 관련 청구를 제기한 후 법률적 불확실성을 이유로 예비적으로 A은행을 피고로 추가한 상황이다. 쟁점으로 피고 특정의 적법성과 예비적 피고 추가 형태의 허용 여부 및 이에 대한 법원의 심리·판단 방법을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 잘못 지칭된 피고와 예비적 피고 추가의 소송형태에 관한 법리 및 법원의 조치와 판단에 대해 논한다.

II. 예비적 공동소송과 피고 추가의 법정 요건

1. 주관적 예비적 공동소송의 요건

(1) 의의 및 취지

- 공동소송인 일부에 대한 청구가 다른 공동소송인에 대한 청구와 법률상 양립할 수 없는 경우를 주관적 예비적 공동소송이라 한다. 이는 재판의 모순·저촉을 방지하고 분쟁을 한꺼번에 해결하기 위한 제도이다.

(2) 법률상 양립 불가능성

- 양립할 수 없는 관계란 한쪽 피고에 대한 청구가 인용되면 타방 청구는 당연히 기각되는 관계를 뜻한다. 실제법상 채무의 귀속 주체가 누구인지 불분명하여 모순되는 주장을 하는 경우 등이 이에 속한다.

2. 예비적 피고 추가의 적법성

(1) 피고 추가의 허용 여부

- 민사소송법 제70조 제1항은 예비적 공동소송에 필수적 공동소송인 추가에 관한 제68조를 준용한다. 따라서 소송계속 중 예비적 피고를 추가하는 후발적 피고 추가도 적법하게 인정된다.

(2) 추가의 시기적 한계

- 피고 추가 신청은 제1심의 변론을 종결할 때까지만 할 수 있다. 항소심 단계에서의 예비적 피고 추가는 피고의 심급의 이익을 해칠 우려가 있어 원칙적으로 허용되지 않는다.

III. 피고 추가 신청에 대한 법원의 조치

1. 피고 추가의 신청과 허가

(1) 원고의 신청

- 원고가 기존 피고 외에 다른 사람을 예비적 피고로 추가하고자 할 때에는 서면으로 신청하여야 한다.

(2) 법원의 허가결정

- 법원은 추가 요건을 심사하여 적법한 경우 제1심 변론종결 전까지 결정으로 피고 추가를 허가한다.

2. 허가결정에 따른 송달 및 소급효

(1) 정본 및 부분의 송달

- 법원은 허가결정을 한 때에는 결정 정본을 당사자 모두에게 송달하여야 하며, 추가될 피고에게는 소장 부분도 송달하여야 한다.

(2) 소제기의 소급효

- 추가된 피고에 대한 관계에서는 처음의 소가 제기된 때에 소가 제기된 것으로 간주되므로 시효중단 등의 효력이 소급하여 발생한다.

IV. 예비적 공동소송에 대한 법원의 판단

1. 심판의 범위와 전부판결의 의무

(1) 심판 대상의 범위

- 민사소송법 제70조 제2항에 따라 주위적·예비적 공동소송에서는 모든 공동소송인에 관한 청구에 대하여 판결을 하여야 한다.

(2) 일부판결의 금지

- 법원은 일부 피고에 대해서만 판단을 내리고 누락하여서는 안 되며, 누락 시 일부판결 금지 원칙에 위배되어 부적법하다.

2. 주위적 피고와 예비적 피고에 대한 개별 판단

(1) 주위적 피고 乙에 대한 판단

- 리스크관리본부장은 은행 내부 기관에 불과하여 당사자능력이 없다. 乙 개인에 대한 소로 보더라도 퇴직금 지급의 실제법상 의무자가 아니므로 피고격이 없어 소각하 또는 청구기각 판결을 내려야 한다.

(2) 예비적 피고 A은행에 대한 판단

- A은행은 법인으로서 당사자능력 및 퇴직금 지급의 실제법상 의무를 부담하는 피고격적자이다. 따라서 법원은 乙에 대한 소를 배척함과 동시에 A은행에 대한 청구의 존부를 실질적으로 심리하여 판결해야 한다.

V. 사안의 적용

1. 소송형태의 적법성 판단

(1) 양립 불가능성 충족

- 퇴직금 지급의무자가 乙 개인인지, 아니면 법인인 A은행인지 여부는 법률상 양립할 수 없는 관계이므로 주관적 예비적 공동소송의 요건을 구비한다.

(2) 피고 추가의 적법성

- 원고 甲이 제1심 소송 계속 중에 A은행을 예비적 피고로 추가한다는 취지의 준비서면을 제출한 것은 제1심 변론종결 전의 서면 신청으로 적법한 피고 추가 신청이다.

2. 법원의 조치 및 판단의 대입

(1) 법원의 허가 및 송달 조치

- 수소법원은 甲의 신청을 피고 추가 신청으로 다루어 허가결정을 내려야 한다. 허가결정 정본을 乙과 A은행에 송달하고, A은행에는 소장 부분도 함께 송달하여 절차를 마쳐야 한다.

(2) 전부판결의 수행

- 법원은 乙에 대한 청구와 A은행에 대한 청구 모두를 판단하여야 한다. 당사자능력이 없는 乙에 대한 청구는 각하하되, 예비적 피고인 A은행에 대해서는 본안을 실질적으로 심리하여 판결한다.

V. 결론

- 원고 甲이 乙을 상대로 제기한 소송 중 A은행을 예비적 피고로 추가한 소송형태는 법률상 양립 불가능한 공동소송 및 피고 추가 요건을 충족하므로 적법하다. 법원은 피고 추가 허가결정을 내리고 정본과 소장 부분을 송달하여야 한다. 또한 전부판결 원칙에 따라 乙에 대한 청구를 각하·기각함과 동시에 예비적 피고인 A은행에 대한 청구를 판단하여야 한다.

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제01절 공동소송>

[기출][2020-3]유사필수적 공동소송의 의의, 성립요건 및 소송수행상의 특징

《【문제3】 유사필수적 공동소송에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 유사필수적 공동소송의 의의, 성립요건 및 소송수행상의 특징

I. 유사필수적 공동소송의 의의

- 유사필수적 공동소송이란 공동소송인들 각자가 단독으로 소를 제기할 권능이 있으나, 법률의 규정에 의하여 판결의 효력이 제3자에게 미치거나(대세효) 판결의 결과가 반드시 일치해야 하는 공동소송을 의미한다.(민사소송법 제67조 준용) 이는 고유필수적 공동소송과 달리 당사자 전원이 함께 소를 제기하거나 제기당할 필요는 없지만, 일단 공동소송이 성립하면 그 절차 내에서는 심리 및 확정 of 통일이 강제되는 형태이다. 주로 회사관계 소송이나 행정소송 등에서 판결의 모순을 방지하기 위해 인정된다.

II. 유사필수적 공동소송의 성립요건

1. 공동소송인 간의 합일확정 필요성

- 판결의 결과가 공동소송인들 사이에서 서로 모순되지 않게 일치해야 할 법률상 필요성이 있어야 한다. 이는 주로 판결의 효력이 당사자 이외의 제3자에게도 미치는 대세효가 인정되는 경우에 발생한다.

2. 소송의 개시와 당사자 적격

- 고유필수적 공동소송과 달리, 공동소송인 전원이 소송의 당사자가 될 필요는 없다. 각 당사자는 단독으로 소를 제기하거나 피고가 될 수 있는 당사자 적격을 가진다. 다만, 여러 사람이 동일한 대상에 대하여 소를 제기하여 소송이 병합된 경우에 비로소 유사필수적 공동소송으로서의 성질을 갖게 된다.

III. 유사필수적 공동소송의 구체적 사례

1. 회사관계 소송

- 상법상 주주총회결의 취소의 소, 무효확인 of 소 등이 대표적이다. 동일한 결의에 대하여 여러 주주가 각기 소를 제기한 경우, 판결의 효력이 모든 주주에게 미치므로(상법 제190조 준용) 병합된 소송은 유사필수적 공동소송이 된다.

2. 행정소송

- 행정처분의 취소를 구하는 소송에서 여러 사람이 동일한 처분에 대하여 소를 제기한 경우, 취소판결의 제3자효(행정소송법 제29조)로 인하여 합일확정이 필요하므로 유사필수적 공동소송이 성립한다.

IV. 소송수행상의 특징 [민사소송법 제67조 준용]

1. 소송자료의 공통

- 공동소송인 중 1인의 소송행위는 전원의 이익을 위해서만 효력을 가진다. 따라서 1인이 제출한 유리한 증거나 주장은 다른 공동소송인에게도 효력이 미치지 않지만, 1인이 행한 자백이나 포기 등 불리한 행위는 전원이 함께하지 않는 한 효력이 발생하지 않는다.

2. 소송진행의 공통

- 공동소송인 1인에 대한 중단이나 중지 사유는 전원에게 영향을 미친다. 또한 기일의 통지나 송달 등 절차적 사항도 전원을 대상으로 이루어져야 소송 절차의 통일성을 유지할 수 있다.

3. 판결의 합일확정

- 법원은 공동소송인들에 대하여 반드시 하나의 판결을 내려야 하며, 판결의 주문에서 각 당사자별로 결론이 달라져서는 안 된다. 일부 당사자에 대한 일부 판결은 허용되지 않는다.

V. 상소 제기 시의 취급

1. 상소의 불가분 원칙

- 공동소송인 중 1인이 상소를 제기하면 소송 전체가 상소심으로 이전하며, 상소를 제기하지 않은 다른 공동소송인도 상소심의 당사자가 된다. 이는 판결의 합일확정을 위해 필수적인 조치이다.

2. 상소심의 심판 범위

- 상소심 법원은 상소를 제기한 당사자의 불복 범위에 국한되지 않고, 공동소송인 전체의 청구에 대하여 심리하고 판결해야 한다.

VI. 고유필수적 공동소송과의 구별

1. 소의 제기 단계에서의 차이

- 고유필수적 공동소송은 처음부터 전원이 함께 소를 제기하지 않으면 소 자체가 부적법하여 각하되나, 유사필수적 공동소송은 단독 제기가 가능하며 절차 도중의 병합을 통해 필수적 공동소송의 형태를 띠는 점에서 차이가 있다.

2. 추가의 허용 여부

- 유사필수적 공동소송에서는 민사소송법 제68조에 따른 공동소송인 추가 제도가 적용되지 않는다. 단독으로 소 제기가 가능하므로 누락된 자를 추가할 필요가 없기 때문이다.

VI. 결론

- 유사필수적 공동소송은 판결의 대세효로 인해 발생할 수 있는 법적 혼란을 방지하기 위한 제도적 장치이다. 단독 소제기의 자유를 보장하면서도 일단 병합된 이후에는 심리의 통일을 강제함으로써 재판의 모순을 제거하고 사법 신뢰를 높이는 기능을 수행한다. 실무적으로는 회사 소송이나 다수인이 연루된 행정소송에서 빈번히 활용되므로, 법원은 합일확정의 원칙에 따라 소송자료의 공통과 상소의 불가분 원칙을 엄격히 적용하여 당사자 간의 형평을 기해야 한다.

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제01절 공동소송>

[기출][2021-1-2]공동소송인 독립의 원칙과 증거공통의 원칙에 따른 청구기각 판결의 적법성

《【문제1】 甲은 乙에게 5,000만 원을 대여하였고, 丙은 乙의 대여금채무를 보증하였다. 乙이 변제하지 않자 甲은 5,000만 원을 반환받기 위해서 乙과 丙을 공동 피고로 하여, 乙에 대해서는 주채무의 이행을 구하고 丙에 대해서는 보증채무의 이행을 구하는 소를 제기하였다. 다음 물음에 답하십시오. (단, 아래의 각 물음은 상호 독립적임) (50점)》

(물음2) 제1심 제1회 변론기일에 乙은 甲에게 대여금 5,000만 원을 모두 변제했다고 주장하고 그에 관한 증거를 제출하였다. 그러나 丙은 답변서도 제출하지 않았고 변론기일에도 불출석하였다. 법원이 증거조사한 결과 乙의 주장이 타당하다는 심증을 형성하였다면, 甲의 乙과 丙에 대한 각 청구를 기각하는 판결을 할 수 있는가? (25점)》

<문제1의 물음2> 공동소송인 독립의 원칙과 증거공통의 원칙에 따른 청구기각 판결의 적법성

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 乙을 주채무자로, 丙을 보증채무자로 하여 대여금 반환을 구하는 공동소송을 제기하였고, 乙은 변제항변과 증거를 제출한 반면 丙은 소송에 응하지 않은 상황이다. 쟁점으로 공동소송인 중 일부 당사자의 주장과 증거가 다른 공동소송인에 대한 청구 판단에 미치는 영향 및 법원이 甲의 각 청구를 함께 기각할 수 있는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 공동소송의 형태와 심판방법, 공동소송인 사이의 주장·증거의 효력 및 이에 따른 법원의 판결 가능 여부를 설명한다.

II. 통상공동소송의 심리원칙과 자백간주의 법리

1. 공동소송인 독립의 원칙과 주장공통의 원칙

(1) 공동소송인 독립의 원칙

- 민사소송법 제66조에 의하면 공동소송인 1인의 소송행위, 상대방의 소송행위 및 1인에 대해 생긴 사항은 다른 공동소송인에게 영향을 미치지 아니한다. 이를 공동소송인 독립의 원칙이라 하며, 사안의 주채무자·보증인 간 소송과 같은 통상공동소송에 전면 적용된다.

(2) 주장공통의 원칙의 인정 여부

- 공동소송인 독립의 원칙상 공동소송인 중 1인이 제출한 주요사실에 관한 주장은 다른 공동소송인에게 효력이 미치지 않는바, 이를 주장공통의 원칙 부정이라 한다. 대법원 역시 통상공동소송에서는 공동소송인 독립의 원칙이 적용되므로 공동소송인 중 1인이 한 주장은 다른 공동소송인에게 원칙적으로 효력이 미치지 않는다고 판시하여 이를 명백히 부정한다.

2. 증거공통의 원칙과 자백간주의 법리

(1) 증거공통의 원칙

- 증거공통의 원칙이란 공동소송인 중 1인이 제출한 증거는 다른 공동소송인과의 관계에서도 사실인정의 자료로 삼을 수 있다는 법리이다. 판례는 공동소송인 독립의 원칙에도 불구하고 소송 자료의 유기적 결합을 위해 이를 인정한다. 다만 변론주의 원칙상 사실의 주장이 전제되어야 하므로, 당사자가 주장하지 않은 사실을 타방의 증거만을 통해 임의로 인정할 수는 없다.

(2) 답변서 미제출 및 기일 불출석의 효과

- 민사소송법 제150조 제1항·제3항에 의하면, 당사자가 답변서를 제출하지 아니하고 변론기일에 출석하지 아니한 때에는 상대방이 주장한 사실을 자백한 것으로 본다. 이를 자백간주라 하며 법원은 이에 구속된다.

III. 사안의 적용

1. 피고 乙에 대한 청구의 판단

- 피고 乙은 제1회 변론기일에 변제 사실을 독자적으로 주장하였고 적법한 증거를 제출하였다. 수소법원이 심리 및 증거조사를 통해 乙의 변제 주장이 타당하다는 확고한 심증을 형성하였으므로, 대여금채무는 변제로 인하여 소멸한 사실이 인정된다. 따라서 법원은 원고 甲의 피고 乙에 대한 청구를 기각하여야 한다.

2. 피고 丙에 대한 청구의 판단

(1) 주장공통원칙의 부정에 따른 제한

- 피고 丙은 소송과정에서 어떠한 변제 주장도 제기하지 않았다. 주장공통의 원칙이 부정되므로 주채무자 乙이 행한 변제 주장은 보증인 丙에게 효력이 미치지 않는다.

(2) 증거공통원칙의 적용 한계와 자백간주의 성립

- 乙이 제출한 증거가 증거공통의 원칙에 따라 丙을 위해서도 사용될 수 있으나, 변론주의의 한계상 丙이 변제 사실 자체를 주장하지 않았으므로 법원은 丙을 위하여 변제 사실을 인정할 수 없다. 나아가 丙은 답변서를 제출하지 않고 변론기일에 불출석하였으므로 민사소송법 제150조에 따라 甲이 주장한 대여금 채무의 존재를 자백한 것으로 의제된다.

(3) 부증성의 예외적 차단과 판결의 범위

- 보증채무의 부증성이라는 실체법적 성질이 존재하나, 소송법적으로는 변론주의와 공동소송인 독립의 원칙이 우선 적용된다. 따라서 법원은 丙에 대하여 변제 사실을 인정할 수 없으며 자백간주에 구속되므로, 보증채무의 이행을 구하는 甲의 丙에 대한 청구는 인용하여야 한다.

IV. 결론

- 수소법원은 주채무자인 피고 乙에 대한 청구는 변제 사실의 인정에 의하여 기각하여야 하는 반면, 보증인인 피고 丙에 대한 청구는 자백간주 성립에 의하여 인용하여야 한다. 결과적으로 법원은 피고 乙에 대한 청구는 기각하고 피고 丙에 대한 청구는 인용하는 일부인용(일부기각) 판결을 선고하여야 하므로, 甲의 乙과 丙에 대한 각 청구를 모두 기각하는 판결을 할 수는 없다.

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제01절 공동소송>

[기출][2022-1-2]공동선정당사자 중 1인의 진술이 가지는 소송상 효력

《[문제1] 동업관계에 있는 乙, 丙, 丁, 戊는 자신들의 사업장 앞에 있는 X토지를 甲으로부터 임차하여 주차장으로 사용하고 있었다. 위 4인을 대표한다고 주장하는 乙은 X토지를 甲으로부터 매수하기로 하고 甲과 X토지에 대한 매매계약을 체결하였다. 사업자금의 대출을 위해 X토지의 등기가 필요하다는 사정을 들은 甲은 매매대금의 전액을 지급받지 못하였음에도 불구하고 X토지의 등기를 위 4인에게 이전하여 주었으나 위 4인은 매매잔대금을 지급하지 않고 있다. 이에 甲은 乙, 丙, 丁, 戊를 상대로 주위적으로는 매매계약이 유효하다면 X토지의 매매대금 전액의 지급을 구하고, 예비적으로는 매매계약이 무효라면 X토지의 소유권이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. (단, 아래의 각 물음은 독립적임) (50점)

(물음2) 소송계속 중 乙, 丙, 丁, 戊는 乙과 丙을 선정당사자로 선정하였다. 심리 도중 丙은 매매대금의 일부가 甲에게 이미 지급되었다고 주장하고 있으나, 乙은 甲이 주장하는 바와 같이 매매대금의 전액이 미지급상태에 있다고 진술하였다. 이러한 乙의 진술은 소송상 어떠한 효력을 가지는지 설명하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 공동선정당사자 중 1인의 진술이 가지는 소송상 효력

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙, 丙, 丁, 戊가 선정당사자를 선정하여 소송을 수행하는 과정에서 선정당사자인 乙과 丙이 서로 다른 내용의 진술을 하고 있는 상황이다. 쟁점으로 선정당사자가 복수인 경우 각 선정당사자의 소송상 진술이 다른 선정자 및 다른 선정당사자에게 미치는 효력과 그 법적 의미를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 선정당사자의 소송수행권과 선정당사자 상호 간 진술의 효력 및 소송상 취급을 검토한다.

II. 선정당사자 제도의 의의 및 법적 지위

1. 의의

- 선정당사자란 공동의 이해관계를 가진 다수의 사람 중에서 그 집단을 대표하여 소송을 수행하기 위해 선정된 사람을 말한다.(민사소송법 제53조) 이는 다수당사자 소송의 복잡함을 피하고 소송경제를 도모하기 위한 제도이다.

2. 법적 지위

- 선정당사자는 선정자들로부터 소송수행권을 위임받은 법정소송담당자이다. 선정당사자가 선정되면 선정자들은 소송에서 탈퇴하게 되며, 선정당사자가 받은 판결의 효력은 민사소송법 제218조 제3항에 따라 선정자 전원에게 미친다.

III. 공동선정당사자의 소송수행 방식

1. 소송수행의 독립성 원칙

- 선정당사자가 여러 명 선정된 경우, 각 선정당사자는 원칙적으로 독립하여 소송을 수행할 수 있다. 즉, 각자가 전원을 위하여 소송행위를 할 수 있는 권한을 가진다.

2. 필수적 공동소송 규정의 준용 여부

(1) 학설 및 판례의 태도

- 공동선정당사자 간의 관계에 대하여 판례는 민사소송법 제67조의 필수적 공동소송에 관한 규정을 준용한다. 선정당사자들은 선정자 전원을 위하여 하나의 소송물을 다투는 것이므로, 판결의 합일확정이 요구되기 때문이다.

(2) 소송행위의 효력 제한

- 필수적 공동소송 규정이 준용됨에 따라, 공동선정당사자 중 1인의 소송행위가 전원에게 이익이 되는 경우에는 효력이 발생하지만, 전원에게 불이익한 행위는 전원이 함께 하지 않으면 효력이 발생하지 않는다.

IV. 사안의 적용 : 乙의 진술에 대한 효력 판단

1. 乙과 丙의 진술 성격 분석

- 丙의 일부 지급 주장은 피고 측에 유리한 항변인 반면, 乙의 전액 미지급 진술은 원고의 주장을 시인하는 것으로서 피고 측(선정자 포함)에게 불리한 사실상의 자백 또는 자백에 준하는 진술에 해당한다.

2. 불리한 소송행위의 효력 제한 [민사소송법 제67조 제1항]

- 필수적 공동소송의 원칙상 공동당사자 중 1인의 소송행위가 다른 공동당사자에게 불리한 경우에는 그 효력이 발생하지 않는다. 乙의 진술은 丙의 항변을 부정하고 원고의 청구 원인을 인정하는 것이므로 선정자들 전체에게 불이익한 행위이다.

3. 진술의 상충과 법원의 처리

- 공동선정당사자 간의 진술이 일치하지 않는 경우, 불이익한 진술을 한 乙의 행위는 효력이 없다. 따라서 乙의 진술은 재판상 자백으로서의 효력을 가질 수 없으며, 법원은 丙이 주장한 일부 변제 사실에 대하여 증거조사를 거쳐 사실관계를 확정하여야 한다.

V. 결론

- 공동선정당사자 중 1인인 乙이 행한 매매대금 전액 미지급이라는 진술은 다른 선정당사자인 丙의 진술과 상충하며, 선정자 전원에게 불리한 소송행위이다. 선정당사자 간에는 필수적 공동소송 규정이 준용되므로, 乙의 이러한 불리한 진술은 소송법상 효력이 발생하지 않는다. 법원은 乙의 자백에 구속되지 않고 丙의 항변을 바탕으로 대금 지급 여부를 심리하여야 한다.

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제01절 공동소송>

[기출][2024-1-1]원고가 제1심 소송계속 중 연대보증인을 예비적 피고로 추가한 행위의 적법성 여부

《【문제1】 甲은 乙에 대해 1억 원의 대여금을 청구하는 소를 제기(이하 '이 사건 소송'이라 하며, 원금 이외의 이자나 지연손해금 등은 고려하지 않는다)하였다. 다음 물음에 답하시오. (아래의 각 물음은 독립적이며, 문제에서 제시되지 아니한 사항은 적법한 것으로 본다.) (50점)

(물음1) 원고 甲은 제1심 소송계속 중 피고 乙의 원고 甲에 대한 1억 원의 대여금 채무 전액에 대해서 연대보증한 丙을 예비적 피고로 추가하였다. 이러한 예비적 피고의 추가가 적법한지 설명하시오. (20점)》

<문제1의 물음1> 원고가 제1심 소송계속 중 연대보증인을 예비적 피고로 추가한 행위의 적법성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기한 후 제1심 소송계속 중 해당 채무를 연대보증한 丙을 예비적 피고로 추가하려는 상황이다. 쟁점으로 소송 계속 중 제3자를 예비적 피고로 추가하는 것이 허용되는지와 그 요건 및 소송법상 취급을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 예비적 피고 추가의 법적 성질과 허용 여부 및 그 적법요건을 설명한다.

II. 주관적 예비적 · 선택적 공동소송의 의의와 요건

1. 의의

- 공동소송인들 사이에 법률상 양립할 수 없는 관계가 있어, 주위적 피고에 대한 청구가 인용되지 않을 것을 대비하여 예비적 피고에 대한 청구를 병합하거나, 누구에 대한 청구인지 선택적으로 판단을 구하는 형태를 말한다.

2. 성립 요건

- 민사소송법 제70조 제1항에 따르면, 공동소송인들 가운데 일부의 청구가 다른 공동소송인의 청구와 법률상 양립할 수 없어야 한다.

(1) 법률상 양립 불가능성

- 법률상 양립할 수 없다는 것은 동일한 사실관계에 바탕을 둔 권리관계에서 어느 한쪽의 권리가 인정되면 다른 쪽의 권리가 부정되는 관계를 의미한다. 예를 들어 갑이 소유자인지 을이 소유자인지와 같은 관계이다.

(2) 상호 관련성

- 각 피고에 대한 청구는 동일한 법률관계나 사실관계에 기초하여야 한다.

III. 소송계속 중 피고 추가(주관적 추가적 병합)의 허용 여부

1. 원칙적 불허

- 민사소송법은 소송계속 중 제3자를 새로운 피고로 추가하는 주관적 추가적 병합을 원칙적으로 허용하지 않는다. 이는 피고의 교체나 추가가 무분별하게 이루어질 경우 소송 절차가 지연되고 새로운 피고의 심급의 이익을 해칠 우려가 있기 때문이다.

2. 예외적 허용 [민사소송법 제70조 제1항 단서]

- 과거에는 소송 제기 시에만 예비적 공동소송이 가능했으나, 2002년 민사소송법 개정을 통해 소송계속 중에도 부진정연대채무나 양립 불가능한 관계에 있는 피고를 추가할 수 있는 근거가 마련되었다. 다만, 이는 제67조 내지 제69조의 규정을 준용하는 범위 내에서 엄격한 요건 하에 허용된다.

IV. 사안의 적용

1. 법률상 양립 가능성 검토

- 주채무자 乙에 대한 대여금 청구와 연대보증인 丙에 대한 보증채무 이행 청구는 법률상 양립 가능하다. 주채무가 인정된다고 하여 보증채무가 부정되는 것이 아니며, 오히려 보증채무는 주채무의 존재를 전제로 하는 부종성을 가진다. 따라서 乙과 丙에 대한 청구는 법률상 양립할 수 없는 관계가 아니다.

2. 피고 추가의 적법성 판단

- 사안의 경우 乙과 丙은 실질적으로 연대하여 채무를 부담하는 관계이거나 주채무-보증채무의 관계에 불과하므로, 민사소송법 제70조가 요구하는 양립 불가능 요건을 충족하지 못한다. 또한, 소송계속 중 예비적 피고를 추가하기 위해서는 제70조 제1항의 요건을 갖추어야 하는데, 본 사안은 이에 해당하지 않는다.

V. 결론

- 원고 甲이 丙을 예비적 피고로 추가하는 것은 민사소송법 제70조 제1항 소정의 예비적 공동소송 요건(법률상 양립 불가능성)을 갖추지 못하였으므로 부적법하다. 따라서 법원은 甲의 피고 추가 신청을 각하하거나 허가하지 않아야 한다.

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제01절 공동소송>

[모의][12.01-1]민법상 조합의 당사자능력 및 선정당사자 제도의 요건과 효과

【문제12.1】

<사례>

A, B, C 세 사람은 공동으로 식당을 운영하기 위하여 동업계약을 체결하고 "행복식당"이라는 명칭을 정하였다. 이들은 식당 운영에 필요한 자재를 공급받았으나 그 대금을 지급하지 못하고 있다. 자재 공급업자인 丁은 "행복식당" 또는 동업자들을 상대로 소를 제기하여 대금을 회수하고자 한다.

또한, 위 동업자들은 식당 인근의 공사 현장에서 발생하는 소음으로 인해 영업에 큰 차질을 빚게 되자, 공사 업체인 戊를 상대로 손해배상청구의 소를 제기하기로 하였다. 이들은 소송의 효율성을 위해 동업자 중 1인인 A를 소송수행자로 정하여 소를 제기하고자 한다.

丁이 "행복식당" 자재를 피고로 하여 소를 제기할 수 있는지 여부를 민법상 조합의 당사자능력 관점에서 판단하고, A가 동업자들을 대표하여 戊를 상대로 소를 제기하기 위해 필요한 민사소송법상 요건 및 그 효과에 대하여 설명하시오.》

<문제12.1> 민법상 조합의 당사자능력 및 선정당사자 제도의 요건과 효과

I. 문제의 제기

- 사안에서 A, B, C가 공동으로 식당을 운영하는 동업관계에 있고, 자재대금채권자인 丁이 행복식당 또는 동업자들을 상대로 소를 제기하려 하며, 동업자들이 A를 소송수행자로 정하여 손해배상청구소송을 제기하려는 상황이다. 쟁점으로 민법상 조합의 당사자능력 인정 여부와 선정당사자 제도에 따른 소송수행의 요건 및 그 효과를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 조합의 당사자능력과 선정당사자에 의한 소송수행의 허용 요건 및 법적 효과를 설명한다.

II. 민법상 조합의 당사자능력

1. 원칙 : 당사자능력의 부정

(1) 조합의 실체

- 민법상 조합은 2인 이상이 상호 출자하여 공동사업을 경영할 것을 약정함으로써 성립하는 계약 관계에 불과하다. 따라서 조합은 법인격이 없으며, 원칙적으로 민사소송법 제51조·제52조에 따른 당사자능력이 인정되지 않는다.

(2) 소송 수행 방식

- 조합의 채권자나 채무자는 조합원 전원을 공동원고 또는 공동피고로 하여 소를 제기하여야 한다. 이는 조합 재산이 조합원의 합유에 속하기 때문에 발생하는 소송법적 결과다.

2. 판례의 태도

(1) 비법인사단과의 구별

- 판례는 단체의 실체가 사단적 형태를 갖추고 대표자가 정해져 있는 등 비법인사단(민사소송법 제52조)으로 볼 수 있는 경우에는 당사자능력을 인정한다. 그러나 단순한 동업 계약에 기초한 민법상 조합에 대해서는 일관되게 당사자능력을 부정하고 있다.

(2) 행복식당의 경우

- 사안의 행복식당은 A, B, C의 동업 계약에 의해 운영되는 단체이므로, 특별한 사단적 실체가 증명되지 않는 한 민법상 조합에 해당한다. 따라서 丁은 행복식당 자재를 피고로 할 수 없고, 동업자 A, B, C 전원을 공동피고로 하여 소를 제기하여야 한다.

III. 선정당사자 제도

1. 의의 및 취지

- 선정당사자란 공동의 이해관계를 가진 다수의 사람 중에서 그들을 대표하여 소송을 수행하기 위해 선정된 자를 말한다. 이는 다수당사자 소송의 복잡함을 피하고 소송 경제를 도모하기 위한 제도다.

2. 요건

(1) 공동의 이해관계

- 선정자와 피선정자 사이에 소송물이 공통되거나 소송의 목적이 되는 권리·의무가 같은 법률상 또는 사실상의 원인에 바탕을 두고 있어야 한다. 사안의 동업자들은 공사 소음으로 인한 영업권 침해라는 동일한 사실관계에 기초한 손해배상청구권을 가지므로 공동의 이해관계가 인정된다.

(2) 다수자의 존재

- 선정자는 여러 명이어야 하며, 이들이 피선정자(선정당사자)를 선임해야 한다.

(3) 피선정자의 자격

- 선정당사자는 공동의 이해관계를 가진 당사자 중에서 선정되어야 한다. 동업자 중 1인인 A는 당사자 중 한 명이므로 피선정자 자격이 있다.

3. 선정의 방법과 시기

- 선정은 서면으로 증명해야 하며, 소송 계속 전후를 불문하고 가능하다. 또한 심급마다 선정할 수도 있고 전 소송을 통틀어 선정할 수도 있다.

IV. 선정의 효과 및 소송수행

1. 선정자의 지위

- 선정이 완료되면 선정자들은 소송에서 탈퇴하게 되며, 소송의 당사자 지위를 상실한다. 따라서 이들은 별도로 소를 제기하거나 소송에 직접 참여할 수 없다.

2. 선정당사자의 권한

(1) 소송수행권의 독점

- 선정당사자는 선정자들을 위하여 일체의 소송행위를 할 권한을 갖는다. 여기에는 소의 취하, 화해, 포기, 인낙 등 처분권 행사가 포함되나, 선정자들이 권한을 제한한 경우에는 그에 따라야 한다.

(2) 판결의 효력(기판력)

- 선정당사자가 받은 판결의 효력은 민사소송법 제218조 제3항에 따라 선정자 전원에게 미친다. 따라서 판결 확정 후 선정자들은 동일한 사안으로 다시 소를 제기할 수 없다.

V. 사안의 적용

1. 丁의 소 제기

- 丁은 민법상 조합인 행복식당을 피고로 삼을 수 없다. 판례에 따라 당사자능력이 없는 조합을 상대로 한 소는 부적법각하 대상이 되므로, 丁은 동업자 A, B, C를 공동피고로 하여 소를 제기하여야 한다.

2. A의 선정당사자 소송

- 동업자 B와 C가 A를 선정당사자로 선정하는 서면을 제출한다면, A는 동업자 전체를 대표하여 戊를 상대로 소를 제기할 수 있다. 이 경우 B와 C는 소송에서 탈퇴하며, A가 얻은 판결의 결과는 B와 C에게도 귀속된다. 이는 변호사 대리의 원칙을 잠탈하지 않으면서도 다수자의 소송 편의를 도모하는 적법한 방식이다.

V. 결론

- 민법상 조합은 당사자능력이 없으므로 조합 자체를 피고로 할 수 없으나, 조합원들이 선정당사자 제도를 이용하는 것은 가능하다. A가 적법하게 선정당사자로 선임된다면 동업자들의 공동 이해관계를 효율적으로 실현할 수 있으며, 그 판결의 효력은 동업자 전원에게 미치게 된다.

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제01절 공동소송>

[모의][12.01-2]필수적 공동소송의 의의 및 통상공동소송과의 구별, 분류 및 발생원인, 심리상 특징

《【문제12.1-2】 필수적 공동소송에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제12.1의 물음2> 필수적 공동소송의 의의 및 통상공동소송과의 구별, 분류 및 발생원인, 심리상 특징

I. 필수적 공동소송의 의의 및 통상공동소송과의 구별

1. 필수적 공동소송의 의의

- 필수적 공동소송이란 소송물이 공동소송인 전체에 대하여 합일적으로 확정되어야 하는 공동소송을 말한다.(민사소송법 제67조) 이는 공동소송인 간에 서로 모순·저촉되는 판결이 선고되는 것을 방지함으로써 법적 안정성을 도모하고 분쟁을 유기적으로 해결하기 위해 인정되는 제도이다.

2. 통상공동소송과의 구별

- 통상공동소송은 각 공동소송인이 독립하여 소송을 수행하는 공동소송인 독립의 원칙(민사소송법 제66조)이 적용된다. 따라서 공동소송인 중 1인의 소송행위가 다른 공동소송인에게 영향을 미치지 않는다. 반면 필수적 공동소송은 판결의 합일확정 필요성으로 인하여 이러한 독립의 원칙이 배제되고 심리상의 강력한 제약과 특칙이 적용된다는 점에서 구별된다.

II. 필수적 공동소송의 분류 및 발생 원인

1. 고유필수적 공동소송

- 고유필수적 공동소송은 공동소송인 전원이 함께 소를 제기하거나 제기당하여야만 소송당사자적격(소송수행권)이 인정되는 형태이다. 만약 일부가 누락된 채 소가 제기되면 당사자적격 흠결로 소 전체가 부적법 각하된다. 대표적인 발생 원인으로는 공유물분할청구의 소, 합유물에 관한 소송 등이 있다.

2. 유사필수적 공동소송

- 유사필수적 공동소송은 당사자들이 처음부터 반드시 공동으로 소를 제기할 필요는 없지만, 일단 공동소송이 된 이상 판결이 합일적으로 확정되어야 하는 형태이다. 일부가 누락되더라도 소 제기 자체는 적법하지만, 공동소송이 개시된 후에는 합일확정을 위한 심리 특칙이 적용된다. 주주총회결의취소의 소 등이 이에 해당한다.

III. 심리상의 특칙 [민사소송법 제67조]

1. 소송자료의 제출과 소송행위의 공동 원칙

(1) 유리한 소송행위의 효력

- 공동소송인 중 1인의 소송행위는 전원의 이익을 위해서만 효력을 가진다.(민사소송법 제67조 제1항) 따라서 공동소송인 중 1인이 제출한 유리한 소송자료(증거의 제출, 항변 등)는 다른 공동소송인에게도 유효하게 효력을 미친다.

(2) 불리한 소송행위의 제한

- 공동소송인 중 1인의 소송행위가 다른 공동소송인에게 불리한 경우(소의 취하, 청구의 포기·인낙, 재판상 자백 등)에는 공동소송인 전원이 공동으로 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 않는다.(민사소송법 제67조 제2항)

2. 상대방의 소송행위와 소송절차의 중단

(1) 상대방의 소송행위의 효력

- 상대방이 공동소송인 중 1인에 대하여 한 소송행위(예: 소송고지, 상소 제기 등)는 공동소송인 전원에 대하여 그 효력이 발생한다.(민사소송법 제67조 제3항)

(2) 소송절차의 중단 및 수계

- 공동소송인 중 1인에게 소송절차의 중단 사유(예: 사망)가 발생한 경우, 소송절차는 전원에 대하여 중단된다. 이에 따른 소송 수계 신청 역시 전원에 대하여 행해져야만 중단 상태가 해소된다.

IV. 공동소송인의 추가 제도 [민사소송법 제68조]

1. 공동소송인 추가의 의의와 요건

- 고유필수적 공동소송에서 공동소송인의 일부가 누락된 경우 소각하 판결을 피하기 위하여 법원의 허가를 얻어 누락된 자를 소송에 추가하는 제도이다. 이는 제1심의 변론종결 전까지 원고의 신청에 의하여만 가능하며, 서면으로 신청하여야 한다.

2. 추가 결정의 법적 효과

- 법원의 허가 결정이 있으면 추가된 자는 최초로 소가 제기된 때에 공동소송인으로 소를 제기하거나 제기당한 것으로 본다.(소급효) 이로 인해 제척기간의 준수나 소멸시효 중단의 효력이 소급하여 발생한다.

V. 결론

- 필수적 공동소송은 재판의 합일확정이라는 공익적 요청을 달성하기 위한 제도로서, 통상공동소송과 달리 심리상의 엄격한 통일성을 요한다. 민사소송법 제67조는 공동소송인 간의 이해관계를 조절하기 위해 유리한 소송행위와 불리한 소송행위의 효력을 다르게 규정하고 있으며, 제68조의 추가 제도를 두어 당사자적격의 흠결로 소가 무자비하게 각하되는 것을 예방하고 있다. 법원은 이러한 제도들을 유기적으로 결합하여 소송경제와 실체적 정의를 함께 달성해야 할 것이다.

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제02절 제3자의 소송참가>

[기출][2011-2-1]보조참가인에 대한 재판의 효력의 의의 및 성질과 범위

《【문제2】 다음 문제를 설명하시오.

(물음1) 보조참가인에 대한 재판의 효력 (25점)》

<문제2의 물음1> 보조참가인에 대한 재판의 효력의 의의 및 성질과 범위

I. 참가적 효력의 의의

- 보조참가란 타인 간의 소송계속 중 소송결과에 대하여 이해관계가 있는 제3자가 한쪽 당사자의 승소를 돕기 위하여 소송에 참여하는 형태를 말한다. **민사소송법 제77조**는 보조참가인에 대하여 판결의 효력이 미친다고 규정하고 있는데, 이를 기판력과 구별하여 참가적 효력이라고 부른다. 이는 피참가인이 패소하였을 때 참가인이 피참가인에게 패소의 책임을 전가하지 못하게 함으로써 재판의 모순을 방지하는 데 목적이 있다.

II. 참가적 효력의 본질 및 성질

1. 학설의 대립

(1) 기판력설

- 보조참가인에 미치는 효력을 **민사소송법 제218조 제1항**의 기판력으로 보는 견해이다. 그러나 보조참가인은 당사자가 아니라는 점과 기판력은 승패와 무관하게 발생하나 참가적 효력은 패소 시에만 문제된다는 점에서 비판받는다.

(2) 특수효력설(참가적 효력설)

- 기판력과는 별개로 보조참가라는 소송제도에 특유한 정책적 효력으로 보는 견해이다. 피참가인과 참가인 사이에서만 발생하는 상대적 효력이라는 점을 강조한다.

2. 판례의 태도

- **판례**는 보조참가인에게 미치는 판결의 효력은 기판력이 아니라 이른바 참가적 효력이라고 본다. 이는 피참가인이 패소한 경우에 참가인과 피참가인 사이에 한하여 발생하는 효력으로서, 참가인이 판결의 기초가 된 사실상·법률상 판단이 부당하다고 주장할 수 없는 구속력을 의미한다.

III. 참가적 효력의 발생요건

1. 유효한 보조참가의 계속

- 참가인이 소송에 실제로 참여하여 공격방어방법을 제출할 수 있는 상태에 있어야 한다.

2. 피참가인의 패소 판결

- 참가적 효력은 참가인이 도운 피참가인이 패소했을 때만 발생한다. 만약 피참가인이 승소했다면 참가인에게 불이익이 없으므로 효력이 발생할 여지가 없다.

3. 판결의 확정

- 판결이 상소 등으로 확정되지 않은 상태에서는 효력이 발생하지 않으며, 확정 판결의 결론뿐만 아니라 그 전제가 된 판단에도 효력이 미친다.

IV. 참가적 효력의 범위

1. 주관적 범위

- 참가적 효력은 피참가인과 보조참가인 사이에서만 발생한다. 따라서 상대방 당사자와 참가인 사이, 혹은 제3자와 참가인 사이에는 이 효력이 미치지 않는다.

2. 객관적 범위

(1) 주문 및 이유 중의 판단

- 기판력이 판결주문에만 미치는 것과 달리, 참가적 효력은 판결주문뿐만 아니라 그 전제가 된 이유 중의 사실인정 및 법률적 판단에도 미친다.

(2) 효력이 미치는 판단의 범위

- 다만, 모든 판단에 미치는 것은 아니며 판결의 결론에 도달하기 위해 필수적인 주요 사실 및 법률 판단에 한하여 미친다. 판결의 결론과 직접 관련 없는 방론이나 부수적 판단에는 미치지 않는다.

V. 참가적 효력의 배제(한계)

1. 민사소송법 제77조 단서의 배제사유

(1) 참가 시 소송상태에 따른 제한

- 참가 당시 이미 소송이 진행되어 참가인이 공격방어방법을 제출할 수 없었던 경우(**제77조 제1호**)에는 효력이 미치지 않는다.

(2) 피참가인의 행위에 의한 제한

- 피참가인이 참가인의 소송행위와 저촉되는 행위를 하여 참가인의 활동이 방해받은 경우(**제77조 제2호**)에는 참가인에게 책임을 물을 수 없다.

(3) 피참가인의 고의·과실에 의한 제한

- 피참가인이 참가인에게 알리지 않고 소송을 진행하거나 고의·과실로 상대방의 공격방법에 대응하지 않은 경우(**제77조 제3호**)에도 효력은 배제된다.

2. 신의칙에 의한 제한

- 참가인이 소송에 참여하였더라도 피참가인의 불성실한 소송수행으로 인하여 적절한 방어를 하지 못한 특별한 사정이 있다면 신의칙상 효력을 제한할 수 있다.

VI. 결론

- 보조참가인에 대한 재판의 효력인 참가적 효력은 피참가인과 참가인 사이의 공평한 책임 분담을 위한 특수한 효력이다. 이는 판결의 이유 중 판단에까지 미친다는 점에서 기판력보다 넓은 객관적 범위를 가지나, 피참가인과 참가인 사이라는 한정된 주관적 범위를 갖는다. 결국 보조참가인은 자신이 도운 당사자가 패소했을 때 그 결과에 대하여 연대책임을 지되, **민사소송법 제77조 단서**가 정한 방어권 보장이 미흡했던 경우에는 그 효력에서 벗어날 수 있도록 함으로써 절차적 정의와 재판의 모순 방지를 조화시키고 있다.

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제02절 제3자의 소송참가>

[기출][2017-1-1]보조참가인에 대한 전소 판결의 참가적 효력 인정 여부

《【문제1】 乙 회사의 근로자 丙이 업무상 운전하던 차량이 보행자 甲을 충격하여 부상을 입혔다. 甲이 乙 회사를 피고로 하여 제기한 교통사고로 인한 손해배상청구의 소(전소)에서 丙이 乙 회사측에 보조참가하여 소송이 진행되었고, 법원은 丙의 운전상의 과실을 인정하여 甲 청구인용판결을 선고하여 이 판결이 확정되었다. 그 후 乙 회사가 丙을 피고로 위 손해배상에 대한 구상금을 청구하는 소(후소)를 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(아래 각 질문은 상호 무관함)

(물음1) 丙이 보조참가한 전소의 甲 청구인용의 확정판결이 후소에 효력을 미치는지를 설명하시오. (35점)》

<문제1의 물음1> 보조참가인에 대한 전소 판결의 참가적 효력 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 乙 회사를 상대로 한 손해배상청구소송에서 丙이 보조참가인으로 소송에 관여하여 확정판결이 내려진 후, 乙 회사가 丙을 상대로 구상금청구의 소를 제기한 상황이다. 쟁점으로 보조참가인이 관여한 전소의 확정판결이 후소에서 보조참가인인 丙에게 미치는 효력과 그 범위를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 보조참가인의 참가적 효력과 확정판결의 후소에 대한 구속력 여부를 설명한다.

II. 보조참가의 의의 및 요건

1. 의의

- 보조참가란 타인 사이의 소송계속 중 소송결과에 대하여 법률상 이해관계를 가진 제3자가 한쪽 당사자의 승소를 돕기 위해 소송에 참여하는 것을 말한다.

2. 요건

- 타인 사이의 소송이 계속 중이어야 하며, 소송결과에 대하여 법률상 이해관계가 있어야 한다. 사안의 丙은 乙이 패소할 경우 구상권 행사를 당할 처지에 있으므로 법률상 이해관계가 인정된다.

III. 참가적 효력의 이론적 기초

1. 의의 및 성격

- 참가적 효력이란 보조참가인이 참여한 소송의 판결이 확정된 경우, 참가인과 피참가인 사이에 발생하는 특수한 구속력을 의미한다. 이는 기판력과는 구별되는 효력으로서, 피참가인이 패소했을 때 참가인이 '내가 참여했다라면 이겼을 것'이라거나 '피참가인이 소송을 잘못 수행했다'고 주장하며 전소 판결의 부당함을 다투는 것을 방지하여 패소의 책임을 분담시키기 위한 제도이다.

2. 기판력과의 구별

- 기판력은 소송물인 법률관계의 존부에 대해 당사자 상호 간 및 후소 법원에 발생하는 효력이지만, 참가적 효력은 참가인과 피참가인이라는 내부 관계에서만 발생한다. 또한 기판력은 판결 주문에 한하여 발생하나, 참가적 효력은 판결 이유 중의 사실인정이나 법률판단에도 미친다는 점에서 차이가 있다.

IV. 참가적 효력의 발생 범위

1. 주관적 범위

- 참가적 효력은 참가인과 피참가인 사이에서만 발생한다. 따라서 전소의 상대방인 甲과 참가인 丙 사이에는 이러한 효력이 발생하지 않는다.

2. 객관적 범위

- 판결의 주문뿐만 아니라 판결의 결론을 도출하기 위해 판단된 사실관계와 법률적 판단 전부에 미친다. 다만, 피참가인의 패소와 직결되지 않는 부수적 판단이나 방론에는 미치지 않는다.

3. 시적 범위

- 전소의 사실심 변론종결 시를 기준으로 발생한다. 따라서 변론종결 후에 발생한 새로운 사정은 참가적 효력에 의해 차단되지 않는다.

V. 참가적 효력의 차단(효력의 제한)

1. 규정의 취지 [민사소송법 제86조 단서]

- 참가인이 참가 당시의 소송 정도에 따라 소송행위를 할 수 없었거나, 피참가인이 참가인의 소송행위를 방해한 경우 등에는 참가적 효력이 제한된다.

2. 구체적 사유

- 피참가인이 고의 또는 과실로 참가인에게 유리한 증거를 제출하지 않았거나, 참가인이 알 수 없었던 공격방어방법을 피참가인이 태만히 하여 행하지 않은 경우 등이 이에 해당한다.

VI. 사안의 적용

1. 丙에 대한 참가적 효력의 발생

- 丙은 전소에 보조참가하여 소송을 수행하였고 乙이 패소하여 판결이 확정되었으므로, 민사소송법 제86조 본문에 따라 丙과 乙 사이에는 참가적 효력이 발생한다.

2. 후소에서의 영향

- 전소 판결의 이유에서 丙의 운전상 과실이 인정되었고 이것이 乙의 패소 원인이 되었으므로, 이 사실인정은 참가적 효력의 객관적 범위에 포함된다. 따라서 乙이 丙을 상대로 제기한 구상금 청구 소송(후소)에서 丙은 전소 판결이 부당하다거나 자신에게 과실이 없었다는 주장을 할 수 없다. 후소 법원 역시 전소 판결의 판단과 모순되는 사실인정을 할 수 없으므로 丙의 과실을 전제로 구상 책임을 판단해야 한다.

3. 예외적 상황의 고려

- 만약 乙이 丙의 참가를 방해했거나 丙이 알 수 없는 사유로 적절한 방어를 하지 못한 특별한 사정이 입증된다면 참가적 효력이 배제될 수 있으나, 사안에 그러한 정황이 없다면 효력은 온전하게 발생한다.

VI. 결론

- 전소인 甲과 乙 사이의 손해배상청구 소송 판결은 보조참가인 丙과 피참가인 乙 사이에 참가적 효력을 미친다. 따라서 후소인 구상금 청구 소송에서 丙은 전소 판결에서 확정된 자신의 과실 유무를 다시 다툴 수 없으며, 전소 판결의 결과에 따른 책임을 乙과 분담해야 한다. 이는 소송수행의 책임을 공정하게 분배하려는 보조참가 제도의 취지에 부합하는 결과이다.

I. 문제의 제기

- 사안에서 피해자 甲이 乙 회사를 상대로 제기한 전소에 丙이 보조참가하여 丙의 과실이 인정되어 판결이 확정된 후, 乙 회사가 丙을 상대로 후소로서 구상금 청구 소송을 제기하였다. 이때 전소 판결의 기판력이 후소의 수소법원과 당사자 丙을 구속하는지, 아니면 **민사소송법 제77조**의 참가효가 발생하는지 및 그 적용 범위가 쟁점이 된다. 이하에서는 전소 판결이 후소에 미치는 소송법상 효력에 대하여 구체적으로 설명한다.

II. 보조참가인에 대한 판결의 효력 법리

1. 기판력과 참가효의 관계

(1) 기판력의 인적 범위 한계

- 기판력은 대립하는 당사자인 원고와 피고 사이에만 미치는 것이 원칙이다. (**민사소송법 제218조 제1항**) 따라서 공동의 편에 서서 소송을 수행한 피참가인과 보조참가인 상호간에는 전소 판결의 기판력이 미치지 않는다.

(2) 참가효의 의의 및 본질

- 참가효는 보조참가인이 공동으로 소송을 수행하였음에도 피참가인이 패소한 경우, 신의칙에 기하여 보조참가인과 피참가인 사이에 발생하는 특수한 소송법상 효력이다. (**민사소송법 제77조**) 이는 패소의 책임을 상호간에 공평하게 부담하도록 하는 데 취지가 있다.

2. 참가효의 주체적·객관적 범위 및 한계

(1) 참가효의 주체적 및 객관적 범위

- 참가효는 피참가인과 보조참가인 사이에서만 발생하며, 상대방 당사자에게는 미치지 않는다. 객관적 범위로는 판결 주문뿐만 아니라, 판결이유 중에서 패소의 원인이 된 사실인정 및 법률판단에까지 미친다는 점에서 기판력보다 넓은 범위를 가진다.

(2) 참가효의 예외적 배제 사유

- **민사소송법 제77조 단서**에 의하면, 보조참가인이 참가할 당시 소송정도가 진행되어 공격방어방법을 제출할 수 없었거나, 피참가인의 고의·과실로 인해 방해를 받은 경우 등 참가인에게 책임을 돌릴 수 없는 사유가 존재한다면 참가효는 예외적으로 배제된다.

III. 사안의 적용

1. 기판력의 미작용

- 전소의 소송당사자는 甲과 乙 회사이며 丙은 보조참가인에 불과하였다. 따라서 乙 회사와 丙 사이에서 진행되는 후소 구상금 소송에는 전소 확정판결의 기판력이 미치지 않는다.

2. 참가효의 발생 및 구체적 영향

(1) 전소 판결에 따른 참가효의 성립

- 丙은 전소에서 피고 乙 회사의 보조참가인으로 소송에 참여하였고, 전소에서 乙 회사의 패소 판결이 확정되었다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 전소 확정판결의 효력으로서 乙 회사와 丙 사이에는 참가효가 유효하게 발생한다.

(2) 후소 구상금 소송에의 구체적 차단 효과

- 전소에서 乙 회사가 패소하게 된 결정적 원인은 '丙의 운전상 과실'이었다. 이는 전소 판결이유 중 패소의 원인이 된 핵심적 사실인정에 해당하므로 참가효의 객관적 범위에 포함된다. 따라서 후소에서 丙은 전소 판결의 내용과 모순되게 자신에게 과실이 없었다고 주장할 수 없으며, 수소법원 역시 丙의 과실을 전제하여 구상금 청구의 당부를 심리해야 한다.

IV. 결론

- 전소 확정판결은 乙 회사와 丙 사이에 기판력은 미치지 않으나, **민사소송법 제77조**에 기한 참가효를 미친다. 따라서 전소 판결이유 중 패소의 원인이 된 丙의 과실 인정에 대하여 참가효가 발생하므로, 丙은 후소에서 자신의 과실을 부인하는 주장을 할 수 없다.

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제02절 제3자의 소송참가>

[기출][2018-2]소송고지의 의의, 요건, 절차 및 방식, 효력

《【문제2】 소송고지에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 소송고지의 의의, 요건, 절차 및 방식, 효력

I. 소송고지의 의의

- 소송고지란 소송계속 중 당사자가 그 소송에 참가할 수 있는 제3자에 대하여 소송계속의 사실을 법정의 방식에 따라 통지하는 것을 말한다.(민사소송법 제84조) 이는 고지자에게는 보조참가를 할 수 있는 자를 소송에 끌어들여 장래의 구상소송 등에서 판결의 효력을 미치게 함으로써 유리한 지위를 확보하게 하고, 피고지자에게는 소송 참여의 기회를 제공하여 자신의 권리를 방어할 수 있도록 하는 데 목적이 있다. 특히 고지자가 패소했을 때 피고지자가 '내가 참여했더라면 이겼을 것'이라고 주장하는 것을 방지하는 소송법적 효력이 발생한다.

II. 소송고지의 요건

1. 소송계속 중일 것

- 소송고지는 소송이 법원에 계속되어 있는 상태에서만 가능하다. 제1심뿐만 아니라 항소심에서도 가능하나, 판결이 확정된 후에는 고지할 수 없다.

2. 고지자와 피고지자의 자격

- 고지는 소송당사자(원고, 피고)뿐만 아니라 이미 참가한 보조참가인도 할 수 있다. 피고지자는 당해 소송에 참가할 수 있는 제3자여야 한다. 즉, 법률상 이해관계가 있어 보조참가나 공동소송참가, 독립당사자참가 등을 할 수 있는 자여야 한다.

3. 고지 사유의 존재

- 고지자는 피고지자에게 소송고지를 하는 이유를 명시해야 한다. 통상 고지자가 소송에서 패소할 경우 피고지자에게 구상권을 행사하거나, 반대로 피고지자로부터 책임을 추궁당할 염려가 있는 경우 등이 이에 해당한다.

III. 소송고지의 절차 및 방식

1. 서면에 의한 고지

- 소송고지는 고지 이유와 소송의 진행 정도를 적은 서면을 법원에 제출하여야 한다(민사소송법 제84조 제2항) 법원은 이 서면을 상대방과 피고지자에게 송달한다.

2. 고지의 시기

- 소송고지의 시기에 대해서는 특별한 제한이 없으나, 피고지자가 유효하게 소송에 참가하여 방어행위를 할 수 있는 시점에 이루어져야 효력이 온전하게 발생한다.

IV. 소송고지의 효력(참가적 효력)

1. 효력의 발생 근거

- 피고지자가 소송에 참가한 경우는 물론, 참가할 수 있었음에도 참가하지 않은 경우에도 민사소송법 제86조에 따라 참가적 효력이 발생한다. 이는 참가인과 피참가인 사이의 판결의 구속력을 의미한다.

2. 참가적 효력의 내용

- 참가적 효력은 기판력과는 구별되는 특수한 효력이다. 피고지자는 고지자와의 후행 소송에서 전소 판결이 부당하다고 주장하며 다툴 수 없게 된다.

(1) 주관적 범위

- 참가적 효력은 고지자와 피고지자 사이에서만 발생하며, 전소의 상대방에게는 미치지 않는다.

(2) 객관적 범위

- 판결의 주문뿐만 아니라 판결 이유 중에서 판단된 사실관계나 법률적 판단에 대해서도 효력이 미친다.

3. 효력의 제한

- 피고지자가 참가하지 못한 것에 정당한 사유가 있거나, 고지자가 소송수행을 태만히 하여 패소한 경우 등에는 참가적 효력이 제한될 수 있다. 또한 고지 시점이 너무 늦어 피고지자가 방어 기회를 전혀 갖지 못한 경우에도 효력은 발생하지 않는다.

V. 결론

- 소송고지는 분쟁의 일회적 해결과 관련 당사자 간의 공평을 기하기 위한 중요한 제도이다. 고지자는 이를 통해 향후 발생할 수 있는 구상 소송 등에서의 입증 부담을 덜 수 있고, 피고지자는 자신의 이해관계가 걸린 소송에 조기에 개입하여 불이익을 방지할 수 있다. 법원은 소송고지서가 적법하게 송달되었는지와 피고지자의 참가 자격 유무를 면밀히 살펴야 한다. 또한 소송고지에 따른 참가적 효력은 기판력보다 넓은 범위에 미치므로, 그 적용에 있어 당사자의 절차적 보장이 충분히 이루어졌는지를 엄격히 판단해야 할 것이다.

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제02절 제3자의 소송참가>

[기출][2019-3]공동소송참가의 의의, 성립요건 및 소송수행상의 효력

《【문제3】 공동소송참가에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 공동소송참가의 의의, 성립요건 및 소송수행상의 효력

I. 공동소송참가의 의의

- 공동소송참가란 타인 사이의 소송계속 중 그 소송의 판결의 효력이 제3자에게도 미치거나, 소송물이 제3자와 합일확정되어야 할 경우에 그 제3자가 자기의 권리를 보호하기 위하여 당사자 일방의 공동소송인으로서 소송에 가입하는 것을 의미한다.(민사소송법 제83조) 이는 판결의 대세효가 인정되는 소송에서 제3자의 절차적 보장을 도모하고, 판결의 모순·저촉을 방지하여 분쟁을 일회적으로 해결하기 위한 제도이다. 일반 보조참가와 달리 참가인이 독자적인 당사자 지위를 가지며, 필수적 공동소송의 규정이 준용된다는 점에 특징이 있다.

II. 공동소송참가의 요건

1. 타인 사이의 소송이 계속 중일 것

- 공동소송참가는 이미 개시된 소송에 중도 가입하는 것이므로, 제1심 또는 제2심의 변론종결 전까지 소송이 유효하게 계속되어 있어야 한다. 상고심에서의 참가는 원칙적으로 허용되지 않는다.

2. 소송물이 합일확정되어야 할 경우일 것

- 참가인이 원고 또는 피고 중 어느 일방과 공동소송인이 되어 판결의 결론이 반드시 일치해야 하는 관계여야 한다.

(1) 판결의 효력이 제3자에게 미치는 경우

- **상법상** 주주총회결의 취소의 소나 무효확인 소와 같이 판결의 효력이 대세적으로 미치는 소송이 대표적이다.

(2) 고유필수적 공동소송인 중 일부가 누락된 경우

- 권리관계의 성질상 당사자 전원이 함께 소송을 수행해야 함에도 일부가 누락되어 소송이 진행 중일 때, 누락된 자가 공동소송참가 신청을 함으로써 소송요건의 흠결을 보완할 수 있다.

III. 참가의 절차 및 심판

1. 참가의 신청

- 참가하려는 제3자는 참가의 취지와 이유를 명시하여 서면으로 신청해야 한다. 이때 참가인은 기존 당사자 중 누구의 공동소송인이 될 것인지를 분명히 해야 한다.

2. 참가신청에 대한 허부 결정

- 법원은 참가신청이 요건을 갖추었는지 심사한다. 상대방이 이의를 제기하거나 법원이 부적법하다고 판단하면 결정으로 각하할 수 있으나, 요건을 갖춘 경우 별도의 허가 결정 없이도 참가의 효력이 발생한다.

IV. 소송수행상의 효력

1. 당사자 지위의 취득

- 참가인은 단순히 보조적인 지위에 그치는 것이 아니라, 독립된 공동소송인으로서의 지위를 취득한다. 따라서 소송물의 처분이나 포기, 화해 등 독자적인 소송행위를 할 수 있다.

2. 필수적 공동소송 규정의 준용 [민사소송법 제67조]

- 공동소송참가인과 기존 당사자 사이에는 합일확정의 필요성이 있으므로 필수적 공동소송에 관한 규정이 적용된다.

(1) 소송자료의 공통

- 참가인 1인의 소송행위는 전원의 이익을 위해서만 효력을 가진다. 따라서 1인이 제출한 유리한 증거는 다른 당사자에게도 효력이 미치지만, 1인이 행한 자백이나 청구의 포기 등 불리한 행위는 전원이 함께하지 않는 한 효력이 발생하지 않는다.

(2) 소송진행의 공통

- 당사자 1인에게 발생한 소송절차의 중단이나 중지 사유는 전원에게 그 효력이 미친다. 판결 역시 모든 공동소송인에 대하여 동시에 선고되어야 하며 결론이 일치해야 한다.

V. 상소 제기 시의 취급

1. 상소의 불가분 원칙

- 공동소송인 중 1인이 상소를 제기하면 사건 전체가 상소심으로 이전하며, 상소하지 않은 나머지 당사자들도 상소심의 당사자가 된다. 이는 판결의 합일확정을 유지하기 위함이다.

2. 상소심의 심판 범위

- 상소심 법원은 불복하지 않은 당사자의 부분에 대해서도 심리하고 판결해야 하며, 전원에 대하여 하나의 판결을 선고해야 한다.

VI. 결론

- 공동소송참가는 판결의 효력을 직접 받게 되는 제3자에게 소송 참여의 기회를 보장함으로써 재판의 적정과 공정을 기하는 제도이다. 특히 대세효가 있는 소송이나 필수적 공동소송에서 누락된 자를 구제하여 소송경제와 분쟁의 일회적 해결에 기여한다. 법원은 참가인의 당사자 지위를 충분히 보장하되, 합일확정의 원칙에 따라 기존 당사자와의 조화를 도모해야 한다.

<제6편 상소심절차.제13장 총설.제02절 상소의 적법요건>

[모의][13.02-1]항소기간 도과와 소송행위의 추후보완 요건 및 절차

《【문제13.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 2억 원의 손해배상청구소송을 제기하였다. 제1심 법원은 심리 결과 乙의 과실을 60%로 인정하여 "乙은 甲에게 1억 2,000만 원을 지급하라"는 원고 일부승소 판결을 선고하였다. 판결서 정본은 2024. 2. 1. 甲과 乙에게 각각 적법하게 송달되었다.

乙은 위 판결에 불복하고자 하였으나, 항소장 제출 기한인 2024. 2. 15.에 갑작스러운 폭설로 인해 교통이 마비되어 법원에 출석하지 못하였고 전자소송 시스템에도 접속하지 못하여 결국 2024. 2. 16.에야 항소장을 제출하였다. 한편, 甲은 제1심 판결 선고 직후 乙과 만나 "더 이상 이 사건으로 다투지 않겠다"며 상소권을 포기하기로 합의하였으나, 마음을 바꿔 2024. 2. 10. 항소를 제기하였다.

또한, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 전부 승소 판결을 받았다. 그런데 판결 이유 중에서 법원은 丙이 주장한 매매계약의 성립 시점을 丙의 주장과 다르게 판단하였다. 丙은 판결 결과(주문)에는 만족하지만, 판결 이유 중의 사실인정이 향후 다른 분쟁에 영향을 미칠 것을 우려하여 항소를 제기하고자 한다.

(물음1) 乙이 항소기간을 도과하여 제출한 항소가 "책임질 수 없는 사유"로 인한 것인지 여부를 검토하고, 민사소송법 제173조에 따른 소송행위의 추후보완(추완)이 인정되기 위한 요건과 그 절차에 대하여 설명하시오.》

<문제13.2의 물음1> 항소기간 도과와 소송행위의 추후보완 요건 및 절차

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 제1심 판결에 대한 항소기간 내 항소장을 제출하지 못하였고, 폭설로 인한 교통 마비 및 전자소송 장애를 이유로 기간 도과 후 항소를 제기하려는 상황이다. 쟁점으로 항소기간 도과가 당사자가 책임질 수 없는 사유에 의한 것인지 여부와 추후보완의 요건 및 절차를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소송행위의 추후보완 제도의 의의와 책임질 수 없는 사유의 판단 기준 및 추완절차를 설명한다.

II. 소송행위의 추후보완(추완) 일반론

1. 의의 및 취지

- 당사자가 그 책임을 질 수 없는 사유로 말미암아 불변기간을 지킬 수 없었던 경우에는 그 사유가 없어진 날부터 2주 이내에 게을리한 소송행위를 보완할 수 있다.(민사소송법 제173조 제1항) 이는 절차의 안정을 위한 불변기간의 엄격성과 당사자의 권리 구제라는 실질적 형평을 조화시키기 위한 제도이다.

2. 추완의 대상

- 항소기간, 상고기간, 재심제기기간 등 법률이 불변기간으로 정한 것에 한정된다. 사안의 항소기간(2주)은 대표적인 불변기간에 해당한다.

III. 책임질 수 없는 사유의 판단 기준

1. 학설 및 판례의 태도

(1) 개념 정의

- 책임질 수 없는 사유란 당사자가 소송행위를 하기 위하여 일반적으로 하여야 할 주의를 다하였음에도 불구하고 피할 수 없었던 사정을 의미한다.

(2) 구체적 사례

- 천재지변, 갑작스러운 중병, 법원의 잘못된 교시 등이 이에 해당한다. 단순히 당사자의 과실이나 소송대리인의 부주의, 주소지 부재 등은 원칙적으로 포함되지 않는다.

2. 사안의 검토 (폭설 및 전산 장애)

- 폭설로 인해 교통이 완전히 마비되어 물리적으로 법원에 출석할 수 없었고, 동시에 전자소송 시스템까지 접속이 불가능하여 전자적 제출도 할 수 없었던 상황이라면, 이는 당사자가 통상적인 주의력을 행사하더라도 피할 수 없는 객관적 장애에 해당한다. 따라서 乙에게 책임을 묻기 어려운 사유로 볼 수 있다.

IV. 추완의 요건 및 절차

1. 요건

(1) 불변기간의 도과

- 적법한 불변기간(항소기간 등)이 경과하여야 한다.

(2) 당사자의 무과실

- 당사자나 그 대리인이 기간을 지키지 못한 데에 과실이 없어야 한다.

(3) 기간의 준수

- 사유가 없어진 날부터 2주(외국에 있는 경우 30일) 이내에 추완신청을 하여야 한다.

2. 절차 및 방법

(1) 신청 방식

- 게을리한 소송행위(항소장 제출 등)를 함과 동시에 추완신청서를 제출하는 것이 일반적이다. 별도의 신청서 없이 항소장을 제출하면서 그 사유를 기재하는 방식도 허용된다.

(2) 심리 및 재판

- 추완 사유의 존부는 수소법원이 심리한다. 사유가 인정되면 본안 심리에 들어가고, 인정되지 않으면 소각하 판결(또는 항소각하)을 한다.

V. 사안의 적용

1. 乙의 과실 유무

- 乙은 항소기간 마지막 날에 예상치 못한 폭설과 시스템 장애라는 이종의 장애에 직면하였다. 판례의 경향에 비추어 볼 때, 천재지변에 준하는 교통 마비와 전산 마비는 당사자의 책임 범위를 벗어난 것으로 판단될 가능성이 높다.

2. 추완의 적법성

- 乙은 장애 사유가 해소된 직후인 2024. 2. 16.에 바로 항소장을 제출하였다. 이는 사유가 없어진 날부터 2주 이내라는 기간 요건을 충족한 것이며, 게을리한 소송행위인 항소장 제출을 완료하였으므로 추완의 절차적 요건을 모두 갖추었다고 볼 수 있다.

VI. 결론

- 乙이 제출한 항소는 민사소송법 제173조에 따른 소송행위의 추후보완 요건을 갖춘 것으로 판단된다. 갑작스러운 폭설과 전산망 장애는 당사자가 책임질 수 없는 사유에 해당하며, 乙은 사유 종료 후 즉시 항소장을 제출함으로써 절차를 이행하였다. 따라서 법원은 乙의 항소를 적법한 것으로 받아들여 제1심 판결에 대한 본안 심리를 진행하여야 한다.

<제6편 상소심절차.제13장 총설.제02절 상소의 적법요건>

[모의][13.02-2]상소권 포기의 효력 및 형식적 불복설에 따른 상소의 이익 인정 여부

《【문제13.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 2억 원의 손해배상청구소송을 제기하였다. 제1심 법원은 심리 결과 乙의 과실을 60%로 인정하여 "乙은 甲에게 1억 2,000만 원을 지급하라"는 원고 일부승소 판결을 선고하였다. 판결서 정본은 2024. 2. 1. 甲과 乙에게 각각 적법하게 송달되었다.

乙은 위 판결에 불복하고자 하였으나, 항소장 제출 기한인 2024. 2. 15.에 갑작스러운 폭설로 인해 교통이 마비되어 법원에 출석하지 못하였고 전자소송 시스템에도 접속하지 못하여 결국 2024. 2. 16.에야 항소장을 제출하였다. 한편, 甲은 제1심 판결 선고 직후 乙과 만나 "더 이상 이 사건으로 다투지 않겠다"며 상소권을 포기하기로 합의하였으나, 마음을 바꿔 2024. 2. 10. 항소를 제기하였다.

또한, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 전부 승소 판결을 받았다. 그런데 판결 이유 중에서 법원은 丙이 주장한 매매계약의 성립 시점을 丙의 주장과 다르게 판단하였다. 丙은 판결 결과(주문)에는 만족하지만, 판결 이유 중의 사실인정이 향후 다른 분쟁에 영향을 미칠 것을 우려하여 항소를 제기하고자 한다.

(물음2) 甲이 상소권 포기 합의 후 제기한 항소가 적법한지 여부를 상소권 포기의 방식 및 효력과 관련하여 논하고, 전부 승소한 丙이 판결 이유만을 다투기 위해 제기한 항소에 "상소의 이익"이 인정되는지 판례의 태도인 형식적 불복설에 근거하여 기술하시오.》

<문제13.2의 물음2> 상소권 포기의 효력 및 형식적 불복설에 따른 상소의 이익 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 乙과 상소권 포기에 관한 합의를 한 후 항소를 제기하였고, 丙은 전부 승소판결을 받은 뒤 판결 이유의 사실인정만을 다투기 위해 항소하려는 상황이다. 쟁점으로 상소권 포기의 방식과 효력에 따른 항소의 적법 여부 및 전부 승소한 당사자에게 판결 이유에 대한 상소의 이익이 인정되는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 상소권 포기의 요건과 효력 및 형식적 불복설에 따른 상소의 이익 인정 여부를 기술한다.

II. 상소권의 포기

1. 의의 및 방식

(1) 의의

- 상소권의 포기란 상소권을 행사하지 않겠다는 당사자의 의사표시이다. 이는 소송계속 중 또는 판결 선고 후에 이루어질 수 있으며, 상소권을 소멸시키는 효과를 가진다.

(2) 방식 [민사소송법 제394조]

- 상소권의 포기는 상소를 제기하기 전에는 제1심 법원에, 상소를 제기한 후에는 기록이 있는 법원에 서면으로 신청하여야 한다. 다만, 변론기일 등에서는 말로 할 수 있으며 이를 조서에 기재하여야 한다.

2. 상소권 포기 합의의 효력

(1) 소송외 합의의 성질

- 사안과 같이 당사자 쌍방이 법정 밖에서 만나 '더 이상 다투지 않겠다'고 약정하는 것은 이른바 부상소의 합의(소송협약)에 해당한다. 판례는 이러한 소송외 합의가 유효하기 위해서는 처분할 수 있는 권리에 관한 것이어야 하고, 특정된 법률관계에 기반하며, 합의 시 당사자가 예상할 수 있는 범위 내여야 한다고 본다.

(2) 위반 시의 효과

- 적법한 부상소 합의가 있음에도 불구하고 상소를 제기한 경우, 판례는 이를 권리보호의 이익이 없는 부적법한 상소로 보아 각하 판결을 내린다.

III. 상소의 이익과 형식적 불복설

1. 상소의 이익의 의의

- 상소의 이익이란 상소를 통해 제1심 판결보다 유리한 판결을 얻을 수 있는 가능성을 의미한다. 상소의 이익이 없는 상소는 부적법하여 각하된다.

2. 판단 기준에 관한 판례의 태도 (형식적 불복설)

(1) 개념

- 판례는 상소의 이익 유무를 판단함에 있어 원칙적으로 형식적 불복설을 취하고 있다. 이는 당사자가 제1심에서 신청한 청구취지와 비교하여 판결 주문 상 그보다 적은 결과를 얻었을 때(일부 패소)에만 상소의 이익을 인정하는 견해이다.

(2) 구체적 적용

- 승소 판결의 이유에 불만이 있다 하더라도 주문에서 청구한 바를 전부 얻어냈다면 원칙적으로 상소의 이익이 없다. 즉, 사실인정의 오류나 법리 판단의 불만은 상소 사유가 되지 않는다.

IV. 사안의 적용

1. 甲의 항소 제기 건

(1) 합의의 효력

- 甲은 판결 선고 후 乙과 상소권을 포기하기로 합의하였다. 이는 특정된 손해배상청구 사건에 관한 것으로서 유효한 부상소의 합의이다.

(2) 항소의 적법성

- 甲이 합의를 어기고 항소를 제기한 것은 소송법상 신의칙 또는 부상소 합의의 효력에 반하는 것으로서 권리보호의 이익이 없다. 따라서 甲의 항소는 부적법하여 각하되어야 한다.

2. 丙의 항소 제기 건

(1) 사실관계의 확인

- 丙은 제1심에서 전부 승소 판결을 받았다. 판결 주문은 丙이 원하는 대로 소유권이전등기를 명하고 있다.

(2) 상소의 이익 판단

- 형식적 불복설에 의하면 전부 승소한 丙은 판결 주문에서 불이익을 입은 바가 없다. 비록 판결 이유 중 매매계약 성립 시점에 대한 판단이 자신의 주장과 다르다 하더라도, 이는 기판력이 발생하는 주문의 결론이 아니므로 상소로써 다투는 이익이 없다. 따라서 丙의 항소 역시 부적법하여 각하 대상이다.

V. 결론

- 甲의 항소는 유효한 상소권 포기 합의에 위반하여 제기된 것이므로 소송법상 권리보호이익이 없어 부적법하다. 또한 丙의 항소는 판결 이유만을 다투기 위한 것으로서, 형식적 불복설을 취하는 **판례**의 태도에 비추어 볼 때 전부 승소한 자에게는 상소의 이익이 인정되지 않으므로 이 또한 부적법하다. 민사소송 절차는 판결 주문상의 불이익을 구제하는 것을 목적으로 하므로, 당사자 간의 합의나 객관적인 승소 결과는 절차의 종료를 정당화하는 강력한 근거가 된다.

<제6편 상소심절차.제13장 총설.제03절 상소의 효력>

[기출][2024-1-2]원고만이 항소한 경우 항소심 법원이 상계항변을 받아들여 청구 전부를 기각한 판결의 적법성

《【문제1】 甲은 乙에 대해 1억 원의 대여금을 청구하는 소를 제기(이하 '이 사건 소송'이라 하며, 원금 이외의 이자나 지연손해금 등은 고려하지 않는다)하였다. 다음 물음에 답하시오. (아래의 각 물음은 독립적이며, 문제에서 제시되지 아니한 사항은 적법한 것으로 본다.) (50점)

(물음2) 이 사건 소송에서 피고 乙은 1억 원 전액을 원고 甲에게 변제하였다는 항변을 하였다. 제1심 법원은 피고 乙이 3,000만 원만 변제한 사실을 인정하여 원고 甲의 청구금액 1억 원 중 7,000만 원만 인용하면서 나머지 3,000만 원의 청구에 대해서는 기각하는 판결(이하 '제1심 판결'이라 한다)을 하였다. 이러한 제1심 판결에 대하여 원고 甲만이 기각된 3,000만 원의 청구에 대해서도 인용해달라는 취지로 항소를 제기하였다. 항소심에서 피고 乙은 새롭게 1억 원의 상계의 항변을 주장하였다. 항소심 법원은 피고 乙의 변제항변은 전부 이유 없지만, 피고 乙의 상계항변은 전부 인정된다는 이유로 원고 甲의 피고 乙에 대한 청구 전부를 기각하는 판결을 하였다. 이러한 항소심 판결이 적법한지 설명하시오. (30점)》

<문제1의 물음2> 원고만이 항소한 경우 항소심 법원이 상계항변을 받아들여 청구 전부를 기각한 판결의 적법성

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 제1심에서 일부 기각된 3,000만 원 부분에 대하여 항소한 후 항소심에서 乙이 새롭게 상계항변을 하였고, 항소심 법원이 이를 받아들여 甲의 청구 전부를 기각한 상황이다. 쟁점으로 항소심에서 새로운 공격방어방법인 상계항변을 제출할 수 있는지와 항소심 법원이 제1심보다 불리한 판단을 할 수 있는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 항소심의 심판범위와 불이익변경금지 원칙에 따른 상계항변의 허용 여부 및 판결의 적법성을 검토한다.

II. 상소의 원칙

1. 상소의 불가분 원칙과 이심의 범위

(1) 상소의 불가분 원칙

- 상소의 제기는 판결의 확정을 차단하고 사건 전체를 상소심으로 이심시키는 효력이 있다. 이를 상소의 불가분 원칙이라 한다. 따라서 판결의 일부에 대해서만 상소를 하더라도 원칙적으로 당해 판결의 전체가 상소심으로 이심된다.

(2) 사안의 이심 범위

- 원고 甲은 기각된 3,000만 원 부분에 대해서만 항소를 제기하였으나, 상소의 불가분 원칙에 따라 제1심 판결의 전체인 1억 원 청구 부분이 항소심으로 이심된다. 다만, 이심된 부분 중 항소인이 불복하지 않은 부분은 항소심의 심판 대상에서는 제외되는 것이 원칙이다.

2. 불이익변경금지의 원칙

(1) 의의

- 항소심 법원은 항소인의 불복 신청 범위 내에서만 제1심 판결의 당부를 심판할 수 있으며, 항소인에게 제1심 판결보다 불리한 판결을 할 수 없다는 원칙이다.(민사소송법 제415조) 이는 당사자의 처분권주의가 상소심 절차에서도 관철된 결과이다.

(2) 적용 요건

- 상대방이 항소하거나 부대항소를 제기하지 않은 경우에 한하여 적용된다. 본 사안에서 피고 乙은 항소나 부대항소를 제기하지 않았으므로, 원고 甲만이 항소한 이 사건에서 불이익변경금지 원칙이 적용된다.

III. 항소심의 심판 범위와 상계항변

1. 심판 대상의 한정

- 원고 甲은 제1심에서 기각된 3,000만 원의 인용을 구하며 항소하였다. 따라서 항소심의 심판 대상은 원칙적으로 원고가 불복한 3,000만 원 부분에 한정된다. 제1심에서 원고가 승소한 7,000만 원 부분은 피고가 항소하지 않았으므로 원고에게 유리하게 확정될 대기 상태에 있는 부분이다.

2. 상계항변의 처리와 불이익변경 여부

- 항소심에서 피고가 상계항변을 제출한 경우, 법원은 이를 심리할 수 있다. 그러나 그 결과가 원고에게 제1심보다 불리한 결과를 초래해서는 안 된다.

(1) 항소 부분(3,000만 원)에 대한 판단

- 항소심 법원은 피고의 변제항변이 이유 없다고 판단했으므로, 일단 원고의 항소는 이유 있는 것이 된다. 그러나 피고의 상계항변이 1억 원 전액에 대해 인정되므로, 항소 대상인 3,000만 원 청구는 상계에 의해 소멸되어 기각하는 것이 타당하다. 이는 제1심 판결(기각)과 결과가 동일하므로 불이익변경에 해당하지 않는다.

(2) 제1심 인용 부분(7,000만 원)에 대한 판단

- 문제는 제1심에서 이미 원고가 승소했던 7,000만 원 부분이다. 피고가 항소하지 않았으므로 항소심 법원은 이 부분을 원고에게 불리하게 변경할 수 없다. 그럼에도 불구하고 항소심 법원이 상계항변을 이유로 청구 전부(1억 원 전체)를 기각한 것은, 원고가 항소하지 않았더라면 얻었을 7,000만 원의 승소 확정 지위를 박탈한 것이 되어 불이익변경금지 원칙에 정면으로 위배된다.

IV. 사안의 적용

1. 항소심 판결의 내용 분석

- 항소심 법원은 원고의 청구 전부를 기각하였다. 이는 제1심에서 인용되었던 7,000만 원 부분까지 취소하고 원고 패소 판결을 내린 것과 같다.

2. 위법성 판단

- 피고의 부대항소가 없는 상황에서 원고의 항소만으로 제1심 승소 부분까지 반복하여 원고에게 더 불리한 판결을 내리는 것은 민사소송법 제415조에 위반된다. 항소심 법원은 원고의 항소 부분(3,000만 원)에 대해서만 상계항변을 적용하여 항소를 기각(제1심 결과 유지)했어야 하며, 제1심 인용 부분인 7,000만 원은 그대로 유지했어야 한다. 이하에서는 이와 같은 법리를 바탕으로 결론을 도출한다.

V. 결론

- 항소심 법원이 피고의 상계항변을 근거로 제1심에서 원고가 승소했던 부분까지 포함하여 청구 전부를 기각한 판결은 불이익변경금지의 원칙을 위반한 것이므로 위법하다. 항소심 법원은 원고의 항소를 기각함으로써 제1심 판결의 결과를 유지하는 선에서 판결했어야 한다.

<제6편 상소심절차.제14장 항소.제02절 항소의 제기>

[기출][2023-3]부대항소의 의의, 요건, 절차와 방식, 효력, 특수한 경우의 부대항소

《【문제3】 부대항소에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 부대항소의 의의, 요건, 절차와 방식, 효력, 특수한 경우의 부대항소

I. 부대항소의 의의

- 부대항소란 항소를 당한 피항소인이 항소인의 항소에 의하여 개시된 항소심 절차에 편승하여 자기에게 유리하도록 제1심 판결을 변경할 것을 구하는 신청을 말한다.(민사소송법 제403조) 이는 항소권이 소멸하여 독립하여 항소를 할 수 없는 상태라 하더라도, 상대방이 항소를 제기해 온 이상 공평의 원칙상 피항소인에게도 불복의 기회를 부여하기 위한 제도이다. 또한 불이익변경금지의 원칙을 깨뜨리고 항소심의 심판 범위를 피항소인이 불복하는 범위까지 확장시키는 기능을 한다.

II. 부대항소의 요건

1. 주된 항소가 적법하게 계속 중일 것

- 부대항소는 주된 항소에 의존하는 종된 권리이므로, 주된 항소가 적법하게 제기되어 항소심에 계속 중이어야 한다. 만약 주된 항소가 부적법하여 각하된 다면 부대항소 역시 그 효력을 잃게 된다.

2. 피항소인이 항소인을 상대로 제기할 것

- 부대항소는 피항소인이 항소인을 상대로 제기하여야 한다. 통상적인 항소심 절차의 당사자 사이에서 이루어지며, 보조참가인이 피참가인을 위하여 부대항소를 하는 것도 허용된다.

3. 항소심의 변론종결 전까지 제기할 것

- 부대항소는 항소심의 변론종결 전까지 제기하여야 한다. 독립된 항소와 달리 항소기간의 제한을 받지 않으므로, 자신의 항소기간이 도과하거나 항소권을 포기한 후라도 항소심 변론종결 전이라면 언제든지 제기할 수 있다.

III. 부대항소의 절차와 방식

1. 부대항소장의 제출

- 부대항소는 항소에 관한 규정에 따라 부대항소장을 항소심 법원에 제출함으로써 한다. 부대항소장에는 부대항소의 취지와 이유를 적어야 하며, 독립된 항소장과 마찬가지로 인지를 첨부하여야 한다.

2. 불복 범위의 기재

- 부대항소인은 제1심 판결 중 자신에게 불리하게 판결된 부분에 대하여 어느 범위까지 변경을 구하는지 명확히 기재하여야 한다. 이에 따라 항소심의 심판 범위가 확장된다.

IV. 부대항소의 효력

1. 불이익변경금지 원칙의 배제

- 원칙적으로 항소심은 항소인의 불복 범위 내에서만 심판하며 항소인에게 불리하게 판결을 변경할 수 없으나, 부대항소가 제기되면 법원은 피항소인이 불복한 범위까지 심판할 수 있게 된다. 결과적으로 항소인에게 제1심보다 불리한 판결이 내려질 수 있다.

2. 주된 항소와의 종속성

- 부대항소는 주된 항소가 취하되거나 부적법하여 각하된 때에는 그 효력을 잃는 것이 원칙이다.(민사소송법 제404조 본문)

(1) 예외 : 독립항소 요건을 갖춘 경우

- 다만, 부대항소가 항소기간 내에 제기되어 독립된 항소로서의 요건을 갖추고 있는 경우에는 주된 항소가 취하되더라도 독립된 항소로 보아 그 효력이 유지된다.(민사소송법 제404조 단서)

(2) 상계항변과 부대항소

- 최근 판례는 상계항변이 인용되어 승소한 피고가 원고의 항소에 대하여 부대항소를 제기하지 않더라도, 항소심에서 다시 상계항변을 유지하거나 반대채권의 존부를 다투는 것은 부대항소 없이도 가능하다고 보아 피항소인의 방어권을 존중하고 있다.

V. 특수한 형태의 부대항소

1. 가집행선고만을 구하는 부대항소

- 제1심에서 가집행선고만 불지 않은 경우 피항소인은 항소심에서 가집행선고만을 구하기 위한 부대항소를 제기할 수 있다.

2. 예비적 부대항소

- 주된 항소가 인용될 것을 대비하여 예비적으로 제1심 판결의 변경을 구하는 형태의 부대항소도 가능하다.

VI. 결론

- 부대항소는 항소심 절차에서 당사자 간의 실질적인 형평을 기하고 분쟁을 일거에 해결할 수 있게 하는 유용한 제도이다. 특히 항소권이 소멸한 피항소인에게 다시금 불복의 기회를 제공함으로써 처분권주의와 공평의 원칙을 조화시킨다. 법원은 부대항소의 종속성과 심판 범위 확장 효과를 정확히 파악하여, 주된 항소의 운명에 따른 부대항소의 처리에 유의하여야 하며 당사자의 방어권이 침해되지 않도록 운영하여야 한다.

<제6편 상소심절차:제14장 항소:제03절 항소심의 심리>

[모의][14.03-1]항소심의 속심제 구조와 소멸시효 항변의 적시제출의무 위반 여부

《【문제14.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 제1심 소송에서 乙은 대여사실 자체를 부인하였으나, 법원은 증거조사를 거쳐 甲의 주장을 인정하고 원고 전부승소 판결을 선고하였다. 乙은 이에 불복하여 항소를 제기하였다.

항소심 변론기일에서 乙은 제1심에서 주장하지 않았던 새로운 방어방법으로, 실령 대여사실이 인정된다 하더라도 이미 시효가 완성되어 채무가 소멸하였다는 "소멸시효 항변"을 제출하였다. 이에 대해 甲은 乙이 제1심에서 충분히 주장할 수 있었음에도 불구하고 소송을 지연시키기 위해 뒤늦게 항변을 제출하는 것이라며 이를 각하해 달라고 요청하였다.

한편, 항소심 재판부는 심리 중 제1심에서 제출되지 않았던 새로운 증인 丙의 진술이 사건의 핵심 열쇠라고 판단하였다. 하지만 丙은 甲의 친인척으로서 제1심 당시에도 충분히 증인으로 신청할 수 있었던 인물이었다. 또한 乙은 항소심 진행 중에 甲에 대하여 별도로 가지고 있던 5,000만 원의 채권을 가지고 "상계 항변"을 추가로 제출하고자 한다.

(물음1) 민사소송법상 항소심의 구조인 "속심제"의 의의와 관련하여, 乙이 항소심에서 처음으로 제출한 "소멸시효 항변"이 적절한 공격방어방법으로서 수용될 수 있는지 여부와 민사소송법 제285조 및 제412조에 따른 제출 제한 사유(실기한 공격방어방법 등)를 근거로 논하시오.》

<문제14.3의 물음1> 항소심의 속심제 구조와 소멸시효 항변의 적시제출의무 위반 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 제1심에서 대여사실을 부인하여 패소한 후 항소심에서 소멸시효 항변 등 새로운 공격방어방법을 제출하는 상황이다. 쟁점으로 **항소심의 속심제 구조에 따라 새로운 공격방어방법의 제출이 허용되는지**와 **실기한 공격방어방법 등에 의한 제출 제한 여부를 검토할** 필요가 있다. 이하에서는 乙이 항소심에서 제출한 소멸시효 항변의 적법성과 그 제한 사유를 논한다.

II. 항소심의 구조와 속심제

1. 속심제의 의의

- 속심제란 항소심이 제1심의 판결이 사후적으로 옳은가를 심판하는 것이 아니라, 제1심의 심리상태를 인계받아 변론종결 시까지 제출된 모든 자료를 기초로 사건의 본안을 다시 심리하는 구조를 말한다.

2. 속심제의 효과

(1) 새로운 자료의 제출

- 당사자는 항소심 변론종결 전까지 새로운 공격방어방법을 제출할 수 있는 것이 원칙이다. 이는 제1심에서 제출하지 못했던 증거나 항변을 보완할 기회를 부여한다.

(2) 제1심과의 연속성

- 제1심에서 행한 소송행위와 증거조사 결과는 항소심에서도 그대로 효력을 유지하며, 항소심은 이를 기초로 추가적인 심리를 진행한다.

III. 공격방어방법의 제출 제한 (적시제출주의)

1. 적시제출주의의 원칙 [민사소송법 제146조]

- 공격 또는 방어의 방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다. 이는 소송의 지연을 방지하고 집중심리를 구현하기 위함이다.

2. 실기한 공격방어방법의 각하 [민사소송법 제285조]

(1) 요건

- ① 당사자가 고의 또는 중대한 과실로 적절한 시기를 놓쳐 뒤늦게 제출하였어야 한다. ② 그 결과 소송의 완결을 지연시키게 되어야 한다.

(2) 항소심에서의 적용 [민사소송법 제412조]

- 항소심에서도 적시제출주의는 적용된다. 특히 제1심에서 충분히 제출할 수 있었음에도 불구하고 항소심에 이르러서야 새로운 항변을 제출하는 것은 실기한 공격방어방법으로 취급될 가능성이 높다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 소멸시효 항변과 속심제

- 속심제의 원칙에 따르면 乙이 항소심에서 새로운 방어방법인 소멸시효 항변을 제출하는 것 자체는 일단 허용된다. 항소심은 제1심의 속행으로서 새로운 사실관계와 법률적 주장을 수용할 수 있는 구조적 유연성을 갖기 때문이다.

2. 실기한 공격방어방법 해당 여부

(1) 고의·중과실 여부

- 乙은 제1심에서 대여사실 자체만을 다투었으나, 소멸시효는 채무자로서 통상적으로 쉽게 인지할 수 있는 사항이다. 특별한 사정이 없는 한 제1심에서 충분히 주장 가능했음에도 항소심에 이르러 제출한 것은 乙의 과실이 인정될 소지가 크다.

(2) 소송 지연 여부

- 만약 乙의 항변을 심리하기 위해 새로운 증거조사나 추가 기일이 필요하게 된다면, 이는 제1심에서 종결될 수 있었던 사건을 불필요하게 연장하는 결과가 되어 소송의 완결을 지연시키는 것으로 볼 수 있다.

(3) 소결

- 甲의 주장처럼 乙의 항변이 오로지 소송 지연을 목적으로 하거나, 乙의 중과실로 뒤늦게 제출되어 새로운 심리가 불가피하다면 법원은 **민사소송법 제285조** 및 **제412조**에 의거하여 해당 항변을 각하할 수 있다.

V. 결론

- 항소심은 속심제를 취하므로 乙이 소멸시효 항변을 제출하는 것은 원칙적으로 가능하나, 이는 적시제출주의의 제한을 받는다. 乙이 제1심에서 충분히 제출할 수 있었음에도 불구하고 만연히 항소심에서 이를 주장한 것이 소송의 완결을 지연시킨다고 판단될 경우, 재판부는 이를 실기한 공격방어방법으로 보아 각하할 수 있다. 다만 실무적으로 소멸시효와 같은 강력한 법률적 방어수단은 실제적 진실 발견을 위해 각하에 신중을 기하는 경향이 있으나, 요건을 충족한다면 절차적 정의를 위해 각하될 수 있음이 타당하다.

<제6편 상소심절차.제14장 항소.제03절 항소심의 심리>

[모의][14.03-2]항소심 변론의 범위와 상계항변의 적시제출주의 위반 여부 및 판례의 태도

《[문제14.3]

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 제1심 소송에서 乙은 대여사실 자체를 부인하였으나, 법원은 증거조사를 거쳐 甲의 주장을 인정하고 원고 전부승소 판결을 선고하였다. 乙은 이에 불복하여 항소를 제기하였다.

항소심 변론기일에서 乙은 제1심에서 주장하지 않았던 새로운 방어방법으로, 실령 대여사실이 인정된다 하더라도 이미 시효가 완성되어 채무가 소멸하였다는 "소멸시효 항변"을 제출하였다. 이에 대해 甲은 乙이 제1심에서 충분히 주장할 수 있었음에도 불구하고 소송을 지연시키기 위해 뒤늦게 항변을 제출하는 것이라며 이를 각하해 달라고 요청하였다.

한편, 항소심 재판부는 심리 중 제1심에서 제출되지 않았던 새로운 증인 丙의 진술이 사건의 핵심 열쇠라고 판단하였다. 하지만 丙은 甲의 친인척으로서 제1심 당시에도 충분히 증인으로 신청할 수 있었던 인물이었다. 또한 乙은 항소심 진행 중에 甲에 대하여 별도로 가지고 있던 5,000만 원의 채권을 가지고 "상계항변"을 추가로 제출하고자 한다.

(물음2) 항소심에서 변론의 범위는 제1심 변론과 어떻게 연결되는지(변론의 집중)를 설명하고, 乙이 추가로 제출하려는 "상계항변"이 항소심의 심리 단계에서 어느 정도까지 허용되는지 판례가 제시하는 "적시제출의 원칙"과 관련하여 기술하시오.》

<문제14.3의 물음2> 항소심 변론의 범위와 상계항변의 적시제출주의 위반 여부 및 판례의 태도

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 항소심 계속 중 제1심에서 주장하지 않았던 상계항변을 추가로 제출하려는 상황이다. 쟁점으로 항소심에서의 변론 범위와 변론의 집중에 따른 새로운 공격방어방법 제출의 허용 여부 및 적시제출의 원칙에 따른 제한을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙이 항소심에서 추가한 상계항변의 허용 범위와 그 제출 제한 여부를 기술한다.

II. 항소심 변론의 범위와 제1심과의 연결

1. 변론의 일체성 (단일성)

(1) 의의

- 항소심의 변론은 제1심 변론의 속행으로서, 제1심에서 행한 소송행위와 증거조사 결과는 항소심에서도 그대로 효력을 가진다. 이를 변론의 일체성 또는 단일성이라 한다.

(2) 변론의 집중과 속심제

- 항소심은 제1심의 심리를 인계받아 변론종결 시까지 제출된 모든 자료를 기초로 판결한다. 따라서 당사자는 원칙적으로 항소심 변론종결 전까지 새로운 공격방어방법을 제출할 수 있다.

2. 변론의 집중을 위한 제한

- 실질적으로 항소심이 제1심의 반복이 되는 것을 방지하고 재판의 신속을 기하기 위하여, 민사소송법은 적시제출주의(제146조)를 근거로 실기한 공격방어방법의 각하(제285조, 제412조) 규정을 두고 있다. 이는 항소심에서의 무분별한 새로운 주장 제출을 억제하는 기능을 한다.

III. 상계항변의 제출과 적시제출의 원칙

1. 상계항변의 특수성

- 상계항변은 소송 외적인 채권·채무 관계를 소송 내로 끌어들이 심리하는 것으로, 다른 방어방법에 비해 심리가 복잡해질 가능성이 크다. 따라서 이를 뒤늦게 제출하는 경우 소송 지연의 우려가 더 높게 평가될 수 있다.

2. 적시제출주의와 실기한 공격방어방법

(1) 각하 요건

- ① 당사자가 고의 또는 중대한 과실로 적기에 제출하지 않았어야 한다. ② 그 방어방법의 제출로 인하여 소송의 완결이 지연되어야 한다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 상계항변이 제1심에서 충분히 주장할 수 있었음에도 불구하고 항소심에 이르러서야 제출된 경우, 그것이 소송의 상태에 비추어 새로운 증거조사를 필요로 하거나 심리 기일을 연장시키는 결과를 초래한다면 실기한 공격방어방법으로서 각하될 수 있다고 본다.

(3) 판단 기준

- 판례에 따르면 소송의 완결을 지연시키는지 여부는 그 방어방법을 각하했을 때 소송이 즉시 종결될 수 있는 상태인지를 기준으로 판단한다. 즉, 이미 심리가 충분히 이루어져 판결을 내릴 수 있는 단계에서 새로운 상계항변이 제출되어 추가적인 심리가 필요하다면 이는 지연으로 간주된다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 상계항변 제출 시기

- 乙은 제1심에서 대여사실만을 부인하다가 항소심 진행 중에 비로소 5,000만 원의 채권을 근거로 상계항변을 제출하려 한다. 상계의 기초가 되는 채권이 제1심 당시 이미 존재하고 있었고 乙이 이를 인지하고 있었다면, 이를 항소심에서야 제출하는 것은 고의 또는 중대한 과실에 의한 지연으로 평가될 가능성이 높다.

2. 소송 지연의 실질적 판단

- 사안에서 항소심 재판부가 이미 새로운 증인 丙의 진술을 핵심 열쇠로 판단하여 심리를 진행 중인 상황이라 하더라도, 乙이 제출하려는 상계항변이 별개의 채권 존재 여부를 다투어야 하는 등 추가적인 증거조사를 필요로 한다면 이는 명백히 소송의 완결을 지연시키는 사유가 된다. 특히 상계항변은 반대채권의 존부에 대한 심리가 선행되어야 하므로 소송 경제 측면에서 엄격히 제한될 수 있다.

V. 결론

- 乙의 상계항변은 항소심이 속심제라는 점에서 원칙적으로 제출 가능하나, 판례가 제시하는 적시제출의 원칙에 따라 엄격한 제한을 받는다. 乙이 제1심에서 충분히 주장할 수 있었던 사정(고의·중과실)이 인정되고, 해당 항변으로 인해 기존에 예정된 항소심 판결 시기가 늦춰진다면(소송 지연), 법원은 민사소송법 제412조 및 제285조를 적용하여 이를 각하하여야 한다. 이는 항소심을 사실상의 제2의 제1심으로 오용하는 것을 방지하고 변론의 집중을 실현하기 위한 필수적인 조치이다.

<제6편 상소심절차.제14장 항소.제04절 항소심의 중국재판>

[모의][14.04-1]피고만이 항소한 경우 불이익변경금지의 원칙 적용 여부와 항소기각의 재판 형식

【문제14.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 2억 원의 손해배상청구소송을 제기하였다. 제1심 법원은 乙의 책임을 인정하면서도 과실상계를 적용하여 "乙은 甲에게 1억 원을 지급하라"는 원고 일부승소 판결을 선고하였다. 이에 대하여 피고 乙만이 항소하였고, 원고 甲은 항소하지 않았다.

항소심 심리 결과, 재판부는 乙의 과실이 제1심판결보다 더 크다고 판단하여 손해배상액이 1억 5,000만 원이 적정하다는 결론에 도달하였다. 반면, 乙은 제1심판결이 전제한 사실관계 자체가 오인되었으므로 제1심판결을 취소하고 甲의 청구를 전부 기각해야 한다고 주장하고 있다.

또 다른 사건에서, A는 B를 상대로 소를 제기하였으나 제1심 법원은 소의 제기 요건에 흠결이 있다는 이유로 "소각하판결"을 선고하였다. A는 이에 불복하여 항소하였고, 항소심 법원은 심리 결과 제1심의 판단과 달리 소의 요건이 구비되어 적법하다고 판단하였다. 그러나 항소심 법원은 본안 심리를 충분히 하지 않은 상태에서 스스로 판결(자판)을 내릴지, 아니면 다시 제1심 법원으로 사건을 돌려보낼지 검토 중이다.

(물음1) 피고 乙만이 항소한 사례에서 항소심 법원이 제1심판결보다 乙에게 불리한 1억 5,000만 원의 지급을 명하는 판결을 선고할 수 있는지 여부를 "불이익변경금지의 원칙"과 관련하여 논하고, 만약 항소가 이유 없다고 판단될 때 항소심 법원이 내려야 할 "항소기각" 재판의 형식을 기술하시오.》

<문제14.4의 물음1> 피고만이 항소한 경우 불이익변경금지의 원칙 적용 여부와 항소기각의 재판 형식

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙만이 제1심 일부승소판결에 대하여 항소하여 항소심에서 제1심보다 증액된 손해배상액의 판단 가능성이 문제되는 상황이다. 쟁점으로 **항소심 법원이 불이익변경금지의 원칙에 따라 원심보다 불리한 판결을 할 수 있는지와 항소가 이유 없다고 판단될 경우의 재판 형식**을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 항소심의 불이익변경금지 적용 여부와 항소기각 판결의 형식을 기술한다.

II. 불이익변경금지의 원칙

1. 의의 및 근거

(1) 의의

- 불이익변경금지의 원칙이란 상소심 법원은 상소인(항소인)이 신청한 불복의 한도 내에서만 제1심 판결의 당부를 조사할 수 있으며, 상소인에게 제1심 판결보다 불리한 판결을 할 수 없다는 원칙을 말한다.

(2) 근거

- 이는 처분권주의(**민사소송법 제203조**)의 상소심적 발현이다. 상소인은 자신이 불복한 범위 내에서만 심판을 구하는 것이므로, 상대방이 부대항소를 제기하는 등의 특별한 사정이 없는 한 법원이 그 범위를 넘어서는 심판을 할 수 없다.

2. 사안의 경우 적용 여부

(1) 심판의 범위

- 피고 乙만이 항소한 경우, 항소심의 심판 대상은 乙이 불복한 1억 원 지급 부분에 한정된다. 원고 甲은 항소하지 않았으므로 甲이 패소한 나머지 1억 원 부분은 항소심의 심판 대상에서 제외된다.

(2) 불이익변경의 판단

- 제1심 판결은 1억 원 지급을 명하였으나, 항소심 법원이 1억 5,000만 원 지급을 명하는 것은 항소인인 乙에게 제1심보다 더 무거운 의무를 지우는 것이다. 이는 전형적인 불이익변경에 해당하며, 원고 甲의 항소나 부대항소가 없는 이상 허용되지 않는다.

3. 예외적 허용 범위

- 상대방이 부대항소를 제기하거나, 판결의 주문이 아닌 이유 중의 판단(예 : 과실상계 비율 등)을 변경하는 과정에서 계산상의 차이가 발생하는 경우 등 극히 예외적인 상황이 아니라면 이 원칙은 엄격히 준수되어야 한다.

III. 항소기각 재판의 형식

1. 항소기각 판결의 의의

- 항소인이 제기한 항소가 절차상 적법하기는 하나, 실체적인 심리 결과 제1심 판결이 정당하다고 인정될 때 항소심 법원이 항소를 배척하는 판결을 말한다.

2. 재판의 형식 [민사소송법 제414조]

(1) 항소기각 판결의 원칙

- 항소심 법원이 제1심 판결을 검토한 결과 乙의 항소이유가 근거 없고 제1심의 결론(1억 원 지급)이 적절하다고 판단한다면, 피고의 항소를 기각한다는 판결을 선고해야 한다.

(2) 이유 교체에 의한 기각 [민사소송법 제414조 제2항]

- 제1심 판결의 이유(예 : 사실관계 판단이나 과실상계 비율)는 부당하더라도 다른 이유에 의하여 그 결과(1억 원 지급)가 정당하다고 인정되는 경우에도 항소심 법원은 항소를 기각하여야 한다. 사안에서 법원이 乙의 과실이 더 크다고 보아 1억 5,000만 원이 적정하다고 판단했다더라도, 불이익변경금지 원칙상 1억 원을 초과하여 인용할 수 없으므로 결국 결론적으로는 제1심의 1억 원 인용이 유지되어야 하며, 이때의 형식 역시 항소기각이 된다.

IV. 사안의 적용

1. 불이익변경금지 원칙의 위반

- 피고 乙만이 항소한 본 사안에서 항소심 법원이 1억 5,000만 원을 지급하라고 판결하는 것은 乙에게 불리하게 판결을 변경하는 것이므로 불이익변경금지의 원칙에 위배되어 위법하다. 비록 객관적인 손해액이 1억 5,000만 원이라 하더라도 법원은 1억 원을 한도로 판결할 수밖에 없다.

2. 재판 형식의 결정

- 乙의 항소이유(사실오인에 따른 전부 기각 주장)가 이유 없고, 법원이 보기에 제1심 판결의 액수(1억 원)가 乙에게 최소한 억울하지 않은 금액(오히려 더 적은 금액)임이 확인되었다면, 법원은 제1심 판결의 주문을 유지하는 항소기각 판결을 내려야 한다. 이때 법원은 판결 이유 중에서 제1심의 과실상계가 잘못되었음을 지적하되, 원고의 항소가 없으므로 주문에서는 1억 원을 유지한다는 취지를 명시하게 된다.

V. 결론

- 항소심 법원은 피고 乙만이 항소한 경우 불이익변경금지의 원칙에 따라 제1심 판결인 1억 원보다 乙에게 불리한 1억 5,000만 원을 선고할 수 없다. 실령 항소심 재판부가 실체적 진실에 비추어 1억 5,000만 원이 적정하다고 판단하더라도, 처분권주의에 의한 절차적 제약으로 인해 제1심의 인용 금액을 유지해야 한

다. 따라서 법원은 乙의 항소가 이유 없음을 이유로 항소기각 판결을 선고함으로써 제1심 판결의 효력을 존속시켜야 한다.

<제6편 상소심절차.제14장 항소.제04절 항소심의 중국재판>

[모의][14.04-2]제1심의 소각하판결이 부당한 경우 항소심 법원의 환송 및 자판 여부

《【문제14.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 2억 원의 손해배상청구소송을 제기하였다. 제1심 법원은 乙의 책임을 인정하면서도 과실상계를 적용하여 "乙은 甲에게 1억 원을 지급하라"는 원고 일부승소 판결을 선고하였다. 이에 대하여 피고 乙만이 항소하였고, 원고 甲은 항소하지 않았다.

항소심 심리 결과, 재판부는 乙의 과실이 제1심판결보다 더 크다고 판단하여 손해배상액이 1억 5,000만 원이 적정하다는 결론에 도달하였다. 반면, 乙은 제1심판결이 전제한 사실관계 자체가 오인되었으므로 제1심판결을 취소하고 甲의 청구를 전부 기각해야 한다고 주장하고 있다.

또 다른 사건에서, A는 B를 상대로 소를 제기하였으나 제1심 법원은 소의 제기 요건에 흠결이 있다는 이유로 "소각하판결"을 선고하였다. A는 이에 불복하여 항소하였고, 항소심 법원은 심리 결과 제1심의 판단과 달리 소의 요건이 구비되어 적법하다고 판단하였다. 그러나 항소심 법원은 본안 심리를 충분히 하지 않은 상태에서 스스로 판결(자판)을 내릴지, 아니면 다시 제1심 법원으로 사건을 돌려보낼지 검토 중이다.

(물음2) A가 제기한 항소심에서 제1심의 소각하판결이 부당하다고 인정되는 경우, 항소심 법원이 사건을 반드시 제1심 법원으로 환송해야 하는지(필수적 환송) 아니면 직접 본안판결을 할 수 있는지 여부를 민사소송법 제418조의 규정과 "심급의 이익" 관점에서 설명하시오.》

<문제14.4의 물음2> 제1심의 소각하판결이 부당한 경우 항소심 법원의 환송 및 자판 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A가 제1심 소각하판결에 불복하여 항소하였고, 항소심에서 제1심 판단과 달리 소가 적법하다고 인정된 상황이다. 쟁점으로 소각하판결이 취소되는 경우 항소심 법원이 심급의 이익을 고려하여 사건을 제1심 법원에 환송하여야 하는지 또는 직접 본안판결을 할 수 있는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 민사소송법 제418조에 따른 필수적 환송 여부와 항소심의 자판 가능성을 설명한다.

II. 필수적 환송과 자판의 법리

1. 민사소송법 제418조의 규정

(1) 원칙 : 필수적 환송

- 민사소송법 제418조 본문은 소를 각하한 제1심 판결을 취소하는 경우에 그 소송절차가 본안판결을 할 수 있을 정도로 심리되어 있지 않다면 항소심 법원은 사건을 제1심 법원에 환송하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 제1심에서 본안심리가 이루어지지 않았음을 전제로 한다.

(2) 예외 : 자판의 허용

- 다만, 민사소송법 제418조 단서에서는 사건이 본안판결을 할 수 있을 정도로 충분히 심리되었거나, 당사자의 동의가 있는 경우에는 항소심 법원이 스스로 본안판결을 할 수 있도록 규정하고 있다.

2. 심급의 이익 관점

(1) 이익

- 심급의 이익이란 당사자가 동일한 쟁점에 대하여 하급심과 상급심에서 반복하여 재판을 받을 수 있는 권리를 의미한다. 우리 민사소송법은 원칙적으로 3심제를 채택하여 당사자에게 충분한 방어 기회를 부여하고 있다.

(2) 소각하판결과 심급의 이익

- 제1심에서 소제기 요건만을 이유로 소를 각하한 경우, 본안의 실체적 쟁점에 대해서는 아무런 심리가 이루어지지 않은 상태이다. 만약 항소심이 곧바로 본안판결을 내린다면, 당사자는 실질적으로 본안에 대하여 단 한 번의 사실심 재판만을 받게 되어 3심제 하에서의 심급의 이익을 침해당하게 된다. 따라서 민사소송법 제418조 본문의 필수적 환송 규정은 이러한 심급의 이익을 보장하기 위한 제도적 장치이다.

3. 환송 여부의 판단 기준

(1) 본안심리의 정도

- 제1심에서 비록 소각하판결을 하였더라도, 기록상 본안에 관한 증거조사가 충분히 이루어져 항소심에서 즉시 판결을 내릴 수 있는 상태라면 예외적으로 자판이 가능하다.

(2) 당사자의 동의

- 심급의 이익은 사익적 성격이 강하므로, 당사자가 신속한 재판을 위해 항소심에서의 자판에 동의한다면 환송하지 않고 직접 판결할 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 제1심 판결의 부당성 확인

- 사안에서 항소심 법원은 심리 결과 제1심의 판단과 달리 소의 요건이 구비되어 적법하다고 판단하였다. 따라서 제1심의 소각하판결은 부당하므로 항소심 법원은 이를 취소하여야 한다.

2. 필수적 환송의 원칙 적용

- 문제에서 항소심 법원은 본안 심리를 충분히 하지 않은 상태라고 명시하고 있다. 이는 민사소송법 제418조 단서의 자판 요건인 사건이 본안판결을 할 수 있을 정도로 심리되었을 때에 해당하지 않음을 의미한다.

3. 심급의 이익 보호의 필요성

- 원고 A와 피고 B는 본안의 실체 관계(손해배상 책임의 유무 등)에 대하여 제1심 법원의 판단을 받을 기회를 전혀 가지지 못하였다. 만약 항소심 법원이 자판을 강행할 경우 당사자의 심급의 이익이 심각하게 침해된다. 따라서 특별한 사정(당사자의 전원 동의 등)이 없는 한 법원은 사건을 제1심 법원으로 환송하여 본안 심리를 처음부터 다시 받게 해야 한다.

IV. 결론

- 민사소송법 제418조에 의하면 제1심의 소각하판결이 부당하여 취소하는 경우, 본안 심리가 충분히 이루어지지 않았다면 사건을 제1심 법원으로 환송하는 것이 원칙이다.(필수적 환송) 이는 당사자가 본안에 대하여 하급심의 판단을 받아볼 수 있는 심급의 이익을 보호하기 위함이다. 사안의 경우 본안 심리가 불충분하므로 항소심 법원은 스스로 판결을 내릴 것이 아니라 사건을 제1심 법원으로 환송하여야 한다.

<제6편 상소심절차.제15장 상고.제02절 상고이유>

[모의][15.02-1]상고이유서 제출기한 도과 후 제출된 절대적 상고이유의 심리 가능성 여부

《【문제15.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제1심과 항소심에서 모두 승소하였다. 항소심 판결은 2024. 3. 1. 乙에게 송달되었고, 乙은 항소심 판결 중 사실인정에 채증법칙 위반의 잘못이 있고 대여금의 소멸시효가 완성되었음을 주장하며 상고를 제기하고자 한다.

그런데 乙은 상고장 제출 당시 상고이유를 기재하지 않았고, 상고기록 접수통지를 받은 날로부터 20일이 지나도록 상고이유서를 제출하지 않았다. 그 후 乙은 뒤늦게 상고이유서를 제출하면서, 항소심 판결에 관여한 판사 A가 제1심 판결에도 관여하여 민사소송법 제424조 제1항 제1호의 "법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 판사가 판결에 관여한 때"에 해당한다는 점을 새로이 주장하였다.

또한, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소를 제기하였으나 항소심에서 패소하였다. 丙은 상고심에서 항소심 판결이 "이유를 밝히지 아니하거나 이유에 모순이 있는 때"에 해당한다며 상고하였다. 그런데 대법원은 심리 중 丙의 상고이유와는 별개로, 이 사건 항소심 재판의 전제가 된 소송대리권의 흠결이나 전속관할 위반 여부 등에 대해 의문을 갖게 되었다.

(물음1) 乙이 상고이유서 제출기한을 도과하여 제출한 상고이유서에 기재된 "절대적 상고이유(판결에 관여할 수 없는 법관의 관여)"를 상고심 법원이 심리할 수 있는지 여부를 민사소송법 제429조(상고이유서를 내지 아니한 경우의 처분)와 관련하여 논하시오.》

<문제15.2의 물음1> 상고이유서 제출기한 도과 후 제출된 절대적 상고이유의 심리 가능성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙이 항소심 판결에 대하여 상고를 제기하였으나 상고이유서 제출기한을 도과한 후 절대적 상고이유를 주장한 상황이다. 쟁점으로 상고이유서 미제출 또는 지연제출의 경우에도 절대적 상고이유에 해당하는 사유를 상고심 법원이 직권으로 심리할 수 있는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 민사소송법 제429조에 따른 상고이유서 제출의무와 절대적 상고이유의 심리 가능성을 논한다.

II. 상고이유서 제출기한과 상고기간

1. 민사소송법 제427조 및 제429조의 규정

(1) 상고이유서 제출기한

- 상고인은 상고장에 상고이유를 적지 아니한 때에는 상고기록 접수통지를 받은 날부터 20일 이내에 상고이유서를 제출하여야 한다. 이 기한은 법정기간으로서 연장될 수 없는 것이 원칙이다.

(2) 기한 도과의 효과

- 민사소송법 제429조 본문에 의하면 상고인이 위 기간 내에 상고이유서를 제출하지 아니한 때에는 상고심 법원은 결정이 아닌 판결로 상고를 기각하여야 한다. 이는 상고심의 신속한 진행을 위한 제재적 규정이다.

2. 상고기간 판결의 예외

- 민사소송법 제429조 단서에 의하면 상고이유서가 제출되지 않았거나 기한을 넘겼더라도, 상고장에 상고이유가 적혀 있거나 직권으로 조사하여야 할 사유가 있는 경우에는 기한 도과를 이유로 바로 상고를 기각할 수 없다.

III. 절대적 상고이유의 심리 가능성

1. 절대적 상고이유의 의의 및 성격

(1) 의의

- 민사소송법 제424조 제1항 각 호에 규정된 사유들로, 판결에 관여할 수 없는 판사가 판결에 관여한 경우(제1호), 법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 법관이 판결에 관여한 경우 등을 포함한다.

(2) 법적 성격

- 이러한 사유들은 소송절차의 중대한 하자를 구성하며, 당사자의 상고이유 기재 여부와 관계없이 법원이 직권으로 조사하여 판결의 당부를 판단해야 하는 직권조사사항에 해당한다.

2. 제출기한 도과와의 관계

(1) 직권조사사항에 대한 판례의 태도

- 대법원은 상고이유서 제출기간 내에 상고이유서를 제출하지 않았거나, 기간 경과 후에 상고이유서를 제출한 경우라 하더라도, 그 상고이유서에 기재된 내용이 직권조사사항에 해당하거나 절대적 상고이유에 해당하는 경우에는 법원이 이를 심리하여야 한다고 판단한다.

(2) 법리적 근거

- 상고이유서 제출기한을 두는 목적은 상고심의 효율성이지만, 법률에 어긋난 재판이나 중대한 절차적 하자가 있는 판결을 그대로 확정시키는 것은 재판의 적정성과 정의에 반하기 때문이다. 따라서 민사소송법 제429조 단서의 직권으로 조사하여야 할 사유에는 절대적 상고이유가 포함되는 것으로 해석된다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 상고이유 분석

- 乙이 뒤늦게 주장한 사유는 판결에 관여할 수 없는 판사가 판결에 관여한 경우이다. 이는 민사소송법 제424조 제1항 제1호에 해당하는 절대적 상고이유이자 직권조사사항이다.

2. 법원의 심리 의무

- 乙이 상고기록 접수통지를 받은 날로부터 20일을 지나 상고이유서를 제출한 것은 사실이나, 제출된 내용에 중대한 법률 위반인 절대적 상고이유가 포함되어 있다. 민사소송법 제429조 단서에 따라 직권조사사항이 있는 경우에는 기한 도과를 이유로 상고를 기각할 수 없으므로, 상고심 법원은 乙의 상고이유서 제출 시점과 관계없이 해당 사유를 심리하여야 한다.

V. 결론

- 상고이유서 제출기한을 도과하여 제출된 상고이유서라 하더라도, 그 내용이 민사소송법 제424조 제1항의 절대적 상고이유에 해당하는 경우에는 법원이 이를 직권으로 심리하여야 한다. 이는 민사소송법 제429조 단서가 규정한 직권조사사항의 예외에 해당하기 때문이다. 따라서 사안에서 상고심 법원은 乙이 주장한 법관의 관여 문제를 심리하여 항소심 판결의 위법 여부를 판단하여야 한다.

《【문제15.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제1심과 항소심에서 모두 승소하였다. 항소심 판결은 2024. 3. 1. 乙에게 송달되었고, 乙은 항소심 판결 중 사실인정에 채증법칙 위반의 잘못이 있고 대여금의 소멸시효가 완성되었음을 주장하며 상고를 제기하고자 한다.

그런데 乙은 상고장 제출 당시 상고이유를 기재하지 않았고, 상고기록 접수통지를 받은 날로부터 20일이 지나도록 상고이유서를 제출하지 않았다. 그 후 乙은 뒤늦게 상고이유서를 제출하면서, 항소심 판결에 관여한 판사 A가 제1심 판결에도 관여하여 민사소송법 제424조 제1항 제1호의 "법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 판사가 판결에 관여한 때"에 해당한다는 점을 새로이 주장하였다.

또한, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소를 제기하였으나 항소심에서 패소하였다. 丙은 상고심에서 항소심 판결이 "이유를 밝히지 아니하거나 이유에 모순이 있는 때"에 해당한다며 상고하였다. 그런데 대법원은 심리 중 丙의 상고이유와는 별개로, 이 사건 항소심 재판의 전제가 된 소송대리권의 흠결이나 전속관할 위반 여부 등에 대해 의문을 갖게 되었다.

(물음2) 상고심이 원칙적으로 상고이유서에 기재된 범위 내에서만 심리하는 법률심임에도 불구하고, 丙의 사례와 같이 상고이유에 포함되지 않은 소송요건이나 전속관할 위반 등의 사항을 대법원이 직권으로 조사하여 판단할 수 있는지 그 근거와 한계에 대하여 기술하시오.》

<문제15.2의 물음2> 상고심의 직권조사사항의 근거와 한계

I. 문제의 제기

- 사안에서 丙이 항소심 판결에 대하여 상고를 제기하면서 이유불비 등의 상고이유를 주장하였으나, 상고심 법원이 소송요건이나 전속관할 위반 여부를 별도로 발견한 상황이다. 쟁점으로 법률심인 상고심이 상고이유서에 기재되지 않은 사항에 대하여도 직권으로 조사·판단할 수 있는지와 그 범위를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 상고심의 심리범위와 직권조사사항의 인정 근거 및 한계를 기술한다.

II. 상고심의 심리 범위와 직권조사사항

1. 변론주의와 직권조사사항의 관계

(1) 원칙(상고이유 구속의 원칙)

- 민사소송법 제431조에 의하면 상고법원은 상고이유에 의하여 불복신청한 범위 안에서 심리한다. 이는 당사자가 제기한 오류에 대해서만 판단하겠다는 취지이다.

(2) 예외(직권조사사항)

- 소송요건이나 전속관할, 소송대리권의 존부 등 소송의 전제가 되는 사항은 당사자의 주장 여부와 상관없이 법원이 스스로 조사하여 판결의 기초로 삼아야 한다. 이는 공공의 이익과 직결되는 절차적 정당성을 확보하기 위함이다.

2. 민사소송법상 근거

(1) 제434조(준용규정)

- 상고심 절차에는 항소심의 규정이 준용되며, 항소심에서는 소송요건 등 직권조사사항에 대해 당사자의 불복 유무를 불문하고 심리할 수 있다.

(2) 제429조 단서

- 상고이유서 제출기한을 초과하더라도 직권으로 조사하여야 할 사유가 있는 경우에는 상고를 기각할 수 없다고 규정하여, 직권조사사항이 상고이유에 우선함을 명시하고 있다.

III. 직권조사사항의 구체적 범위와 근거

1. 소송요건 및 소송대리권

- 소송요건은 법원이 소송의 주체, 객체, 절차에 관하여 공익적 견지에서 미리 확정해 두어야 할 사항이다. 특히 소송대리권의 흠결은 적법한 절차를 거치지 않은 재판이 될 우려가 있으므로 상고심에서도 반드시 직권으로 조사해야 한다.

2. 전속관할

- 관할권 중 전속관할은 국가의 사법행정상 이유나 공익적 목적에 의해 강제된 것이므로, 당사자의 합의나 변론으로 변경할 수 없다. 따라서 전속관할 위반 여부는 상고심의 직권조사 대상이 된다.

3. 절대적 상고이유

- 민사소송법 제424조 제1항 각 호에 규정된 절대적 상고이유(법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 판사의 관여 등)는 그 하자가 매우 중대하여 당사자의 주장이 없더라도 대법원이 스스로 파악하여 파기 사유로 삼을 수 있다.

IV. 직권조사의 한계

1. 사실인정의 한계

- 상고심은 법률심이므로 새로운 증거조사를 할 수 없는 것이 원칙이다. 따라서 직권조사사항이라 하더라도 그 기초가 되는 사실관계가 원심 판결문이나 기록에 나타나 있어야 한다. 다만, 소송요건 중 법원의 권한에 속하는 사항은 필요한 경우 예외적으로 사실을 탐지할 수 있다.

2. 상고의 이익에 의한 한계

- 상고인은 자기에게 불이익한 판결에 대해서만 상고할 수 있다. 직권조사사항이라 하더라도 원심 판결이 상고인에게 유리하게 선고되었다면, 상고인이 주장하지 않은 유리한 직권조사사항을 근거로 원심을 파기하는 것은 상고의 이익 원칙에 반할 수 있다.

3. 처분권주의와의 관계

- 청구의 당부와 직접 관련된 본안의 사실관계는 직권조사의 대상이 될 수 없다. 소멸시효의 완성이나 채무의 변제와 같은 항변 사항은 당사자가 상고이유로 주장하지 않는 한 대법원이 직권으로 판단할 수 없다.

V. 사안의 적용

1. 丙의 상고이유와 직권조사사항의 관계

- 사안에서 丙은 이유불비 및 이유모순을 상고이유로 들었으나, 대법원이 인지한 소송대리권의 흠결 및 전속관할 위반은 소송요건 및 공익적 관할에 관한 사항이다. 이는 민사소송법상 직권조사사항에 해당하므로 丙의 상고이유 포함 여부와 관계없이 대법원이 심리할 수 있다.

2. 대법원의 판단 가능성

- 대법원은 상고이유서에 기재되지 않은 사항이라 하더라도 소송대리권 흠결 여부를 조사하여야 한다. 만약 대리권이 없거나 전속관할을 위반한 사실이 기록상 확인된다면, 丙이 주장한 이유불비에 대한 판단에 앞서 원심판결을 직권으로 파기하고 사건을 환송하거나 이송하여야 한다.

V. 결론

- 상고심은 법률심으로서 상고이유에 구속되는 것이 원칙이나, 소송요건이나 전속관할 위반 등과 같은 직권조사사항에 대해서는 그 한계를 준수하는 범위 내에서 상고이유에 포함되지 않았더라도 직권으로 심리·판단할 수 있다. 이는 사법 정의의 실현과 적법절차의 원칙을 수호하기 위한 법원의 책무이기 때문이다. 따라서 대법원은 丙의 사례에서 발견된 절차적 흠결을 직권으로 조사하여 판결에 반영할 수 있다.

<제6편 상소심절차.제15장 상고.제03절 상고심절차의 개시와 심리>

[모의][15.03-1]상고이유서 제출기한 도과에 따른 대법원의 조치와 직권조사사항 포함 시 재판 결과의 변화

《【문제15.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 항소심에서 승소하였다. 피고 乙은 이에 불복하여 2024. 4. 1. 상고장을 제출하였고, 대법원은 2024. 4. 15. 乙에게 상고기록접수통지서를 송달하였다. 乙은 상고이유서를 작성하던 중 질병으로 입원하게 되어, 통지서를 받은 날로부터 21일째 되는 날에야 상고이유서를 우체국에 접수하였다.

한편, 乙이 제출한 상고이유서에는 "원심판결이 법령의 해석을 그르쳐 대법원 판례와 상반되는 판단을 하였다"는 내용이 포함되어 있었다. 대법원은 이 사건이 상고심절차에 관한 특례법 제4조에서 정한 심리불속행 사유에 해당하는지 여부를 검토하고 있다.

또한, 별개의 소송에서 丙은 丁을 상대로 손해배상을 청구하였으나 항소심에서 기각되었다. 丙은 상고심에서 항소심이 판단하지 않은 새로운 사실관계인 "丁의 추가적인 불법행위"를 주장하며 관련 증거를 대법원에 제출하였다. 대법원은 丙이 제출한 새로운 증거를 기초로 항소심 판결을 뒤집을 수 있는지 확인 중이다.

(물음1) 乙이 상고기록접수통지를 받은 날로부터 20일의 기간을 도과하여 상고이유서를 제출한 경우, 대법원이 민사소송법 제429조에 따라 취해야 할 조치와 만약 乙이 제출한 상고이유서에 "직권조사사항"에 해당하는 내용이 포함되어 있다면 재판 결과가 달라질 수 있는지 논하시오.》

<문제15.3의 물음1> 상고이유서 제출기한 도과에 따른 대법원의 조치와 직권조사사항 포함 시 재판 결과의 변화

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 상고기록접수통지를 받은 후 법정기간인 20일을 경과하여 상고이유서를 제출하였고, 그 상고이유서에는 직권조사사항에 해당할 수 있는 내용도 포함되어 있는 상황이다. 쟁점으로 상고이유서 제출기간을 도과한 경우 대법원이 민사소송법 제429조에 따라 어떠한 조치를 하여야 하는지와 상고이유서에 직권조사사항이 포함된 경우 그에 따라 재판 결과가 달라질 수 있는지를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 상고이유서 제출기간 도과의 효과와 직권조사사항이 있는 경우의 심리 및 재판 가능성을 논한다.

II. 상고이유서 제출기한 도과와 대법원의 조치

1. 상고이유서 제출기간의 성격

- 민사소송법 제427조는 상고인이 상고기록접수통지를 받은 날부터 20일 이내에 상고이유서를 제출하여야 한다고 규정하고 있다. 이 기간은 불변기간은 아니나, 소송절차의 신속을 기하기 위한 법정기간으로서 그 준수 여부는 엄격하게 판단된다.

2. 기한 도과 시의 원칙적 조치(상고기각판결)

(1) 민사소송법 제429조의 규정

- 상고인이 민사소송법 제427조의 기간 내에 상고이유서를 제출하지 아니한 때에는 상고법원은 변론 없이 판결로 상고를 기각하여야 한다. 이는 상고이유의 부존재를 법률상 추정하여 신속하게 절차를 종결하기 위함이다.

(2) 예외적 수리 가능성

- 대법원 판례에 의하면, 상고이유서 제출기한을 단 하루라도 도과한 경우에는 원칙적으로 기각 대상이다. 다만, 제출기한 내에 상고이유를 기재하지 않은 상고장을 제출하였더라도 대법원이 상고기각판결을 내리기 전까지 상고이유서를 제출하였다면 이를 참작해야 한다는 견해가 있으나, 현행법상 20일의 기한은 강행적 의미를 갖는다.

III. 직권조사사항이 포함된 경우의 재판 결과 변화

1. 민사소송법 제429조 단서의 취지

- 민사소송법 제429조 단서는 상고장에 상고이유가 적혀 있는 때 또는 직권으로 조사하여야 할 사유가 있는 때에는 기한 도과를 이유로 상고를 기각할 수 없다고 규정하고 있다. 이는 절차적 태만보다 실체법적 혹은 절차법적 중대 하자를 우선시하겠다는 입법적 결단이다.

2. 직권조사사항의 범위와 효력

(1) 범위

- 직권조사사항이란 소송요건의 존부, 전속관할 위반, 소송대리권의 흠결, 재판권의 부존재 등 법원이 당사자의 주장 여부와 관계없이 스스로 조사하여 판단해야 할 사항을 의미한다.

(2) 효력

- 乙이 제출한 상고이유서가 비록 20일의 기간을 도과하여 제출되었다 하더라도, 그 내용 중에 위와 같은 직권조사사항에 해당하는 중대한 하자가 포함되어 있다면 대법원은 제429조 본문에 따른 상고기각판결을 할 수 없다. 이 경우 대법원은 기한 도과 사실을 묵인하고 본안심리에 들어가 직권조사사항에 대한 판단을 내려야 한다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 상고이유서 제출과 기한 도과

- 乙은 2024. 4. 15. 통지를 받았으므로 그로부터 20일이 되는 날은 2024. 5. 5.이다. 乙이 21일째 되는 날에 우체국에 접수하였다면 이는 명백한 기한 도과에 해당한다. 질병으로 인한 입원은 특별한 사정이 없는 한 민사소송법상 추완 사유나 기한 연장 사유로 인정되기 어렵다. 따라서 원칙적으로 대법원은 무변론 상고기각판결을 내려야 한다.

2. 직권조사사항 포함 시의 결과

- 그러나 乙이 늦게 제출한 상고이유서에 단순한 법리 오해나 사실인정의 오류를 넘어, 소송요건 흠결과 같은 직권조사사항이 포함되어 있다면 상황은 반전된다. 민사소송법 제429조 단서에 의해 대법원은 기한 도과를 이유로 상고를 기각할 수 없으며, 해당 직권조사사항을 심리하여 원심판결의 적법성을 판단해야 한다.

3. 상반된 판단(제4조 사유)과의 구별

- 乙이 주장한 대법원 판례와 상반되는 판단은 상고심절차 특례법상의 심리불속행 제외 사유일 뿐, 그 자체로 민사소송법 제429조 단서의 직권조사사항은 아니다. 따라서 乙이 제출한 내용이 단순한 판례 위반 주장이라면 기각을 면할 수 없으나, 별도의 소송요건 흠결 등이 포함되어 있다면 재판 결과는 기각에서 본안심리(파기 혹은 기각)로 달라지게 된다.

V. 결론

- 乙이 상고이유서 제출기한을 도과한 경우 대법원은 원칙적으로 민사소송법 제429조 본문에 따라 변론 없이 판결로 상고를 기각하여야 한다. 그러나 乙이 제출한 상고이유서에 소송대리권 흠결이나 전속관할 위반 등 직권조사사항이 포함되어 있다면, 대법원은 기한 도과를 이유로 상고를 기각할 수 없으며 해당 사유를 심리하여 판결해야 하므로 재판 결과는 달라진다.

<제6편 상소심절차:제15장 상고:제03절 상고심절차의 개시와 심리>

[모의][15.03-2]심리불속행 제도의 취지 및 범위와 상고심에서 새로운 사실 및 증거 제출의 허용 여부

《【문제15.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 항소심에서 승소하였다. 피고 乙은 이에 불복하여 2024. 4. 1. 상고장을 제출하였고, 대법원은 2024. 4. 15. 乙에게 상고기록접수통지서를 송달하였다. 乙은 상고이유서를 작성하던 중 지병으로 입원하게 되어, 통지서를 받은 날로부터 21일째 되는 날에야 상고이유서를 우체국에 접수하였다.

한편, 乙이 제출한 상고이유서에는 "원심판결이 법령의 해석을 그르쳐 대법원 판례와 상반되는 판단을 하였다"는 내용이 포함되어 있었다. 대법원은 이 사건이 상고심절차에 관한 특례법 제4조에서 정한 심리불속행 사유에 해당하는지 여부를 검토하고 있다.

또한, 별개의 소송에서 丙은 丁을 상대로 손해배상을 청구하였으나 항소심에서 기각되었다. 丙은 상고심에서 항소심이 판단하지 않은 새로운 사실관계인 "丁의 추가적인 불법행위"를 주장하며 관련 증거를 대법원에 제출하였다. 대법원은 丙이 제출한 새로운 증거를 기초로 항소심 판결을 뒤집을 수 있는지 확인 중이다.

(물음2) 상고심절차에 관한 특례법상 "심리불속행" 제도의 취지와 적용 범위를 설명하고, 丙의 사례와 같이 상고심에서 새로운 사실이나 증거를 제출하는 것이 법률심의 원칙상 허용되는지 여부를 판례의 태도에 근거하여 기술하시오.》

<문제15.3의 물음2> 심리불속행 제도의 취지 및 범위와 상고심에서 새로운 사실 및 증거 제출의 허용 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 대법원은 상고이유가 심리불속행 대상에 해당하는지를 검토하고 있으며, 별개의 사례에서는 상고심에서 새로운 사실과 증거를 제출하여 원심판결을 다투려는 상황이다. 쟁점으로 상고심절차에 관한 특례법(이하 '특례법')상 심리불속행 제도의 취지와 적용 범위 및 상고심에서 새로운 사실이나 증거를 제출하는 것이 법률심의 원칙상 허용되는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 심리불속행 제도의 취지와 적용 범위 및 상고심에서 새로운 사실과 증거 제출의 허용 여부를 기술한다.

II. 심리불속행 제도의 취지와 적용 범위

1. 제도의 취지

- 심리불속행 제도란 상고이유에 관한 주장이 법률령 위반 등 특례법이 정한 특정한 사유를 포함하지 않는 경우, 더 이상의 본안 심리를 거치지 않고 판결로 상고를 기각하는 제도이다. 이는 대법원에 사건이 과도하게 집중되는 것을 방지하여 사법 자원을 효율적으로 배분하고, 중대한 법령 해석의 통일이 필요한 사건에 집중함으로써 최고법원으로서의 기능을 정상화하는 데 그 목적이 있다.

2. 적용 범위

(1) 대상 사건

- 심리불속행 제도는 민사사건, 가사사건, 행정사건의 상고심 절차에 적용된다. 다만, 형사사건에는 적용되지 않으며, 민사사건 중에서도 재심사건이나 전원합의체에서 다루어야 할 판례 변경의 필요성이 있는 사건 등은 제외될 수 있다.

(2) 심리불속행 사유 [특례법 제4조]

- 대법원은 상고이유에 관한 주장이 다음 각 호의 사유를 포함하지 아니한다고 인정하면 더 나아가 심리를 하지 아니한다. ❶ 원심판결이 헌법에 위반되거나 헌법을 부당하게 해석한 경우, ❷ 원심판결이 법령의 해석을 그르쳐 대법원 판례와 상반되는 판단을 한 경우, ❸ 대법원 판례가 없거나 이를 변경할 필요가 있는 경우, ❹ 그 밖에 중대한 법령 위반이 있는 경우 등이다.

III. 상고심에서 새로운 사실 및 증거 제출의 허용 여부

1. 법률심 및 사후심의 원칙

- 상고심은 원심판결 시까지 제출된 자료를 기초로 원심판결의 법률적 정당성을 판단하는 사후심이다. 따라서 사실심의 변론종결 전까지 주장하고 입증하지 아니한 새로운 사실을 상고심에서 주장하거나 증거를 제출하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.

2. 판례의 태도

(1) 새로운 사실과 증거의 배척

- 판례는 상고심은 법률심이므로 새로운 증거조사를 할 수 없고, 상고심에서 비로소 주장하는 새로운 사실이나 제출하는 새로운 증거는 원심판결의 당부를 판단하는 자료로 삼을 수 없다는 입장을 일관되게 유지하고 있다.

(2) 예외적 허용 사항

- 다만, 소송요건에 관한 사항이나 전속관할, 소송대리권 등 법원이 직권으로 조사하여야 할 사항에 대해서는 상고심에서도 새로운 자료를 제출할 수 있으며, 법원은 이를 참작하여 판단할 수 있다. 그러나 본안에 관한 실체적 사실관계에 대해서는 엄격히 금지된다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 사례와 심리불속행

- 乙은 상고이유서에 원심판결이 대법원 판례와 상반되는 판단을 하였다고 명시하였다. 이는 특례법 제4조 제1항 제2호에 해당하는 사유로, 만약 대법원이 심리 결과 실제로 판례 위반의 소지가 있다고 판단한다면 심리불속행 기각을 할 수 없고 본안 심리를 속행하여야 한다.

2. 丙의 사례와 새로운 증거 제출

- 丙은 항소심에서 판단하지 않은 새로운 사실관계인 丁의 추가적인 불법행위와 관련 증거를 대법원에 제출하였다. 이는 전형적인 새로운 실체적 사실의 주장 및 증거 제출에 해당한다. 상고심은 법률심이자 사후심으로서 원심 변론종결 시를 기준으로 판결의 당부를 가려야 하므로, 대법원은 丙이 제출한 새로운 증거를 기초로 항소심 판결을 뒤집을 수 없다. 丙의 주장은 원심 판결에 대한 적법한 상고이유가 될 수 없으며 대법원은 이를 심리 자료로 삼아서는 안 된다.

V. 결론

- 심리불속행 제도는 대법원의 기능 효율화를 위해 중대한 법령 위반이 없는 상고를 조기에 종결시키는 제도이며, 특례법 제4조의 사유가 없는 경우에 적용된다. 또한 상고심은 법률심이자 사후심이므로 丙이 제출한 새로운 사실관계와 증거는 원심판결의 당부를 판단하는 근거가 될 수 없다. 따라서 대법원은 丙의 새로운 증거를 배척하고 원심판결 당시의 자료만을 토대로 법률적 판단을 내려야 한다.

<제6편 상소심절차.제15장 상고.제04절 상고심의 중국재판>

[모의][15.04-1]파기환송 판결의 기속력 및 범위와 사실관계 변동 시 기속력의 한계

《【문제15.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제1심에서는 승소하였으나, 항소심에서는 乙의 소멸시효 항변이 받아들여져 패소하였다. 甲은 이에 불복하여 상고하였고, 대법원은 심리 결과 항소심이 소멸시효 중단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 판단하였다. 이에 대법원은 항소심 판결을 파기하고 사건을 다시 심리하도록 하기 위해 원심법원인 고등법원으로 환송하는 판결을 선고하였다.

파기환송 판결을 받은 환송 후 원심법원은 재판을 다시 진행하게 되었다. 그런데 환송 후 원심법원의 재판부는 대법원이 파기 사유로 삼았던 법적 판단이 최근의 다른 유사 사건에 대한 대법원 전원합의체 판결의 취지와 배치된다고 생각하여, 대법원의 기속력에 반하여 기존 항소심 판결과 동일한 취지로 甲의 청구를 기각하는 판결을 내리고자 한다.

한편, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 항소심에서 승소하였다. 丁이 상고하였으나 대법원은 상고이유가 없다고 판단하여 상고기각 판결을 선고하였다. 그 후 丙은 상고심 재판 과정에서 대법원이 중요한 증거를 판단에서 누락하였다는 대법원에 다시 한번 판단을 구해달라고 요청하고 있다.

(물음1) 대법원이 원심판결을 파기하고 사건을 환송한 경우, 환송을 받은 법원이 대법원의 파기이유가 된 사실상 및 법률상 판단에 기속되는지 여부(기속력)와 그 범위에 대하여 설명하고, 만약 환송 후 새로운 증거가 제출되어 사실관계가 변동된 경우에도 여전히 대법원의 판단에 구속되는지 논하시오.》

<문제15.4의 물음1> 파기환송 판결의 기속력 및 범위와 사실관계 변동 시 기속력의 한계

I. 문제의 제기

- 사안에서 대법원이 항소심판결을 파기환송한 후 환송법원이 대법원의 법리판단과 달리 재판하러 하고, 환송 후에는 새로운 증거 제출로 사실관계의 변동 가능성도 있는 상황이다. 쟁점으로 파기환송판결의 기속력이 환송법원의 사실상 및 법률상 판단에 어떠한 범위까지 미치는지와 환송 후 새로운 증거 제출 등으로 사실관계가 변동된 경우에도 대법원의 판단에 계속 기속되는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 파기환송판결의 기속력과 그 범위 및 사실관계 변동이 있는 경우의 기속력의 효력을 논한다.

II. 파기환송 판결의 기속력과 범위

1. 기속력의 의미

- 민사소송법 제436조 제2항은 상고법원이 파기의 이유로 삼은 사실상 및 법률상의 판단은 하급심을 기속한다고 규정하고 있다. 이는 재판의 확정력을 보장하고 소송경제 및 심급제도의 목적을 달성하기 위한 법적 강제력이다. 환송받은 법원은 대법원이 파기 사유로 명시한 판단과 상반되는 결론을 내릴 수 없다.

2. 기속력의 범위

(1) 주관적 범위

- 기속력은 사건을 환송받은 원심법원뿐만 아니라, 그 사건이 다시 상고되었을 때의 재상고심 법원에도 미친다. 따라서 동일한 사건에 대하여 대법원은 스스로 내린 이전의 파기 이유와 다른 판단을 할 수 없는 것이 원칙이다.

(2) 객관적 범위

- 판결의 기속력은 파기의 이유가 된 판단에만 미친다. 즉, 상고심에서 판단의 기초가 된 사실상 판단과 법률상 판단 모두에 미친다. 다만, 대법원이 판단하지 않은 사항이나 방론(Obiter Dictum)에 해당하는 부분에 대해서는 기속력이 발생하지 않는다.

III. 기속력의 한계와 사실관계 변동 시의 처리

1. 기속력의 한계 사유

(1) 새로운 사실의 주장과 증거의 제출

- 환송 후 원심법원의 심리 과정에서 새로운 사실이 주장되거나 새로운 증거가 제출되어 대법원 판결의 기초가 되었던 사실관계에 변동이 생긴 경우에는 대법원의 판단은 더 이상 기속력을 가지지 않는다. 이는 기속력이 동일한 사실관계를 전제로 하기 때문이다.

(2) 법령의 변경 및 판례의 변경

- 환송 후 법률이 개정되거나 대법원 전원합의체 판결에 의하여 환송 판결의 기초가 된 법리가 변경된 경우에도 기속력은 상실된다. 하급심 법원은 변경된 법령이나 판례에 따라 재판할 의무가 있기 때문이다.

2. 판례의 태도

- 판례는 상고법원이 파기 이유로 삼은 판단은 환송받은 법원을 기속하지만, 환송 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속력의 판단 기초가 된 사실관계에 변동이 생긴 때에는 그 기속력이 미치지 않는다고 판시하고 있다. 즉, 환송 후 법원이 대법원이 전제한 사실과 다른 사실을 확정하는 것은 기속력 위반이 아니다.

IV. 사안의 적용

1. 법리 판단에 대한 기속력 준수 여부

- 사안에서 환송 후 원심법원은 대법원의 법적 판단이 최근의 다른 전원합의체 판결과 배치된다고 생각하여 기존 항소심과 동일한 취지로 판결하고자 한다. 그러나 당해 사건에 대하여 대법원이 내린 구체적인 파기환송 판결의 기속력은 하급심을 엄격히 구속한다. 만약 해당 법리가 실제로 변경되었다 하더라도, 그것이 당해 사건의 파기환송 판결 이후에 확립된 전원합의체 판결이 아니라면 환송 후 법원은 대법원의 판단을 따라야 한다. 임의로 기속력에 반하는 판결을 하는 것은 심급질서 위반이다.

2. 사실관계 변동 시의 기속력 배제

- 만약 환송 후의 재판 과정에서 甲이나 乙이 새로운 증거를 제출하여 소멸시효 중단과 관련된 사실관계 자체가 대법원이 판단했을 때와 달라졌다면 이야기는 달라진다. 사실관계의 변동은 기속력의 전제를 무너뜨리므로, 환송 후 법원은 변동된 사실을 기초로 독자적인 판단을 내릴 수 있다. 이 경우 대법원의 판단에 구속되지 않고 제반 사정을 고려하여 다시 판결할 수 있다.

V. 결론

- 대법원의 파기환송 판결은 환송 후 원심법원을 사실상·법률상으로 기속하므로 법원은 이에 따라 재판해야 함이 원칙이다. 그러나 환송 후 새로운 증거의 제출 등으로 인해 대법원 판결의 기초가 되었던 사실관계가 변동된 경우에는 기속력이 미치지 않는다. 따라서 사안의 환송 후 원심법원은 단순히 법리에 대한

견해 차이만으로는 대법원의 판단을 거부할 수 없으나, 새로운 증거에 의해 사실관계가 달라졌음이 확인된다면 대법원의 판단에 구속되지 않고 새로운 판결을 할 수 있다.

<제6편 상소심절차.제15장 상고.제04절 상고심의 중국재판>
[모의][15.04-2]파기자판의 요건 및 상고기각 판결 확정 후의 불복 방법

《【문제15.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제1심에서는 승소하였으나, 항소심에서는 乙의 소멸시효 항변이 받아들여져 패소하였다. 甲은 이에 불복하여 상고하였고, 대법원은 심리 결과 항소심이 소멸시효 중단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 판단하였다. 이에 대법원은 항소심 판결을 파기하고 사건을 다시 심리하도록 하기 위해 원심법원인 고등법원으로 환송하는 판결을 선고하였다.

파기환송 판결을 받은 환송 후 원심법원은 재판을 다시 진행하게 되었다. 그런데 환송 후 원심법원의 재판부는 대법원이 파기 사유로 삼았던 법적 판단이 최근의 다른 유사 사건에 대한 대법원 전원합의체 판결의 취지와 배치된다고 생각하여, 대법원의 기속력에 반하여 기존 항소심 판결과 동일한 취지로 甲의 청구를 기각하는 판결을 내리고자 한다.

한편, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 항소심에서 승소하였다. 丁이 상고하였으나 대법원은 상고이유가 없다고 판단하여 상고기각 판결을 선고하였다. 그 후 丙은 상고심 재판 과정에서 대법원이 중요한 증거를 판단에서 누락하였다는 대법원에 다시 한번 판단을 구해달라고 요청하고 있다.

(물음2) 대법원이 원심판결을 파기할 때 반드시 사건을 환송해야 하는지, 아니면 직접 중국판결을 내릴 수 있는 "파기자판"의 요건은 무엇인지 기술하시오. 또한 丙의 사례와 같이 상고기각 판결이 확정된 후 대법원 판결의 당부(當否)를 일반적인 상소 절차로 다시 다룰 수 있는지 여부를 설명하시오.》

<문제15.4의 물음2> 파기자판의 요건 및 상고기각 판결 확정 후의 불복 방법

I. 문제의 제기

- 사안에서 대법원은 항소심판결을 파기하여 환송하였고, 별개의 사례에서는 상고기각 판결이 확정된 후 그 판단의 당부를 다시 다루려는 상황이다. 쟁점으로 대법원이 원심판결을 파기한 경우 반드시 환송하여야 하는지 또는 직접 중국판결을 하는 파기자판이 가능한 요건과 상고기각 판결이 확정된 후 그 당부를 일반적인 상소절차로 다시 다룰 수 있는지를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 파기자판의 요건과 상고기각 판결에 대한 일반 상소의 허용 여부를 설명한다.

II. 파기자판의 의의 및 요건

1. 파기자판의 의의

- 파기자판이란 상고법원이 원심판결을 파기한 경우, 사건을 하급심으로 돌려보내지 않고 스스로 사건의 실체에 대하여 중국판결을 내리는 것을 말한다. 이는 민사소송법 제437조에 규정되어 있으며, 상고법원의 법률심적 성격에 대한 예외에 해당한다.

2. 파기자판의 요건

(1) 확정된 사실에 대한 법령적용의 오류

- 확정된 사실에 대하여 법령을 적용함이 부적당하다는 이유로 판결을 파기하는 경우로서, 사건이 심리 부족 등의 사유 없이 충분히 성숙하여 상고법원이 직접 판결하기에 충분한 상태여야 한다.

(2) 사건이 재판하기에 충분히 성숙한 경우

- 원심이 확정된 사실만으로도 즉시 판결을 내릴 수 있을 정도로 소송자료가 갖추어져 있어야 한다. 만약 추가적인 증거조사나 사실확정이 필요하다면 재판할 수 없고 환송해야 한다.

(3) 소송경제 및 재판의 신속

- 사건을 환송하는 것이 불필요한 절차의 반복을 초래하거나, 재판의 신속을 기하기 위해 상고법원이 직접 결론을 내리는 것이 합리적이라고 판단되는 경우이다.

III. 확정된 상고심 판결에 대한 불복 방법

1. 일반적인 상소 절차의 불가능

(1) 심급의 종료

- 상고심 판결은 선고와 동시에 확정된다. 확정된 판결에 대해서는 더 이상 항소나 상고와 같은 통상의 상소 절차를 통해 당부(當否)를 다룰 수 없다. 이는 재판의 확정력(기판력) 때문이다.

(2) 상고기각 판결의 효과

- 대법원이 상고기각 판결을 내리면 원심판결이 확정된다. 丙이 주장하는 증거 누락 등의 사유는 상고심 절차 내에서의 오류를 주장하는 것이나, 이미 판결이 선고되어 확정된 이상 일반적인 방법으로는 구제받을 수 없다.

2. 재심 절차를 통한 불복

(1) 재심의 의의

- 확정된 중국판결에 중대한 흠이 있는 경우, 예외적으로 그 판결의 부당함을 다투어 취소를 구하고 다시 심판을 청구하는 비상구제방법이다.

(2) 재심사유 [민사소송법 제451조]

- 재판에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락한 경우(민사소송법 제451조 제1항 제9호) 등 법이 정한 엄격한 재심사유가 있어야 한다. 丙이 주장하는 중요한 증거의 판단 누락은 재심사유에 해당할 여지가 있으나, 이는 상고심 판결 자체가 아닌 원심판결의 흠을 다투는 것이라면 상고심 판결에 대한 재심이 아닌 원심판결에 대한 재심 청구의 형식을 취해야 할 경우도 있다.

IV. 사안의 적용

1. 파기자판 가능성 판단

- 대법원이 소멸시효 중단에 관한 법리 오해를 이유로 판결을 파기할 때, 만약 원심이 확정된 사실관계만으로도 시효 중단 여부를 법률적으로 명백히 확정할 수 있다면 대법원은 사건을 환송하지 않고 직접 재판하여 甲의 승소 판결을 내릴 수 있다. 그러나 사실관계에 대한 추가 확인이 필요하다면 반드시 환송해야 한다.

2. 丙의 구제 방법

- 丙은 이미 상고기각 판결이 확정되었으므로 다시 한번 판단해달라는 일반적인 요청(상고 등)으로는 구제받을 수 없다. 오직 민사소송법 제451조에서 정한 재심사유를 갖추어 재심의 소를 제기함으로써만 확정 판결의 효력을 다룰 수 있다. 丙이 주장하는 증거 누락이 재심사유인 판단누락에 해당한다면 재심 절차를 통해 다시 재판받을 가능성이 열려 있다.

V. 결론

- 상고법원은 법리 오해 등으로 파기할 때 사실관계가 확정되어 자판하기에 충분하면 파기자판을 할 수 있으나, 그렇지 않으면 환송함이 원칙이다. 확정된 상고심 판결에 대해서는 통상의 상소로 다룰 수 없으며, 丙은 재심사유가 존재함을 입증하여 재심 절차를 통해서만 불복할 수 있다.

<제6편 상소심절차.제16장 항고.제02절 항고의 절차>

[모의][16.02-1]소장각하명령에 대한 항고절차 및 항고법원의 조치

《【문제16.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하였으나, 제1심 법원은 소장이 접수된 후 인지가 첩부되지 않았음을 이유로 재판장이 보정명령을 내렸음에도 甲이 응하지 않자 소장각하명령을 내렸다. 이에 불복하고자 하는 甲은 소장각하명령 정본을 송달받은 날로부터 1주일 이내에 "항고장"을 작성하여 항고법원이 아닌 원심법원에 제출하였다.

그런데 甲이 제출한 항고장에는 항고이유가 기재되어 있지 않았으며, 별도의 항고이유서도 기재 기한 내에 제출되지 않았다. 원심법원의 재판장은 항고장에 항고이유가 없음을 발견하였으나, 이를 즉시 각하하지 않고 사건 기록을 항고법원으로 보냈다. 항고법원은 기록을 송부받은 후 甲에게 항고이유를 소명할 것을 요구하는 심리 절차를 진행하고자 한다.

한편, 丙은 丁과의 소송비용액확정 절차에서 법원이 내린 결정에 불복하여 즉시항고를 제기하였다. 丙은 즉시항고장에 항고이유를 적지 않았으나, 항고장을 제출한 날로부터 10일 이내에 구체적인 항고이유를 담은 항고이유서를 원심법원에 제출하였다. 丁은 丙이 항소와 달리 항고이유서를 법정 기한 내에 제출하지 않았으므로 해당 항고가 부적법하다고 주장하고 있다.

(물음1) 甲이 항고장을 항고법원이 아닌 원심법원에 제출한 것이 적절한 절차인지 검토하고, 항고장에 항고이유가 기재되지 않았음에도 원심재판장이 보정명령이나 각하명령을 내리지 않은 경우 항고법원이 취해야 할 심리 방식과 조치에 대하여 논하시오.》

<문제16.2의 물음1> 소장각하명령에 대한 항고절차 및 항고법원의 조치

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 소장각하명령에 대한 항고장을 원심법원에 제출하였으나 항고이유를 기재하지 않았고, 원심재판장은 별도의 조치 없이 사건기록을 항고법원으로 송부한 상황이다. 쟁점으로 항고장을 원심법원에 제출한 절차의 적법 여부와 항고장에 항고이유가 기재되지 않았음에도 원심재판장이 보정명령이나 각하명령을 하지 않은 경우 항고법원이 어떠한 심리 방식과 조치를 취하여야 하는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 항고장의 제출 방식의 적법 여부와 항고법원의 심리 방식 및 조치를 논한다.

II. 항고장의 제출 법원 및 적법성 검토

1. 원칙적인 제출 법원

- 민사소송법 제443조에 의해 준용되는 제396조 등에 따르면, 항고는 항고장을 원심법원에 제출함으로써 한다. 이는 상소의 일종인 항소나 상고가 원심법원에 제출되어야 하는 것과 궤를 같이한다.

2. 사안의 경우

- 甲은 소장각하명령에 불복하여 항고장을 작성한 후, 항고법원이 아닌 명령을 내린 원심법원에 제출하였다. 이는 법령이 정한 적법한 절차에 따른 것이므로 제출 법원의 관점에서 甲의 항고는 적법하다.

III. 항고이유 기재 여부에 따른 법원의 조치

1. 항고이유 부기 의무의 성격

(1) 일반항고와 즉시항고의 구별

- 민사소송법상 일반적인 항고의 경우 항고장에 항고이유를 반드시 기재해야 하는 것은 아니며, 항고이유서를 제출하지 않았다고 하여 항고가 바로 부적법해지는 것은 아니다. 그러나 즉시항고의 경우 신속한 결정을 위해 항고이유를 적도록 권장된다.

(2) 소장각하명령에 대한 즉시항고

- 소장각하명령에 대한 불복은 즉시항고(제254조 제4항)에 해당한다. 다만, 항소와 달리 항고 절차에서는 항고이유서를 기간 내에 제출하지 않았다고 하여 항고를 각하한다는 명시적인 규정이 없으므로, 이유 기재가 없다는 사실만으로 곧바로 각하할 수는 없다.

2. 원심재판장의 조치

(1) 항고장 심사권

- 원심재판장은 항고장이 접수되면 형식적 요건을 심사한다. 항고기간의 도과나 인지의 미첩부 등 명백한 부적법 사유가 있다면 보정을 명하거나 각하해야 한다.

(2) 이유 미기재 시의 대응

- 항고이유가 기재되지 않은 것은 항고장의 필수적 기재사항 위반이 아니므로, 원심재판장이 이를 이유로 보정명령을 내리거나 각하할 수는 없다. 따라서 원심재판장이 사건 기록을 항고법원으로 보낸 조치는 적절하다.

3. 항고법원의 조치

(1) 심리 방식

- 항고법원은 기록을 송부받은 후 항고이유가 기재되어 있지 않다면, 항고인에게 항고의 구체적인 이유를 밝히도록 독려하거나 서면 제출을 명하는 심리 절차를 진행해야 한다.

(2) 항고이유의 소명 및 판단

- 항고인이 끝내 이유를 밝히지 않거나 제출된 이유가 이유 없다고 판단되면 항고기각 결정을 내린다. 반대로 원심의 소장각하명령이 부당하다는 점(예 : 이미 인지를 첩부했음에도 착오로 명령이 내려진 경우 등)이 밝혀지면 원심명령을 취소한다.

IV. 사안의 적용

1. 항고장 제출의 적법성

- 甲이 원심법원에 항고장을 제출한 것은 민사소송법 제443조 및 제396조의 취지에 부합하는 적법한 절차이다.

2. 법원의 후속 조치

- 원심재판장이 항고이유 미기재를 이유로 각하하지 않고 기록을 송부한 것은 타당하다. 항고법원은 甲에게 항고이유를 소명할 기회를 부여해야 하며, 甲이 소장각하명령의 원인이 된 인지 미첩부 사유를 해소했거나 명령의 부당함을 소명한다면 항고법원은 원심명령을 취소하고 사건을 다시 진행하도록 해야 한다.

V. 결론

- 甲의 항고장 제출은 적법한 법원에 이루어졌다. 항고이유의 기재는 항소와 달리 강제되는 요건이 아니므로, 항고법원은 즉시 각하할 것이 아니라 심리 절차를 통해 항고인에게 이유 소명 기회를 부여한 후 항고의 당부를 판단해야 한다.

<제6편 상소심절차.제16장 항고.제02절 항고의 절차>

[모의][16.02-2]즉시항고의 항고이유서 제출 기한의 성질과 효과 및 각하 가능성

《【문제16.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하였으나, 제1심 법원은 소장이 접수된 후 인지가 첩보되지 않았음을 이유로 재판장이 보정명령을 내렸음에도 甲이 응하지 않자 소장각하명령을 내렸다. 이에 불복하고자 하는 甲은 소장각하명령 정본을 송달받은 날로부터 1주일 이내에 "항고장"을 작성하여 항고법원이 아닌 원심법원에 제출하였다.

그런데 甲이 제출한 항고장에는 항고이유가 기재되어 있지 않았으며, 별도의 항고이유서도 기재 기한 내에 제출되지 않았다. 원심법원의 재판장은 항고장에 항고이유가 없음을 발견하였으나, 이를 즉시 각하하지 않고 사건 기록을 항고법원으로 보냈다. 항고법원은 기록을 송부받은 후 甲에게 항고이유를 소명할 것을 요구하는 심리 절차를 진행하고자 한다.

한편, 丙은 丁과의 소송비용액확정 절차에서 법원이 내린 결정에 불복하여 즉시항고를 제기하였다. 丙은 즉시항고장에 항고이유를 적지 않았으나, 항고장을 제출한 날로부터 10일 이내에 구체적인 항고이유를 담은 항고이유서를 원심법원에 제출하였다. 丁은 丙이 항소와 달리 항고이유서를 법정 기한 내에 제출하지 않았으므로 해당 항고가 부적법하다고 주장하고 있다.

(물음2) 즉시항고를 제기한 丙의 사례와 관련하여, 민사소송법 제445조에 규정된 "항고이유서 제출 기한"의 성질과 이를 준수하지 못했을 때의 효과를 항소이유서 제출 절차와 비교하여 설명하고, 丁의 주장대로 항고이유서 미제출을 이유로 곧바로 항고각하 결정을 내릴 수 있는지 여부를 기술하시오.》

<문제16.2의 물음2> 즉시항고의 항고이유서 제출 기한의 성질과 효과 및 각하 가능성

I. 문제의 제기

- 사안에서 丙은 소송비용액확정 결정에 대하여 즉시항고를 제기하면서 항고장에는 항고이유를 기재하지 않았으나 항고장을 제출한 후 10일 이내에 항고이유서를 제출하였고, 丁은 이를 이유로 항고가 부적법하다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 민사소송법 제445조상 항고이유서 제출기한의 성질과 그 기한을 준수하지 못한 경우의 효과를 항소이유서 제출 절차와 비교하여 항고이유서 미제출만을 이유로 곧바로 항고각하를 할 수 있는지를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 항고이유서 제출기한의 법적 성질과 미제출 시의 효과 및 항고각하 가능 여부를 기술한다.

II. 즉시항고와 항고이유서 제출

1. 즉시항고이유서 제출 기한 [민사소송법 제445조]

- 민사소송법 제445조는 즉시항고를 제기할 때 항고장에 이유를 적지 아니한 때에는 항고장을 제출한 날부터 10일 이내에 항고이유서를 제출하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 2002년 민사소송법 개정 당시 즉시항고 절차의 신속성을 도모하기 위해 신설된 규정이다.

2. 제출 기한의 성질

(1) 혼시적 규정 여부

- 항고이유서 제출 기한인 10일이 불변기간인지, 아니면 단순한 혼시규정인지가 문제 된다. 판례와 통설은 이 기한을 준수하지 않았다고 하여 곧바로 항고를 각하할 수 있는 강제적인 집행력을 가진 기간으로 보지 않는다.

(2) 항소절차와의 비교

- 항소의 경우, 항소장에 이유를 적지 않았더라도 항소기록송부 통지를 받은 날로부터 20일이라는 엄격한 항소이유서 제출 기한이 있고, 이를 어길 시 항소각하 판결을 하도록 규정되어 있다.(민사소송법 제427조, 제429조) 그러나 항고 절차에는 이와 유사한 각하 규정이 존재하지 않는다.

III. 항고이유서 미제출 시의 효과

1. 법적 근거의 부재

- 민사소송법은 항소나 상고의 경우 이유서 미제출 시의 각하 규정을 명시하고 있으나, 항고 절차에서는 민사소송법 제445조를 위반하여 10일 이내에 이유서를 제출하지 않은 경우에 대한 제재 규정을 두고 있지 않다. 따라서 조문의 문언상 기한 도과만으로 항고가 부적법해진다고 단정하기 어렵다.

2. 법원의 심리 의무

- 항고법원은 항고이유서가 기한 내에 제출되지 않았더라도, 항고장에 기재된 내용이나 기록에 나타난 자료를 바탕으로 원심재판의 당부를 심사하여야 한다. 만약 항고이유가 전혀 나타나지 않는다면 보정을 명하거나 심리 절차를 통해 이유를 소명할 기회를 주어야 한다.

IV. 사안의 적용

1. 丙의 항고이유서 제출의 효력

- 사안에서 丙은 즉시항고장을 제출한 날로부터 10일 이내에 항고이유서를 제출하였다. 이는 민사소송법 제445조에서 정한 기간을 준수한 것이며, 설령 이 기간을 도과하여 제출하였다 하더라도 앞서 살펴본 바와 같이 항고 자체가 부적법해지는 것은 아니다.

2. 丁의 주장에 대한 판단

- 丁은 항소이유서 제출 절차를 유추 적용하여 丙의 항고가 부적법하다고 주장한다. 그러나 항고 절차는 항소 절차와 달리 이유서 미제출에 따른 각하 규정이 없으며, 제445조의 기한은 절차의 신속을 위한 권고적 성격이 강하다. 따라서 丙이 이유서를 기한 내에 제출했는지 여부와 상관없이, 이유서가 제출된 이상 법원은 그 내용을 심리해야 하므로 丁의 주장은 타당하지 않다.

V. 결론

- 즉시항고에서 항고이유서 제출 기한(10일)은 항소이유서와 달리 그 미준수 시 각하를 강제하는 효력이 없다. 따라서 丙의 항고는 적법하며, 법원은 丁의 주장대로 항고이유서 제출 시점을 이유로 항고를 각하할 수 없다. 법원은 丙이 제출한 항고이유서를 바탕으로 소송비용액확정 결정의 정당성을 실질적으로 심리하여야 한다.

<제7편 재심절차.제17장 재심.제02절 재심의 소송물>

[모의][17.02-1]재심의 소송물 이론에 따른 재심사유의 관계 및 본안 심리 절차의 구조

《【문제17.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 승소 판결을 받았고, 이 판결은 2023. 5. 1. 확정되었다. 그런데 2024. 6. 1. 乙은 위 소송의 핵심 증거였던 매매계약서가 甲에 의해 위조되었다는 사실을 증명하는 형사판결이 확정되었음을 알게 되었다. 이에 乙은 2024. 6. 15. 민사소송법 제451조 제1항 제6호를 재심사유로 하여 재심의 소를 제기하였다.

乙은 재심청구취지에 "확정판결을 취소하고, 원고 甲의 청구를 기각한다"는 내용을 담았으며, 재심사유로 증거서류의 위조뿐만 아니라 "판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락하였다"는 점(동조 제1항 제9호)도 함께 주장하였다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 소송에서 패소 판결을 받고 재심을 제기하였으나, 재심법원은 심리 결과 재심사유가 인정되지 않는다는 이유로 재심기각 판결을 선고하였다. 丙은 이 재심기각 판결에 대해서도 다시 재심사유가 존재한다고 "재심판결에 대한 재심"을 제기하고자 한다.

(물음1) 재심의 소송물을 "재심사유(본안전 소송물)"와 "재심대상판결의 당부(본안 소송물)"로 구분하는 견해에 근거하여, 乙이 주장하는 두 가지 재심사유가 하나의 재심의 소에서 어떠한 관계를 갖는지 기술하고, 재심법원이 재심사유가 존재한다고 판단할 경우 본안 심리에 들어가는 절차적 구조에 대하여 설명하시오.》

<문제17.2의 물음1> 재심의 소송물 이론에 따른 재심사유의 관계 및 본안 심리 절차의 구조

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 확정판결에 대하여 증거서류의 위조와 판단누락을 함께 재심사유로 주장하여 하나의 재심의 소를 제기한 상황이다. 쟁점으로 재심의 소송물을 재심사유와 재심대상판결의 당부로 구분하는 견해에 비추어 두 재심사유의 관계와 재심법원이 재심사유의 존재를 인정한 후 본안 심리로 나아가는 절차적 구조를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 재심사유의 관계와 재심법원의 본안 심리 절차를 설명한다.

II. 재심의 소송물과 재심사유의 관계

1. 재심의 소송물 이론

(1) 재심사유(본안전 소송물)

- 재심의 소는 먼저 재심대상판결에 민사소송법 제451조 제1항 각 호에서 정한 재심사유가 존재하는지 여부를 심사한다. 이를 본안전 소송물이라 하며, 재심사유의 존부는 본안 심리를 개시하기 위한 요건이 된다.

(2) 재심대상판결의 당부(본안 소송물)

- 재심사유가 인정되면 법원은 원래의 소송 상태로 돌아가 청구의 당부를 다시 심판한다. 이를 본안 소송물이라 하며, 이는 재심대상판결이 되었던 원래 소송의 소송물과 동일하다.

2. 복수의 재심사유 사이의 관계

(1) 병합의 형태

- 하나의 재심의 소에서 여러 개의 재심사유를 주장하는 경우, 이는 소송법상 단순병합의 관계로 본다. 재심법원은 원고가 내세운 여러 사유 중 어느 하나라도 인정되면 재심개시결정을 하거나 본안 심리에 들어갈 수 있다.

(2) 심리의 범위

- 법원은 청구된 재심사유 전부에 대하여 심리할 의무가 있으나, 그중 하나의 사유만 정당하다고 인정되면 나머지 사유에 대하여 별도로 판단하지 않고도 본안 심리로 나아갈 수 있다. 다만, 재심 청구를 기각할 경우에는 주장된 모든 재심사유가 부정됨을 명시하여야 한다.

III. 재심 절차의 구조

1. 재심의 3단계 구조

(1) 제1단계 : 재심의 제소요건 심사

- 재심의 소가 적법한지(당사자 적격, 제척기간 준수 등)를 심사한다. 요건을 갖추지 못한 경우 소각하 판결을 내린다.

(2) 제2단계 : 재심사유의 유무 심사(재심소송절차)

- 주장된 재심사유가 실제로 존재하는지 심리한다. 재심사유가 없으면 재심청구기각 판결을 선고하며, 사안의 丙과 같이 이 판결에 대해서도 다시 재심을 제기할 수 있다.

(3) 제3단계 : 본안사건의 심리(본안소송절차)

- 재심사유가 존재한다고 판단되면, 취소되는 재심대상판결에 의하여 종료되었던 원래의 소송절차를 부활시켜 사건의 본안을 다시 심판한다.

2. 본안 심리로의 이행 방식

(1) 중간판결 또는 재심개시결정

- 현행법상 법원은 재심사유가 인정되는 경우 별도의 중간판결을 거치지 않고 바로 본안 심리를 병행하여 진행한 후 하나의 종국판결로 선고하는 것이 일반적이다. 다만, 재심사유 유무에 관한 판단을 명확히 하기 위해 중간판결 형식을 취할 수도 있다.

(2) 판결의 통합성

- 본안 심리 결과 재심대상판결이 부당하다고 판단되면 이를 취소하고 새로운 판결을 선고한다. 만약 재심사유는 인정되나 본안 심리 결과 재심대상판결의 결론이 정당하다면 재심청구기각 판결을 내리게 된다.

IV. 사안의 적용

1. 乙이 주장하는 재심사유의 관계

- 乙은 제6호와 제9호의 사유를 함께 주장하고 있으므로 이는 단순병합된 상태이다. 법원은 형사판결 확정으로 증명된 제6호(증거 위조) 사유만으로도 충분히 재심사유의 존재를 인정할 수 있으며, 이 경우 제9호 사유에 대한 판단을 생략하더라도 재심개시에는 지장이 없다.

2. 본안 심리 절차의 구조

- 재심법원은 乙의 소가 제척기간(재심사유를 안 날로부터 30일) 내에 제기되어 적법함을 확인한 후, 증거 위조라는 재심사유를 확정한다. 이후 법원은 소유권이전등기청구라는 원래의 본안 소송물로 돌아가, 위조된 매매계약서를 배제한 상태에서 甲의 청구가 정당하지 다시 심리하여야 한다. 乙이 청구취지에 담은 원고 甲의 청구 기각 여부는 이 본안 심리 단계에서 최종 결정된다.

V. 결론

- 재심의 소송물 이론에 의할 때 乙의 두 재심사유는 단순병합 관계에 있으며, 법원은 그중 하나라도 인정되면 본안 심리를 개시한다. 절차적으로는 재심사유 존부 심사 후 본안 심리로 이행하며, 최종적으로 재심대상판결의 취소 여부와 원래 청구의 당부를 하나의 종국판결로 확정하게 된다.

<제7편 재심절차.제17장 재심.제02절 재심의 소송물>

[모의][17.02-2]재심제기기간의 기산점 판단 및 재심판결에 대한 재심의 소송물 확정

《【문제17.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 승소 판결을 받았고, 이 판결은 2023. 5. 1. 확정되었다. 그런데 2024. 6. 1. 乙은 위 소송의 핵심 증거였던 매매계약서가 甲에 의해 위조되었다는 사실을 증명하는 형사판결이 확정되었음을 알게 되었다. 이에 乙은 2024. 6. 15. 민사소송법 제451조 제1항 제6호를 재심사유로 하여 재심의 소를 제기하였다.

乙은 재심청구취지에 "확정판결을 취소하고, 원고 甲의 청구를 기각한다"는 내용을 담았으며, 재심사유로 증거서류의 위조뿐만 아니라 "판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락하였다"는 점(동조 제1항 제9호)도 함께 주장하였다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 소송에서 패소 판결을 받고 재심을 제기하였으나, 재심법원은 심리 결과 재심사유가 인정되지 않는다는 이유로 재심기각 판결을 선고하였다. 丙은 이 재심기각 판결에 대해서도 다시 재심사유가 존재한다며 "재심판결에 대한 재심"을 제기하고자 한다.

(물음2) 재심의 소는 재심사유를 안 날로부터 30일 이내에 제기하여야 하는바, 乙이 주장하는 "증거서류의 위조"와 "판단누락" 각각에 대한 재심제기 기간의 기산점이 동일한지 여부를 판단하시오. 또한 丙의 사례와 같이 재심기각 판결에 대하여 다시 재심을 제기하는 경우의 소송물 확정 문제를 재심의 소송물 이론과 관련하여 논하시오.》

<문제17.2의 물음2> 재심제기기간의 기산점 판단 및 재심판결에 대한 재심의 소송물 확정 문제

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 증거서류의 위조와 판단누락을 재심사유로 주장하여 재심의 소를 제기하고, 丙은 재심기각 판결에 대하여 다시 재심을 제기하려는 상황이다. 쟁점으로 증거서류의 위조와 판단누락에 관한 재심제기기간의 기산점이 동일한지와 재심기각 판결에 대한 재심이 허용되는 경우 소송물을 어떻게 확정할 것인지(1)를 재심의 소송물 이론과 관련하여 검토할 필요가 있다. 이하에서는 재심사유별 재심제기기간의 기산점과 재심기각 판결에 대한 재심의 소송물 확정 문제를 논한다.

II. 재심제기기간의 기산점

1. 재심제기기간의 원칙

- 민사소송법 제456조 제1항에 의하면 재심의 소는 당사자가 판결이 확정된 후 재심의 사유를 안 날로부터 30일 이내에 제기하여야 한다. 이때 안 날이란 단순히 재심사유에 해당하는 사실을 안 것만으로는 부족하고, 그것이 법률상 재심사유에 해당한다는 것까지 구체적으로 안 날을 의미한다.

2. 각 사유별 기산점의 개별적 판단

(1) 제451조 제1항 제6호(증거 위조)

- 증거가 되는 서류의 위조를 이유로 재심을 제기하는 경우에는 동조 제2항에 따라 유죄의 판결이 확정된 때 또는 증거부족 외의 이유로 유죄의 확정판결을 얻을 수 없는 때에 한하여 재심을 제기할 수 있다. 따라서 이 사유의 기산점은 유죄판결이 확정되었다는 사실을 안 날이 된다. 乙의 경우 2024. 6. 1.에 형사판결 확정 사실을 알았으므로 이때가 기산점이 된다.

(2) 제451조 제1항 제9호(판단 누락)

- 판단 누락은 판결문 자체에 나타나는 하자이다. 판례에 의하면 판단 누락과 같이 판결문 자체에 의하여 재심사유의 존부를 알 수 있는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 판결 정본이 송달된 날에 그 사유를 알았다고 보아야 한다. 乙의 경우 원판결 확정일인 2023. 5. 1. 이전에 이미 판결 정본을 송달받았을 것이므로, 제9호 사유의 기산점은 제6호 사유의 기산점보다 훨씬 앞서게 된다.

III. 재심판결에 대한 재심과 소송물

1. 재심의 소송물 이론

- 재심의 소송물은 재심대상판결의 당부(본안 소송물)와 재심사유의 유무(본안전 소송물)로 구성된다. 재심법원은 먼저 재심사유의 존부를 심사하고, 사유가 인정될 때에만 본안 심리로 나아가는 단계적 구조를 취한다.

2. 재심기각판결에 대한 재심의 소송물 확정

(1) 재심기각판결의 성격

- 재심사유가 인정되지 않아 내려진 재심기각판결도 하나의 확정된 종국판결이므로, 이 판결 자체에 재심사유가 있다면 다시 재심을 제기할 수 있다.

(2) 소송물의 범위

- 재심기각판결에 대한 재심에서 본안전 소송물은 재심기각판결 자체에 존재하는 재심사유이다. 만약 이 재심의 소에서 사유가 인정되어 재심기각판결이 취소된다면, 절차는 다시 전 단계의 재심절차로 복귀하게 된다. 즉, 丙이 제기하는 재심의 소송물은 재심기각판결이 정당한가의 여부이며, 이는 원칙적으로 원판결(丁과의 소송)의 당부와는 직접적인 관련이 없는 독립된 소송물로 취급된다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 재심제기기간 준수 여부

(1) 제6호 사유에 대한 판단

- 乙은 2024. 6. 1. 형사판결 확정 사실을 알았고, 그로부터 14일 뒤인 2024. 6. 15. 재심을 제기하였으므로 30일의 불변기간을 준수하였다.

(2) 제9호 사유에 대한 판단

- 제9호(판단 누락) 사유는 판결 송달 시에 알았다고 보아야 하므로, 2024. 6. 15. 시점에서는 이미 30일의 제척기간이 도과했을 가능성이 매우 높다. 따라서 乙이 주장하는 두 사유의 기산점은 동일하지 않으며, 제9호 사유는 기간 도과로 인해 부적법 각하될 가능성이 크다.

2. 丙의 재심 소송물 확정

- 丙이 제기하는 재심판결에 대한 재심의 소송물은 丁과의 원소송에 관한 것이 아니라, 재심기각판결 자체의 하자 여부이다. 재심법원은 재심기각판결 심리 과정에서 판사가 뇌물을 받았거나(제1호) 판단을 누락하는 등(제9호) 그 판결 자체에 결함이 있는지를 심리하게 된다.

V. 결론

- 乙이 주장하는 두 사유의 기산점은 동일하지 않다. 제6호 사유는 형사판결 확정 사실을 안 날부터 기산되나, 제9호 사유는 판결 송달 시부터 기산되므로 乙의 제9호 주장은 기간 도과로 부적법하다. 또한 丙의 사례에서 재심판결에 대한 재심의 소송물은 원판결의 당부가 아닌 재심판결 자체의 재심사유 유무 및 당부로 한정된다.

<제7편 재심절차.제17장 재심.제03절 적법요건>

[모의][17.03-1]재심사유의 보충성 원칙 위배 여부 및 재심대상의 확정 원칙

《【문제17.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제1심에서 승소하였다. 乙은 이에 불복하여 항소하였으나 항소심에서도 패소하였고, 상고를 제기하였으나 대법원에서 상고기각 판결이 선고되어 2023. 8. 1. 판결이 최종 확정되었다. 이후 2024. 9. 1. 乙은 항소심 당시 자신의 소송대리인이었던 A가 상대방 甲과 공모하여 乙에게 불리한 진술을 하는 등 대리권의 흠결이 있었음을 알게 되었다.

乙은 2024. 9. 20. 항소심 판결에 대하여 재심의 소를 제기하고자 한다. 그런데 확인 결과 乙은 항소심 재판 과정에서 이미 A의 대리권 행사에 문제가 있음을 인지하고 항소이유서 등에 이를 언급하며 다툰 사실이 있었다. 또한 乙은 항소심 판결뿐만 아니라 대법원의 상고기각 판결에 대해서도 재심사유가 존재한다고 하며 동시에 재심을 제기하려 한다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 소송에서 "화해권고결정"을 받아 확정되었으나, 이후 그 결정의 기초가 된 증거가 위조되었음을 발견하였다. 丙은 일반적인 판결에 대한 재심 절차에 따라 화해권고결정에 대한 재심의 소를 제기할 수 있는지 여부를 고민하고 있다.

(물음1) 乙이 주장하는 재심사유인 "대리권의 흠결"이 민사소송법 제451조 제1항 단서의 보충성 원칙에 위배되는지 여부를 乙이 항소심에서 이를 주장하였던 사정과 관련하여 논하고, 항소심 판결과 상고기각 판결이 모두 존재하는 경우 재심 대상의 확정(재심의 소의 대상)에 관한 원칙을 설명하시오.》

<문제17.3의 물음1> 재심사유의 보충성 원칙 위배 여부 및 재심대상의 확정 원칙

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 항소심에서 이미 소송대리인의 대리권 흠결을 주장하였음에도 이를 재심사유로 항소심 판결에 대한 재심을 제기하고, 상고기각 판결에 대해서도 함께 재심을 구하려는 상황이다. 쟁점으로 대리권의 흠결이 민사소송법 제451조 제1항 단서의 보충성 원칙에 위배되는지와 항소심 판결 및 상고기각 판결이 모두 존재하는 경우 재심의 소의 대상을 어느 판결로 확정할 것인지가 검토할 필요가 있다. 이하에서는 재심사유의 보충성 원칙 위반 여부와 재심의 소의 대상이 되는 판결을 설명한다.

II. 재심사유의 보충성 원칙

1. 보충성 원칙의 의미

- 재심의 소는 상소에 의하여 구제받을 수 없었던 경우에 한하여 허용되는 최후의 수단이다. 따라서 민사소송법 제451조 제1항 단서에 의하여 당사자가 상소에 의하여 재심사유를 주장하였거나, 상소 제기 당시에 그 사유를 알고 있었음에도 불구하고 이를 주장하지 않은 경우에는 재심의 소를 제기할 수 없다.

2. 대리권 흠결과 보충성 원칙

(1) 원칙적 적용

- 재심사유 중 법정대리권·소송대리권의 흠결은 민사소송법 제451조 제1항 제3호에 해당한다. 만약 당사자가 판결 확정 전의 소송절차에서 대리권의 흠결을 알고 있었고 이를 충분히 주장할 수 있었음에도 불구하고 주장하지 않았다면, 판결 확정 후 이를 이유로 재심을 제기하는 것은 보충성 원칙에 반하여 허용되지 않는다.

(2) 사안의 특수성

- 사안에서 乙은 항소심 재판 과정에서 이미 A의 대리권 행사에 문제가 있음을 인지하였고, 항소이유서 등을 통해 이를 언급하며 다툰 사실이 있다. 이는 당사자가 상소 절차에서 해당 사유를 이미 주장한 경우에 해당하므로, 법문의 취지상 동일한 사유를 내세워 다시 재심을 제기하는 것은 보충성 원칙에 위배될 소지가 크다.

III. 재심대상의 확정(재심의 소의 대상)

1. 기본 원칙

- 재심은 원칙적으로 확정된 중국판결을 대상으로 한다. 그러나 하나의 사건에 대하여 제1심, 항소심, 상고심 판결이 순차적으로 내려져 모두 확정된 경우, 어느 판결을 재심대상으로 삼을 것인가가 문제된다.

2. 심급에 따른 대상 확정

(1) 항소심 판결과 상고심 판결의 관계

- 본안에 대하여 항소심 판결이 있고 이에 대한 상고가 기각되어 상고심 판결이 확정된 경우, 재심의 대상은 원칙적으로 본안판결인 항소심 판결이 된다. 상고심의 상고기각 판결은 하급심 판결의 당부를 심사하여 이를 유지하는 것이므로, 실질적인 판단의 기초가 된 항소심 판결에 재심사유가 있다면 항소심 판결을 대상으로 재심을 제기해야 한다.

(2) 상고심 판결 자체가 대상이 되는 경우

- 만약 재심사유가 항소심 판결에는 없고 오직 상고심의 소송절차나 상고심 판결 자체에만 존재하는 경우(예 : 상고심에서의 판단누락 등)에는 예외적으로 상고심 판결을 대상으로 재심을 제기할 수 있다.

(3) 흡수설과 독립설의 태도

- 판례는 원칙적으로 하급심 판결이 상급심 판결에 의하여 확정된 경우, 하급심 판결에 재심사유가 있다면 하급심 판결을 대상으로 재심을 제기해야 한다는 입장이다. 다만, 상고심에서 본안판결을 한 경우(상고기각이 아닌 파기자판 등)에는 상고심 판결이 대상이 된다. 사안과 같이 상고기각 판결로 항소심 판결이 확정된 경우에는 항소심 판결이 재심의 대상이 되는 것이 원칙이다.

IV. 사안의 적용

1. 보충성 원칙 위배 여부

- 사안의 乙은 항소심 과정에서 소송대리인 A의 대리권 흠결 문제를 인지하였고 이를 항소이유서에서 주장하며 다투었다. 이는 민사소송법 제451조 제1항 단서의 상소에 의하여 그 사유를 주장한 때에 해당한다. 재심은 상소로 구제받지 못한 경우에 한하여 보충적으로 허용되는 것이므로, 이미 항소심에서 심리되었거나 주장되었던 사유를 다시 재심사유로 삼는 것은 보충성 원칙에 위배되어 부적법하다.

2. 재심대상의 확정

- 乙은 항소심 판결과 상고기각 판결에 대하여 동시에 재심을 제기하려 한다. 대리권의 흠결이라는 사유가 항소심 변론 과정에서의 행위에 기인한 것이라면, 재심의 대상은 실질적인 심리가 이루어진 항소심 판결이 되어야 한다. 상고심 판결은 법률심으로서 항소심 판결을 확정시킨 것에 불과하므로, 항소심 절차상의 하자를 이유로 상고심 판결에 대해 재심을 제기하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 따라서 乙은 항소심 판결을 대상으로 재심을 제기하여야 하며, 상고기각 판결에 대한 재심은 특별한 사유(상고심 자체의 하자)가 없는 한 대상적격이 인정되기 어렵다.

V. 결론

- 사안의 乙이 주장하는 대리권 흠결 사유는 이미 항소심에서 주장된 바 있으므로 보충성 원칙에 위배되어 재심사유로 삼을 수 없다. 또한 재심대상 확정에서 있어서는 실질적 판단의 기초가 된 항소심 판결이 대상이 되어야 하며, 상고기각 판결은 원칙적으로 재심의 대상이 될 수 없다.

<제7편 재심절차.제17장 재심.제03절 적법요건>

[모의][17.03-2]재심제기기간의 적법성 판단 및 준재심의 요건과 절차

《【문제17.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제1심에서 승소하였다. 乙은 이에 불복하여 항소하였으나 항소심에서도 패소하였고, 상고를 제기하였으나 대법원에서 상고기각 판결이 선고되어 2023. 8. 1. 판결이 최종 확정되었다. 이후 2024. 9. 1. 乙은 항소심 당시 자신의 소송대리인이었던 A가 상대방 甲과 공모하여 乙에게 불리한 진술을 하는 등 대리권의 흠결이 있었음을 알게 되었다.

乙은 2024. 9. 20. 항소심 판결에 대하여 재심의 소를 제기하고자 한다. 그런데 확인 결과 乙은 항소심 재판 과정에서 이미 A의 대리권 행사에 문제가 있음을 인지하고 항소이유서 등에 이를 언급하며 다툰 사실이 있었다. 또한 乙은 항소심 판결뿐만 아니라 대법원의 상고기각 판결에 대해서도 재심사유가 존재한다며 동시에 재심을 제기하려 한다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 소송에서 "화해권고결정"을 받아 확정되었으나, 이후 그 결정의 기초가 된 증거가 위조되었음을 발견하였다. 丙은 일반적인 판결에 대한 재심 절차에 따라 화해권고결정에 대한 재심의 소를 제기할 수 있는지 여부를 고민하고 있다.

(물음2) 재심제기기간의 준수 여부와 관련하여, 乙이 재심사유를 "안 날"로부터 30일 이내에 소를 제기하였으나 판결 확정 후 1년이 경과한 경우 재심의 적법성을 판단하시오. 또한 丙의 사례와 같이 화해권고결정이나 확정된 지급명령 등 판결이 아닌 준재심 대상에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있는지 그 요건과 절차를 기술하시오.》

<문제17.3의 물음2> 재심제기기간의 적법성 판단 및 준재심의 요건과 절차

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 재심사유를 안 날부터 30일 이내이지만 판결 확정 후 1년이 지난 시점에 재심의 소를 제기하려 하고, 丙은 화해권고결정 등 준재심 대상에 대하여 불복을 구하려는 상황이다. 쟁점으로 재심제기기간의 준수 여부와 재심사유를 안 날부터의 기간 및 판결 확정 후 제척기간의 관계, 그리고 화해권고결정이나 확정된 지급명령 등에 대한 준재심의 허용 요건과 절차를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 재심제기기간의 적법 여부와 준재심의 요건 및 절차를 기술한다.

II. 재심제기기간의 준수 여부

1. 재심제기기간의 이중적 제한

(1) 주관적 제척기간

- 당사자가 판결이 확정된 후 재심의 사유를 안 날로부터 30일 이내에 제기하여야 한다.(민사소송법 제456조 제1항) 이는 당사자의 인지 시점을 기준으로 하는 주관적 기간이다.

(2) 객관적 제척기간

- 판결이 확정된 날로부터 5년을 경과한 때에는 재심의 소를 제기하지 못한다.(민사소송법 제456조 제3항) 이는 판결 확정이라는 객관적 사실을 기준으로 하는 기간이다.

2. 대리권 흠결에 대한 특칙

(1) 기간 제한의 배제

- 민사소송법 제456조 제4항에 의하면, 제451조 제1항 제3호(대리권의 흠결)를 사유로 하는 재심의 소에는 위 30일 및 5년의 기간 제한 규정을 적용하지 아니한다. 이는 대리권의 흠결이 소송의 근본적인 절차적 정의를 침해하는 중대한 하자로 보기 때문이다.

(2) 사안의 판단

- 乙이 주장하는 재심사유는 소송대리인 A의 대리권 흠결(제451조 제1항 제3호)에 해당한다. 따라서 乙은 판결 확정 후 1년이 경과하였더라도 기간의 제한 없이 재심을 제기할 수 있다. 설령 乙이 재심사유를 안 날로부터 30일이 경과했더라도 대리권 흠결의 경우에는 기간 제한이 적용되지 않으므로 소 제기는 적법하다.

III. 준재심의 요건과 절차

1. 준재심의 의의

- 준재심이란 확정판결은 아니지만 판결과 동일한 효력을 가지는 조서(화해조서, 인낙조서)나 결정(화해권고결정, 확정된 지급명령 등)에 재심사유가 있는 경우, 재심 절차에 준하여 취소나 변경을 구하는 절차를 말한다.(민사소송법 제461조)

2. 준재심의 요건

(1) 대상적격

- 화해권고결정, 확정된 지급명령, 화해조서, 조정조서 등과 같이 확정판결과 동일한 효력을 가지는 것이어야 한다. 사안의 丙이 받은 화해권고결정은 이의 신청 없이 확정된 경우 확정판결과 동일한 효력을 가지므로 준재심의 대상이 된다.

(2) 재심사유의 존재

- 민사소송법 제451조 제1항 각 호에서 규정하는 재심사유가 존재해야 한다. 丙의 사례에서 결정의 기초가 된 증거가 위조된 경우(제451조 제1항 제6호)는 전형적인 재심사유에 해당한다.

3. 준재심의 절차

(1) 관할 및 방식

- 준재심의 소는 해당 조서나 결정이 성립한 법원의 관할에 속한다. 소송 절차는 일반적인 재심의 소의 규정을 준용하며, 소장 형식으로 제출하여야 한다.

(2) 불복 기간

- 일반 재심과 마찬가지로 사유를 안 날로부터 30일, 확정된 날로부터 5년 이내에 제기하여야 한다. 단, 대리권 흠결을 사유로 하는 경우에는 기간 제한이 없다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 재심제기 적법성

- 乙은 2023. 8. 1. 판결이 확정된 후 1년이 지난 시점인 2024. 9. 20.에 소를 제기하였다. 일반적인 재심사유라면 안 날로부터 30일은 준수했으나 확정 후 기간에 대한 검토가 필요할 수 있으나, 乙의 사유는 대리권 흠결이다. 민사소송법 제456조 제4항에 따라 대리권 흠결에 의한 재심은 제기기간의 제한을 받지 않으므로, 乙의 재심의 소 제기는 기간 측면에서 적법하다.

2. 丙의 준재심 제기 가능성

- 丙은 화해권고결정에 대해 재심의 소를 제기할 수 있는지 고민하고 있다. 화해권고결정은 확정판결과 동일한 효력을 가지므로 [민사소송법 제461조](#)에 따른 준재심의 대상이 된다. 丙은 증거위조라는 재심사유를 발견하였으므로, 해당 사유를 안 날로부터 30일 이내에 화해권고결정을 내린 법원에 준재심의 소를 제기함으로써 구제받을 수 있다.

V. 결론

- 乙의 재심의 소는 대리권 흠결을 사유로 하므로 기간 제한의 적용을 받지 않아 적법하다. 丙은 화해권고결정에 대하여 [민사소송법 제461조](#)의 준재심 절차에 따라 증거위조를 사유로 한 불복이 가능하며, 이는 일반 재심의 규정과 절차를 준용하여 처리된다.

<제7편 재심절차.제17장 재심.제03절 적법요건>

[모의][17.03-3]제3자 재심청구의 의의 및 제도적 취지, 적법요건, 제소기간, 절차 및 결과 처리

《【문제17.3-3】 제3자 재심청구에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제17.3-3> 제3자 재심청구의 의의 및 제도적 취지, 적법요건, 제소기간, 절차 및 결과 처리

I. 제3자 재심청구의 의의 및 제도적 취지

1. 제3자 재심청구의 의의

- 제3자 재심청구란 확정된 취소판결로 인해 권리 또는 이익을 침해받은 제3자가 자신에게 책임 없는 사유로 소송에 참가하지 못해 판결에 영향을 미칠 공방방법을 제출하지 못한 때, 확정판결에 대해 재심을 청구하여 구제받는 제도이다.(행정소송법 제31조 제1항)

2. 제3자 재심청구의 제도적 취지

- 취소판결은 제3자에게도 효력이 미치므로(행정소송법 제29조 제1항), 소송에 참여하지 못한 제3자가 불측의 피해를 볼 수 있다. 이에 제3자에게 최종적인 불복 기회를 제공하여 법적 안정성과 구체적 정의를 조화시키고자 한다.

II. 재심청구의 적법 요건

1. 주관적 요건 (재심청구인적격)

(1) 권리 또는 이익의 침해를 받은 제3자일 것

- 재심을 청구하려면 확정판결로 권리나 법률상 이익을 침해받은 제3자여야 하며, 단순한 사실상·경제상 이해관계인은 제외된다. 판결의 대세효뿐 아니라 기속력에 따른 후속 처분으로 침해받는 자도 포함되나, 행정청은 이에 해당하지 않는다.

(2) 소송절차에 참가하지 못한 데 책임이 없을 것

- 제3자에게 책임 없는 사유로 소송절차에 참가하지 못하였어야 한다. 소송 계속 사실을 알지 못했거나, 알았더라도 참가가 불가능했던 객관적 사정이 인정되어야 하며, 고의나 중과실로 참가를 해태한 경우에는 적격이 부정된다.

2. 객관적 요건 (대상 및 재심사유와 제소기간)

(1) 대상적격 및 판결의 영향

- 재심청구의 대상은 처분등을 취소하는 확정된 종국판결이다. 또한 제3자가 소송에 참가하여 판결의 결과에 영향을 미칠 만한 공격 또는 방어방법을 제출하지 못하였음이 인정되어야 한다.

(2) 제3자 재심청구의 기간

- 판결이 확정되었음을 안 날부터 30일 이내, 판결이 확정된 날부터 1년 이내에 제기하여야 한다.(행정소송법 제31조 제2항) 이는 불변기간이므로 기간 도과 시 부적법 각하된다.

III. 재심청구의 절차 및 심리 결과의 처리

1. 소송 절차

(1) 전속관할과 소의 제기

- 재심청구는 원판결을 내린 법원의 전속관할에 속하며, 서면으로 신청하여야 한다. 청구서에는 당사자, 대리인, 대상 판결, 청구 취지 및 재심 사유를 명시하여 제출하여야 한다.

(2) 집행정지의 병합 신청

- 재심의 소 제기만으로는 판결의 집행을 정지되지 않으므로, 권리구제의 실효성을 확보하기 위해 필요한 경우 원판결의 효력이나 집행을 정지해 달라는 집행정지 신청을 병합하여 제기할 수 있다.

2. 법원의 심리 결과 처리

(1) 청구가 부적법한 경우 (재심각하)

- 소송요건을 결여하였거나 제소기간을 경과하여 부적법한 제3자 재심청구에 대해서는 법원이 본안 심리를 하지 않고 각하결정 또는 각하판결을 내린다.

(2) 본안 심리 결과에 따른 처리 (재심기각 및 청구인용)

① 재심기각의 판단

- 재심청구가 적법하나 심리 결과 제3자의 주장이 이유 없거나 기존 판결의 결과를 바꿀 영향이 없다면 기각 판결을 내린다.

② 재심인용의 판단

- 제3자의 공방방법이 타당하여 기존 판결을 유지할 수 없다고 인정되면 기존 판결을 취소·변경하고 새로운 판단을 내린다.

IV. 결론

- 제3자 재심청구는 행정소송의 대세효와 국민의 재판청구권 보장을 조화롭게 실현하는 소송법상 구제 수단이다. 비록 법적 안정성 수호를 위해 적법 요건과 불변기간을 엄격히 규정하고 있으나, 절차적 흠결로 침해당한 국민의 구체적 권리 구제를 실질적으로 보장하는 최종적인 법적 안전망으로 기능한다.

<제7편 재심절차.제17장 재심.제04절 재심절차>

[모의][17.04-1]재심절차의 본안심리에서 새로운 공격방어방법 제출 가능성 및 심판 범위

《【문제17.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 승소 판결을 받았고, 이 판결은 확정되었다. 이후 乙은 판결의 기초가 된 서류가 위조되었음을 이유로 재심의 소를 제기하였다. 재심법원은 심리 결과 乙이 주장하는 재심사유가 인정된다고 판단하여 본안 심리에 착수하였다.

본안 심리 과정에서 乙은 전소(원래의 소송)에서 주장하지 않았던 새로운 방어방법으로 "취득시효 완성"을 주장하였다. 이에 대해 甲은 재심절차는 확정된 판결의 부당함을 시정하는 비상구제수단이므로 전소의 변론종결 전까지 제출했어야 할 공격방어방법을 새로이 제출하는 것은 허용되지 않는다고 맞서고 있다. 한편, 丙은 丁을 상대로 한 판결이 확정된 후 재심을 제기하여 "재심대상판결을 취소하고 원고 丁의 청구를 기각한다"는 내용의 재심판결을 받아냈다. 그런데 재심판결이 확정되기 전, 丁은 재심대상판결(전소 판결)에 기하여 이미 丙의 재산을 강제집행하여 대금을 회수해 간 상태였다. 丙은 재심판결을 근거로 丁에게 기집행된 대금의 반환을 구하고자 한다.

(물음1) 재심법원이 재심사유가 있다고 인정하여 본안 심리를 진행할 때, 당사자가 전소의 변론종결 전의 사유를 새로운 공격방어방법으로 제출할 수 있는지 여부를 재심절차의 성격(소송의 부활)과 관련하여 논하고, 재심법원의 심판 범위가 재심사유로 주장된 범위에 한정되는지 여부를 기술하시오.》

<문제17.4의 물음1> 재심절차의 본안심리에서 새로운 공격방어방법 제출 가능성 및 심판 범위

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 재심사유가 인정되어 본안 심리가 진행되는 재심절차에서 전소의 변론종결 전에 존재하였으나 주장하지 않았던 취득시효 완성을 새로운 방어방법으로 제출한 상황이다. 쟁점으로 재심절차의 소송부활적 성격에 비추어 전소의 변론종결 전 사유를 새로운 공격방어방법으로 제출할 수 있는지와 재심법원의 심판 범위가 재심사유로 주장된 범위에 한정되는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 재심절차에서 새로운 공격방어방법의 제출 가능 여부와 재심법원의 심판 범위를 기술한다.

II. 재심절차의 본안심리와 공격방어방법의 제출

1. 재심절차의 이단계 구조

- 재심절차는 재심청구가 적법하고 재심사유가 존재하는지를 심사하는 재심소송절차(준비절차)와, 재심사유가 인정될 경우 사건의 본안을 다시 심판하는 본안심판절차로 나뉜다. 법원이 재심사유가 있다고 인정하여 본안 심리에 착수하면, 전소의 판결은 효력을 잃고 사건은 판결 전의 상태로 돌아가게 된다.

2. 소송의 부활과 새로운 공격방어방법

(1) 소송의 부활(Litigatio Reviviscit)의 원칙

- 재심사유가 인정되어 본안 심리에 들어가면 종전의 소송절차가 다시 부활한다. 이 단계에서 재심법원은 전소의 상급심으로서가 아니라, 재심대상판결을 한 법원의 지위에서 사건을 다시 심리한다.

(2) 새로운 공격방어방법의 제출 가능성

- 재심본안절차는 종전 소송절차의 연장이므로, 당사자는 전소의 변론종결 전의 사유는 물론 변론종결 후에 발생한 사유도 새로운 공격방어방법으로 제출할 수 있다. 이는 재심절차가 단순히 재심사유의 존부만을 다루는 것이 아니라, 사건의 적절한 해결을 목적으로 하는 본안 재판이기 때문이다.

(3) 학설 및 판례의 태도

- 통설과 판례는 재심사유가 인정되어 본안 심리를 하는 경우, 당사자는 전소에서 제출하지 않았던 새로운 공격방어방법을 자유롭게 제출할 수 있다고 본다. 다만, 재심절차가 상고심인 경우에는 상고심의 특성상 새로운 사실이나 증거를 제출할 수 없다는 제약이 따를 뿐이다.

III. 재심법원의 심판 범위

1. 불이익변경금지의 원칙 준용

- 재심절차에서도 불이익변경금지의 원칙이 적용된다. 즉, 재심법원은 재심원고가 신청한 불복의 범위 내에서만 재심대상판결을 취소하거나 변경할 수 있다.

2. 재심사유와 본안 심리의 관계

(1) 심판 범위의 한정 여부

- 재심법원이 본안을 심리할 때, 그 심판의 범위가 당사자가 주장한 재심사유와 관련된 부분에만 한정되는지가 문제된다. 법리는 재심사유의 존부 판단은 본안 심리에 들어가기 위한 전제조건일 뿐이며, 일단 본안 심리에 들어간 이상 재심사유와 무관한 본안의 모든 쟁점이 심판 대상이 된다고 본다.

(2) 변론주의의 적용

- 재심본안심리에서도 일반 소송절차와 마찬가지로 변론주의가 적용되므로, 당사자가 주장하지 않은 사실을 법원이 임의로 심판할 수는 없으나, 당사자가 적법하게 제출한 공격방어방법이라면 재심사유와 관련이 없더라도 법원은 이를 심리하여 판결의 기초로 삼아야 한다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 새로운 방어방법 제출에 대한 판단

- 사안에서 乙은 재심본안심리 과정에서 취득시효 완성이라는 새로운 방어방법을 제출하였다. 재심사유(서류 위조)가 인정되어 본안 심리가 개시되었다면, 소송은 부활하여 종전 절차의 연장선상에 있게 된다. 따라서 乙은 전소에서 주장하지 않았던 사유라 할지라도 본안의 승패를 가를 수 있는 방어방법을 새로이 제출할 수 있다. 甲의 주장은 재심절차의 소송 부활적 성격을 오해한 것으로 타당하지 않다.

2. 재심법원의 심판 범위 적용

- 재심법원은 乙이 주장한 재심사유인 서류 위조 여부에 대해서만 심리하는 것이 아니라, 乙이 새로 제출한 취득시효 완성 여부에 대해서도 심리해야 한다. 본안 심리에 착수한 이상 법원의 심판 범위는 재심사유로 주장된 범위에 한정되지 않으며, 부활한 소송 전체에 대해 다시 심리하여 결론을 내려야 하기 때문이다.

V. 결론

- 재심사유가 인정되어 본안 심리에 착수한 경우 소송은 부활하므로, 당사자인 乙은 전소의 변론종결 전의 사유인 취득시효 완성을 새로운 방어방법으로 제출할 수 있다. 또한 재심법원의 심판 범위는 당사자가 주장한 재심사유의 범위에 국한되지 않고 본안 전체에 미치므로, 법원은 乙의 새로운 주장을 심리하여 판결에 반영하여야 한다.

<제7편 재심절차.제17장 재심.제04절 재심절차>

[모의][17.04-2]재심대상판결의 취소에 따른 강제집행 결과의 원상회복청구 방법 및 요건

《【문제17.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 승소 판결을 받았고, 이 판결은 확정되었다. 이후 乙은 판결의 기초가 된 서류가 위조되었음을 이유로 재심의 소를 제기하였다. 재심법원은 심리 결과 乙이 주장하는 재심사유가 인정된다고 판단하여 본안 심리에 착수하였다.

본안 심리 과정에서 乙은 전소(원래의 소송)에서 주장하지 않았던 새로운 방어방법으로 "취득시효 완성"을 주장하였다. 이에 대해 甲은 재심절차는 확정된 판결의 부당함을 시정하는 비상구제수단이므로 전소의 변론종결 전까지 제출했어야 할 공격방어방법을 새로이 제출하는 것은 허용되지 않는다고 맞서고 있다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 판결이 확정된 후 재심을 제기하여 "재심대상판결을 취소하고 원고 丁의 청구를 기각한다"는 내용의 재심판결을 받아냈다. 그런데 재심판결이 확정되기 전, 丁은 재심대상판결(전소 판결)에 기하여 이미 丙의 재산을 강제집행하여 대금을 회수해 간 상태였다. 丙은 재심판결을 근거로 丁에게 기집행된 대금의 반환을 구하고자 한다.

(물음2) 재심판결에 의해 재심대상판결이 취소된 경우, 이미 취소된 판결에 기하여 집행된 결과에 대하여 丙이 재심절차 내에서 직접 원상회복을 청구할 수 있는 방법(민사소송법 제461조)과 그 요건에 대하여 설명하시오.》

<문제17.4의 물음2> 재심대상판결의 취소에 따른 강제집행 결과의 원상회복청구 방법 및 요건

I. 문제의 제기

- 사안에서 丙은 재심판결로 재심대상판결이 취소된 후 그 취소된 판결에 기하여 이미 이루어진 강제집행으로 회수된 대금의 반환을 재심절차에서 구하고자 하는 상황이다. 쟁점으로 재심판결에 의해 재심대상판결이 취소된 경우 민사소송법 제461조에 따라 재심절차 내에서 직접 원상회복을 청구할 수 있는지와 그 요건을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 재심절차에서의 원상회복청구의 방법과 그 요건을 설명한다.

II. 원상회복신청의 의의 및 성격

1. 제도의 의의

- 민사소송법 제461조에 의하면, 재심대상판결이 취소되는 경우 피고(재심원고)는 그 판결에 기하여 이미 집행된 부분에 대하여 원상회복과 집행으로 인한 손해배상을 재심절차 내에서 함께 청구할 수 있다. 이는 승소한 피고의 보호와 소송경제의 도모를 목적으로 한다.

2. 법적 성격

(1) 병합소송의 성격

- 원상회복신청은 재심의 소에 병합하여 제기하는 소송의 성격을 갖는다. 즉, 재심사유의 존부를 다투는 절차와는 별개로, 재심대상판결이 취소될 것을 조건으로 하는 조건부 병합소송이다.

(2) 반소와의 구별

- 이 신청은 형식상 반소와 유사하지만, 법률에 의해 특별히 허용된 독립된 신청이다. 따라서 반소의 일반적 요건(상호 관련성 등)을 갖출 필요는 없으며, 제461조가 정한 요건만 충족하면 족하다.

III. 원상회복신청의 요건

1. 주관적 요건

(1) 신청권자

- 재심의 소를 제기한 당사자(재심원고)만이 신청할 수 있다. 사안의 丙이 이에 해당한다.

(2) 상대방

- 재심대상판결에 기하여 강제집행을 실시하여 이익을 얻은 자(재심피고)를 상대로 해야 한다. 사안의 丁이 이에 해당한다.

2. 객관적 요건

(1) 재심대상판결의 존재와 집행을 완료

- 확정된 재심대상판결이 존재해야 하며, 그 판결에 기하여 이미 강제집행이 행하여졌거나 채무자가 판결의 강제를 면하기 위해 임의로 이행(임의변제)을 완료한 상태여야 한다.

(2) 재심대상판결의 취소 가능성

- 원상회복신청은 재심대상판결이 취소되고 본안 청구가 기각될 것을 전제로 하므로, 재심사유가 인정되지 않아 재심청구가 기각될 경우에는 원상회복신청 역시 판단될 수 없다.

3. 절차적 요건

(1) 신청의 시기

- 재심의 소가 제기되어 심리가 진행 중인 동안에만 신청이 가능하다. 즉, 재심의 변론종결 전까지 신청해야 한다.

(2) 신청의 방식

- 소의 제기예 준하는 방식이 필요하다. 서면으로 신청하는 것이 원칙이며, 인지대 등 소정의 비용을 납부해야 한다.

IV. 원상회복의 범위와 심리

1. 회복의 범위

(1) 원상회복

- 강제집행으로 인하여 인도한 물건이나 지급한 금전의 반환을 청구할 수 있다. 금전의 경우 집행 시부터 반환 시기까지의 법정이자도 포함된다.

(2) 손해배상

- 집행 자체로 인하여 발생한 부수적인 손해에 대해서도 배상을 청구할 수 있다. 다만, 이는 집행행위와 인과관계가 있는 손해에 한정된다.

2. 법원의 심리 및 판결

- 법원은 먼저 재심사유를 심리하여 재심대상판결을 취소하는 경우에 한하여 원상회복신청을 심리한다. 만약 재심사유가 인정되어 판결을 취소하고 청구를 기각한다면, 동시에 원상회복을 명하는 판결을 선고한다. 이때 원상회복판결에는 가집행 선고를 붙일 수 있다.

V. 사안의 적용

1. 丙의 구제방법(민사소송법 제461조의 활용)

- 사안에서 丙은 이미 재심을 제기하여 재심대상판결을 취소하고 丁의 청구를 기각한다는 재심판결을 받아낸 상태이다. 다만, 재심판결이 확정되기 전이므로 丙은 해당 재심절차의 변론종결 전까지 **민사소송법 제461조**에 따른 원상회복신청을 병합하여 제기했어야 한다. 만약 이미 변론이 종결되어 재심판결이 선고된 상황이라면 별도의 부당이득반환청구소송을 제기해야 할 것이나, 재심절차가 계속 중이라면 직접 신청이 가능하다.

2. 요건 구비 여부 판단

- 丙은 재심원고로서 집행채권자인 丁을 상대로 신청할 수 있다. 丁이 재심대상판결에 기하여 丙의 재산을 강제집행하여 대금을 회수한 사실이 명백하므로, 집행 완료라는 객관적 요건도 충족한다. 재심법원이 이미 丁의 청구를 기각하는 판단을 내렸으므로, 원상회복의 근거인 판결의 취소 조건도 달성되었다.

V. 결론

- 丙은 **민사소송법 제461조**에 의거하여 재심의 소가 계속 중인 법원에 원상회복신청을 함으로써, 별도의 소송 없이 丁에게 기집행된 대금 및 이에 대한 이자의 반환을 청구할 수 있다. 이는 재심대상판결의 취소를 당연한 전제로 하며, 丙은 이를 통해 강제집행 전의 상태로 재산을 회복할 수 있는 효율적인 구제를 받게 된다.

<제7편 재심절차.제17장 재심.제05절 준재심>

[모의][17.05-1]확정된 화해권고결정에 대한 준재심의 소의 요건과 재심 규정의 준용 범위

《【문제17.5】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였고, 법원은 소송 계속 중 양 당사자의 합의를 이끌어내기 위해 "화해권고결정"을 내렸다. 甲과 乙 모두 결정서를 송달받은 날로부터 2주 이내에 이의를 신청하지 않아 위 결정은 확정판결과 동일한 효력을 가지게 되었다. 그런데 3개월 뒤 乙은 위 화해권고결정의 기초가 된 갑 제출의 영수증이 위조된 것임을 알게 되었다.

한편, 丙은 丁을 상대로 물품대금 지급을 구하는 "지급명령"을 신청하였고, 丁이 이의를 제기하지 않아 지급명령이 확정되었다. 그러나 이후 丁은 丙이 지급명령 신청 당시 丁의 주소를 허위로 기재하여 송달받지 못하게 함으로써 방어할 기회를 박탈당했다는 사실을 깨달았다. 丁은 이미 확정된 지급명령의 효력을 제거하고자 한다.

또한, 소송법상 "조정"이 성립하여 조정조서가 작성된 경우에도 당사자 일방이 조정 성립 과정에 중대한 절차적 하자가 있음을 이유로 그 효력을 다투려 하고 있다. 이들은 모두 일반적인 재심의 소가 아닌 "준재심"의 방법으로 구제받을 수 있는지 의문이다.

(물음1) 확정된 화해권고결정에 대하여 乙이 취할 수 있는 불복 방법인 "준재심의 소"의 요건을 민사소송법 제461조와 관련하여 기술하고, 재심의 소에 관한 규정이 준재심 절차에 어느 정도까지 준용되는지 그 범위에 대하여 설명하시오.》

<문제17.5의 물음1> 확정된 화해권고결정에 대한 준재심의 소의 요건과 재심 규정의 준용 범위

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲과 乙은 이의 없이 확정되어 확정판결과 동일한 효력이 발생한 화해권고결정의 기초가 된 영수증이 위조된 사실을 뒤늦게 알게 되어 그 효력을 다투려는 상황이다. 쟁점으로 확정된 화해권고결정에 대하여 민사소송법 제461조에 따른 준재심의 소가 허용되는 요건과 재심의 소에 관한 규정이 준재심 절차에 어느 범위까지 준용되는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 확정된 화해권고결정에 대한 준재심의 소의 요건과 재심 규정의 준용범위를 설명한다.

II. 준재심의 소의 의의 및 대상

1. 제도의 의의

- 준재심이란 확정판결이 아님에도 불구하고 그와 동일한 효력을 가지는 조서(재판상 화해, 조정조서 등)나 결정 등에 재심사유에 해당하는 하자가 있는 경우, 그 효력을 배제하기 위해 제기하는 비상구제수단이다.

2. 대상 [민사소송법 제461조]

(1) 제461조 본문

- 조서가 확정판결과 동일한 효력을 가지는 경우로서 재판상 화해조서, 청구의 포기·인낙조서가 대표적이다.

(2) 제461조 단서

- 확정판결과 동일한 효력을 가지는 결정이나 명령이 이에 해당한다. 사안의 화해권고결정은 민사소송법 제231조에 의해 확정판결과 동일한 효력을 가지므로 준재심의 대상이 된다.

III. 준재심의 소의 요건

1. 주관적 요건

(1) 당사자 적격

- 준재심 대상인 결정이나 조서의 당사자 또는 그 승계인이 신청할 수 있다. 사안에서는 화해권고결정의 당사자인 乙이 원고가 된다.

(2) 상대방

- 해당 절차의 상대방 당사자(사안의 甲)를 피고로 하여 제기해야 한다.

2. 객관적 요건

(1) 준재심 사유의 존재

- 민사소송법 제451조 제1항 각 호에서 정한 재심사유가 존재해야 한다. 사안의 경우 증거가 된 문서가 위조된 것은 제451조 제1항 제6호의 사유에 해당한다. 다만, 문서 위조를 이유로 할 때는 원칙적으로 처벌받을 확정판결이 있어야 하나, 사안처럼 증거 흠결로 확정판결을 얻을 수 없는 때에는 제452조에 의해 위조 사실을 증명하여 제기할 수 있다.

(2) 대상의 확정

- 화해권고결정의 경우 이의신청 기간이 경과하여 확정판결과 동일한 효력을 갖춘 상태여야 한다.

3. 절차적 요건

(1) 제소기간

- 재심과 마찬가지로 준재심 사유를 안 날로부터 30일 이내, 결정이 확정된 날로부터 5년 이내에 제기해야 한다. 乙은 위조 사실을 안 날로부터 30일 이내에 소를 제기해야 한다.

(2) 관할법원

- 해당 결정이나 조서가 성립한 법원의 전속관할에 속한다.

IV. 재심 규정의 준용 범위

1. 준용의 원칙

- 민사소송법 제461조는 제451조 내지 제460조의 규정을 준용한다고 명시하고 있다. 따라서 재심의 절차, 재심사유, 기간, 심리 방식 등은 준재심 절차에 원칙적으로 그대로 적용된다.

2. 준용의 구체적 내용

(1) 재심사유의 준용

- 민사소송법 제451조 제1항 각 호의 사유가 그대로 준재심 사유가 된다. 따라서 조서의 내용 자체가 허위이거나 절차상 중대한 하자가 있는 경우 등이 포함된다.

(2) 재심제기기간의 준용

- 민사소송법 제456조의 기간 규정이 적용된다. 불변기간인 30일의 제척기간과 5년의 장기 제척기간이 적용되나, 상소의 효력이 있는 하자가 있는 경우 등 특정 사유에 대해서는 5년의 제한이 적용되지 않는다.

(3) 심리 및 재판 절차의 준용

- 재심의 소제기 방식, 재심개시절차와 본안심리의 2단계 구성, 판결의 형식 등이 준용된다.

3. 준용의 한계

- 준재심은 판결이 아닌 조서나 결정을 대상으로 하므로, 판결의 속성을 전제로 하는 규정은 성질상 준용되지 않거나 변형되어 적용된다. 예를 들어, 재심대상판결이 취소되면 전소송이 부활하여 다시 심리하지만, 화해조서에 대한 준재심이 인용되어 조서가 취소되면 화해 성립 전의 소송상태로 복귀하게 된다.

V. 사안의 적용

1. 乙의 구제수단

- 乙은 **민사소송법 제461조**에 따라 준재심의 소를 제기할 수 있다. 화해권고결정은 확정판결과 동일한 효력을 가지며, 乙이 주장하는 영수증 위조는 **민사소송법 제451조 제1항 제6호**의 재심사유에 해당하기 때문이다.

2. 절차적 준수사항

- 乙은 영수증이 위조되었다는 사실을 안 날로부터 30일 이내에 화해권고결정을 내린 법원에 준재심의 소를 제기해야 한다. 재심 규정이 준용되므로, 乙은 위조 사실을 증명하는 자료를 첨부하여 소를 제기해야 하며 법원은 1단계로 준재심 사유 유무를 심사한 후 본안을 심리하게 된다.

VI. 결론

- 확정된 화해권고결정의 효력을 다투기 위해 乙은 준재심의 소를 제기해야 한다. 이는 **민사소송법 제461조**에 근거하며, 재심에 관한 제반 규정(사유, 기간, 심리절차 등)이 원칙적으로 준용된다. 다만, 준재심 인용 시에는 판결의 취소와 달리 당해 사건이 화해권고결정 전의 소송계속 상태로 복귀한다는 점에서 실무적 차이가 존재한다.

<제7편 재심절차.제17장 재심.제05절 준재심>

[모의][17.05-2]확정된 지급명령에 대한 준재심 제기 가능성 및 조서의 특수성에 따른 준재심 사유

《【문제17.5】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였고, 법원은 소송 계속 중 양 당사자의 합의를 이끌어내기 위해 "화해권고결정"을 내렸다. 甲과 乙 모두 결정서를 송달받은 날로부터 2주 이내에 이의를 신청하지 않아 위 결정은 확정판결과 동일한 효력을 가지게 되었다. 그런데 3개월 뒤 乙은 위 화해권고결정의 기초가 된 갑 제출의 영수증이 위조된 것임을 알게 되었다.

한편, 丙은 丁을 상대로 물품대금 지급을 구하는 "지급명령"을 신청하였고, 丁이 이의를 제기하지 않아 지급명령이 확정되었다. 그러나 이후 丁은 丙이 지급명령 신청 당시 丁의 주소를 허위로 기재하여 송달받지 못하게 함으로써 방어할 기회를 박탈당했다는 사실을 깨달았다. 丁은 이미 확정된 지급명령의 효력을 제거하고자 한다.

또한, 소송법상 "조정"이 성립하여 조정조서가 작성된 경우에도 당사자 일방이 조정 성립 과정에 중대한 절차적 하자가 있음을 이유로 그 효력을 다투려 하고 있다. 이들은 모두 일반적인 재심의 소가 아닌 "준재심"의 방법으로 구제받을 수 있는지 의문이다.

(물음2) 丙이 丁을 상대로 얻은 확정된 지급명령에 대하여 丁이 준재심을 제기할 수 있는지 여부를 판례의 태도에 근거하여 판단하고, 조정조서나 재판상 화해와 같이 "판결"이 아닌 처분권주의가 적용되는 조서에 대한 준재심 사유의 특수성을 재심사유와 비교하여 논하시오.》

<문제17.5의 물음2> 확정된 지급명령에 대한 준재심 제기 가능성 및 조서의 특수성에 따른 준재심 사유

I. 문제의 제기

- 사안에서 丁은 확정된 지급명령이 허위 주소 기재로 인해 송달받지 못한 상태에서 확정되었음을 이유로 그 효력을 다투고자 하고, 조정조서 등에 대해서도 준재심으로 다룰 수 있는지가 문제되는 상황이다. 쟁점으로 확정된 지급명령에 대한 준재심의 허용 여부와 판결이 아닌 조정조서·재판상 화해 등에 대한 준재심 사유의 특수성을 재심사유와 비교하여 검토할 필요가 있다. 이하에서는 지급명령에 대한 준재심의 허용 여부와 조정조서 등에 대한 준재심 사유의 특수성을 논한다.

1. 지급명령의 효력 및 구제수단

(1) 지급명령의 효력

- 민사소송법 제474조에 따라 확정된 지급명령은 확정판결과 같은 효력을 가진다. 다만 판결과 달리 기판력이 인정되는지에 대해서는 견해의 대립이 있으나, 민사집행법 제58조 제3항은 확정된 지급명령에 대한 청구이의의 소에서 기판력의 시간적 한계에 따른 제한을 두지 않고 있다.

(2) 구제방법의 분화

- 확정된 지급명령의 효력을 배제하기 위한 방법으로는 청구이의의 소(민사집행법 제58조)가 일반적이다. 사안처럼 송달의 하자가 있는 경우에는 준재심의 소를 제기할 수 있는지에 대한 판례의 검토가 요구된다.

2. 판례의 태도

(1) 준재심 부정설

- 판례는 확정된 지급명령에 대하여 민사소송법 제461조가 정한 준재심의 소를 제기할 수 없다는 입장이다. 지급명령은 기판력이 없으므로 그 효력을 다투기 위해서는 청구이의의 소를 제기하거나, 송달 자체가 부적법하여 확정되지 않았음을 주장하며 이의신청 및 추완이의를 하는 방식으로 해결해야 한다고 본다.

(2) 사안의 경우

- 사안에서 丁은 丙이 주소를 허위 기재하여 송달을 가로챘음을 주장하고 있다. 판례에 따르면 이 경우 지급명령은 적법하게 송달된 것으로 볼 수 없어 확정되지 않았으므로, 丁은 준재심을 제기할 것이 아니라 지급명령에 대한 이의신청을 하거나 청구이의의 소를 통해 다투어야 한다.

II. 조서에 대한 준재심 사유의 특수성

1. 재판상 화해 및 조정조서의 성질

(1) 이원적 성격

- 재판상 화해나 조정조서는 소송법상 판결과 동일한 효력을 가지는 소송행위인 동시에, 당사자 간의 합의라는 사법상 계약의 성격을 병유한다.

(2) 처분권주의의 발현

- 판결이 법원의 판단에 의한 것인 반면, 조서는 당사자의 의사 합치에 기초한다. 따라서 그 효력을 다투는 사유 역시 판결에 대한 재심사유와는 차이가 발생할 수밖에 없다.

2. 준재심 사유의 확장 여부(사법상 하자)

(1) 원칙(재심사유 한정)

- 민사소송법 제461조는 제451조의 재심사유를 준용한다고 규정하므로, 원칙적으로 법문에 열거된 재심사유가 있어야만 준재심이 가능하다.

(2) 특수성(실체법상 하자)

- 재판상 화해나 조정은 사법상 합의를 기초로 하므로, 합의 자체에 민법상 무효나 취소 사유(의사표시의 착오, 사기, 강박 등)가 있는 경우 이를 준재심 사유로 인정할 것인지가 핵심이다. 판례는 화해조서 등의 내용이 실체법상 계약의 원인 무효 사유가 있더라도 그것이 민사소송법이 정한 재심사유에 해당하지 않는 한 준재심의 소를 제기할 수 없다는 태도를 견지해 왔다.

3. 재심사유와 비교한 특수성

(1) 절차적 하자의 중시

- 조서의 경우 제451조 제1항 제3호(당사자의 대리권 흠결) 등 절차적 공정성을 해치는 사유가 준재심에서 핵심적으로 다루어진다.

(2) 사법상 하자의 포섭 노력

- 비록 판례는 엄격히 재심사유에 한정하나, 해석상 제451조 제1항 제9호(판결의 기초가 된 재판의 변경) 등을 원용하여 실체법상 하자를 간접적으로 수용하려는 학설적 시도가 존재한다. 그러나 현행 실무상 판결에 대한 재심보다 의사의 합치라는 성립 요건의 하자가 더 중요하게 다루어진다는 점이 조서 준재심의 특수성이다.

III. 사안의 적용

1. 지급명령에 대한 丁의 불복

- 丁이 제기하려는 준재심은 **판례**의 태도에 비추어 볼 때 부적법하다. 丁은 주소 허위 기재 및 송달 불능을 근거로 지급명령 이의신청(또는 추완이의)을 하거나, 집행력을 배제하기 위한 청구이의의 소를 제기하는 것이 타당한 구제수단이다.

2. 조정조서에 대한 불복

- 조정 성립 과정에 증대한 절차적 하자가 있다는 주장은 **민사소송법 제461조** 및 **제451조 제1항** 소정의 사유(예 : 대리권의 흠결 등)에 해당할 경우 준재심의 소를 통해 다룰 수 있다. 다만 단순히 조정 내용이 불공정하다거나 사법상 착오가 있었다는 사유만으로는 **판례상** 준재심 청구가 기각될 가능성이 높다.

V. 결론

- 확정된 지급명령은 기판력이 없고 별도의 불복 방법이 존재하므로 준재심의 대상이 되지 않는다는 것이 확립된 **판례**이다. 또한 재판상 화해나 조정조서에 대한 준재심은 판결과 달리 사법상 계약의 성질을 가지나, 우리 법제는 법적 안정성을 위해 **민사소송법**상 열거된 재심사유가 있는 경우에 한하여 준재심을 허용하므로 청구인은 이를 엄격히 증명하여야 한다.